



DAMÁSIO
de Jesus

André **ESTEFAM**
atualizador

DIREITO PENAL

Crimes contra a fé pública a Crimes
contra a Administração Pública

4

parte especial

20ª edição

Atualizada de acordo com as Leis n. 13.804/2019,
n. 13.827/2019, n. 13.834/2019, n. 13.869/2019
(Lei de Abuso de Autoridade) e n. 13.964/2019 (Lei Anticrime)

saraiva *jur*

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva.

A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

ISBN 9788553619894

Jesus, Damásio de

Parte especial: crimes contra a fé pública a crimes contra a administração pública – arts. 289 a 359-H do CP / Damásio de Jesus ; atualização André Estefam. – Direito penal vol. 4 – 20. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.

368 p.

Bibliografia

1. Direito penal. 2. Direito penal – Brasil. I. Estefam, André. II. Título.

20-0056

CDD 340

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Código penal 343(81)(094.4)

Direção executiva *Flávia Alves Bravin*

Direção editorial *Renata Pascual Müller*

Gerência editorial *Roberto Navarro*

Gerência de produção e planejamento *Ana Paula Santos Matos*

Gerência de projetos e serviços editoriais *Fernando Penteado*

Planejamento *Clarissa Boraschi Maria (coord.)*

Novos projetos *Melissa Rodriguez Arnal da Silva Leite*

Edição *Aline Darcy Flôr de Souza*

Produção editorial *Luciana Cordeiro Shirakawa*

Arte e digital *Mônica Landi (coord.) | Amanda Mota Loyola | Camilla Felix Cianelli Chaves |*

Claudirene de Moura Santos Silva | Deborah Mattos | Fernanda Matajs | Guilherme H. M. Salvador | Tiago Dela Rosa | Verônica Pivisan Reis

Planejamento *Clarissa Boraschi Maria (coord.)*

Projetos e serviços editoriais *Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Mônica Gonçalves Dias*

Diagramação (Livro Físico) *Laís Soriano*

Revisão *Estela Janiski Zumbano | Lillian Moreira Mendes*

Capa *IDÉE arte e comunicação*

Livro digital (E-pub)

Produção do e-pub *Guilherme Henrique Martins Salvador*

Data de fechamento da edição: 23-1-2020

Dúvidas?

Acesse sac.sets@somoseducacao.com.br

Sumário

Nota do Atualizador à 20ª edição

XI – DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Capítulo I

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Princípios gerais

1. OBJETIVIDADE JURÍDICA GENÉRICA
2. SUJEITOS DOS DELITOS
3. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA
4. CARACTERÍSTICAS DOS CRIMES DE FALSIDADE
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS TIPOS
6. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
7. POTENCIALIDADE LESIVA
8. CLASSIFICAÇÃO

Capítulo II

DA MOEDA FALSA

Moeda falsa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. CONCURSO DE CRIMES

7. CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA

- a) Conceito e objeto jurídico
- b) Sujeitos do delito
- c) Elementos objetivos do tipo
- d) Elemento subjetivo do tipo
- e) Momento consumativo e tentativa

8. FIGURA TÍPICA PRIVILEGIADA

- a) Conceito e objeto jurídico
- b) Sujeitos do delito
- c) Elementos objetivos do tipo
- d) Elementos subjetivos do tipo
- e) Momento consumativo e tentativa

9. FABRICAÇÃO OU EMISSÃO IRREGULAR DE MOEDA

- a) Conceito e objetividade jurídica
- b) Sujeitos do delito
- c) Elementos objetivos do tipo
- d) Elemento subjetivo do tipo
- e) Momento consumativo e tentativa

10. DESVIO E CIRCULAÇÃO ANTECIPADA

- a) Conceito e objetividade jurídica
- b) Sujeitos do delito
- c) Elementos objetivos do tipo
- d) Elemento subjetivo do tipo
- e) Consumação e tentativa

11. PENAS E AÇÃO PENAL

Crimes assimilados ao de moeda falsa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. TIPO QUALIFICADO
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Petrechos para falsificação de moeda

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. ABSORÇÃO PENAL
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Emissão de título ao portador sem permissão legal

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS COMO DINHEIRO
8. PENAS E AÇÃO PENAL

Capítulo III

DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

Da falsidade de papéis públicos

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. USO DE PAPÉIS PÚBLICOS FALSIFICADOS E DEMAIS CONDUTAS EQUIPARADAS
7. SUPRESSÃO DE SINAIS INDICATIVOS DE INUTILIZAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS
8. USO DE PAPÉIS PÚBLICOS COM INUTILIZAÇÃO SUPRIMIDA
9. RESTITUIÇÃO À CIRCULAÇÃO
10. TIPO QUALIFICADO
11. PENAS E AÇÃO PENAL

Petrechos de falsificação

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. CONFLITO APARENTE DE NORMAS
7. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
8. PENA E AÇÃO PENAL

Capítulo IV

DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação de selo ou sinal público

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. USO DE SELO OU SINAL FALSIFICADO
7. UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE SELO OU SINAL LEGÍTIMO
8. EMPREGO ILÍCITO DE SÍMBOLOS IDENTIFICADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
9. TIPO QUALIFICADO
10. PENAS E AÇÃO PENAL

Falsificação de documento público

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. TIPO QUALIFICADO
8. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PREVIDENCIÁRIO (ART. 297, §§ 3º E 4º)
9. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO
10. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E CRIMES AFINS
11. PENAS E AÇÃO PENAL

Falsificação de documento particular

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, ESTELIONATO E CRIMES AFINS
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Falsidade ideológica

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ABUSO DE FOLHA EM BRANCO
5. SIMULAÇÃO
6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
8. FALSIDADE DE REGISTRO CIVIL
9. CRIME COMETIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO
10. CONCURSO DE CRIMES
11. PENAS E AÇÃO PENAL

Falso reconhecimento de firma ou letra

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. PENAS E AÇÃO PENAL

Certidão ou atestado falso

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO
8. FIGURA TÍPICA QUALIFICADA
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Falsidade de atestado médico

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. TIPO QUALIFICADO
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. USO PARA FINS DE COMÉRCIO

8. PENAS E AÇÃO PENAL

Uso de documento falso

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. CONCURSO DE CRIMES
7. PENA E AÇÃO PENAL

Supressão de documento

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E OUTROS CRIMES
3. SUJEITOS DO DELITO
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Capítulo V

DE OUTRAS FALSIDADES

Falsificação de sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

6. PENAS E AÇÃO PENAL

Falsa identidade

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA
3. SUJEITOS DO DELITO
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
8. FALSA IDENTIDADE E OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Uso de documento de identidade alheia

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA
3. SUJEITOS DO DELITO
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Fraude de lei sobre estrangeiros

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. ATRIBUIÇÃO DE FALSA QUALIDADE A ESTRANGEIRO

7. PENAS E AÇÃO PENAL

Falsidade em prejuízo da nacionalização de sociedade

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO CRIME
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. NORMA PENAL EM BRANCO
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

1. CONCEITO
2. AUTONOMIA TÍPICA
3. OBJETIVIDADE JURÍDICA
4. OBJETOS MATERIAIS
5. TIPO ELÁSTICO
6. SUJEITOS DO DELITO
7. CONDUTAS TÍPICAS
8. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
9. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
10. CRIME FUNCIONAL (§ 1º)
11. FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE PARTICIPA DE LICENCIAMENTO OU REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO OU REMARCADO (§ 2º)
12. PENAS E AÇÃO PENAL

Fraude em certames de interesse público

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. NOVATIO LEGIS INCRIMINADORA
3. ORIGEM DA MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA
4. SUJEITOS DO DELITO
5. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
8. FIGURA EQUIPARADA
9. FORMA QUALIFICADA
10. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
11. PENA E AÇÃO PENAL

XII – DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Capítulo VI

PRINCÍPIOS GERAIS

1. OBJETIVIDADE JURÍDICA GENÉRICA
2. CLASSIFICAÇÃO
3. CRIMES FUNCIONAIS
4. CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO
 - a) Conceito de funcionário público para efeitos penais
 - b) Funcionário público por equiparação e causa de aumento de pena
 - c) Conceito de funcionário público estrangeiro para efeitos penais
5. ELEMENTO SUBJETIVO DOS TIPOS
6. CONCURSO DE PESSOAS
7. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
8. RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Capítulo VII

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Peculato

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. FIGURAS TÍPICAS
3. SUJEITOS DO DELITO
4. OBJETO MATERIAL
5. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
8. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
9. PECULATO-FURTO
10. PECULATO CULPOSO
11. FORMAS TÍPICAS QUALIFICADAS
12. PENAS E AÇÃO PENAL
13. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E REDUÇÃO DA PENA

Peculato mediante erro de outrem

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. FORMA TÍPICA QUALIFICADA
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Inserção de dados falsos em sistema de informações

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. PENAS E AÇÃO PENAL
7. VACATIO LEGIS

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
8. PENAS E AÇÃO PENAL
9. VACATIO LEGIS

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. OBJETO MATERIAL
4. CONDUTA TÍPICA
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
7. SUBSIDIARIEDADE
8. TIPO QUALIFICADO
9. PENA E AÇÃO PENAL

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. VIGÊNCIA
4. MODALIDADES DO TIPO
5. CONDUTA TÍPICA
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. TIPO QUALIFICADO
8. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
9. EXCLUSÃO DA ILICITUDE
10. PENAS E AÇÃO PENAL

Concussão

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
8. TIPO QUALIFICADO
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Excesso de exação

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. FIGURAS DO TIPO PENAL
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

5. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO
6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
8. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
9. TIPO QUALIFICADO
10. PENAS E AÇÃO PENAL

Corrupção passiva

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. TIPO AGRAVADO PELA QUALIDADE DO AUTOR
7. CORRUPÇÃO PASSIVA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA QUALIFICADA
8. CORRUPÇÃO PASSIVA PRÓPRIA PRIVILEGIADA
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Facilitação de contrabando ou descaminho

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. CONCEITOS DE CONTRABANDO E DESCAMINHO
4. CONDUTA TÍPICA
5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
8. TIPO QUALIFICADO
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Prevaricação

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. PREVARICAÇÃO E OUTROS DELITOS
8. PENAS E AÇÃO PENAL

Modalidade equiparada à prevaricação (ou prevaricação imprópria)

1. INTRODUÇÃO
2. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
3. SUJEITOS DO DELITO
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
8. PENAS E AÇÃO PENAL

Condescendência criminosa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. TIPO QUALIFICADO
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Advocacia administrativa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. TIPO QUALIFICADO
7. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
8. PENAS E AÇÃO PENAL

Violência arbitrária

1. REVOGAÇÃO
2. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
3. SUJEITOS DO DELITO
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. PENA E AÇÃO PENAL

Abandono de função

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. FIGURAS TÍPICAS QUALIFICADAS
8. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

9. PENAS E AÇÃO PENAL

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. EXCLUSÃO GENÉRICA DA ILICITUDE
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. TIPO QUALIFICADO
8. PENAS E AÇÃO PENAL

Violação de sigilo funcional

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA
3. SUJEITOS DO DELITO
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
7. EXCLUSÃO DA ILICITUDE
8. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
9. TIPO QUALIFICADO
10. SIGILO FUNCIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
11. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DE ÁUDIO OU VÍDEO RETRATANDO PRESOS FEDERAIS
12. PENAS E AÇÃO PENAL

Violação de sigilo de proposta de concorrência

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. TIPO QUALIFICADO
7. PENAS E AÇÃO PENAL
8. EFEITO DA CONDENAÇÃO

Capítulo VIII

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

PRINCÍPIOS GERAIS

Usurpação de função pública

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. TIPO QUALIFICADO
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Resistência

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

7. TIPO QUALIFICADO
8. CONCURSO DE CRIMES
9. PENA E AÇÃO PENAL

Desobediência

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. COMINAÇÃO DE SANÇÃO CIVIL OU ADMINISTRATIVA
8. FORMAS ESPECIAIS DE DESOBEDIÊNCIA
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Desacato

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO CRIME DE DESACATO
7. CONCURSO DE CRIMES
8. PENA E AÇÃO PENAL

Tráfico de influência

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. CONCURSO DE CRIMES
7. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
8. PENAS E AÇÃO PENAL

Corrupção ativa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. CORRUPÇÃO ATIVA E OUTROS CRIMES
8. TIPO QUALIFICADO
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Descaminho

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. QUESTÃO PREJUDICIAL
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. DESCAMINHO POR ASSIMILAÇÃO
8. TIPO QUALIFICADO
9. PENAS E AÇÃO PENAL
10. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

11. PERDIMENTO DE BENS

Contrabando

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. QUESTÃO PREJUDICIAL
5. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
8. CONTRABANDO POR ASSIMILAÇÃO
9. TIPO QUALIFICADO
10. PENAS E AÇÃO PENAL
11. PERDIMENTO DE BENS

Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. CONCURSO DE CRIMES
7. ABSTENÇÃO VENAL DE LICITANTE
8. PENAS E AÇÃO PENAL

Inutilização de edital ou sinal

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

6. PENAS E AÇÃO PENAL

Subtração ou inutilização de livro ou documento

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. DISTINÇÃO COM OUTROS DELITOS

3. SUJEITOS DO DELITO

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

7. PENA E AÇÃO PENAL

Sonegação de contribuição previdenciária

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

6. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

7. PERDÃO JUDICIAL

8. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

9. PARCELAMENTO DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO

10. ART. 95 DA LEI N. 8.212/91

11. PENAS E AÇÃO PENAL

12. VACATIO LEGIS

Capítulo IX

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

INADEQUAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES

Corrupção ativa em transação comercial internacional

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. ORIGEM DA NORMA DE CONDUTA
3. EXCEÇÃO PLURALISTA DO PRINCÍPIO UNITÁRIO
4. SUJEITOS DO DELITO
5. CONDUTAS TÍPICAS
6. OBJETO MATERIAL
7. TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL
8. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
9. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
10. REALIZAÇÃO, RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE ATO DE OFÍCIO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA (PARÁGRAFO ÚNICO)
11. PENAS E AÇÃO PENAL

Tráfico de influência em transação comercial internacional

1. ORIGEM DA NORMA DE COMANDO
2. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
3. SUJEITOS DO DELITO
4. CONDUTAS TÍPICAS
5. VANTAGEM
6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
8. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Capítulo X

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Reingresso de estrangeiro expulso

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
7. PENA E AÇÃO PENAL

Denúnciação caluniosa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA, CALÚNIA, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO E AUTOACUSAÇÃO FALSA
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. TIPOS QUALIFICADO E PRIVILEGIADO
8. FORMAS ESPECIAIS DE DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA
9. PENAS
10. AÇÃO PENAL

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. PENAS E AÇÃO PENAL

Autoacusação falsa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. PENA E AÇÃO PENAL

Falso testemunho ou falsa perícia

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. CONCURSO DE PESSOAS
4. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
5. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
8. FIGURAS TÍPICAS AGRAVADAS
9. RETRATAÇÃO
10. PENAS E AÇÃO PENAL

Corrupção ativa de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

5. FIGURA TÍPICA AGRAVADA
6. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
8. CONCURSO DE PESSOAS
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Coação no curso do processo

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. PENA E AÇÃO PENAL

Exercício arbitrário das próprias razões

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. PENA E AÇÃO PENAL

Subtração ou dano de coisa própria em poder de terceiro

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. OBJETO MATERIAL
4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

5. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
8. PENA E AÇÃO PENAL

Fraude processual

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. FRAUDE EM PROCESSO CRIMINAL
8. SUPRESSÃO DE VESTÍGIOS EM LOCAL DE CRIME
9. PENAS E AÇÃO PENAL

Favorecimento pessoal

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. FIGURAS TÍPICAS
7. ESCUSA ABSOLUTÓRIA
8. PENAS E AÇÃO PENAL

Favorecimento real

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO

3. DISTINÇÕES
4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. PENA E AÇÃO PENAL

Favorecimento real impróprio

1. INTRODUÇÃO
2. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
3. SUJEITOS DO DELITO
4. ELEMENTOS DO TIPO
5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. PENAS E AÇÃO PENAL

Abuso de poder (ou exercício arbitrário) e abuso de autoridade (Lei n. 13.869, de 5-9-2019)

1. REVOGAÇÃO
2. TERMINOLOGIA
3. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
4. SUJEITOS DO CRIME
5. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO
6. AÇÃO PENAL
7. CRIMES EM ESPÉCIE

7.1. Decretação indevida de medida privativa de liberdade e figuras equiparadas

7.2. Decretação indevida de condução coercitiva

7.3. Falta de comunicação da prisão em flagrante ao juiz competente e demais providências relacionadas à detenção e à execução da soltura do

agente

7.4. Constrangimento moral de preso ou detento

7.5. Constrangimento de testemunha com dever de sigilo

7.6. Falta de identificação ou falsa identificação do responsável pela prisão ou detenção

7.7. Submissão de preso a interrogatório noturno

7.8. Impedimento ou retardamento de envio de pedido de apreciação da legalidade de prisão

7.9. Impedimento de entrevista pessoal e reservada entre o preso e seu advogado

7.10. Manutenção de presos em estabelecimento inadequado em razão de sexo ou idade

7.11. Invasão de domicílio com abuso de autoridade

7.12. Fraude processual especial

7.13. Constrangimento de servidor de saúde para alteração de registro de óbito

7.14. Realização ou utilização de prova manifestamente ilícita

7.15. Requisição ou instauração de procedimento investigatório criminal ou administrativo sem justa causa

7.16. Divulgação indevida de gravação sem relação com a prova

7.17. Falsidade sobre informação em procedimento judicial ou investigatório

7.18. Denúnciação caluniosa ou perseguição infundada

7.19. Procrastinação indevida de investigação

7.20. Negativa de acesso aos autos de procedimento investigatório

7.21. Exigência de informação ou cumprimento de obrigação sem amparo legal

7.22. Invocação de condição de agente público para obtenção de vantagem pessoal ou privilégio indevido

7.23. Decretação exacerbada de indisponibilidade de ativos financeiros

7.24. Retardamento demasiado de pedido de vista

7.25. Antecipação de juízo de culpa

7.26. Violação de prerrogativas profissionais

7.27. Penas e ação penal

7.28. Revogação da Súmula 172 do STJ

Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO

3. FIGURAS TÍPICAS

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

7. FORMA TÍPICA CULPOSA

8. TIPOS QUALIFICADOS

9. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

10. PENA E AÇÃO PENAL

Evasão mediante violência contra pessoa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

6. PENA E AÇÃO PENAL

Arrebatamento de preso

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. PENA E AÇÃO PENAL

Motim de presos

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. PENA E AÇÃO PENAL

Patrocínio infiel

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. PENA E AÇÃO PENAL

Patrocínio simultâneo ou tergiversação

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

6. PENA E AÇÃO PENAL

Sonegação de papel ou objeto de valor probatório

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. PENA E AÇÃO PENAL

Exploração de prestígio

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO
6. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA
7. TENTATIVA
8. TIPO QUALIFICADO
9. PENA E AÇÃO PENAL

Violência ou fraude em arrematação judicial

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
6. PENA E AÇÃO PENAL

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. PENA E AÇÃO PENAL

Capítulo XI

DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS

Contratação de operação de crédito

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
6. ELEMENTO ESPACIAL
7. EXCLUSÃO DA ILICITUDE
8. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
9. OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR
10. RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL
11. PENA E AÇÃO PENAL

Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

7. PENA E AÇÃO PENAL

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

5. ELEMENTO TEMPORAL DO TIPO

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

7. PENA E AÇÃO PENAL

Ordenação de despesa não autorizada

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

6. PENA E AÇÃO PENAL

Prestação de garantia graciosa

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

6. PENA E AÇÃO PENAL

Não cancelamento de restos a pagar

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO
6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
7. PENA E AÇÃO PENAL

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. ELEMENTO TÍPICO TEMPORAL
6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA
7. PENA E AÇÃO PENAL

Oferta pública ou colocação de títulos no mercado

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA
2. SUJEITOS DO DELITO
3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO
4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA
6. PENA E AÇÃO PENAL

Damásio de Jesus

Fundador do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Doutor em Direito pela Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Salerno (Itália). Foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo por 26 anos.

André Estefam

Doutor e Mestre em Direito Penal pela PUC-SP. Promotor de Justiça. Assessor Jurídico do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Professor de Direito Penal e Direito Processual Penal do Damásio Educacional. Coordenador pedagógico dos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Penal e Direito Processual Penal do Ibmecc-SP/Instituto de Direito Damásio de Jesus, do Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo – Presidente Prudente e da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp. Professor convidado do curso de pós-graduação de diversas escolas superiores do Ministério Público e da Magistratura.

Nota do Atualizador à 20ª edição

A tarefa de auxiliar o Professor Damásio de Jesus na atualização de uma das obras mais prestigiadas da literatura jurídica nacional, seu Direito Penal, em quatro volumes, é uma honra sem equivalente para qualquer professor.

Minha relação com o mestre se iniciou em 1995, quando aluno de seu conhecido curso preparatório, então denominado “MPM”. O Professor Damásio costumava lançar desafios a seus alunos, propondo a solução de casos complexos em matéria penal e premiando as melhores respostas com livros de sua autoria. Lancei-me ao “desafio” e, para minha alegria, fiquei em terceiro lugar. Nos seguintes, já com um pouco mais de estudo e de esmero, obtive a primeira colocação. Fui então agraciado com um exemplar do Direito Penal – volume 1.

Em 1999, já promotor de justiça, recebi um telefonema, oriundo do então “Complexo Jurídico Damásio de Jesus”. Era a secretária do Professor, comunicando que o mestre gostaria de marcar uma reunião.

Começava minha trajetória como docente no renomado curso preparatório comandado pelo Professor Damásio.

Os anos se passaram e o respeitado doutrinador, com a bênção de sua família, me alegra com um novo convite, ainda mais honroso: auxiliá-lo na atualização de uma de suas obras maiores, os quatro volumes de seu consagrado Direito Penal.

Esses livros foram e ainda são ferramenta indispensável a mim e a outros milhares de bacharéis em suas trajetórias estudantis e profissionais.

A tarefa que me foi incumbida consistiu em imprimir ao texto uma atualização legislativa e jurisprudencial, de maneira a manter esse clássico

um livro contemporâneo, persistindo como leitura indispensável aos que pretendem conhecer o Direito Penal em todos os seus aspectos fundamentais.

Registro meus especiais agradecimentos ao querido Professor Damásio de Jesus, por quem tenho eterna gratidão, e à sua família, na pessoa da Rosana, do Agostinho e da Nathália.

São Paulo, janeiro de 2020.

André Estefam

XI – DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Capítulo I

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Princípios gerais

SUMÁRIO: 1. Objetividade jurídica genérica. 2. Sujeitos dos delitos. 3. Falsidade material e ideológica. 4. Características dos crimes de falsidade. 5. Elementos subjetivos dos tipos. 6. Qualificação doutrinária. 7. Potencialidade lesiva. 8. Classificação.

1. OBJETIVIDADE JURÍDICA GENÉRICA

O homem, por exigência prática e jurídica, diante da multiplicidade das relações sociais, elevou à categoria de imperativo de convivência a necessidade da crença na legitimidade e autenticidade dos documentos. Haveria obstáculo ao progresso se, a todo momento, em face de uma transação ou demonstração de um fato, surgisse a obrigação de provar a veracidade de um documento. Daí a aceitação geral de que os documentos, até prova em contrário, são autênticos. A isso, sob o aspecto objetivo e o subjetivo, dá-se o nome de fé pública. Objetivamente, indica a autenticidade documental; subjetivamente, aponta a confiança a priori que os cidadãos depositam na legitimidade dos sinais, documentos, objetos etc., aos quais o Estado, por intermédio da legislação pública ou privada, atribui valor probatório.

O Estado tem relevante interesse em preservar o objeto jurídico fé pública. Por isso, elevou à categoria de crimes de ação penal pública os fatos atentatórios dessa objetividade jurídica.

O objeto jurídico dos crimes de falso não se esgota na proteção da fé

pública. De forma secundária, outros interesses são tutelados. Assim, por exemplo, no crime de moeda falsa (CP, art. 289), além da fé pública, lesada pela conduta, é protegido o patrimônio do sujeito passivo que, eventualmente, venha a receber o objeto material.

2. SUJEITOS DOS DELITOS

Em regra, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo dos delitos de falso (crimes comuns). Excepcionalmente, porém, em algumas hipóteses de crimes próprios, a norma incriminadora exige determinadas condições do autor principal. Ex.: falsidade de atestado médico (CP, art. 302).

Nos crimes de falsidade, o sujeito passivo eventual é sempre o Estado, titular da fé pública. Como a objetividade jurídica é múltipla, em alguns tipos, a par do Estado como sujeito passivo principal, surge outro, secundário: a pessoa física ou jurídica que vem a sofrer o dano ou a potencialidade de sua ocorrência. Ex.: na falsidade ideológica, além da fé pública, a conduta pode ofender direito de terceiro. Em alguns casos, entretanto, a objetividade jurídica é única. Ex.: o delito de petrechos para a falsificação de moeda (CP, art. 291), que lesa somente a fé pública.

3. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA

A falsidade pode ser:

1ª) externa ou material; e

2ª) pessoal ou ideológica.

Na falsidade material, o vício incide sobre a parte exterior do documento, recaindo sobre o elemento físico do papel escrito e verdadeiro. O sujeito modifica as características originais do objeto material por meio de rasuras, borrões, emendas, substituição de palavras ou letras, números etc. Pode acontecer também que o agente, sem tocar no documento original, crie um outro falso.

A falsidade material pode dar-se:

a) Por alteração: o sujeito modifica o documento verdadeiro, excluindo parte de seu conteúdo, acrescentando-lhe algo etc., conferindo-lhe um aspecto diferente.

b) Por falsificação: o agente cria um documento antes inexistente. Pode ser total ou parcial.

A falsificação parcial se distingue da alteração. Há a primeira quando o documento, podendo ser separado em partes, sofre a ação do sujeito em uma delas. Ex.: emitidos conhecimento de depósito e warrant, um deles é falsificado. Já na alteração, o documento é um só, não podendo ser cindido em partes individualizáveis. Ex.: falsificação de uma assinatura em uma carta.

Na falsidade ideológica (ou pessoal) o vício incide sobre as declarações que o objeto material deveria possuir, sobre o conteúdo das ideias. Inexistem rasuras, emendas, omissões ou acréscimos. O documento, sob o aspecto material, é verdadeiro; falsa é a ideia que ele contém. Daí também chamar-se falso ideal.

Distinguem-se, pois, as falsidades material e ideológica. A primeira pode ser averiguada pela perícia; a segunda não, cumprindo ser demonstrada por outros meios.

4. CARACTERÍSTICAS DOS CRIMES DE FALSIDADE

São três as características gerais dos delitos de falso:

- 1ª) imitação ou alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante;
- 2ª) potencialidade de dano; e
- 3ª) dolo.

A imitação da verdade configura elemento típico dos crimes de falso, uma vez que se pretende, com o fato, enganar o sujeito passivo. Nela, o agente

forma ou fabrica o objeto material (documento, moeda etc.). Deve ser idônea, contendo capacidade para enganar. Se grosseira, à primeira vista verificável, inexistente crime de falsidade, podendo subsistir, conforme o caso, o estelionato.

A alteração da verdade pode também ocorrer no falso. Nela, o agente, por meio da modificação do objeto material legítimo, pretende apresentar como verdadeiro o que é na realidade falso.

A conduta deve incidir sobre fato juridicamente relevante. É necessário que o fato da falsidade crie, modifique, extinga ou perturbe algum direito.

A possibilidade de dano é essencial ao delito. Sem ela o fato é atípico. Exige-se, ao menos, que a falsidade tenha condições de causar um dano. Na maioria das vezes não se exige o dano efetivo, contentando-se a figura penal com a potencialidade lesiva do comportamento.

O dolo será estudado no item seguinte.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS TIPOS

Na falsidade material (CP, arts. 296, 297, 301, § 1º, e 303), a caracterização dos delitos, sob o aspecto do elemento subjetivo do tipo, está condicionada exclusivamente à presença da vontade dirigida à prática da falsificação ou da alteração documental. Na falsidade ideológica, contudo, além do dolo, o tipo reclama um outro elemento subjetivo, contido na expressão “com o fim de” (art. 299, caput).

Para a existência da falsidade formal, é preciso que o sujeito queira cometer o ato da falsidade. Esse dolo, entretanto, não satisfaz a exigência legal. É necessário que a conduta seja realizada com o fim de causar dano a terceiro por intermédio da alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante. Diante disso, a vontade de alterar a verdade despida da finalidade de prejudicar terceiro não é suficiente para integrar o crime.

O tipo da falsidade ideológica é subjetivamente complexo. Além do dolo,

a intenção de causar dano a terceiro constitui elemento ínsito no tipo. Como diz Sylvio do Amaral, em obra clássica acerca do tema, “o elemento subjetivo é integrado também pela consciência e voluntariedade do dano emergente”¹. Enquanto na falsidade material os tipos se perfazem com o dano potencial derivado do falso per se, que lesa a fé pública, na falsidade ideológica há também proteção de outros bens, como o interesse econômico, a paz social, a ordem pública ou familiar, a honra, a liberdade etc. Assim, são insuficientes à configuração delitiva a vontade e a consciência de lesar a fé pública com a prática do falso. É posição firme na doutrina a de que não basta a intenção do sujeito, realizando a falsidade, de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo imprescindível que também vise ao prejuízo de terceiro.

Esse fim ulterior, que se projeta além da vontade da falsidade, visando a um segundo resultado, é chamado na doutrina de “elemento subjetivo do tipo” (ou do injusto, segundo a teoria que se adote). Corresponde à “segunda intenção”. A primeira é o dolo; a segunda, o denominado elemento subjetivo do tipo. Assim, no crime de furto, o dolo está na vontade de retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima (subtrair); o elemento subjetivo do tipo, na expressão “para si ou para outrem”. Esse fim não se projeta no plano do dolo, uma vez que este é a vontade de concretizar os elementos objetivos do tipo. Constitui um estado anímico situado fora das fronteiras do dolo.

Os elementos subjetivos do tipo são considerados características da figura penal, não pertencendo à culpabilidade. Em consequência dessa localização, sua inexistência conduz à atipicidade do fato.

A consequência de ordem prática é a exigência da perquirição do elemento subjetivo do tipo para a aferição da própria existência do fato típico, como valoração anterior imprescindível ao oferecimento da denúncia por falsidade ideológica, e não como indagação reservada para a oportunidade da sentença, momento adequado à apreciação da

culpabilidade do acusado. Ausente esse elemento, a denúncia narrará fato penalmente atípico e, portanto, deverá ser rejeitada (CPP, art. 395).

6. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

Os delitos de falso, em sua maioria, são formais. Descrevem a conduta e o resultado desejado pelo sujeito. Entretanto, não exigem a sua produção. Para a sua existência é suficiente a possibilidade da ocorrência de dano. Não se exige, assim, que terceiro, pessoa física ou jurídica, venha a sofrer, efetivamente, um prejuízo.

7. POTENCIALIDADE LESIVA

Não há delito de falso sem a potencialidade lesiva (possibilidade de dano). É preciso que traga em si mesmo a capacidade de iludir a vítima e, assim, causar-lhe um dano. Se o falso é grosseiro, incapaz de enganar, ou forma um documento nulo (nulidade estranha à própria falsidade), não ofende a fé pública e, por isso, inexistente crime.

A potencialidade de dano não é elemento típico expresso do crime. Está implícito. Entendeu o legislador que o falso como fim em si mesmo, sem a potencialidade lesiva, constitui uma anormalidade. Já faz parte de sua essência. Por isso, está implícito no tipo. Seria redundante, assentou o legislador, expressá-lo em todas as definições legais. Quando fala em “crimes contra a fé pública”, deixa claro que o fato é ofensivo, em primeiro lugar, ao objeto jurídico genérico, a própria fé pública, e, secundariamente, a um grande número de bens jurídicos e objetos materiais, que podem vir a sofrer dano em consequência da conduta delituosa.

8. CLASSIFICAÇÃO

Os delitos contra a fé pública, previstos no Título X da Parte Especial do CP, estão classificados em cinco capítulos:

Capítulo I: Da moeda falsa (arts. 289 a 292);

Capítulo II: Da falsidade de títulos e outros papéis (arts. 293 a 295);

Capítulo III: Da falsidade documental (arts. 296 a 305);

Capítulo IV: De outras falsidades (arts. 306 a 311); e

Capítulo V: Das fraudes em certames de interesse público (art. 311-A).

Existem outros delitos que também lesam a fé pública, como o falso testemunho, a fraude processual, a falsidade de pesos e medidas, a falsa indicação em invólucro ou recipiente etc. O legislador, entretanto, entendeu que tais delitos ofendem outros objetos jurídicos principais, como o patrimônio etc. Por isso, resolveu definir tais crimes em outros títulos do CP.

Capítulo II

DA MOEDA FALSA

Moeda falsa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Concurso de crimes. 7. Circulação de moeda falsa: a) Conceito e objeto jurídico; b) Sujeitos do delito; c) Elementos objetivos do tipo; d) Elemento subjetivo do tipo; e) Momento consumativo e tentativa. 8. Figura típica privilegiada: a) Conceito e objeto jurídico; b) Sujeitos do delito; c) Elementos objetivos do tipo; d) Elementos subjetivos do tipo; e) Momento consumativo e tentativa. 9. Fabricação ou emissão irregular de moeda: a) Conceito e objetividade jurídica; b) Sujeitos do delito; c) Elementos objetivos do tipo; d) Elemento subjetivo do tipo; e) Momento consumativo e tentativa. 10. Desvio e circulação antecipada: a) Conceito e objetividade jurídica; b) Sujeitos do delito; c) Elementos objetivos do tipo; d) Elemento subjetivo do tipo; e) Consumação e tentativa. 11. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 289, caput, do CP, descrevendo o tipo fundamental do crime de moeda falsa, confere ilicitude ao fato de “falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro”.

Protege-se a fé pública, no que diz respeito à confiança que deve existir

na circulação de moedas no País. Constituindo medida e reserva de valor, além de ser meio de troca, têm relevante função na vida social e econômica, merecendo, por parte do Estado, a proteção à confiança que as pessoas nelas depositam.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, a moeda falsa pode ser cometida por qualquer pessoa.

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, pode surgir outro sujeito passivo: a pessoa, física ou jurídica, prejudicada pela conduta.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O comportamento incriminado consiste em falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda em curso no País.

Falsificar significa imitar, fazendo passar por verdadeira o que é moeda falsa, iludindo o sujeito passivo secundário.

A falsificação pode ocorrer mediante:

1ª) fabricação; ou

2ª) alteração.

No primeiro caso, o sujeito faz a moeda; no segundo, modifica a verdadeira. Nas duas hipóteses, a falsificação grosseira elimina o delito. Assim, a fabricação e a alteração devem ser aptas a enganar, fazendo com que seja suposta verdadeira a moeda que, na verdade, é ilegítima. De ver-se, entretanto, que a simples alteração, sem intenção de que a moeda tenha maior valor, não constitui delito. Dessa forma, a alteração do símbolo, da imagem etc. da moeda, permanecendo íntegro o seu valor, não configura delito. Não há também delito no fato de o agente diminuir o seu valor. Como se cuida de crime contra a fé pública, dificilmente é fim em si mesmo, na maioria das vezes se apresentando como meio de locupletamento ilícito. Daí por que se entende inexistir delito em face da

ausência da potencialidade do dano.

A fabricação pode dar-se mediante cunhagem, galvanoplastia ou fusão (moeda metálica) e fotografia, litografia ou tipografia (papel-moeda). A alteração pode ocorrer por meio de tosquia, serradura, raspagem, coloração, substituição de números, letras etc.

Qual o delito do sujeito que apõe em uma nota (papel-moeda) números e letras de outra, com a finalidade de esta apresentar maior valor? Trata-se do crime de moeda falsa (art. 289) ou do delito descrito no art. 290 do CP?

Cuida-se de alteração de moeda, prevista no art. 289, caput. O art. 290, caput, descreve modalidade diversa. No primeiro, existe contrafação, i.e., fabricação total da moeda ilegítima, ou alteração da moeda verdadeira, conferindo-lhe valor mais elevado; no segundo dispositivo, o legislador prevê a formação de moeda com partes de outras com as mesmas características. Na formação inexistente alteração, uma vez que o agente apanha pedaços de cédulas verdadeiras, já sem uso, integrando-as em uma terceira, com aparência de original. Ele cria uma nota com fragmentos de outras.

O objeto material é a moeda metálica ou o papel-moeda de curso legal no País ou no estrangeiro.

Não há distinção quanto à espécie de moeda: pode ser metálica ou papel-moeda (notas de dinheiro). Além disso, o CP estende a proteção penal à moeda estrangeira.

É necessário que a moeda tenha curso legal em nosso país ou no estrangeiro. Moeda de curso legal é a de recebimento obrigatório, imposto por disposição legal.

A moeda deve constituir meio de pagamento. Se já deixou de circular, não possuindo valor de circulação atual, inexistente o crime do art. 289 do CP, podendo subsistir o estelionato.

E se o agente falsifica cédula de reduzido valor econômico (p. ex.: nota

de cinco reais)? Há quem entenda, nesse caso, aplicável o princípio da insignificância, resultando na atipicidade material da conduta. Em nosso modo de ver, como o bem jurídico não é o patrimônio, mas a fé pública, pouco importa a representação econômica da cédula falsificada para fins de configuração do crime. De acordo com o STJ: “Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados” (HC n. 439.958, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe de 1-8-2018).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de falsificar moeda, fabricando-a ou alterando-a. Abrange o conhecimento de que ela tem curso legal no País ou no estrangeiro. Não constitui o delito o fato de o sujeito agir com finalidade artística ou para demonstrar habilidade ou técnica.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O delito atinge o momento consumativo com a fabricação ou alteração da moeda. Não se exige que seja posta em circulação nem que venha a causar dano a outrem.

Para que haja delito, basta a fabricação ou alteração de uma só moeda.

A tentativa é admissível. Ex.: o agente é surpreendido no ato de iniciar a cunhagem da primeira moeda.

6. CONCURSO DE CRIMES

Se, em um só contexto de conduta, o sujeito fabrica ou altera várias moedas, comete crime único. Se em ocasiões diferentes, delito continuado. Se o próprio falsificador introduz a moeda no mercado, responde somente pelo delito de moeda falsa; o fato posterior da introdução é impunível

(progressão criminosa).

7. CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA

a) Conceito e objeto jurídico

Nos termos do art. 289, § 1º, do CP, “nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa”.

Protege-se a fé pública.

b) Sujeitos do delito

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, desde que não seja o autor ou partícipe da falsidade anterior. Quando isso ocorre, o sujeito só responde pelo primeiro delito, constituindo a circulação de moeda post factum impunível.

Sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a vítima do eventual prejuízo.

c) Elementos objetivos do tipo

O tipo apresenta uma formulação casuística, mencionando diversos verbos: importar (fazer entrar o objeto material no País, qualquer que seja o meio: via aérea, marítima ou terrestre), exportar (fazer sair do País), adquirir (obter), vender (dispor), trocar (permutar), ceder (transferir a terceiro), emprestar (entregar provisoriamente a terceiro, com a promessa de devolução), guardar (ter em depósito) e introduzir na circulação (passar a moeda falsa a terceiro como se fosse legítima).

Crime de ação múltipla, responde o sujeito por uma só infração quando realiza as diversas condutas descritas. Assim, comete um só crime o agente que importa, guarda e vende o objeto material.

d) Elemento subjetivo do tipo

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de realizar as condutas típicas, com conhecimento da falsidade da moeda.

e) Momento consumativo e tentativa

O delito atinge a consumação no momento em que o sujeito realiza os comportamentos típicos. Na modalidade de guarda, o delito é permanente, protraindo-se a consumação no tempo.

A tentativa é admissível. Ex.: o agente tenta importar a moeda falsa. Ocorre nas mesmas condições do contrabando.

Se o agente, depois de introduzir na circulação a moeda falsa, por exemplo, adquirindo mercadoria com a cédula espúria, ressarcir o prejuízo do comerciante, pode ser beneficiado com o instituto do arrependimento posterior (CP, art. 16)?

Não. O arrependimento posterior, embora possa ser aplicado em diversos delitos desde que cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, não apenas nos crimes patrimoniais, exige que o sujeito ativo repare o dano (ao bem jurídico) ou restitua a coisa, por ato voluntário, antes de recebida a denúncia ou queixa. No crime de moeda falsa, o objeto jurídico é a fé pública, de tal maneira que o ressarcimento de eventual prejuízo financeiro provocado pela utilização dolosa da moeda falsa não é apto a reparar a lesão à fé pública provocada. Como já decidiu o STJ, sendo este o bem juridicamente protegido, “a vítima é a coletividade como um todo”, o que torna os delitos contra a fé pública “incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída” (STJ, REsp n. 1.242.294/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª TURMA, DJe de 3-2-2015).

8. FIGURA TÍPICA PRIVILEGIADA

a) Conceito e objeto jurídico

De acordo com o § 2º do art. 289 do CP, sujeita-se a pena reduzida “quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade”.

Protege-se a fé pública.

b) Sujeitos do delito

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, desde que não seja o próprio falsificador, uma vez que não estaria de boa-fé.

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, quem recebe o objeto material.

c) Elementos objetivos do tipo

A conduta incriminada consiste em o sujeito, após ter recebido como verdadeira moeda falsa e lhe conhecendo a falsidade, colocá-la em circulação. É indispensável que tenha recebido o objeto material de boa-fé, desconhecendo a falsidade.

É atípico o fato de o sujeito devolver a moeda falsa a quem lhe entregou.

d) Elementos subjetivos do tipo

O tipo apresenta três elementos subjetivos:

1º) O dolo, consistente na vontade livre e consciente de colocar a moeda em circulação.

2º) O conhecimento da falsidade do objeto material.

É necessário que o sujeito tenha plena certeza a respeito da falsidade. Não é suficiente o dolo eventual (dúvida). O conhecimento da falsidade pode ser anterior ou concomitante ao ato da colocação do objeto material em circulação.

3º) O contido na expressão “recebido de boa-fé”. Se o sujeito recebe o

objeto material de má-fé, desde logo lhe conhecendo a falsidade, aplica-se o § 1º.

e) Momento consumativo e tentativa

Consuma-se o delito privilegiado no momento em que o agente coloca a moeda falsa em circulação, i.e., no instante em que a entrega a terceiro.

A tentativa é admissível. Ex.: o agente é surpreendido no momento em que vai entregar a moeda falsa a terceiro, frustrando-se a venda.

9. FABRICAÇÃO OU EMISSÃO IRREGULAR DE MOEDA

a) Conceito e objetividade jurídica

De acordo com o art. 289, § 3º, do CP, constitui delito o fato de o “funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão” fabricar, emitir ou autorizar a fabricação ou emissão:

“I – de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II – de papel-moeda em quantidade superior à autorizada”.

Protege-se a fé pública.

b) Sujeitos do delito

Crime próprio, só determinadas pessoas podem ser sujeitos ativos: o funcionário público, o diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão de moeda. Não se trata de qualquer funcionário público, mas somente daquele que infringe especial dever funcional inerente ao ofício junto à atividade estatal de emissão de moedas.

Sujeito passivo é o Estado.

c) Elementos objetivos do tipo

As condutas proibidas consistem em o sujeito fabricar, emitir ou autorizar a fabricação ou emissão de moeda metálica (inciso I do parágrafo) ou

papel-moeda (inciso II).

Na primeira hipótese, o delito consiste em o agente fabricar, emitir ou autorizar a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao previsto em lei. Título é a proporção que deve existir entre o metal fino e a liga metálica empregados na confecção da moeda. Para que haja delito, é necessário que se produza moeda metálica com título ou peso inferior ao padrão legal.

Não se previu como delito o fato de o sujeito produzir moeda metálica em quantidade superior à autorizada, configurando injustificável lacuna da lei. Note-se que o inciso II da disposição descreve a emissão de papel-moeda em quantidade superior à autorizada. A conduta, por isso, constitui apenas ilícito administrativo. A justificativa de a omissão da incriminação decorrer do pequeno prejuízo financeiro que o fato representaria não convence. Seja papel-moeda ou moeda metálica, deveria constituir delito, nos dois casos, a emissão de quantidade superior à autorizada.

Na segunda hipótese (inciso II), o sujeito produz papel-moeda em quantidade superior à autorizada. A produção de quantidade inferior não constitui delito.

d) Elemento subjetivo do tipo

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de concretizar os elementos objetivos do tipo, abrangendo o conhecimento do excesso ou da violação da autorização, no que diz respeito ao título ou peso, de acordo com a hipótese, da moeda metálica ou do papel-moeda.

e) Momento consumativo e tentativa

Consuma-se o delito no momento em que o sujeito fabrica, emite ou autoriza a emissão do objeto material. Na autorização, não há necessidade de que a conduta seja seguida da emissão ou fabricação da moeda ou do papel-moeda. Trata-se de crime formal, consumando-se com a realização

do comportamento típico, independentemente da produção do resultado pretendido.

A tentativa é admissível.

10. DESVIO E CIRCULAÇÃO ANTECIPADA

a) Conceito e objetividade jurídica

Nos termos do art. 289, § 4º, do CP, configura delito o fato de desviar e fazer circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada.

O objeto jurídico é a fé pública.

b) Sujeitos do delito

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa.

Sujeito passivo é o Estado.

c) Elementos objetivos do tipo

O fato criminoso consiste em desviar e fazer circular, i.e., deslocar o dinheiro de sua destinação legal e introduzi-lo em circulação com abuso (antecipadamente).

O objeto material é a moeda verdadeira.

É irrelevante que o sujeito, com a conduta, venha a obter algum proveito. Este não é previsto no tipo.

d) Elemento subjetivo do tipo

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de desviar e fazer circular a moeda, com conhecimento de que a circulação ainda não estava permitida.

e) Consumação e tentativa

Consuma-se o delito com a entrada da moeda em circulação. Se o sujeito

desvia, porém, por circunstância alheia à sua vontade, e a moeda não entra em circulação, responde somente por tentativa.

11. PENAS E AÇÃO PENAL

No tipo simples de moeda falsa são cominadas reclusão, de três a doze anos, e multa (art. 289, caput).

Para o autor do crime de circulação de moeda falsa (§ 1º), estão previstas as mesmas penas cominadas para o do tipo simples (caput).

A figura típica privilegiada prevê penas mais brandas: detenção, de seis meses a dois anos, e multa (§ 2º).

O tipo qualificado impõe penas mais graves: reclusão, de três a quinze anos, e multa (§ 3º). As mesmas penas estão previstas no § 4º.

A ação penal, em todos os tipos penais, é pública incondicionada.

Crimes assimilados ao de moeda falsa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Tipo qualificado. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O CP, no art. 290, caput, define como crime o fato de “formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros; suprimir, em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização; restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização”.

É protegida a fé pública, procurando o legislador impedir que moedas inutilizadas sejam colocadas criminosamente em circulação.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Tratando-se de funcionário público e tendo cometido o fato aproveitando a facilidade que o cargo lhe atribui, a pena é agravada (art. 290, parágrafo único).

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, quem sofre dano em consequência da conduta.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O crime, em sua feição fundamental, descreve três figuras típicas:

- 1ª) formação de cédula, nota ou bilhete representativo de moeda;
- 2ª) supressão de sinal indicativo de sua inutilização; e
- 3ª) restituição da moeda à circulação.

Formação de cédulas: o sujeito, empregando fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes representativos de moeda verdadeira, forma outra cédula. A conduta incriminada consiste na justaposição, por qualquer forma executória, de partes de outras cédulas ou notas, formando outra capaz de circular como verdadeira. A forma típica não se confunde com a aposição de dizeres e números de uma cédula verdadeira em outra, no sentido de lhe atribuir valor maior, caso em que há alteração (CP, art. 289) e não formação (art. 290).

Supressão de sinal indicativo de inutilização: refere-se o texto a nota, cédula ou bilhete recolhidos, punindo o fato de o sujeito suprimir (por eliminação ou remoção) sinal indicativo de sua inutilização, com a finalidade de restituí-los à circulação. O agente, por qualquer meio executório (lavagem, eliminação de perfurações, raspagem etc.), apaga os sinais de inutilização (riscos em cruz, picotes etc.).

Restituição à circulação: neste caso, o agente restitui à circulação a moeda nas condições apontadas nos itens anteriores (formação de cédulas e supressão de sinal indicativo de sua inutilização). Se o agente forma a moeda ou suprime o sinal de inutilização e depois a restitui à circulação, só responde pela forma típica anterior.

Nos três casos é necessária a potencialidade lesiva do comportamento.

Ao contrário do que ocorre com o crime de moeda falsa (CP, art. 289), a aquisição ou recebimento da moeda nas condições descritas no art. 290, caput, não foi elevado à categoria de crime principal, subsistindo o delito de receptação. Da mesma forma, só há receptação quando o sujeito recebe a moeda, nas condições do art. 290, de boa-fé, e a devolve à circulação.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

Nos verbos formar e restituir, o elemento subjetivo é somente o dolo, consistente na vontade livre e consciente de realizar os elementos objetivos do tipo. No suprimir, além do dolo, exige-se um outro elemento subjetivo do

tipo, contido na expressão “para o fim de restituí-los à circulação” (grifo nosso).

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no momento em que a cédula é formada ou restituída à circulação, ou em que desaparecem os sinais indicativos de sua inutilização.

Na formação de cédula não é necessário que seja posta em circulação, o mesmo ocorrendo na supressão de sinais de inutilização. Na supressão, o crime é formal.

A tentativa é admissível nas três modalidades. Ex.: o agente é surpreendido no ato da lavagem da cédula com substância química, frustrando-se a supressão dos sinais indicativos de sua inutilização.

6. TIPO QUALIFICADO

Nos termos do parágrafo único do art. 290 do CP, as penas são agravadas “se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo”.

A qualificadora incide não só no caso do funcionário público (CP, art. 327) que trabalha na repartição onde a moeda se encontra recolhida, como também na hipótese daquele que aí tem acesso fácil, diante do exercício do cargo. Fundamenta-se a qualificadora na circunstância de ocorrer dupla violação jurídica: à fé pública e aos deveres do cargo público.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

No caput do art. 290, em que está descrito o tipo fundamental, as penas impostas abstratamente são a reclusão, de dois a oito anos, e a multa. No tipo qualificado (parágrafo único), além da multa, a reclusão é de dois a doze anos.

A ação penal é pública incondicionada.

Petrechos para falsificação de moeda

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Absorção penal. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 291 do CP dispõe como delito o fato de “fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda”.

O objeto jurídico é a fé pública, no que concerne à autenticidade da moeda, considerando-se o perigo da falsificação. O legislador erigiu à categoria de crime autônomo os atos preparatórios da falsidade.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

As condutas incriminadas consistem em fabricar (fazer, construir, produzir), adquirir (obter), fornecer (entregar, a título oneroso ou gratuito), possuir (ter a posse), ou guardar (ter em depósito, manter, ter sob a sua guarda) maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Não se trata de qualquer mecanismo, aparelho ou objeto. É necessário que apresente destinação específica, qual seja, a de servir de meio executório de falsificação de moeda, como formas, moldes, fotografias, negativos, clichês, placas, matrizes, cunhos, modelos, lâminas etc. (caso de interpretação analógica). A norma deve ser interpretada restritivamente, evitando-se que, por

intermédio de uma indevida aplicação extensiva, seja alargada a incriminação penal com prejuízo do princípio da reserva legal. Cumpre ao juiz, pois, verificar com exatidão se realmente o objeto material, de forma inequívoca, era destinado à falsificação.

Anote-se que, para o STJ, o crime em questão se configura quando o agente detiver em sua posse petrechos com o propósito de contrafação de moeda, sendo prescindível que o maquinário seja de uso exclusivo para tal fim. Desse modo, o sujeito que possui uma impressora apta a imprimir cédulas de moeda de curso legal, destinada a máquina para tal finalidade, incorre no delito, ainda que também a utilize para outros fins (STJ, REsp n. 1.758.958, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25-9-2018).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de realizar as condutas típicas, abrangendo o conhecimento da destinação específica dos objetos materiais.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

O delito atinge a consumação com a fabricação do objeto material, sua aquisição, fornecimento, posse ou guarda. Nos verbos típicos guardar e possuir, o delito é permanente.

A tentativa é admissível, salvo quanto ao fornecer, caso que pressupõe já tenha o sujeito adquirido, possuído ou guardado o objeto material, com o que o delito já teria atingido a consumação.

6. ABSORÇÃO PENAL

Se o sujeito possui o instrumento de falsificação e depois, usando-o, fabrica ou falsifica moeda, responde somente pelo delito do art. 289 do CP, que absorve o do art. 291.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas abstratamente cominadas são a reclusão, de dois a seis anos, e a multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Emissão de título ao portador sem permissão legal

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Recebimento ou utilização de títulos como dinheiro. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 292, caput, do CP, descrevendo a forma típica simples ou fundamental, constitui delito o fato de o sujeito “emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago”. O parágrafo único, definindo um tipo privilegiado, também considera criminoso, com pena atenuada, o fato de “quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos” no tipo fundamental.

Tutela-se a fé pública, evitando a concorrência de títulos ao portador em detrimento da moeda de curso legal no País.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Tratando-se de funcionário público, é inaplicável a qualificadora do art. 295 do CP, que incide somente sobre os crimes descritos nos arts. 293 e 294.

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, quem sofre o dano.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo emitir, que significa lançar em circulação nota, bilhete, ficha, vale ou título ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Não basta a simples criação do papel de

crédito. É necessário colocá-lo em circulação. Às vezes, na maioria dos casos, subscritor (criador) e emissor (quem coloca o título em circulação) são a mesma pessoa. Nada impede, entretanto, que subscritor e emissor sejam pessoas diversas, hipótese em que, dependendo do elemento subjetivo de cada um, pode surgir concurso de agentes.

Título ao portador é aquele que configura obrigação de pagar certa quantia a quem o apresente como possuidor. É transferível por simples tradição (entrega) manual, sem exigência de endosso ou autorização do emitente. Subentende-se, pela natureza do título, que o emitente se obriga, pelo seu conteúdo, a quem quer que se apresente como possuidor (portador). Não são, porém, todos os títulos ao portador que servem de objeto material do crime, uma vez que a norma os especifica: conferem tipicidade ao fato somente os títulos que contêm promessa de pagamento em dinheiro. Ficam de fora, em face disso, os que representam mercadorias, serviços, utilidades etc., como os warrants e conhecimentos de depósito, vales particulares, passagens de veículos etc. Assim, a norma incriminadora não alcança os chamados “vales íntimos” ou “vales de caixa”, papéis que se entrega a alguém como lembrete para que forneça mercadoria, serviço ou dinheiro. Esses papéis, não possuindo atribuição legal de função de crédito, escapam à tipicidade.

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

A descrição legal contém um elemento normativo, contido na expressão “sem permissão legal”. Tal permissão pode ser genérica, como nos casos de letra de câmbio, cheque, ações de sociedades anônimas, ou específica, quando se exige uma autorização especial para cada caso de emissão de títulos.

A ausência do elemento normativo do tipo, quando presente a permissão legal, não exclui a ilicitude da ação, como se costuma afirmar. Antes disso, i.e., antes de excluir o segundo requisito do delito, que é a antijuridicidade

da conduta, afasta a própria tipicidade do fato. De modo que não há crime por ausência de tipicidade do fato, ficando prejudicada, por desnecessária, a questão da ilicitude. Claro que, havendo permissão de quem de direito, o fato é lícito. Muito antes do tema da licitude, porém, o fato deixou de ser crime por não ser típico.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de emitir o título, vale etc., com conhecimento da ausência de permissão legal.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o crime no momento em que o título é colocado em circulação. Trata-se de crime formal, consumando-se quando o título é entregue a terceiro, independentemente da produção de dano ou da obtenção de lucro ilícito.

A tentativa é admissível. Ex.: subscrito o título, a ação do sujeito é interrompida no momento em que está prestes a entregá-lo a terceiro, colocando-o em circulação.

7. RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS COMO DINHEIRO

Nos termos do parágrafo único do art. 292 do CP, comete também delito quem “recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos” no tipo fundamental (caput).

O comportamento incriminado consiste em receber ou utilizar como dinheiro nota, bilhete, vale etc. Pune o CP não só quem emite tais títulos como quem os recebe, como se fossem dinheiro.

O elemento subjetivo do tipo consiste no dolo, vontade livre e consciente de receber ou utilizar os títulos referidos como se fossem dinheiro, abrangendo o conhecimento da ausência de permissão legal de emissão.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

No caput do art. 292 do CP, em que está descrita a figura fundamental, são impostas penas alternativas: detenção, de um a seis meses, ou multa. No parágrafo único, que define uma forma privilegiada de crime, a pena privativa de liberdade é mais branda: detenção, de quinze dias a três meses, ou multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Capítulo III

DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

Da falsidade de papéis públicos

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Conflito aparente de normas. 7. Causa de aumento de pena. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 293 do CP, constitui delito o fato de “falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I – selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;

II – papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;

III – vale postal;

IV – cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;

V – talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;

VI – bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município”.

Descrevendo o tipo fundamental de crime, o CP protege a fé pública, no

que concerne à garantia da legitimidade de títulos e outros papéis públicos.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Se for funcionário público, poderá incidir a qualificadora do art. 295 do CP, se presentes os seus requisitos típicos.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta simples e fundamental consiste em falsificar, fabricando-os ou alterando-os, os objetos materiais (selos destinados a controle tributário, papéis de crédito público, vales postais etc.). Fabricar significa fazer, produzir, criar materialmente o objeto. Alterar quer dizer modificar. No primeiro caso há contrafação, i.e., o sujeito cria, faz o papel. No segundo, não há contrafação; o objeto já existe, entretanto é modificado para passar a conter valor maior. Nas duas hipóteses, o sujeito falsifica o papel, dando-lhe a aparência de verdadeiro a fim de facilitar-lhe a circulação.

O inciso I se referia a “selo postal, estampilha, papel selado ou qualquer papel de emissão legal, destinado à arrecadação de imposto ou taxa”. Com a entrada em vigor da Lei n. 11.035, de 22 de dezembro de 2004, o dispositivo passou a abranger os seguintes objetos materiais: “selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo” (caso de interpretação analógica).

A Lei n. 6.538/78 considera selo a “estampilha postal, adesiva ou fixa, bem com a estampa produzida por meio de máquina de franquear correspondência, destinadas a comprovar o pagamento da prestação de um serviço postal” (art. 47).

O selo pode ser adesivo, fixo e estampado. O primeiro é a estampilha avulsa que colocamos na carta; o segundo é o emitido na sobrecarta; o último é o produzido por máquina de franquear.

Tem-se em vista o selo nacional em circulação. O retirado ou recolhido não integra o tipo.

No que se refere a selo postal mencionado na anterior redação do inciso I, aplica-se a Lei n. 6.538/78, que cuida da matéria em seu art. 36.

Estampilha é o selo que possui a finalidade de provar o pagamento de impostos ou taxas, aposto em recibos, títulos, requerimentos etc. Quando é fixa, configura o papel selado, referido no dispositivo.

O inciso II menciona “papel de crédito público, que não seja moeda de curso legal”.

Papel de crédito público é o título da dívida pública, como as apólices, as obrigações, letras do Banco Central etc., sejam nominativos ou ao portador. A emissão pode ser federal, estadual ou municipal. É necessário que não configurem moeda de curso legal no País.

O inciso III menciona o “vale postal”.

Vale postal corresponde ao título de crédito de emissão dos correios, em face de depósito da quantia devida, que deve ser paga na mesma agência ou em outra, a favor da pessoa indicada (depositante ou terceiro). Pode ser ordinário (requisição de particulares), oficial (requisição de entidades federais, estaduais ou municipais) e de serviço (pedido do próprio correio, por exigência do seu próprio serviço).

Esse inciso foi revogado e substituído pelo art. 36 da Lei n. 6.538/78.

O inciso IV menciona “cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público”.

Cautela de penhor constitui título de crédito. Efetuado o pagamento da quantia emprestada, sua apresentação obriga a entrega do objeto empenhado. Trata-se de documento público expedido pelas caixas econômicas. Caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro

estabelecimento mantido por entidade de direito público corresponde ao documento expedido e entregue ao depositante, contendo anotações das importâncias depositadas.

O inciso V refere-se a “talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável” (caso de interpretação analógica).

São papéis relacionados com a receita de rendas públicas ou com depósito ou cauções de responsabilidade do Estado. De ver-se que a Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu como crime contra a ordem tributária o fato de “falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável” (art. 1º, III). Talão é a parte que pode ser destacada do caderno ou livro oficial, permanecendo um canhoto com as mesmas anotações. Recibo corresponde à declaração de quitação de uma dívida. Guia é o documento expedido por entidade arrecadadora ou a ela endereçado para efeito de recolhimento de importâncias. Alvará é o documento com destinação de autorizar o recolhimento de rendas públicas ou depósito ou caução por que o poder público seja responsável.

O inciso VI menciona “bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município”.

Não há exigência de que a empresa seja da União, Estado ou Município. Pode ser privada. Entretanto, deve ser administrada pelo poder público. O transporte pode ser aéreo, marítimo, terrestre ou fluvial. É irrelevante a natureza do veículo: aviões, ônibus, navios, trens etc.

Bilhete é o título que contém o contrato de transporte de pessoas. Passe é o documento que contém a permissão de acesso ao local de embarque ou o próprio transporte. Conhecimento é o documento que comprova a entrega de objetos para o transporte, permitindo a sua posterior retirada.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, que na espécie corresponde à vontade livre e consciente de falsificar os objetos materiais, fabricando-os ou alterando-os.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O delito atinge o momento consumativo com a efetiva falsificação do objeto material, precisamente com a sua fabricação ou alteração. Independe de qualquer consequência.

A tentativa é admissível, uma vez que a conduta admite fracionamento. Ex.: o agente é surpreendido no instante em que está iniciando a alteração de um selo, frustrando-se a falsificação.

6. USO DE PAPÉIS PÚBLICOS FALSIFICADOS E DEMAIS CONDU EQUIPARADAS

Dispõe o art. 293, § 1º, I, do CP que incorre na mesma pena cominada no caput quem “usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados” mencionados na norma incriminadora.

O verbo usar deve ser interpretado em sentido amplo. Usa o papel público falsificado não só quem o emprega em sua destinação específica, fazendo-o passar como se fosse verdadeiro, como quem o compra ou dele dispõe, empresta, troca etc.

As condutas típicas consistentes em guardar, possuir ou deter foram acrescentadas pela Lei n. 11.035, de 22 de dezembro de 2004, suprimindo lacuna existente no dispositivo legal.

Se a mesma pessoa é o falsificador e o usuário, o crime de uso é absorvido (princípio da consunção no concurso aparente de normas, aplicando-se o tema do fato posterior impunível).

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que corresponde à vontade livre e consciente de usar o papel público, com conhecimento de sua falsidade.

Consuma-se o delito com o efetivo uso do objeto material, ou quando o agente dele se apossa, obtém a sua guarda ou detenção. A tentativa não é possível, uma vez que, com o primeiro ato de uso, o delito já se encontra consumado. Nas demais modalidades típicas (guardar, possuir ou deter), entretanto, admite-se a forma tentada.

O inciso II do § 1º do art. 293, acrescentado pela Lei n. 11.035, de 22 de dezembro de 2004, tipifica a conduta de quem: importa (introduz no Brasil), exporta (remete para o exterior), adquire (obtém), vende (aliena), troca (permuta), cede (dá, entrega), empresta (dá com obrigatoriedade de devolução), guarda (abriga), fornece (provê, supre) ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. A pena é a mesma do caput, ou seja, reclusão, de dois a oito anos, e multa.

O inciso III, também acrescentado pela Lei n. 11.035, de 22 de dezembro de 2004, descreve comportamentos do agente que, no exercício de atividade comercial (§ 5º) ou industrial, importa (introduz no Brasil), exporta (remete para o estrangeiro), adquire (obtém), vende (aliena), expõe à venda (exibe visando alienar), mantém em depósito (retém, conserva ou mantém o objeto material à sua disposição), guarda (abriga), troca (permuta), cede (dá, entrega), empresta (dá com obrigatoriedade de restituição), fornece (provê, supre), porta (traz consigo) ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio produto ou mercadoria em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado ou sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. A pena é semelhante à do caput.

É de ver que se equipara à atividade comercial, para os fins do mencionado inciso: “qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências” (§ 5º).

Nas modalidades equiparadas, contidas nos incisos II e III, o elemento

subjetivo do tipo é o dolo, que corresponde à vontade livre e consciente de realizar o comportamento descrito na norma incriminadora, com conhecimento da falsidade do objeto material ou da inexistência de selo oficial obrigatório conforme a legislação tributária.

A consumação se dá com a efetiva importação, exportação etc. do selo falsificado destinado a controle tributário (inciso II); com a importação, exportação etc., no exercício de atividade comercial ou industrial, de produto ou mercadoria no qual foi aplicado selo destinado a controle tributário, falsificado (inciso III, a); ou, ainda, quando as ações descritas no tipo são praticadas em produtos ou mercadorias sem o selo oficial, nos casos em que a lei tributária determina sua aposição (inciso III, b). Admite-se a tentativa, porquanto se trata de crimes plurissubsistentes. É de ver, entretanto, que sua ocorrência é difícil, uma vez que o legislador pune como executórios de crime consumado atos que regra geral são meramente preparatórios de condutas mais graves. Assim, v.g., o sujeito impedido de entregar a mercadoria com selo falsificado, caso em que haveria tentativa de venda, é punido pelo porte.

7. SUPRESSÃO DE SINAIS INDICATIVOS DE INUTILIZAÇÃO DE PAPEIS PÚBLICOS

De acordo com o § 2º do art. 293 do CP, constitui crime “suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização”.

O tipo faz referência a objeto material verdadeiro. Aqui não se trata de fabricar ou alterar selo, estampilha etc., mas de papéis autênticos contendo carimbo ou sinal com indicação de sua inutilização.

A conduta incriminada consiste em suprimir (remover, tirar, eliminar) o sinal apostado pelo poder público, nos documentos indicados, de sua inutilização.

O primeiro elemento subjetivo do tipo é o dolo, vontade livre e consciente

de suprimir o carimbo ou o sinal indicativo de inutilização do objeto material. Exige-se outro elemento subjetivo do tipo, contido na expressão “com o fim de torná-los novamente utilizáveis” (os objetos materiais). A ausência de qualquer desses dois elementos conduz à atipicidade do fato.

Consuma-se o delito com a efetiva supressão do sinal ou carimbo indicativo de inutilização do objeto material, não sendo necessária a nova utilização. A tentativa é admissível. Ex.: o sujeito é surpreendido no ato de remover um carimbo de inutilização de um selo, frustrando-se a supressão.

8. USO DE PAPÉIS PÚBLICOS COM INUTILIZAÇÃO SUPRIMIDA

Nos termos do § 3º do art. 293 do CP, “incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior”.

A conduta incriminada é o uso de papel público em que foi suprimido o carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, vontade livre e consciente de usar o papel público, com conhecimento da supressão do carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização.

O delito atinge a consumação com o uso efetivo do objeto material. A tentativa é inadmissível, tendo em vista que, com o primeiro ato de uso, o delito já está consumado.

9. RESTITUIÇÃO À CIRCULAÇÃO

De acordo com o § 4º do art. 293 do CP, comete também delito, com pena atenuada, “quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo” (o caput) “e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração”.

Trata-se de um tipo privilegiado que pode ser concretizado por qualquer

pessoa (delito comum).

Incrimina-se o comportamento de quem, tendo recebido de boa-fé papéis falsificados ou alterados, vindo a tomar conhecimento da falsificação ou alteração, os usa ou os restitui à circulação. Não constitui delito restituir o objeto material à própria pessoa de quem o sujeito o recebeu.

O tipo reclama três elementos subjetivos:

1ª) o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de usar ou restituir à circulação o objeto material;

2ª) contido na expressão “embora recebido de boa-fé”;

3ª) expresse na elementar “depois de conhecer a falsidade ou alteração”.

A consumação ocorre com o uso efetivo ou com a restituição do objeto material à circulação, i.e., com a sua entrega a terceiro.

A tentativa, na conduta de usar, é inadmissível, uma vez que, com o primeiro ato de usar, o delito já se encontra consumado. No verbo restituir, ela é possível.

10. TIPO QUALIFICADO

Se o sujeito ativo do delito é funcionário público, tendo cometido o delito prevalecendo-se do cargo, aplica-se a causa de aumento de pena do art. 295 do CP.

11. PENAS E AÇÃO PENAL

Nos tipos descritos no caput, incisos e § 1º do art. 293, as penas são a reclusão, de dois a oito anos, e a multa. Nos casos dos §§ 2º e 3º, são cominadas reclusão, de um a quatro anos, e multa. No tipo privilegiado (§ 4º), as penas são alternativas: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Tratando-se de funcionário público, havendo abuso da condição funcional, as penas são agravadas de um sexto (art. 295).

A ação penal é pública incondicionada.

Petrechos de falsificação

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Conflito aparente de normas. 7. Causa de aumento de pena. 8. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 294 do CP, constitui delito o fato de “fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior” (selo postal, estampilhas, papel selado etc. destinados à arrecadação de tributos; papel de crédito público que não seja moeda de curso legal; vale postal; cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento bancário mantido por entidade de direito público; talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável; bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pelo poder público).

O bem jurídico protegido é a fé pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

As ações incriminadas são: fabricar (manufaturar, fazer, produzir), adquirir (obter), fornecer (prover, proporcionar), possuir (ter a posse) e guardar (abrigar).

As condutas recaem sobre os objetos materiais, quais sejam, objetos especialmente destinados à falsificação dos papéis mencionados no art. 293. Não alcança qualquer um, mas somente o que tem especial destinação: o de falsificar papéis, tais como carimbos, máquinas, prelos, modelos, matrizes etc.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de realizar as condutas típicas, com conhecimento da destinação específica do objeto que constitui meio de falsificação.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a realização das condutas típicas. Nos verbos possuir e guardar, o delito é permanente.

A tentativa é admissível. Ex.: o sujeito é surpreendido antes de terminar a fabricação de um carimbo destinado à falsificação.

6. CONFLITO APARENTE DE NORMAS

Se o sujeito fabrica o petrecho e comete falsificação, só responde pelo último delito, ficando absorvido o primeiro.

7. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Nos termos do art. 295 do CP, se o sujeito é funcionário público e comete o delito prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.

Não basta a simples condição de funcionário público (CP, art. 327), sendo necessário que esta qualidade lhe tenha proporcionado e favorecido a prática delituosa.

8. PENA E AÇÃO PENAL

A pena abstratamente imposta é de reclusão, de um a três anos, e multa

(art. 294), aumentada de sexta parte no caso de ser o sujeito ativo funcionário público, tendo-se prevalecido do cargo para a prática do delito (art. 295).

Na forma simples, afigura-se cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Capítulo IV

DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação de selo ou sinal público

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Uso de selo ou sinal falsificado. 7. Utilização ilícita de selo ou sinal legítimo. 8. Emprego ilícito de símbolos identificadores da Administração Pública. 9. Tipo qualificado. 10. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 296, caput, do CP, descrevendo o tipo fundamental do crime de “falsificação de selo ou sinal público”, dispõe como delito o fato de “falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I – selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II – selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião”.

Tutela-se a fé pública, com referência a selos ou sinais, que, não configurando documentos, a estes são acoplados, conferindo-lhes autenticidade.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo falsificar, por fabricação ou alteração, matéria que já estudamos no delito de moeda falsa, a que remetemos o leitor (CP, art. 289).

A objetividade material visa, em primeiro lugar, ao selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município (inciso I). Ele não se confunde com o selo postal ou estampilha. Configura uma peça de metal ou sinete, apresentando dizeres, emblemas ou sinais. É necessário que seja destinado a autenticar atos oficiais, i.e., documentos oficiais.

O objeto material, em segundo lugar, consiste em selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou autoridade, ou sinal público de tabelião. Refere-se o tipo a qualquer outro selo ou sinal usado por autoridades administrativas ou pessoas de direito público e também ao sinal empregado por tabeliães no ato de autenticar documentos. Quanto ao selo ou sinal, abrange o referente a autarquia ou entidade paraestatal, uma vez atribuído pela legislação, mas não se estende ao estrangeiro. Sinal público de tabelião corresponde à sua assinatura especial, diversa da verdadeira (sinal raso).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de fabricar ou alterar, assim falsificando-os, os objetos materiais referidos no tipo. No inciso I, é necessário que o dolo abranja o conhecimento da destinação especial do selo.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a fabricação ou alteração do objeto material.

Admite a forma tentada. Ex.: o sujeito é surpreendido no instante em que está fabricando um selo público, frustrando-se a falsificação.

6. USO DE SELO OU SINAL FALSIFICADO

Nos termos do art. 296, § 1º, do CP, nas mesmas penas cominadas no caput da disposição, incorre “quem faz uso do selo ou sinal falsificado” (inciso I).

O CP, na incriminação, não pune o fato de qualquer uso, uma vez que o verbo deve ser interpretado à luz dos dois incisos do caput do dispositivo. Cuida-se do uso que se refere à destinação regular e normal do selo ou sinal de natureza pública, i.e., o emprego do objeto material para autenticar documentos oficiais.

A simples detenção do objeto material não configura infração penal.

Se o usuário é o próprio falsificador, o delito de uso fica absorvido pela falsificação, constituindo um fato posterior impunível (princípio da consunção no conflito aparente de normas).

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, correspondendo à vontade livre e consciente de usar o objeto material, abrangendo o conhecimento de sua falsidade.

A consumação ocorre com o uso efetivo do selo ou sinal. A tentativa é inadmissível, tendo em vista que, com o primeiro ato de uso, o delito já está consumado.

7. UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE SELO OU SINAL LEGÍTIMO

De acordo com o art. 296, § 1º, II, do CP, nas mesmas penas impostas no caput da disposição incorre “quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio”.

Nesta modalidade típica inexistente falsificação de selo ou sinal. Eles são verdadeiros. O seu uso, contudo, é indevido.

Crime comum, pode ser realizado por qualquer pessoa. Normalmente, entretanto, visa o legislador a punir o funcionário público, incidindo a qualificadora do § 2º.

Se o sujeito obteve o objeto material de forma ilícita, como furto, roubo etc., haverá concurso material de crimes.

O primeiro elemento subjetivo do tipo é o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de utilizar o objeto material, abrangendo o conhecimento do caráter abusivo da conduta. A tipicidade subjetiva, contudo, não se esgota no dolo. O tipo exige outro elemento subjetivo, contido na expressão “em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio”. A ausência de qualquer dos dois elementos afasta a tipicidade do fato.

O tipo apresenta um elemento normativo, expresso no atuar indevidamente do agente, significando que o comportamento deve ser ilícito, antijurídico. Se devido, o fato é atípico.

O resultado visado pelo agente é alternativo: obtenção de proveito próprio ou alheio ou prejuízo de outrem. Não é necessário que a vontade esteja dirigida nos dois sentidos (produção de prejuízo e obtenção de proveito). É suficiente que o sujeito vise a um desses dois resultados. O prejuízo e o proveito podem ser materiais ou morais.

Consuma-se o delito no momento da utilização. Ao contrário do que entendem os autores brasileiros, não se exige, para a consumação, que o sujeito cause o prejuízo ou obtenha o proveito. Nesse aspecto, o delito é formal. Consuma-se com a conduta tendente ao resultado, mas não se exige a sua produção. Note-se que a expressão “em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio” constitui elemento subjetivo do tipo. É suficiente, pois, que o agente realize a conduta com a intenção de produzir um desses dois resultados. Sua produção, contudo, não é necessária. Isso ocorre em todos os tipos que possuem a expressão “em proveito próprio ou alheio” ou “em benefício próprio ou alheio” (crimes dos arts. 161, § 1º, I, 173, 174 e 305 do CP). Nas hipóteses típicas citadas, não há discrepância na doutrina de que o delito é de consumação antecipada, atingida com a realização da conduta, sendo prescindível a produção do resultado, i.e., a

obtenção efetiva do proveito. Atendendo a uma só interpretação sistemática, esse mesmo princípio deve ser adotado no tema do momento consumativo do crime de utilização indevida de selo ou sinal verdadeiro.

A tentativa é impossível, uma vez que, com o primeiro ato de utilização do objeto material, o delito está consumado. Tentar utilizar já é utilizar.

8. EMPREGO ILÍCITO DE SÍMBOLOS IDENTIFICADORES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, acrescentou o inciso III ao § 1º do art. 296 do CP, que remete às mesmas penas impostas no caput a “quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública”.

Marca é o designativo que indica produtos e serviços. Não se confunde com o nome comercial. Exemplos para o caso: Linha Azul, um software destinado a pessoas jurídicas, clientes da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública; Diário Oficial, que é o órgão de publicidade do governo federal e de muitos governos estaduais e municipais.

O Código de Propriedade Industrial, em seu art. 123, cita três tipos de marca: a) a marca de produto ou serviço; b) a marca de certificação; e c) a marca coletiva.

A marca de produto ou serviço é a usada para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

A marca de certificação é a utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

A marca coletiva é a usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Logotipo é um agrupamento de letras agregadas num só tipo, constituindo sigla ou palavra representativas de marca comercial ou de fabricação. Exs.: MPM, utilizado nas décadas de 1980 e 1990 para identificar o Curso Preparatório de Carreiras Jurídicas Damásio de Jesus.

Sigla é o ajuntamento das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação ou título. Exemplos, para o caso do dispositivo: INSS, CVM, dentre outros.

As condutas vinculam-se à alteração, que significa modificar os símbolos identificadores, bem como à falsificação ou ao uso indevido. A conduta é vinculada, e o crime é comum, podendo, assim, ser praticado por qualquer pessoa. A tentativa é admissível para as condutas alterar e falsificar, sendo discutível na conduta usar.

Dada a amplitude de conceitos que o tipo enseja, lançando mão, inclusive, de conceitos do Direito Comercial, a interpretação analógica se torna necessária.

9. TIPO QUALIFICADO

Incide sobre a pena uma causa de aumento “se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo” (CP, art. 296, § 2º).

O aumento de pena recai sobre todos os comportamentos descritos no art. 296 (incisos e parágrafos).

Não basta que o autor seja funcionário público. Exige-se que tenha realizado o delito prevalecendo-se do cargo por ocasião ou facilidade.

10. PENAS E AÇÃO PENAL

Nos tipos dos incisos I e II do caput do art. 296 e seu § 1º, as penas são de reclusão, de dois a seis anos, e multa. No tipo qualificado (§ 2º), as penas são aumentadas de um sexto.

A ação penal é pública incondicionada.

Falsificação de documento público

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Tipo qualificado. 8. Falsificação de documento público previdenciário (art. 297, §§ 3º e 4º). 9. Falsificação de documento público e estelionato. 10. Falsificação de documento público e crimes afins. 11. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 297, caput, do CP, definindo o tipo simples de “falsificação de documento público”, dispõe como crime o fato de “falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro”.

É protegida a fé pública, no que concerne aos documentos de natureza pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime comum, admitindo a figura de qualquer pessoa como sujeito ativo. Cuidando-se de funcionário público, tendo cometido o fato com abuso de seus deveres, incide a qualificadora do § 2º do art. 297.

Se o sujeito falsifica e usa o documento, responde somente pelo falso (v. o item “falsificação de documento público e crimes afins” no n. 9).

Sujeito passivo é o Estado. Se, eventualmente, a conduta vier a causar dano a terceiro, este será sujeito passivo secundário.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Estão previstas duas condutas típicas alternativas:

1ª) falsificar, no todo ou em parte, documento público; ou

2ª) alterar documento público verdadeiro.

A primeira modalidade típica, em que o verbo é falsificar, indica a contrafação, i.e., a formação total ou parcial do documento. O agente forma o documento por inteiro (contrafação total) ou acresce dizeres, letras ou números ao documento verdadeiro (contrafação parcial).

Na segunda conduta típica, o verbo é alterar documento público verdadeiro. Neste caso, o agente modifica o conteúdo do objeto material (modificação de dizeres, signos, números, letras etc.). Não deve haver supressão de palavras, números, letras etc. Se isso ocorre, incide a norma do art. 305 do CP (supressão de documento).

Nos dois casos, é imprescindível que a falsificação seja idônea a iludir terceiro. Se é grosseira, perceptível à primeira vista, inexistente o delito em face da ausência da potencialidade lesiva do comportamento.

O fato deve ser potencialmente danoso. Requer seja capaz de produzir dano. O falso inofensivo não constitui delito.

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

O tipo exige um elemento normativo, na modalidade de expressão jurídica, contido na referência ao “documento público”.

Documento público, que corresponde também ao objeto material do delito, é o elaborado por funcionário público, no exercício de sua função, de acordo com a legislação.

Pode ser nacional ou estrangeiro, desde que, no exterior, ele seja considerado documento público, satisfeitas as condições para sua validade entre nós. Como características, apresentam-se a qualidade jurídica de quem o elabora (funcionário público); sua competência em razão do local, da matéria e do ofício; e a forma legal.

O documento público se classifica em:

1ª) formal e substancialmente público;

2ª) formalmente público e substancialmente privado.

O primeiro é elaborado por funcionário público, no exercício de suas funções, tendo conteúdo de natureza pública. Ex.: atos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário etc. O segundo é redigido ou elaborado por funcionário público, porém refere-se a interesse de natureza privada. Exs.: atos de escritões, capitães de navio, corretores. O telegrama, transmitido por funcionário público, no exercício de suas funções, quando diz respeito a assunto de conteúdo público, constitui documento público. O telegrama do particular, porém, não é documento público (mas particular). Assim, a falsificação de telegrama particular não se enquadra na incriminação legal. De ver-se, porém, que haverá esse delito quando a falsificação recair sobre as anotações oficiais que ele contiver.

Constituem também documentos públicos os traslados, fotocópias com autenticação e as certidões. As cópias não autenticadas (fotocópias, xerox), no plano criminal, não são consideradas documentos.

Nos termos do art. 297, § 2ª, do CP, “para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular”. Assim, são equiparados a documentos públicos:

1ª) o documento emitido por entidade paraestatal (as autarquias);

2ª) o título ao portador ou transmissível por endosso: notas promissórias, cheques, duplicatas, letras de câmbio, conhecimentos de depósito etc.;

3ª) as ações de sociedade comercial (sociedade anônima e sociedade em comandita por ações): preferenciais, ordinárias, nominativas ou ao portador etc.;

4ª) os livros mercantis: obrigatórios ou facultativos; e

5ª) o testamento particular (hológrafo).

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, que corresponde à vontade livre e consciente de falsificar documento público ou alterar documento público verdadeiro, abrangendo o conhecimento da potencialidade lesiva da conduta. O tipo não exige, além do dolo, nenhum outro elemento subjetivo.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O delito atinge a consumação com a falsificação ou alteração do objeto material, independentemente de outro resultado.

A tentativa é admissível. Ex.: o agente é surpreendido no momento em que está iniciando a alteração de um documento público verdadeiro, mediante a inserção de palavras. Frustrando-se a alteração, ocorre mera tentativa.

7. TIPO QUALIFICADO

Nos termos do § 1º do art. 297 do CP, a pena é agravada “se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo”.

Não basta a qualidade jurídica do sujeito ativo, sendo necessário que o comportamento tenha sido realizado em face da facilidade que o exercício da função lhe permite.

8. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PREVIDENCIÁRIO (art. 297, §§ 3º E 4º)

A Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2000, com entrada em vigor em 15 de outubro de 2000, inseriu o § 3º no art. 297 do CP, dispondo que “nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: I – na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório; II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado

ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita; e III – em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado”. E, no § 4º, prossegue afirmando que “nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços”.

Distingue-se esse tipo do definido no art. 337-A, pois neste há a finalidade específica da sonegação de contribuições previdenciárias.

Inserir é conduta do próprio agente (inserção direta ou falsidade imediata). Já quando se faz inserir, há a atuação mediante a conduta de terceiro (inserção indireta ou falsidade mediata).

Trata-se de delito formal, com condutas comissivas, em que basta a inserção de dados para consumá-lo, sendo admissível a tentativa.

No inciso I, os elementos espaciais são a folha de pagamento ou outro documento de informações. Devem possuir a destinação específica de fazer prova perante a previdência social. O elemento normativo do tipo volta-se aos segurados obrigatórios, como tais considerados aqueles catalogados no art. 9º do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social).

Quanto ao inciso II, o elemento espacial é a Carteira de Trabalho e Previdência Social e os documentos que devam produzir efeito perante a previdência social. Os objetos materiais desse delito devem produzir efeito, e a declaração, além de falsa ou diversa, deve ocorrer por escrito.

Sobre o inciso III, o objeto material deve ser um documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, cabendo, aqui, a interpretação analógica. A declaração não precisa ser escrita, mas deve ser aquela que deveria ter constado.

Saliente-se que, em todos os crimes nos quais se encontra a falsidade, esta deve ser idônea, i.e., ter a capacidade de enganar, de ser potencialmente lesiva. Não pode, portanto, ser grosseira, sob pena de atipicidade.

O § 4º do art. 297 é um crime remetido, pois refere-se às condutas do § 3º. A omissão incide ou sobre o nome do segurado e seus dados pessoais, ou sobre a sua remuneração, ou sobre a vigência do seu contrato de trabalho, ou, ainda, sobre a sua prestação de serviço.

9. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO

Há quatro orientações a respeito da tipicidade do fato de o sujeito, após falsificar um documento, empregá-lo na prática de estelionato:

1ª) O crime de falsificação de documento público absorve o estelionato.

De acordo com essa corrente, a falsidade que ingressa na extensão da elementar “qualquer outro meio fraudulento”, empregada na descrição típica do estelionato, é o falso vulgar, sem os contornos do crime de falsidade. Quando ocorrem os elementos do crime de falsificação de documento público, o agente responde somente por este delito, que, por ser mais grave, absorve o estelionato. Essa posição, na doutrina estrangeira, encontra fundamento em Impallomeni². Considera-se que a fé pública é o objeto jurídico imediatamente lesado, e, tratando-se de um crime formal (o de falsidade), o prejuízo se insere na fase de exaurimento, não constituindo delito autônomo. Na lição de Nélson Hungria, “a obtenção de lucro ilícito mediante falsum não é mais que um estelionato qualificado pelo meio (Impallomeni). É um estelionato que, envolvendo uma ofensa à fé pública, adquire o nomen juris de ‘falsidade’”³.

2ª) O crime de estelionato absorve o crime de falsificação de documento público.

Para essa posição, a falsidade constitui simples meio de execução do

estelionato, ingressando na elementar “qualquer meio fraudulento”, contida na figura típica do art. 171, caput, do CP. Em face disso, nos termos do princípio da consunção, o estelionato absorve a falsidade. É o que se contém na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. Esse é o entendimento amplamente dominante nos dias atuais.

Importante registrar que a absorção, segundo posição sumulada e reiteradamente confirmada, depende da relação que houver entre o falso e o estelionato. Se a falsidade se exaurir, por completo, no crime patrimonial, restará por ele absorvida. É o que se dá no exemplo corriqueiro do sujeito que falsifica a assinatura de um cheque, fazendo-se passar pelo correntista, e, com isso, adquire mercadoria de uma loja. O título de crédito falsificado esgotou todo o malefício que poderia produzir na compra efetuada e não se presta a aplicar qualquer outro “golpe”.

Quando, porém, o documento falso utilizado para cometer o estelionato tiver potencial de gerar prejuízo a outras pessoas, servindo como meio executório a futuras infrações penais, haverá concurso de crimes. De acordo com o STJ: “Quando a conduta típica praticada como meio para a obtenção do principal intento criminoso ultrapassa os limites deste último, sendo apta a continuar atingindo ou ameaçando o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção, mas na configuração do concurso de crimes” (HC n. 162.404, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe de 19-12-2011). No caso concreto analisado pelo STJ, a ré havia utilizado documento de identidade e cartão de crédito falsos, fazendo-se passar por terceiro, para realizar duas compras de produtos em diferentes estabelecimentos empresariais. Pela natureza do documento utilizado (carteira de identidade), mostrou-se que a falsidade extravasava o estelionato cometido, mantendo sua potencialidade lesiva, pois apta a enganar outras vítimas. Tratava-se, no caso examinado, de imputação de uso de documento público falsificado em concurso material

com estelionato.

3ª) Há concurso formal entre estelionato e falsificação de documento público.

Entende-se haver concurso formal entre estelionato e falsificação de documento público, apoiando-se em Magalhães Noronha: "Há unidade de ação, de desígnio e pluralidade de bens jurídicos violados"⁴. Trata-se de posição isolada.

4ª) Há concurso material entre estelionato e falsificação de documento público.

Essa posição, que vê concurso material entre estelionato e falsificação de documento público, era defendida por Heleno Cláudio Fragoso⁵, que posteriormente alterou sua posição, entendendo haver somente estelionato⁶. Chegou a ser acolhida, na década de 1950, pelo STF. É orientação igualmente isolada.

De acordo com nosso entendimento, a questão deve ser focalizada sob dois aspectos:

1ª) técnico; e

2ª) prático.

Pelo prisma técnico, aplicando-se princípios doutrinários, existe concurso material de crimes: falso e estelionato. Não é possível reconhecer um conflito aparente de normas e, diante disso, aplicar o princípio da progressão criminosa, considerando-se um só delito absorvente do ante factum ou do post factum impunível. O fato antecedente impunível, segundo a doutrina, não existe quando, embora ocorrendo entre duas condutas relação de meio e fim, ofende bens diversos pertencentes a sujeitos passivos diferentes. No caso, a falsidade atinge a fé pública; o estelionato, o patrimônio. No primeiro, o Estado é o sujeito passivo; no segundo, o lesado. Além disso, o falso não é um meio executório necessário ou normal para a prática do estelionato. Por fim, incidem sobre objetos materiais

diferentes: no falso, sobre o documento; no estelionato, sobre a pessoa iludida e a vantagem ilícita. Não seria o estelionato um post factum impunível? Não cremos. De acordo com a doutrina prevalente, essa espécie só ocorre quando o fato posterior é cometido contra o mesmo bem jurídico e do mesmo sujeito passivo, sem causar nova ofensa, requisitos ausentes na hipótese.

Afastada a unidade criminosa, resta saber qual a espécie de concurso: material ou formal?

O concurso formal exige unidade de conduta (CP, art. 70). Na espécie, existe pluralidade de comportamentos (da falsificação e do estelionato), normalmente, distanciados no tempo. Suponha-se que o sujeito falsifique o objeto material em janeiro e engane a vítima em dezembro: como considerar a presença de uma só ação? Para isso, teríamos que apresentar a falsidade e o estelionato como atos de uma mesma conduta. Ora, é difícil aceitar a falsificação só como um ato. Mais difícil ainda acreditar que o estelionato, delito plurissubsistente, com toda sorte de artimanha e engodo, além da concretização da obtenção da vantagem, seja, na espécie, meramente um ato. Na verdade, falso e estelionato, embora isoladamente possam ser cometidos por atos, elevam-se à categoria de condutas, com todos os contornos de fatos típicos quando presentes as outras elementares. Por isso, entendemos haver concurso material de delitos.

É possível que, em casos excepcionais, estejam a falsidade e o estelionato tão interligados no tempo que devam ser considerados atos de uma só ação, diante disso conduzidos ao concurso formal. Ainda assim, não poderíamos fugir à consideração da ausência da unidade de desígnio, ocorrendo um concurso formal imperfeito, com aplicação da regra, quanto à pena, do concurso material (CP, art. 70, caput, 2ª parte). Se o agente quer falsificar um documento e, com ele, cometer estelionato, cremos que não se pode falar em unidade de ideação.

No sentido prático, de ver-se que a jurisprudência, diante da gravidade das penas impostas aos delitos de falso e da aspereza das disposições sobre o concurso material de crimes, ou reconhece a existência de uma só infração penal ou a presença do concurso formal. Trata-se de uma justa preocupação: a louvável intenção de suavizar as regras do CP sobre o cúmulo material. Força é reconhecer, então, sob o aspecto prático, que a consideração de um só delito ou do concurso formal, se não é doutrinariamente correta, tem aceitação prevalente na jurisprudência sob a inspiração de princípios de Política Criminal.

10. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E CRIMES AFINS

Se na mesma pessoa reúnem-se as figuras de falsário e usuário, ela responde por um só delito: o de falsidade, que absorve o de uso (CP, art. 304). O uso, nesse caso, funciona como post factum impunível, aplicando-se o princípio da consunção na denominada progressão criminosa (v. o tema no estudo do crime de uso de documento falso).

Se a finalidade do sujeito, ao falsificar o documento, é a prática de sonegação fiscal, funcionando como delito-meio, há também um só crime, o de sonegação fiscal, em que fica absorvida a falsidade.

Quanto à falsificação de atestado ou certidão de conclusão ou aprovação escolar para efeito de matrícula em escola superior, remetemos o leitor ao estudo do art. 301, § 1º, do CP, onde tratamos da matéria.

11. PENAS E AÇÃO PENAL

Para o tipo simples, definido no caput do art. 297, estão previstas duas penas: reclusão, de dois a seis anos, e multa. Tratando-se de sujeito ativo funcionário público, tendo cometido o delito prevalecendo-se do cargo, incide o aumento de pena de sexta parte (§ 1º).

A ação penal é pública incondicionada.

Falsificação de documento particular

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Falsificação de documento particular, estelionato e crimes afins. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 298 do CP, constitui delito o fato de “falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro”.

Protege-se a fé pública, no que diz respeito à autenticidade dos documentos particulares.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, a falsificação de documento particular pode ser realizada por qualquer pessoa.

Sujeito passivo é o Estado. A pessoa que, eventualmente, vem a sofrer dano deve ser considerada sujeito passivo secundário.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

As condutas incriminadas estão descritas nos verbos falsificar e alterar, matéria já estudada no crime de falsificação de documento público, a que remetemos o leitor.

O objeto material é o documento particular, como tal considerado o que não se inclui na elementar “documento público” simples (CP, art. 297, caput) ou por equiparação (§ 2º do mesmo dispositivo).

Documento é o escrito elaborado por um autor certo, em que se manifesta a narração de fato ou a exposição de vontade, possuindo

importância jurídica. Não tem formalidade especial, é feito por um particular, não sofrendo a intervenção de um funcionário público. Entretanto, o documento público, quando nulo por vício de forma, é considerado documento particular.

O documento apresenta os seguintes característicos:

1ª) Forma escrita: não abrange as fotografias, cópias não autenticadas de documentos, pinturas, gravações etc. A escrita deve ter sido aposta em coisa móvel.

2ª) Autor determinado: a escrita anônima não configura documento.

3ª) Deve conter uma manifestação de vontade ou a exposição de um fato: a simples aposição de uma assinatura em papel em branco não constitui documento. Da mesma forma, não consistem em documentos os papéis com escritos ininteligíveis ou sem sentido.

4ª) Relevância jurídica: é necessário que o escrito possa causar consequências no campo jurídico (características apresentadas por Heleno Cláudio Fragoso). Não constituem documentos os papéis inócuos, os que retratam fatos ou manifestações de vontade sem importância jurídica.

O documento particular falsificado, para integrar a tipicidade penal, deve ser idôneo a causar engano. Cuidando-se de falsificação grosseira, perceptível à primeira vista, não existe delito, uma vez ausente a capacidade de ofender a fé pública. É necessária, pois, sua potencialidade lesiva. Não é delito a falsificação que, por não ser potencialmente lesiva, ressaente-se da capacidade de causar dano. O delito não exige a produção de dano efetivo. Entretanto, requer a possibilidade de sua produção.

A Lei n. 12.737, de 2012, inseriu no dispositivo legal o parágrafo único, determinando que, para fins de falsificação de documento particular, a este se equipara o cartão de crédito ou débito.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de falsificar ou alterar o documento particular verdadeiro, abrangendo o conhecimento da potencialidade lesiva do comportamento. Diante de nossa legislação, o tipo não exige nenhum outro elemento subjetivo.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O delito atinge o momento consumativo com a falsificação, total ou parcial, ou a alteração do objeto material.

Admite a figura da tentativa. Ex.: o agente é surpreendido, frustrando-se a alteração, no instante em que está acrescentando letras a um documento particular. Não se completando a alteração, trata-se de tentativa.

6. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, ESTELIONATO E CRIMES AFINS

Remetemos o leitor ao estudo dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e uso de documento falso (art. 304), onde cuidamos dos seguintes temas, com exposição aplicável ao delito de falsificação de documento particular: concurso entre falsificação de documento e estelionato, falsificação e uso, sonegação fiscal e falsidade como crime-meio.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas cominadas são a reclusão, de um a cinco anos, e multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Falsidade ideológica

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Abuso de folha em branco. 5. Simulação. 6. Elementos subjetivos do tipo. 7. Momento consumativo e tentativa. 8. Falsidade de registro civil. 9. Crime cometido por funcionário público. 10. Concurso de crimes. 11. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 299, caput, do CP, constitui crime de “falsidade ideológica” o fato de “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

Protege-se a fé pública, no que se refere à autenticidade do documento em seu aspecto substancial. Leva-se em consideração o conteúdo intelectual (ideal) do documento, não a sua forma, ao contrário da falsidade documental, em que se leva em conta o aspecto material. Aqui, o documento é formalmente perfeito, sem contrafação ou alteração. Sobre a diferença entre falsidade material e ideológica, remetemos o leitor à parte introdutória do estudo dos crimes contra a fé pública, onde tratamos do assunto.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, a falsidade ideológica pode ser cometida por qualquer pessoa. Tratando-se de funcionário público, incide a qualificadora do parágrafo único do art. 299.

Há dois sujeitos passivos:

1ª) sujeito passivo principal: o Estado;

2ª) sujeito passivo secundário: a pessoa que sofre ou pode sofrer o dano referido no tipo.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Incidindo sobre documento público ou particular, já apreciados nos crimes dos arts. 297 e 298 do CP, a falsidade ideológica pode ser realizada mediante três condutas incriminadas:

1ª) omitir declaração que devia constar do objeto material;

2ª) inserir nele declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita; e

3ª) fazer inserir nele declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.

No primeiro caso, a conduta é omissiva. Devendo constar do documento determinada declaração a respeito de fato ou manifestação de vontade, o sujeito a omite (não a menciona), total ou parcialmente.

No segundo comportamento típico, o agente insere, introduz no documento uma declaração que não corresponde à verdade ou que é diferente daquela que devia estar escrita (inserção direta). Neste caso, o sujeito atua pessoalmente, ele mesmo inserindo no objeto material a declaração inverídica (falsidade imediata).

Na terceira hipótese típica, o agente realiza a conduta mediante a atuação de terceiro, induzindo-o a inserir no documento a declaração falsa ou diferente daquela que dele devia constar (inserção indireta; falsidade mediata).

A falsidade deve ser idônea, i.e., possuir a capacidade de enganar. A falsidade grosseira, desde logo perceptível, não configura o delito. Deve ser potencialmente lesiva, capaz de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

Em qualquer das formas típicas de conduta, a falsidade deve recair sobre

“fato juridicamente relevante”, i.e., a declaração falsa ou a omissão deve, por si só ou em comparação com outros fatos ou circunstâncias, ser capaz, direta ou indiretamente, de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica de direito público ou privado. É preciso que a declaração configure essência do ato ou do documento. Assim, uma simples mentira, sem potencialidade para criar, alterar ou extinguir um direito, não constitui o crime. Em suma: a falsidade deve recair sobre fato ou circunstância cuja veracidade o documento tem a destinação de provar.

Cuidando-se de sujeito ativo particular, é tranquila na doutrina a exigência, para que exista delito, de que tenha o dever jurídico de declarar a verdade. Inexistente esse dever, não há falar-se em falsidade ideológica. A declaração do particular, para configurar a infração penal, deve ser capaz, em si mesma, de concretizar o documento. Se cumpre ao funcionário que a recebe verificar a veracidade de seu conteúdo (documento sujeito a verificação oficial), inexistente o crime. Ex.: declaração falsa em requerimento de atestado de residência.

4. ABUSO DE FOLHA EM BRANCO

É possível que o sujeito a quem foi confiada uma folha assinada em branco ou com espaços em branco, ou que dela tenha a posse ou detenção, venha a preenchê-la com declaração falsa. Nosso CP, ao contrário de outros, não definiu especialmente o fato. Embora sua Exposição de Motivos afirme que constitui falsidade ideológica, a solução não é assim tão fácil. A dificuldade reside em que a folha de papel assinada em branco, por não apresentar conteúdo, não pode ser considerada documento. Daí a perplexidade doutrinária em enquadrar a conduta na falsidade documental. O tema, entretanto, deve ser resolvido pela consideração de que a folha de papel assinada em branco torna-se documento no momento em que é preenchida, ou são preenchidos os seus espaços em branco. Além disso, a questão deve ser solucionada em face das circunstâncias em que o papel

ingressou na disponibilidade do agente. Por isso, segundo a doutrina, as hipóteses diversas devem ser resolvidas de acordo com os seguintes princípios:

1ª) se a folha de papel, parcial ou totalmente, foi confiada ao agente mediante propósito legítimo do signatário, para preenchimento de acordo com sua orientação, a declaração abusiva configura falsidade ideológica;

2ª) se o objeto material foi entregue ao agente para ficar sob sua guarda, ou se foi obtido mediante expediente ilícito (furto, roubo, apropriação indébita etc.), o preenchimento abusivo constitui falsidade material (arts. 297 ou 298);

3ª) se, no primeiro caso, houve revogação do mandato ou extinção da obrigação ou faculdade de preencher a folha, incide o crime de falsidade material (princípios expostos por Heleno Cláudio Fragoso).

5. SIMULAÇÃO

A simulação, desde que capaz de criar obrigação, prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, constitui falsidade ideológica (o tema é controvertido na doutrina). Ocorre quando as expressões contidas no documento são genuínas; a ideia, entretanto, é falsa. Ex.: em separação judicial, o varão, para prejudicar a mulher, em conluio com terceiro, simula a existência de dívidas, emitindo fraudulentamente notas promissórias (ex. de Nélon Hungria). De ver-se que, conforme o caso, a simulação pode configurar outros delitos, como sonegação fiscal, duplicata simulada, crime falimentar etc.

6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de concretizar os elementos objetivos do tipo. Não basta, porém, a vontade de alterar a verdade. Exige-se um segundo elemento subjetivo do tipo, que é a intenção de lesar contida na expressão “com o fim de prejudicar direito,

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. Sobre o tema, remetemos o leitor à parte introdutória do estudo dos crimes contra a fé pública, onde tratamos da matéria.

7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

O delito atinge a consumação com a omissão ou inserção direta ou indireta da declaração, i.e., no momento em que o documento, contendo a falsidade, se completa. Crime formal, não exige a produção de dano, bastando que a conduta se apresente capaz de produzir prejuízo a terceiro.

Quanto à tentativa, é inadmissível na conduta omissiva, uma vez que o delito é omissivo próprio. É possível, porém, nos comportamentos de inserir ou fazer inserir.

8. FALSIDADE DE REGISTRO CIVIL

Nos termos do parágrafo único do art. 299 do CP, a pena é agravada no caso de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil. Os assentamentos estão previstos na Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (inscrições de nascimento, casamento, emancipações, óbitos, declarações de ausência, interdições, abrangendo as averbações).

O agravamento da pena é justificado em face dos interesses de natureza moral e material que tais assentamentos envolvem.

O crime de registro de filho alheio como próprio (“adoção à brasileira”), que antes se enquadrava no parágrafo único do art. 299, hoje está descrito no art. 242 do CP.

O fato de “promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente” constitui delito descrito no art. 241 do CP.

A prescrição, tratando-se de falsificação no registro civil, na modalidade que recai sobre a pretensão punitiva (CP, art. 109), somente começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido da autoridade pública

(CP, art. 111, IV) ou em que se tornou notoriamente divulgado.

9. CRIME COMETIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Agrava-se também a pena no caso de o crime ter sido praticado por funcionário público, prevalecendo-se do cargo.

Não é suficiente, para a incidência da causa de aumento de pena, a qualidade jurídica do sujeito ativo. É necessário que se tenha prevalecido do cargo, i.e., que o exercício da função lhe tenha proporcionado ocasião e facilidade de cometimento do delito.

10. CONCURSO DE CRIMES

Se o usuário é o próprio falsário, responde por um só crime: o de falsidade, em que fica absorvido o uso (CP, art. 304). Nesse caso, o uso constitui um post factum impunível (princípio da consunção na progressão criminosa). Sobre o tema, v. estudo do crime do art. 304 do CP.

Se a finalidade do agente é a prática do crime de sonegação fiscal, aplica-se a Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (o delito de sonegação fiscal absorve a falsidade ideológica).

Quanto à questão do concurso entre falsidade ideológica e estelionato, remetemos o leitor ao estudo do crime de falsidade de documento público (CP, art. 297), onde apreciamos a matéria.

11. PENAS E AÇÃO PENAL

No tipo fundamental ou simples, tratando-se de documento público, são cominadas reclusão, de um a cinco anos, e multa; cuidando-se de documento particular, a reclusão é de um a três anos, além da multa (art. 299, caput). Se o sujeito é funcionário público, tendo cometido o delito com infringência de seus deveres, as penas são agravadas de um sexto (parágrafo único).

A ação penal é pública incondicionada.

	Falso reconhecimento de firma ou letra	
--	---	--

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 300 do CP, constitui delito o fato de “reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja”.

Cuida-se de uma modalidade típica de falsidade ideológica, protegendo-se a fé pública contra a autenticação falsa praticada por quem exerce função pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser sujeito ativo o funcionário público. Mas não qualquer e sim somente aquele que tem a função específica de reconhecimento de firma ou letra, conferindo fé pública à sua afirmação (tabelião de notas, escreventes de tabelionato, oficial de registro civil, cônsules etc.). Admite-se, entretanto, a participação de sujeito não qualificado (particular).

Se o mesmo sujeito comete esse delito e depois usa o documento falsificado, somente responde por um crime, o de falsidade (CP, art. 300), ficando absorvido o de uso (art. 304).

Sujeito passivo é o Estado (sujeito passivo principal); secundariamente, quem sofre a lesão material (sujeito passivo secundário).

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo reconhecer, que significa afirmar a veracidade da assinatura ou letra da pessoa e conferir fé ao documento em que ela é aposta. Firma é a assinatura; letra é o manuscrito da pessoa. O reconhecimento pode ser autêntico, por semelhança ou indireto. Autêntico é o reconhecimento quando o funcionário vê a pessoa assinar ou escrever; é por semelhança quando se compara a assinatura ou letra que o cartório possui em seus papéis com a que lhe é apresentada; é indireto quando duas pessoas, por escrito, declaram que a letra ou a assinatura é de certa pessoa. Em regra, o reconhecimento é semiautêntico: a assinatura ou letra é aposta longe do funcionário, afirmando seu autor ou terceiro a sua veracidade.

A conduta incriminada consiste em reconhecer, como verdadeira, assinatura ou letra falsa. O falso reconhecimento é sempre realizado por escrito e versa, na grande maioria das vezes, sobre a firma (assinatura). Raros são os casos de reconhecimento de letra, como o do testamento do próprio punho.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

Consiste no dolo, vontade livre e consciente de reconhecer a assinatura ou letra, sabendo-a falsa. É suficiente o eventual. A conduta meramente negligente é atípica.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

O crime se consuma com o ato do reconhecimento, independentemente de qualquer resultado (delito formal).

A tentativa é admissível. Ex.: consciente da falsidade da assinatura, o funcionário está preenchendo os campos do carimbo de reconhecimento, sendo impedido de ultimá-lo.

6. PENAS E AÇÃO PENAL

Tratando-se de documento público, a pena é de reclusão, de um a cinco anos, além da multa; se o documento é particular, a pena é de reclusão, de um a três anos, além da multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Certidão ou atestado falso

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Falsidade material de atestado ou certidão. 8. Figura típica qualificada. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 301, caput, do CP, definindo o tipo simples, dispõe como crime o fato de “atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem”.

Esse delito é uma modalidade típica de falsidade ideológica. Protege-se a fé pública, procurando o legislador evitar que o funcionário público, em razão do ofício, venha a fornecer atestado ou certidão ideologicamente falsa e capaz de fazer com que terceiro obtenha qualquer vantagem indevida perante a Administração Pública.

Tratando-se de falsidade material, aplica-se o § 1º do art. 301 (n. 7 do sumário).

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser sujeito ativo o funcionário público no exercício do ofício.

Se a mesma pessoa falsifica e usa o objeto material, responde por um só delito, o de falsidade, ficando absorvido o de uso (CP, art. 304).

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Os núcleos do tipo são os verbos atestar e certificar. Atestar significa provar, afirmar alguma coisa em caráter oficial. Certificar quer dizer convencer da certeza, verdade de alguma coisa, também de natureza pública.

Atestado é um documento que traz em si o testemunho de um fato ou circunstância. O signatário o emite em face do conhecimento pessoal a respeito de seu objeto, obtido, na espécie do tipo, no exercício de suas atribuições funcionais.

Certidão (ou certificado) é o documento pelo qual o funcionário, no exercício de suas atribuições oficiais, afirma a verdade de um fato ou circunstância contida em documento público ou transcreve o conteúdo do texto, total ou parcialmente.

A diferença entre ambos reside em que a certidão tem por fundamento um documento guardado em repartição pública (ou nela em tramitação), enquanto o atestado constitui um testemunho ou depoimento por escrito do funcionário público (na hipótese do tipo) sobre um fato ou circunstância.

A atestação ou a certificação deve ser originária, i.e., deve o funcionário formar, originariamente, o atestado falso. Por isso, a reprodução falsa (total ou parcial) ou cópia de documento oficial não constitui esse delito, podendo configurar falsidade material.

A lei precisa o objeto da certidão ou atestado falso: fato ou circunstância. Não basta, porém, que a falsidade recaia sobre fato ou circunstância. É necessário que seja pressuposto da obtenção de um benefício de natureza pública: obtenção de cargo público, isenção de ônus ou de serviço público ou qualquer outra vantagem. Exs.: atestado de antecedentes para inscrição em concurso público; certificado de serviço prestado ao Tribunal do Júri, como jurado; certificado de serviço prestado na Marinha para isenção de prestação de serviço militar etc. A parte final da disposição apresenta um caso de interpretação analógica. Há uma fórmula inicial casuística

(obtenção de cargo público ou isenção de ônus ou de serviço de caráter público) seguida de uma fórmula genérica ("ou qualquer outra vantagem"). A outra vantagem deve ter a mesma natureza dos fatos mencionados na exemplificação. Diante disso, a outra vantagem deve ter caráter público. A não ser assim, casos graves de falsidade ideológica (CP, art. 299 e seu parágrafo único) seriam punidos com as penas brandas do art. 301. E isto não está na vontade da lei.

O fato e a circunstância objeto da atestação devem estar relacionados com a pessoa a que são destinados. Além disso, não haverá delito se não constituírem requisitos da obtenção da vantagem de natureza pública pretendida.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de atestar fato ou circunstância nas condições descritas no tipo.

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Está na falsidade do atestado ou certidão. Cumpre que seja abrangida pelo dolo. Caso contrário, o fato é atípico.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no momento em que o atestado ou certidão falsa é entregue a terceiro (destinatário ou interessado). Não comungamos da opinião dos que entendem que o delito atinge a sua consumação com a formação do documento, não sendo necessária a sua entrega a terceiro. Para nós, se o funcionário permanece com o atestado falso no bolso, sem usá-lo, ele ainda não ingressou no mundo jurídico, sendo, por isso, segundo acreditamos, incorreta a afirmação da consumação.

Crime formal, independe do resultado pretendido. Assim, há delito ainda que o atestado ou certidão não sejam empregados para o fim desejado ou

que, usados, não permitam, por qualquer circunstância, a obtenção da vantagem de natureza pública pretendida.

Quanto à tentativa, remetemos o leitor ao que dissemos sobre o tema na falsidade ideológica.

7. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO

Nos termos do art. 301, § 1º, do CP, constitui crime “falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem”.

Nesse delito, ao contrário do tipo descrito no caput, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o próprio funcionário público expedidor do documento. Além disso, não se trata de falsidade ideológica, como no tipo fundamental, mas de falsidade material: o sujeito falsifica, total ou parcialmente, ou altera o teor de certidão ou de atestado verdadeiro.

O objeto material é a certidão ou certificado emitido por funcionário público, uma vez que o parágrafo deve ser interpretado à luz do caput do dispositivo.

O elemento subjetivo é o dolo, de natureza igual ao do caput, acrescido de um elemento subjetivo do tipo: a conduta da falsidade é realizada a fim de o documento constituir “prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter” as vantagens de natureza pública descritas na figura típica.

Quanto à expressão “qualquer outra vantagem”, entendemos, como ficou consignado em relação ao fato do caput do dispositivo, que deve ser de natureza pública (caso de interpretação analógica). Por isso, cuidando-se de vantagem de natureza privada, deve-se atentar para o delito de falsidade material do art. 297 do CP.

A falsificação de certificado de aprovação em curso colegial ou de

madureza para fins de inscrição e admissão em curso superior constitui crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Trata-se de documento público, uma vez que é assinado por funcionário público. Mas o fato não se enquadra no art. 301, § 1º, uma vez que, neste delito, a vantagem deve ser de natureza pública. Na hipótese, a vantagem é de ordem privada, subsumindo-se o fato, segundo nosso entendimento, no crime do art. 297 do CP. Com efeito, a hipótese não se enquadra quer na fórmula casuística, quer na fórmula genérica final do dispositivo. Não se trata de prova de fato ou circunstância que torne apto alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público. E nem se enquadra em outra vantagem qualquer, tendo em vista, como ficou consignado, a exigência da natureza pública. Sobre o assunto e nesse sentido há preciosa lição do Des. Andrade Junqueira, contido em voto publicado na RT, 551:329-32.

A consumação ocorre com a efetiva falsificação, admitindo-se a figura da tentativa (ex.: o agente é surpreendido no ato material da falsificação).

8. FIGURA TÍPICA QUALIFICADA

Nos termos do § 2º do art. 301, além da pena detentiva, aplica-se também multa no caso de o crime vir a ser cometido com finalidade lucrativa.

A qualificadora é aplicável aos tipos do caput e do § 1º.

O tipo exige uma circunstância subjetiva, contida na expressão “com o fim de lucro”. Ausente, afasta-se a qualificadora, subsistindo as figuras do caput ou do § 1º.

Não há necessidade de que o agente, em razão da conduta incriminada, venha a obter lucro. Basta esse fim de agir.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

No caput do art. 301 está prevista a pena de detenção, de dois meses a

um ano. No § 1º, a pena de detenção é mais grave: de três meses a dois anos. No tipo qualificado, além da pena privativa de liberdade prevista no caput e no § 1º, impõe-se multa (§ 2º).

A ação penal é pública incondicionada.

Falsidade de atestado médico

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Tipo qualificado. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 302, caput, do CP, constitui delito o fato de “dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso”.

Trata-se de uma forma típica de falsidade ideológica, que, pela sua natureza, atenta contra a fé pública. Procurou o legislador impedir que o médico forneça atestado falso.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ter o médico como executor da conduta. Não fica impedida, entretanto, a participação de terceiro não qualificado.

Tratando-se de médico funcionário público, de aplicar-se o crime do art. 301 do CP, desde que o atestado habilite o terceiro a obter qualquer vantagem de natureza pública.

Se o médico, após a falsidade, usar o atestado, responde somente pelo delito de falsidade, ficando absorvido o de uso (CP, art. 304).

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, quem sofre o dano.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta incriminada consiste em o sujeito ativo, que precisa ser médico, fornecer (dar) atestado falso. Deve ser atestado por escrito, materialmente autêntico e ideologicamente falso. Precisa ser fornecido no exercício da profissão, exigindo-se, por isso, que seu conteúdo esteja relacionado com o fato que compete ao médico verificar. De modo geral,

cuida-se de atestado de saúde ou de constatação de uma doença. Pode ser também referente a fatos diversos, como a morte, causa de uma moléstia, causa da morte, os efeitos de uma doença ou lesão física etc. O atestado, que pode ser total ou parcialmente falso, incide sobre fato ou circunstância verdadeiros ou fictícios. Assim, pode o médico atestar a existência de um fato irreal ou negar a existência de um fato ou circunstância reais. Além disso, o falso, em nossa legislação, não está circunscrito a incidir somente sobre fatos; pode recair sobre opinião ou juízo sobre eles, desde que diga respeito a algo juridicamente importante. Não há delito quando a falsidade recai sobre circunstâncias irrelevantes, como o local ou a hora de realização do exame médico.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

No tipo fundamental, descrito no caput do art. 302 do CP, o elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de fornecer o atestado, sabendo-o total ou parcialmente falso. Pouco importa o fim e o agente, não reclamando a figura penal nenhum outro elemento subjetivo.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no momento em que o médico entrega o atestado falso ao interessado.

A tentativa é admissível. Ex.: após preencher falsamente o atestado, o médico é surpreendido no ato de entregá-lo ao interessado, frustrando-se a entrega.

6. TIPO QUALIFICADO

De acordo com o parágrafo único do art. 302, impõe-se também multa “se o crime é cometido com o fim de lucro”.

Para a existência da qualificadora, não se exige que o médico receba a vantagem indevida. Basta a intenção de obter lucro com o fornecimento do

atestado falso.

Aqui não é suficiente o dolo. O tipo requer uma circunstância subjetiva, sem a qual subsiste a forma simples do crime: a finalidade de lucro.

Tratando-se de funcionário público e cometido o fato em razão do ofício, o crime será de corrupção passiva (CP, art. 317).

7. PENAS E AÇÃO PENAL

No tipo simples é imposta a pena de detenção, de um mês a um ano; no qualificado, são cominadas duas penas: detenção, de um mês a um ano, e multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Uso para fins de comércio. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui crime o fato de “reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça” (CP, art. 303, caput). Comete o mesmo delito quem, “para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica” (parágrafo único).

Esse artigo, entretanto, encontra-se revogado, substituído pelo art. 39 da Lei n. 6.538, de 22 de junho de 1978, que versa sobre serviços postais e apresenta definições semelhantes: “Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica de valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração estiver visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça” (caput). “Incorre nas mesmas penas quem, para fins de comércio, faz uso de selo ou peça filatélica de valor para coleção, ilegalmente reproduzidos ou alterados” (parágrafo único).

É protegida a fé pública, no que concerne à tutela de selos e peças filatélicas, e a confiança de seus colecionadores.

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa.

Sujeito passivo principal é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada pela adulteração ou alteração.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta recai sobre selo ou peça filatélica (objetos materiais do crime). O selo pode ser usado ou novo, nacional ou estrangeiro. Não se protege, entretanto, qualquer selo. Deve ser o já recolhido ou empregado no correio. Pode também ser o novo, mas desde que tenha valor para coleção. Por "peça filatélica" devemos entender os blocos de selos, as "provas", cartões, carimbos comemorativos etc. Seja selo ou peça, impõe-se, para a tipicidade do fato, que possua valor filatélico.

Os comportamentos incriminados são reproduzir, que significa criar, produzir, multiplicar, fazer igual, e alterar, que quer dizer mudar, contrafazer parcialmente, modificar (exs.: alterar a cor, mudar o picote ou a data etc.). Não existe crime, por atipicidade do fato, quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do objeto material.

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Encontra-se na exigência de que o objeto material tenha valor para coleção, impondo ao juiz a tarefa de apreciação valorativa.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente dirigida à reprodução ou alteração do objeto material, abrangendo o conhecimento de seu valor filatélico.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

A consumação ocorre com a reprodução ou alteração do objeto material.

Admite a figura da tentativa. Ex.: o sujeito é surpreendido no ato de alteração do selo ou peça filatélica.

7. USO PARA FINS DE COMÉRCIO

Nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.538/78, também

comete crime “quem, para fins de comércio, faz uso de selo ou peça filatélica de valor para coleção, ilegalmente reproduzidos ou alterados”.

Incrimina-se a posse do objeto material de valor filatélico ilegalmente reproduzido ou alterado para fins de comércio.

Há um só delito quando o usuário é o próprio falsificador ou reproduutor indevido.

O verbo incriminado é usar, que significa empregar. A simples posse, sem finalidade lucrativa, é fato atípico.

Trata-se de crime formal ou de consumação antecipada. Consuma-se com o uso, ainda que o sujeito não consiga vender, trocar etc. o objeto material.

O fato é punido a título de dolo, vontade livre e consciente de usar o objeto material. Exige-se, além dele, um elemento subjetivo do tipo, contido na expressão “para fins de comércio”.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

No caput do art. 39 da Lei n. 6.538/78, que corresponde ao antigo art. 303, caput, do CP, estão previstas as penas de detenção, até dois anos, e multa (de três a dez dias-multa); no parágrafo único, as penas são as mesmas.

A ação penal é pública incondicionada.

Uso de documento falso

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Concurso de crimes. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 304 do CP, constitui delito o fato de “fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302” do CP (falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, falso reconhecimento de firma ou letra, falsidade ideológica de certidão ou atestado, falsidade material de atestado ou certidão e falsidade de atestado médico).

O objeto da tutela penal é a fé pública, proibindo o tipo penal o uso de documentação falsa.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, o uso de documento falso pode ser cometido por qualquer pessoa, desde que não seja o autor da falsificação. Nesse caso, o conflito aparente de normas se resolve pelo princípio da consunção, sendo o uso um *post factum* impunível.

Sujeito passivo é o Estado. Eventualmente, pode ser a pessoa prejudicada pelo delito.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta punível consiste em fazer uso de documento falso como se fosse verdadeiro. Assim, incrimina-se o uso de documento público ou particular material ou ideologicamente falso, de documento com falso reconhecimento de firma ou letra, de atestado, certidão ou atestado médico falsos.

Usar documento falso significa empregá-lo em sua finalidade probatória especial, i.e., empregá-lo como prova do fato de importância jurídica a que diz respeito, como se fosse verdadeiro.

O uso pode ser de qualquer natureza, seja judicial ou extrajudicial. Trata-se de conduta comissiva, inexistindo emprego mediante omissão. É necessário que seja documento falso, não constituindo delito o emprego da fotocópia ou cópia.

Exige-se o uso efetivo. Não constituem delito a simples alusão ao documento, a referência para fim de ostentação etc.

Trata-se de crime remetido, i.e., delito que faz referência a outro. No caso, a existência do uso depende do falso. Assim, faltando um elemento típico do crime de falso, não há delito de uso.

O uso de documento que o sujeito sabe ou deve saber falso ou inexato na prática de crime contra a ordem tributária se encontra descrito no art. 1º, IV, da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que impõe a pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de fazer uso dos documentos referidos no tipo. Abrange o conhecimento da falsidade documental.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com o efetivo uso do documento falso, independentemente da obtenção de proveito ou da produção de dano.

A tentativa é inadmissível, uma vez que o delito já se encontra consumado com o primeiro ato de uso. O simples tentar usar já é uso, estando consumado o crime.

6. CONCURSO DE CRIMES

A reiteração do uso do documento em relação à mesma pessoa ou a pessoas diversas leva à continuidade delitiva. Há crime único no emprego, na mesma conduta, de vários documentos falsos.

E se o sujeito, para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, emprega documento falso: responde por estelionato ou por uso de documento falso? Ou por ambas as infrações, em concurso?

Há quatro posições a respeito:

- 1ª) o estelionato absorve o uso de documento falso;
- 2ª) o uso de documento falso absorve o estelionato;
- 3ª) existe concurso formal de crimes; e
- 4ª) há concurso material de infrações.

A respeito do tema, remetemos o leitor ao estudo do crime de “falsificação de documento público” (CP, art. 297), onde, apreciando o assunto, apresentamos os fundamentos das diversas posições e a nossa orientação.

Se o sujeito falsifica o documento e em seguida usa-o, responde por um só delito: o de falsidade, em qualquer de suas formas típicas (falsificação de documento público ou particular, falsidade ideológica etc.). A unidade complexa que, segundo a doutrina, é considerada uma só conduta, composta de duas ações simples (falsificar e usar o documento), apresenta os requisitos exigidos para que, na progressão criminosa, seja aplicado o princípio do “post factum” impunível: unidade de objeto material, ofensa ao mesmo bem jurídico (fé pública), de titularidade do mesmo sujeito passivo (o Estado). O delito de falso possui a potencialidade lesiva que o uso do objeto material procura concretizar. Consumado o falso, o sujeito realiza o fato posterior do uso, atingindo o mesmo bem jurídico e do mesmo sujeito passivo, procurando tirar proveito da conduta antecedente, mas sem causar

ofensa jurídica diversa. Não se trata de crime progressivo, uma vez que este exige unidade simples de comportamento.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena imposta abstratamente ao usuário do documento falso é a mesma do crime antecedente (crimes dos arts. 297 a 302 do CP).

A ação penal é pública incondicionada.

Registre-se que, segundo o STJ: “A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor” (Súmula 546). Assim, por exemplo, se o agente apresenta documento emitido por órgão estadual perante autarquia federal, gerando, destarte, prejuízo a tal ente público, será competente para o processo e julgamento do caso a Justiça Federal.

De acordo com o STF, na Súmula Vinculante 36: “Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil”.

Supressão de documento

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Supressão de documento e outros crimes. 3. Sujeitos do delito. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 305 do CP, constitui delito o fato de “destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor”.

Tutela-se a fé pública, no que concerne à segurança jurídica dos documentos como meio de prova.

2. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E OUTROS CRIMES

Se a supressão de documento visa à prática de crimes contra a ordem tributária, fica absorvida pela infração especial (Lei n. 8.137, de 27-12-1990).

A destruição de documento exclui o delito de furto. Assim também a sua supressão absorve a apropriação indébita antecedente.

O dano, previsto no art. 163 do CP, não concorre com a supressão de documento, ficando por esta absorvido.

Quando se cuida de documento judicial ou processo, sendo o sujeito ativo procurador ou advogado, aplica-se a norma incriminadora do art. 356 do CP.

3. SUJEITOS DO DELITO

Delito comum pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo dono do documento, quando dele não podia dispor.

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, quem sofre o dano efetivo causado pela supressão de documento.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O comportamento proibido consiste em destruir, suprimir ou ocultar documento. Destruir significa extinguir, eliminar o objeto material, que, fisicamente, deixa de existir. O sujeito pode empregar vários meios de eliminação: incineração, dilaceramento, ingestão etc. Suprimir é fazer desaparecer, sem que haja destruição ou escondimento. Em sentido amplo, a supressão abrange a destruição e a ocultação. Em sentido estrito, só existe supressão quando o sujeito subtrai o objeto material, impedindo o conhecimento do seu conteúdo ou o seu uso por quem de direito ou quando, com a presença de manchas, riscos etc., não se possa ler a documentação. Ocultar é esconder, colocar o objeto em lugar onde não pode ser achado.

O objeto material deve reunir as condições de documento e ser verdadeiro. Cuidando-se de documento falso, inexistente o delito do art. 305, podendo surgir outro, como a fraude processual (CP, art. 347) ou o favorecimento pessoal (CP, art. 348). O documento deve ser original. Não mais existindo este, pode haver delito contra a cópia autêntica. Não há crime, entretanto, quando a conduta visa à cópia autêntica do documento que ainda existe. Nesse caso, pela facilidade de obtenção de outros traslados, cópias e certidões, não há dano à fé pública, inexistindo, por isso, o delito em tela, podendo subsistir outro, como o dano e o furto.

O documento pode ser:

1ª) público; ou

2ª) particular.

Documento público, nos termos do art. 297, § 2º, do CP, para os efeitos penais, deve ser entendido em sentido amplo, equiparando-se a ele o

emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

A expressão “verdadeiro” do tipo penal diz respeito às duas naturezas do documento: público e particular.

Pouco importa se o agente obteve lícita ou ilicitamente a posse do objeto material ou que se lhe tenha sido confiado. Tratando-se do proprietário, é preciso que dele não pudesse dispor. Se podia, o fato é atípico.

O benefício e prejuízo visados pelo agente podem ser de ordem material ou moral.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O crime só é punível a título de dolo, vontade livre e consciente dirigida à concretização das elementares de natureza objetiva (destruir, suprimir ou ocultar o objeto material). A figura penal reclama um elemento subjetivo, contido na expressão “em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio”. Não são exigidos dois elementos subjetivos relacionados com o benefício e o prejuízo. Basta um: ou a intenção é a de obter um benefício (próprio ou de terceiro) ou a de causar prejuízo a outrem. O benefício e o prejuízo queridos pelo agente devem estar relacionados com a fé pública e a veracidade documental como meio de prova. Esse particular aspecto do elemento subjetivo serve de forma de distinção entre a supressão de documento e outros crimes, como o dano, o furto e a apropriação indébita.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime se consuma com a realização das condutas de destruir, ocultar ou suprimir o objeto material. Não há necessidade, para a consumação, de que o sujeito obtenha o proveito ou cause prejuízo. Nesse aspecto, o delito é formal.

A tentativa é admissível. Ex.: lançado o documento no fogo, é retirado

antes de se queimar.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

Tratando-se de documento público, as penas são a reclusão, de dois a seis anos, e a multa; cuidando-se de documento particular, é imposta pena de reclusão, de um a cinco anos, além da multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Capítulo V

DE OUTRAS FALSIDADES

Falsificação de sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 306, caput, do CP, dispõe como delito o fato de “falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem”.

Tutela-se a fé pública no que diz respeito à segurança das formas de autenticação ou certificação pública. O Estado, por intermédio da incriminação, protege a marca ou sinal empregado no contraste de metal precioso, garantindo-lhe a qualidade ou genuinidade. Com a mesma objetividade tutela a marca ou sinal aduaneiro.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

As condutas incriminadas são: 1ª) falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal; 2ª) usar (empregar, utilizar) marca ou sinal falsificado por terceiro.

A falsificação deve ser idônea, capaz de iludir as pessoas, uma vez que se cuida de crime contra a fé pública. No caso do uso, a falsificação da marca ou sinal deve ter sido realizada por terceiro. Se feita pelo próprio sujeito, aplica-se a primeira parte do caput do dispositivo, havendo um só delito.

O objeto material é a marca ou sinal. A marca corresponde a um selo de garantia com destinação de autenticar certos objetos ou de indicar a qualidade de determinados produtos ou a satisfação de requisitos legais. Sinal é a impressão simbólica do poder público com a finalidade de conferir a legitimidade do metal precioso. As marcas se apresentam de várias formas: são gravadas na própria peça (contraste) ou podem ser constituídas por selos, impressos, etiquetas, timbre em chumbo, lacre etc.

Nos termos do parágrafo único do art. 306 do CP, a pena é reduzida “se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal”.

Aqui, o objeto material é diferente: marca ou sinal usado pela autoridade pública (federal, estadual ou municipal) na fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar certos objetos ou para demonstrar a satisfação de formalidade imposta pela lei.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de falsificar ou usar a marca ou sinal nas condições descritas no tipo. No verbo usar, é imprescindível que o sujeito tenha conhecimento de que a marca ou o sinal foi falsificado por terceiro.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O delito atinge a consumação com a fabricação, a alteração ou o uso da marca ou sinal.

A tentativa é inadmissível na conduta de usar; na de fabricar ou alterar, é admissível.

6. PENAS E AÇÃO PENAL

No caso do caput do art. 306, as penas são a reclusão, de dois a seis anos, e a multa; no do parágrafo único, são a reclusão ou detenção, de um a três anos, e a multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Falsa identidade

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Subsidiariedade expressa. 3. Sujeitos do delito. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Elemento normativo do tipo. 7. Momento consumativo e tentativa. 8. Falsa identidade e outras infrações penais. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 307 do CP, constitui delito “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.

A objetividade jurídica visa à fé pública de ordem pessoal, procurando o legislador conceder proteção à segurança da identidade do indivíduo no que concerne à sua condição e estado nas relações jurídicas com as outras pessoas.

2. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA

O preceito sancionador do art. 307 ressalva a possibilidade de o delito configurar elemento de crime de maior gravidade. Assim, a falsa identidade fica absorvida quando aparece integrando o estelionato, a figura fundamental da falsidade ideológica, da violação sexual mediante fraude, da bigamia, da fraude processual etc. Nesses casos, o sujeito não responde por dois delitos. Somente pelo mais grave, em que se subsume a falsa identidade.

3. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa.

Sujeito passivo principal é o Estado. Secundariamente, aparece a pessoa a quem o fato causa dano.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O comportamento incriminado consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, i.e., identidade que não corresponde à pessoa a quem é inculcada. O CP pune a conduta de quem, oralmente ou por escrito, irroga a si mesmo ou a terceiro identidade que não reflete a realidade. Tanto comete delito quem atribui a si ou a terceiro identidade de pessoa existente como quem invoca a de pessoa fictícia, ocorrendo, no primeiro caso, substituição de pessoas.

Não comete crime quem somente silencia a respeito da errônea identidade que lhe é atribuída. Dessa forma, inexistente delito na conduta de quem, confundido com terceiro, não esclarece ao interlocutor sua verdadeira identidade.

A identidade é constituída de todos os elementos que podem individualizar (identificar) uma pessoa: estado civil (filiação, idade, matrimônio, nacionalidade etc.) e condição social (profissão ou qualidade pessoal). cremos que a expressão identidade não pode ser interpretada no sentido restritivo, indicando somente a identidade física. Identidade significa “o conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa, tais como o nome, idade, estado, profissão, sexo” etc. (Dicionário Aurélio). Logo, abrange também as condições sociais (padre, militar, médico etc.).

A vantagem e o dano visados pelo agente podem ser de ordem material ou moral.

De ver que “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa” (Súmula 522 do STJ). Assim, por exemplo, o agente que, ao ser preso em flagrante, fornece dados qualificativos inverídicos para ocultar seus antecedentes criminais não atua amparado pelo direito de defesa e, portanto, responde criminalmente pelo ato praticado, nos termos do art. 307 do CP.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O dolo consiste na vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade. O tipo, porém, não se contenta com o dolo, exigindo um elemento subjetivo contido na expressão “para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem” (grifos nossos).

6. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Está na falsidade da identidade, que deve ser abrangida pelo dolo do agente, sob pena de atipicidade do fato.

7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Crime formal, consuma-se com a falsa atribuição de identidade, independentemente da obtenção da vantagem ou da causação de dano a terceiro.

A tentativa, quando empregado o meio verbal, é inadmissível. É possível, porém, quando a falsa atribuição é realizada por escrito (exemplo doutrinário da carta extraviada).

8. FALSA IDENTIDADE E OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS

Se a atribuição falsa diz respeito à qualidade de funcionário público, aplica-se o art. 45 da LCP. Se, no fato anterior, o sujeito ilegitimamente usa uniforme, incide o art. 46 da mesma lei. Havendo usurpação de função pública, ocorre o crime do art. 328 do CP. Se, perante a autoridade, o agente se recusa a fornecer dados referentes à identidade ou os fornece falsos, aplica-se o art. 68 e parágrafo único da LCP.

Como ficou consignado no item 2 deste estudo, a falsa identidade pode constituir delito de maior gravidade, caso em que fica absorvida.

De acordo com o art. 16 da Lei n. 13.869, de 2019, constitui espécie de abuso de autoridade, sujeito à pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, e

multa, deixar o agente público de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Há crime, ainda, quando o sujeito, sendo o responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixar de identificar-se ao preso ou atribuir a si mesmo falsa identidade, cargo ou função (parágrafo único).

9. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são alternativas: detenção, de três meses a um ano, ou multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Uso de documento de identidade alheia

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Subsidiariedade expressa. 3. Sujeitos do delito. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos da definição do art. 308 do CP, constitui delito o fato de “usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro”.

É um subtipo do crime de falsa identidade (CP, art. 307).

Tutela-se a fé pública que devem merecer determinados documentos referidos no texto (passaporte, título de eleitor etc.).

2. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA

Crime subsidiário, conforme consta do preceito sancionador, a norma do art. 308 só tem aplicação quando o fato não configura delito de maior gravidade objetiva (concurso aparente de normas).

3. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Sujeito passivo é o Estado.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta proibida consiste em o sujeito usar, como próprio, passaporte, caderneta de reservista, título de eleitor ou qualquer outro documento de identidade alheia, ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa espécie, próprio ou alheio.

O sujeito pode realizar a conduta típica de duas formas:

1ª) usando como se fosse dele qualquer dos documentos alheios citados;
ou

2ª) cedendo a terceiro os documentos referidos, para que os use, sejam dele ou alheios.

No elenco dos objetos materiais, o CP emprega a denominada interpretação analógica. Insere uma fórmula casuística (passaporte, título de eleitor e caderneta de reservista), seguida de uma fórmula final genérica ("ou qualquer documento de identidade alheia"). Exs.: CPF, RG, carteira de trabalho etc.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de concretizar os elementos objetivos do tipo. Não requer nenhum fim especial do agente.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com o uso ou com a cessão do documento. Não exige, para a consumação ou tipicidade do fato, que advenha qualquer resultado da ação do sujeito.

Trata-se de crime de mera conduta. Na primeira modalidade típica, atinge o momento consumativo com o simples uso do documento, i.e., com seu emprego em qualquer circunstância. Na segunda, a consumação ocorre com a entrega do objeto material a terceiro.

Quanto à tentativa, é possível na realização da conduta de cessão. No uso, a tentativa é impossível. O início do uso já consoma a infração.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são cumulativas: detenção, de quatro meses a dois anos, e multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Fraude de lei sobre estrangeiros

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Atribuição de falsa qualidade a estrangeiro. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito o fato de o estrangeiro usar, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu (CP, art. 309, caput).

O objeto jurídico é a fé pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, somente pode ser cometido por estrangeiro, admitindo-se participação de brasileiro.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em o sujeito usar nome que não é o seu, por meio verbal ou escrito, de terceiro ou imaginário.

Pretende o sujeito, conforme a descrição típica, entrar ou permanecer em nosso território jurídico, abrangendo o mar territorial, o espaço aéreo, os navios públicos onde se encontrem, as embarcações privadas em mar alto etc.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de usar o estrangeiro nome que não é o seu. Exige-se um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão "para entrar ou permanecer no

território nacional” (grifo nosso).

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O delito atinge o seu momento consumativo com o efetivo uso (emprego) pelo estrangeiro do nome imaginário ou de terceiro, sendo irrelevante que realmente consiga entrar ou permanecer em nosso território. Trata-se de crime formal.

A tentativa não é admissível, tendo em vista que o primeiro ato de uso de nome falso já consoma o delito.

6. ATRIBUIÇÃO DE FALSA QUALIDADE A ESTRANGEIRO

Constitui também delito o fato de “atribuir a estrangeiro falsa qualidade, para promover-lhe a entrada em território nacional”, sujeitando o autor a pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa (parágrafo único do art. 309, introduzido pela Lei n. 9.426, de 24-12-1996; corresponde ao antigo art. 310 do CP).

São protegidas a fé pública e a seleção de imigrantes.

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa.

Sujeito passivo é o Estado.

A conduta consiste em atribuir falsa qualidade a estrangeiro.

Atribuir quer dizer imputar, inculcar etc. A atribuição pode ser verbal ou por escrito, imputando ao estrangeiro qualidade que não possui (comerciante, médico, engenheiro, advogado, sacerdote, militar etc.). Para que haja delito, entretanto, é necessário que a qualidade imputada constitua condição para que o estrangeiro ingresse em nosso território.

O comportamento é dirigido a que o estrangeiro entre em nosso território. Não constitui delito a ação dirigida a que ele permaneça em nosso território (atipicidade).

Delito formal, consoma-se com a atribuição falsa (oralmente ou por

escrito), independentemente de o estrangeiro conseguir entrar no território nacional.

A tentativa é de difícil ocorrência.

O primeiro elemento subjetivo do tipo é o dolo, vontade livre e consciente de realizar a falsa atribuição. Exige-se, além disso, um outro, contido na expressão “para promover-lhe a entrada em território nacional” (grifo nosso).

São impostas reclusão, de um a quatro anos, e multa. Na hipótese do parágrafo único, a pena é de um a quatro anos de reclusão, além de multa.

A ação penal é pública incondicionada.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas cominadas são a detenção, de um a três anos, e a multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Falsidade em prejuízo da nacionalização de sociedade

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do crime. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Norma penal em branco. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito o fato de “prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens” (CP, art. 310, de acordo com a Lei n. 9.426, de 24-12-1996; corresponde ao antigo art. 311 do CP).

São protegidos a fé pública e o interesse concernente à segurança nacional, no que tange à proibição imposta ao estrangeiro de possuir ou ter a propriedade de determinados bens. A matéria é regida pela CF (art. 222).

2. SUJEITOS DO CRIME

O delito pode ser cometido por qualquer pessoa, desde que brasileira. Não pode ser realizado por estrangeiro.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta típica consiste em o brasileiro prestar-se a figurar como “testa de ferro” do estrangeiro, aparecendo falsamente como proprietário ou possuidor de bens daquele. É necessário que os bens (ações, títulos ou qualquer outro valor) pertençam a estrangeiro e que lhe seja proibida a sua posse e propriedade. Exs.: proibição a estrangeiro de possuir empresa jornalística, de televisão etc.

4. NORMA PENAL EM BRANCO

O art. 310 fala em casos em que ao estrangeiro é vedada por lei a posse ou a propriedade de certos bens. Trata-se, pois, de norma penal em branco, a ser completada por outros dispositivos (CF, art. 222).

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente dirigida à concretização dos elementos objetivos da figura típica. Exige-se que o sujeito tenha consciência da proibição legal imposta ao estrangeiro.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no momento em que o sujeito assume a posição de proprietário ou possuidor dos bens.

A tentativa é admissível.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

São impostas detenção, de seis meses a três anos, e multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

SUMÁRIO: 1. Conceito. 2. Autonomia típica. 3. Objetividade jurídica. 4. Objetos materiais. 5. Tipo elástico. 6. Sujeitos do delito. 7. Condutas típicas. 8. Elemento subjetivo do tipo. 9. Momento consumativo e tentativa. 10. Crime funcional (§ 1º). 11. Funcionário público que participa de licenciamento ou registro indevido de veículo com sinal de identificação adulterado ou remarcado (§ 2º). 12. Penas e ação penal.

1. CONCEITO

De acordo com o art. 311 do CP, com redação da Lei n. 9.426, de 24 de dezembro de 1996, constitui delito o fato de adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento (caput). A pena é agravada se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela (§ 1º). Comete o mesmo crime o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial (§ 2º).

2. AUTONOMIA TÍPICA

Trata-se de crime autônomo, independente da receptação do veículo automotor.

3. OBJETIVIDADE JURÍDICA

A fé pública. Secundariamente, o tipo protege a identificação do veículo.

4. OBJETOS MATERIAIS

São os sinais identificadores de veículo automotor, como sua placa ou seu chassi.

5. TIPO ELÁSTICO

A expressão “qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento” amplia demasiadamente a incriminação, com prejuízo dos princípios da reserva legal e da segurança jurídica.

6. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Praticado por funcionário público, aplica-se, conforme o fato, os §§ 1º ou 2º do art. 311. Sujeito passivo é o Estado.

7. CONDUTAS TÍPICAS

Adulterar ou remarcar sinais identificadores de veículo automotor, equipamento ou componentes. Ex.: número do chassi.

Adulterar significa modificar irregularmente, alterando os sinais identificadores, de maneira a impedir ou dificultar que se identifiquem os caracteres originais.

Remarcar quer dizer alterar os caracteres, seja modificando os existentes ou inserindo novos elementos para transformar os sinais identificadores do veículo.

E se o agente efetuar alteração provisória, como a inserção de fitas adesivas sobre as placas do automóvel, de maneira a alterar um dos números e, com isso, evitar multas relacionadas com a restrição de circulação (“rodízio de veículos”)?

Há quem sustente, nesse caso, não existir ofensa ao bem jurídico protegido. Inexistiria vulneração à fé pública e, portanto, tratar-se-ia de mera infração de trânsito. Não é essa nossa posição. O tipo penal não distingue a natureza da adulteração ou remarcação (se definitiva ou transitória), razão pela qual a conduta se enquadra no dispositivo legal. O STJ firmou entendimento de que “(...) a norma contida no art. 311 do

Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa do automóvel...” (STJ, AgRg no REsp n. 1.327.888, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe de 11-3-2015).

8. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade de adulterar ou remarcar sinais identificadores de veículo automotor. Não se exige qualquer finalidade específica. É indiferente, portanto, a razão pela qual o sujeito pratique o fato (burlar o “rodízio de veículos”, não receber multas por infrações de trânsito, evitar ser identificado pela Polícia etc.).

9. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

A consumação ocorre no instante da adulteração ou remarcação. A tentativa é admissível.

Sendo o agente surpreendido pela Polícia conduzindo veículo automotor com o chassi ou as placas adulteradas, mas não se comprovando ter sido ele o autor da adulteração (ou remarcação), responde por algum crime?

Sim, há receptação (CP, art. 180). A caracterização deste crime ficará mais evidenciada caso se comprove que o objeto conduzido era produto de crime patrimonial anterior, como furto, receptação, apropriação indébita, estelionato etc. Assim, se o agente conduzia um automóvel roubado há um mês, já estando este com as placas alteradas, mesmo não se demonstrando que ele as modificou, responde pela receptação (conquanto comprovadas, por óbvio, todas as elementares deste tipo penal). Se ficar provado nos autos que ele não só tinha ciência dessa origem como foi o responsável pela remarcação, dar-se-á o concurso material (CP, art. 69).

Há casos, porém, em que a alteração foi de tal maneira que não se consegue demonstrar a origem do bem, havendo incerteza quanto à sua procedência (p. ex.: a numeração do chassi foi totalmente suprimida

mediante abrasão). Esse cenário parece mais complexo, pois não há provas de que o veículo era produto de algum delito anterior ou de que o condutor surpreendido pela Polícia foi o responsável pela adulteração (ou remarcação) do chassi. O agente, porém, deve responder por receptação, desde que ciente da modificação no sinal identificador do bem conduzido. Isso porque, tendo conhecimento dessa ilicitude, estava conduzindo coisa que sabia ser produto de crime. Mas de qual delito? Justamente o art. 311 do CP. O motorista sabia que dirigia um automóvel produto de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

10. CRIME FUNCIONAL (§ 1º)

O tipo agrava “a pena” de um terço. O caput da disposição, entretanto, comina duas penas. Há imprecisão. Observe-se que o § 2º menciona “nas mesmas penas”.

11. FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE PARTICIPA DE LICENCIAMENTO REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO OU REMARCADO (§ 2º)

Não se trata de “veículo adulterado ou remarcado”, como diz o texto, e sim de sinal de identificação adulterado ou remarcado. O tipo exige um elemento normativo. O fornecimento de material ou informação oficial deve ser “indevido”. Se “devido”, o fato é atípico.

12. PENAS E AÇÃO PENAL

São impostas reclusão, de três a seis anos, e multa. A ação penal é pública incondicionada.

Trata-se de infração que admite a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Fraude em certames de interesse público

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Novatio legis incriminadora. 3. Origem da modificação legislativa. 4. Sujeitos do delito. 5. Elementos objetivos do tipo. 6. Elementos subjetivos do tipo. 7. Consumação e tentativa. 8. Figura equiparada. 9. Forma qualificada. 10. Causa de aumento de pena. 11. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

A fraude em certames de interesse público consiste no ato de utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previstos em lei.

Trata-se de crime contra a fé pública, de tal modo que a objetividade jurídica reside na crença coletiva acerca da veracidade, autenticidade e lisura do concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previstos em lei.

2. NOVATIO LEGIS INCRIMINADORA

Cuida-se a presente disposição de novatio legis incriminadora, motivo pelo qual não se aplica retroativamente, nos termos dos arts. 5º, XL, da CF e 2º do CP. Incide apenas para fatos ocorridos após sua entrada em vigor, que se deu no dia 16 de dezembro de 2011.

É de ver, contudo, que alguns comportamentos abrangidos pelo art. 311-A do CP já recebiam punição criminal por meio de outras disposições, como o art. 325 do CP, o qual tipifica o delito de violação de sigilo funcional. Nesse caso, houve novatio legis in pejus (pois a pena cominada ao crime do

art. 311-A é superior à do art. 325 do CP).

Elogia-se o dispositivo legal, uma vez que supre algumas lacunas existentes em nossa legislação penal, notadamente no que se refere a determinadas fraudes perpetradas por candidatos em certames de interesse público.

Cremos, ainda, que o novel tipo pode ser empregado para punir o autor da chamada “cola eletrônica”, em que o aspirante emprega instrumentos, como aparelhos de comunicação móvel, para obter as respostas da prova, conduta até então considerada atípica pelo Supremo Tribunal Federal (vide HC n. 88.967/AC, DJU, 13-4-2007, p. 102 – publicado in RT, 863/506). É necessário, porém, que o comportamento seja praticado mediante defraudação de sigilo inerente ao certame, do contrário não se encontrará abrangido pela esfera de proteção do tipo. Assim, se o sujeito se comunicar com terceiro, enquanto faz a prova, e este lhe transmitir as respostas sem violação do segredo mencionado (p. ex., depois de obter a folha de perguntas de outro candidato que já deixou o local do exame e resolver a distância as questões), o ato não se subsumirá ao crime em estudo. Se, porém, receber as informações de quem previamente obteve a folha de perguntas, rompendo o sigilo inerente à avaliação, exame ou concurso, o delito restará configurado.

3. ORIGEM DA MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA

A presente disposição resulta da Lei n. 12.550, de 15 de dezembro de 2011, destinada primordialmente à criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH.

Mencionada pessoa jurídica surgiu com o advento da Medida Provisória n. 520, de 31 de dezembro de 2010, que teve seu prazo de vigência expirado em 1º de junho de 2011, conforme o Ato Declaratório n. 23, do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, de 6 de junho de 2011 (Diário Oficial da União – Seção 1 – 7-6-2011, p. 2).

O Poder Executivo, então, apresentou, em julho de 2011, o Projeto de Lei n. 1.749, visando retomar a discussão tendente à criação da citada empresa pública.

Deve-se destacar que em todos os Textos apresentados pelo Executivo não havia uma disposição sequer destinada a modificar o Código Penal. Cuidava-se de regras estritamente ligadas à constituição da EBSEH.

Durante a tramitação na Casa de origem, porém, foi apresentado um substitutivo, no qual se deu a proposta de inclusão no Código Penal do inciso V do art. 47 e do art. 311-A. A intenção, no mérito, mostrou-se louvável, pois visava “coibir o cometimento de fraudes e promover a observância dos princípios da moralidade e da impessoalidade”, consoante destacou o Relator do Projeto, Deputado Danilo Forte; mas não se pode deixar de registrar o franco desrespeito às diretrizes preconizadas na Lei Complementar n. 95, de 1998, notadamente o art. 7º, I e II, segundo o qual “excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto” e “a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”.

A inobservância de tal critério, todavia, não invalida a lei, embora seja lamentável que se promova a inclusão de modificações na legislação penal, de carona, em Projetos de Lei em andamento que, pelo interesse e pressão do Executivo, acabam sendo aprovados.

4. SUJEITOS DO DELITO

Cuida-se de crime comum: qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, não somente aquela que possui o dever de sigilo, mas toda pessoa que utilizar ou divulgar a informação secreta, com a finalidade preconizada no tipo.

Inclui-se no alcance da incriminação, assim, o candidato que, tendo conhecimento prévio das perguntas, obtidas fraudulentamente antes da

realização da prova, se beneficia desse conhecimento para acertá-las.

O sujeito passivo é, em primeiro lugar, a coletividade, pois constitui crime contra a fé pública; em segundo plano, é a entidade que organiza o certame ou a prova. Na hipótese de o agente lograr o benefício próprio ou alheio, os demais licitantes ou candidatos, eventualmente preteridos em razão da fraude, serão prejudicados, em face de seu interesse civil, mas não figurarão como vítimas do delito.

5. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Pune-se quem utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previstos em lei.

As condutas nucleares são:

- a) utilizar: fazer uso, empregar de qualquer modo;
- b) divulgar: narrar alguma coisa a um número indeterminado de pessoas.

O objeto material, é dizer, a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, deve ser o conteúdo sigiloso de:

- a) concurso público (p. ex.: a folha de perguntas contendo provas de concursos para ingresso em carreiras públicas);
- b) avaliação ou exame públicos (p. ex.: as questões do Exame de Ordem, necessário ao exercício da advocacia);
- c) processo seletivo para ingresso no ensino superior (trata-se dos exames vestibulares);
- d) exame ou processo seletivo previstos em lei (é o caso, p. ex., da prova do ENEM – Ensino Nacional do Exame Médio).

Não estão abrangidas as avaliações de desempenho dos alunos ou provas

regulares em instituições de ensino, ainda que públicas. O discente que frauda a prova bimestral ou semestral, mesmo o fazendo em faculdade pública, depois de obter as questões prévia e ilicitamente e beneficiar a si próprio ou a terceiro, não pratica delito algum.

6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

Além do elemento subjetivo genérico consubstanciado no dolo, isto é, a vontade e a consciência de concretizar os elementos objetivos do tipo, exige-se elemento específico, traduzido no fim de beneficiar a si próprio ou a terceiro ou de comprometer a credibilidade do certame.

7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O tipo fundamental consuma-se com a efetiva utilização das informações. O delito, porém, é formal, não exigindo que o benefício pretendido (a si ou a terceiro ou, ainda, o comprometimento à credibilidade do certame público) seja atingido. O candidato que, na prova do concurso público do Conselho Regional de Medicina, emprega dados secretos indevidamente obtidos e, mesmo assim, não obtém aprovação, fica sujeito às penas do art. 311-A.

Note-se que, se houver dano à Administração Pública (p. ex.: a anulação do certame em face da descoberta da fraude), incide a figura qualificada (§ 2º).

Na conduta “divulgar”, a realização integral do tipo ocorre quando a informação sigilosa chega ao conhecimento de um número indeterminado de pessoas.

Admite-se, em qualquer caso, a forma tentada, pois se trata de delito plurissubsistente.

8. FIGURA EQUIPARADA

De acordo com o § 1º, incorre nas mesmas penas quem permite ou

facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

Os verbos núcleo do tipo são:

a) permitir: autorizar, franquear;

b) facilitar: favorecer, tornar fácil, afastar dificuldades.

O objeto material é o acesso das pessoas às informações sigilosas mencionadas na cabeça do artigo.

O delito é comum, já que não se exige qualidade específica por parte do sujeito ativo, muito embora se trate de comportamento mais afeto àqueles que têm proximidade ou acesso às informações secretas que serão objeto de defraudação.

Cuida-se de crime de forma livre, pois pode ser cometido por qualquer meio executório, seja ele físico ou eletrônico, presencial, a distância etc.

9. FORMA QUALIFICADA

De acordo com o § 2º, se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública, a pena é de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

A presente figura representa um crime qualificado pelo resultado naturalístico, consistente no dano efetivo à Administração Pública.

Admite-se qualquer forma de dano (patrimonial ou moral). Considera-se presente a qualificadora, portanto, se a prova foi anulada, gerando a necessidade de refazer o concurso.

10. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

A sanção será exasperada em 1/3 (um terço) se o fato for cometido por funcionário público.

Entende-se como tal, nos termos do art. 327, caput, do CP, "... quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou

função pública”. De lembrar-se que a citada definição se aplica sempre que o funcionário público figurar como sujeito ativo da infração penal.

11. PENA E AÇÃO PENAL

Na modalidade fundamental, a pena é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Admite, portanto, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) e observa o procedimento comum ordinário.

Na figura qualificada, a sanção é de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Não comporta o sursis processual e segue o mesmo rito da figura básica.

A ação penal é pública incondicionada.

XII – DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Capítulo VI

PRINCÍPIOS GERAIS

SUMÁRIO: 1. Objetividade jurídica genérica. 2. Classificação. 3. Crimes funcionais. 4. Conceito de funcionário público: a) Conceito de funcionário público para efeitos penais; b) Funcionário público por equiparação e causa de aumento de pena. c) Conceito de funcionário público estrangeiro para efeitos penais. 5. Elemento subjetivo dos tipos. 6. Concurso de pessoas. 7. Princípio da insignificância. 8. Responsabilidade civil e administrativa de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública.

1. OBJETIVIDADE JURÍDICA GENÉRICA

O CP, no último título da Parte Especial, define os delitos contra a Administração Pública, tomada, em seu sentido amplo, como o conjunto das funções realizadas pelos órgãos do poder público. Pretende o legislador proteger o normal desenvolvimento da máquina administrativa em todos os setores de sua atividade, no sentido do bem-estar e do progresso da sociedade. Proíbe-se, pela incriminação penal, não só a conduta ilícita dos agentes do poder público, os funcionários públicos (intranei), como a dos estranhos, os particulares (extranei), que venha, de forma comissiva ou omissiva, causar ou expor a perigo de dano a função administrativa (em sentido estrito), legislativa e judiciária.

De forma secundária, o estatuto penal também protege interesses particulares. Assim, por exemplo, no delito de peculato (art. 312), o objeto material pode pertencer ao Estado (em sentido amplo) ou ao particular. Neste caso, a tutela penal também se estende ao bem particular lesado

pelo funcionário público.

A intenção de proteger as funções desempenhadas pela máquina administrativa foi ainda reforçada com a alteração advinda da Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, que ampliou o conceito de funcionário público (art. 327, § 1º), tornando evidente o propósito de tutelar a adequada prestação de serviços públicos.

2. CLASSIFICAÇÃO

Os crimes contra a Administração Pública estão classificados em cinco grupos:

1º) crimes cometidos por funcionário público contra a administração em geral (arts. 312 a 326);

2º) crimes praticados por particular contra a administração em geral (arts. 328 a 337-A);

3º) crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B a 337-D);

4º) crimes contra a administração da justiça (arts. 338 a 359);

5º) crimes contra as finanças públicas (arts. 359-A a 359-H).

3. CRIMES FUNCIONAIS

Os chamados delitos funcionais pertencem à categoria dos crimes próprios, que só podem ser praticados por determinada classe de pessoas em face de a norma incriminadora exigir uma condição ou situação particular. São os que só podem ser cometidos por pessoas que exercem funções públicas. Denominam-se *delicta in officio*, i.e., crimes dos que realizam a atividade estatal, cujo exercício pode ser efetivado a qualquer título, definitivo ou precário, ainda que sem qualquer remuneração, como ocorre nas hipóteses de convocação de particulares pelo Estado (p. ex.: jurados).

Classificam-se em:

1ª) delitos funcionais próprios; e

2ª) delitos funcionais impróprios.

Nos primeiros, a qualidade de funcionário público atua como elementar do tipo e, sem ela, o fato se torna absolutamente atípico. Ex.: prevaricação (art. 319). Provado que o sujeito, ao tempo do fato, não era funcionário público, desaparece a prevaricação e não surge nenhum outro delito. A qualidade do sujeito ativo aparece como elemento da tipicidade penal.

Nos crimes funcionais impróprios, excluída a qualidade de funcionário público, há dois efeitos:

1ª) desaparece o crime de que se trata; ou

2ª) opera-se desclassificação para outro delito.

Exemplo: peculato (art. 312). Excluída a elementar “funcionário público”, desaparece, por atipicidade relativa, o crime de peculato, subsistindo a apropriação indébita (CP, art. 168).

Os delitos funcionais próprios (típicos) são aqueles que o CP denomina “crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral” (arts. 312 a 326). De observar-se, entretanto, que nem todos os delitos funcionais típicos estão definidos no Capítulo I do Título XI. Assim, o rol dos arts. 312 e s. não esgota o elenco. Outros há espalhados pelo estatuto penal, em que a qualidade de funcionário público do sujeito ativo aparece como elementar ou circunstância qualificadora. Ex.: arts. 150, § 2º, 300, 301 etc.

4. CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO

a) Conceito de funcionário público para efeitos penais

Nos termos do art. 327, caput, do CP, “considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem

remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”.

Nosso estatuto penal, seguindo a tradição de outros códigos, colocou o conceito de funcionário público no capítulo relativo aos delitos cometidos por funcionário público contra a administração em geral. De modo que a disposição, para efeito da consideração do sujeito ativo do crime como funcionário público, tem aplicação a toda a legislação.

O CP mantém a expressão “funcionário público” para designar o que os administrativistas nominam, na atualidade, de agente público, incluindo os que se encontram vinculados a cargos, empregos ou funções públicas, sendo designados por servidores públicos e agentes administrativos. Os agentes administrativos, em face do regime constitucional, podem ser concursados (CF, art. 37, II), ocupantes de cargos ou empregos em comissão (CF, art. 37, V) e servidores temporários (CF, art. 37, IX). É indiferente, pois, a designação, podendo ser empregadas as expressões funcionários públicos, agentes públicos, agentes administrativos, servidores públicos ou servidores temporários.

O que caracteriza a figura do funcionário público, permitindo distinção em relação aos outros servidores, é a titularidade de um cargo criado por lei, com especificação própria, em número determinado e pago pelos cofres da entidade estatal a que pertence.

Esse conceito administrativo, entretanto, é muito restrito. Para a finalidade do Direito Penal, de acordo com a lei, devemos entender por funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Portanto, a permanência ou a remuneração pelo Estado não se faz necessária ao conceito. Incluem-se, por consequência, não só os funcionários que desempenham cargos criados por lei, regularmente investidos, nomeados e pagos pelos cofres públicos, como também os que exercem função pública ou são investidos em empregos (contratados, menselistas, diaristas ou nomeados a título precário).

A disposição menciona, em primeiro lugar, cargo público, que corresponde ao criado por lei, com denominação própria, em número certo e pago pelos cofres públicos (Lei n. 8.112, de 11-12-1990 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, art. 3º, parágrafo único).

A seguir, a norma menciona emprego público, indicando os que não titularizam cargos criados por lei e mantêm vínculo empregatício com a Administração direta ou indireta, regidos pela CLT (os chamados “celetistas”).

Por último, o dispositivo menciona a função pública, referindo-se ao conjunto de atribuições que o poder público impõe aos seus servidores para a realização de serviços no plano do Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo.

Verifica-se que o funcionário público, diante do Direito Penal, caracteriza-se pelo exercício da função pública. Portanto, o que importa não é a qualidade do sujeito, de natureza pública ou privada, mas sim a natureza da função por ele exercida.

São funcionários públicos o Presidente da República, os membros do Congresso Nacional e dos Tribunais, os servidores, os vereadores, os jurados, os serventuários da justiça, os extranumerários, diaristas etc. Não são funcionários públicos os curadores e tutores nomeados, os inventariantes judiciais etc.

Tratando-se, entretanto, de crime relacionado com licitação pública praticado por funcionário público, de aplicar-se o art. 84, caput, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

b) Funcionário público por equiparação e causa de aumento de pena

De acordo com o § 1º do art. 327, com nova redação determinada pela Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2000, com entrada em vigor em 15 de outubro de 2000,

“equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública”.

Entidade paraestatal, no sentido da norma penal, é pessoa jurídica de Direito Privado, criada por lei ou de criação autorizada por lei, constituída por patrimônio público ou misto (público e particular), com o fim de concretização de atividades, obras ou serviços de interesse social, sob disciplina e controle do Estado. A utilização da designação paraestatal é equivocada, pois dá sentido de entidade localizada além do Estado, fora da Administração ou paralela ao Estado. Com tal sentido, abrangeria as pessoas jurídicas de Direito Privado que assumem a execução de atividades típicas do poder público, como as organizações sociais e os serviços sociais autônomos. Na verdade, a norma pretende referir-se à Administração indireta, composta pelas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas (Dec.-lei n. 200/67, art. 4.^o, II, a, b, c e d), uma vez que a parte final do dispositivo se ocupou de integrar os vinculados às pessoas jurídicas constituídas pela iniciativa privada.

A nova redação do dispositivo veio a corroborar o entendimento jurisprudencial da equiparação, para fins de responsabilidade, das entidades paraestatais às concessionárias e conveniadas para a execução de atividade típica da Administração Pública. Com isso, alargou-se o campo de aplicação do dispositivo.

O conceito de atividade típica da Administração Pública vincula-se às tarefas essenciais do Estado, tais como saúde, educação, transportes, cultura, segurança, higiene, dentre outras.

Difere o contrato do convênio porque, naquele, é a Administração Pública, mediante concessão, quem contrata o particular para o exercício de atividade pública. Já no convênio verifica-se um acordo de duas ou mais

entidades para a realização de um serviço público de competência de uma delas, que deve ser, nesse particular, uma entidade pública.

Quanto à aplicação do dispositivo, ao tempo de sua redação original, que não fazia referência a “trabalhador de empresa prestadora de serviço”, havia duas correntes, que estamos mantendo no texto para efeito de melhor compreensão da matéria.

1ª) Restritiva: para essa posição, a equiparação só alcança as autarquias (pessoas jurídicas que realizam atividades públicas típicas), não se aplicando às sociedades de economia mista ou àquelas em que o poder público figura como acionista majoritário. Para essa corrente, o disposto no § 2º não ampliou o rol do § 1º, tendo incidência restrita aos casos de que trata.

2ª) Ampliativa: o § 2º ampliou o rol do § 1º, de modo que para ela também são funcionários públicos os funcionários das sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas pelo poder público.

As correntes restritiva e ampliativa perderam a razão de ser em face da nova redação do § 1º do art. 327. O texto anterior, que justificava os divergentes posicionamentos doutrinários, equiparava a funcionário público apenas quem exercia “cargo, emprego ou função em entidade paraestatal” (sublinhado nosso). Atualmente, a norma alcança quem está vinculado por relação funcional ou empregatícia a entidade paraestatal ou empresa privada contratada para a execução de atividade típica da Administração Pública. O cerne passa a ser, assim, a vinculação à entidade paraestatal e, para os demais, a execução de atividade típica da Administração Pública. De modo que não cabe mais discutir sobre a extensão do conceito, se é extensivo ou restritivo, tendo em vista que a lei passa a alcançar não apenas as pessoas físicas vinculadas às autarquias, mas também as que operam nas sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações

criadas ou mantidas pelo poder público, independentemente de terem sido conectadas para a prestação de serviço público (que constitui a regra) ou para a exploração de atividade econômica (admitida apenas de forma excepcional).

Ocorre que a norma empregou a expressão paraestatal e condicionou o exercício de atividade típica da Administração Pública apenas às empresas privadas contratadas ou consorciadas (parte final do dispositivo). O exercício de atividade típica da Administração Pública consiste na produção de bens, serviços ou utilidades para a população (saúde, ensino, segurança pública, calçamento de ruas, limpeza pública etc.). Excepcionalmente, o poder público explora atividade própria da iniciativa privada (atividade econômica) e o faz por meio de pessoas jurídicas que a lei cria ou autoriza que sejam criadas na forma do direito privado (ex.: as que seguem o modelo das sociedades anônimas). A CF ordena que a exploração de atividade econômica pelo poder público se realize de forma excepcional, quando interessar aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art. 173), impondo à entidade criada para tal fim o regime jurídico próprio das empresas privadas, mas sujeita à fiscalização pelo Estado e pela sociedade (art. 173, § 1º, I e II), o que se justifica pelo interesse público em jogo e pelo comprometimento de recursos públicos. O regime jurídico dessas entidades passa a ser híbrido (público e privado). De maneira que o entendimento anterior da posição restritiva, que apenas incluía os servidores vinculados às autarquias, não mais subsiste, sob pena de inegável contrariedade ao sentido da norma penal, que tratou de equiparar expressamente empregados de empresas privadas contratadas ou conveniadas com o poder público. Assim, se fosse possível conferir prevalência à interpretação restritiva, ter-se-ia nítida contradição: responderiam como funcionários públicos os empregados de concessionárias privadas de serviços públicos, mas não responderiam nessa qualidade os empregados de concessionárias públicas de serviços públicos. A lei adotou,

pois, o conceito da antiga interpretação ampliativa, incluindo o pessoal que compõe os quadros da Administração direta e indireta.

A parte final do dispositivo, que permite a equiparação de funcionários vinculados a empresas privadas contratadas ou conveniadas para a execução de atividade típica da Administração Pública, deve ser interpretada restritivamente, sem vinculação com as antigas correntes ampliativa e restritiva. Os serviços públicos devem ser prestados pela Administração Pública direta ou indireta, mas podem também ser realizados por empresas privadas contratadas ou conveniadas. É cada vez maior a parcela de serviços públicos entregues ao setor privado, seja por concessão, permissão ou autorização (institutos de direito administrativo), gerindo o particular interesse público e, por isso, equiparando-se a pessoa física a funcionário público para efeitos penais. A norma faz referência a contratos e convênios administrativos firmados ou celebrados com o fim de execução de atividades da Administração e não com a finalidade de exercício de atividades para a Administração (consumo interno da Administração). Com isso, exclui os funcionários de empresas contratadas para a execução de obras ou serviços de interesse da própria Administração Pública, como a construção ou a reforma de um edifício público. Ex.: o pedreiro ou pintor de empresa contratada para a reforma de um edifício público não é equiparado a funcionário público. Resulta, assim, que os executores de obra para a Administração não são equiparados aos funcionários de empresa concessionária ou permissionária de serviços públicos (como as que exploram as rodovias, telefonia, energia elétrica etc.). A distinção fundamental está no interesse em disputa: se a atividade é usufruída pela comunidade (o serviço é da Administração, ainda que realizado indiretamente por particulares), são equiparados a funcionários públicos os seus prestadores; se a atividade, porém, é destinada a atender a demanda da própria Administração (o serviço é para a Administração), não são equiparados os funcionários da empresa privada contratada. Tanto assim

que os crimes relacionados com o objeto de licitação recebem tratamento específico, não sendo aplicável o § 1º do art. 327 do CP, e sim o art. 84, § 1º, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações Públicas).

Resumo:

Em face da alteração legislativa, resulta:

Conceito penal de funcionário público: pessoa física incumbida do exercício de função pública, a qualquer título, com ou sem remuneração (CP, art. 327, caput);

Funcionário público por equiparação: quanto à vinculação funcional ou empregatícia pode ser:

a) vinculado ao poder público de forma indireta (CP, art. 327, § 1º, primeira parte);

b) vinculado diretamente à empresa privada e ao poder público por contrato ou convênio (CP, art. 327, § 1º, parte final):

1) pessoa física incumbida do exercício de função em entidades da Administração Pública indireta (autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, coligadas ou incorporadas);

2) pessoa física vinculada a empresa ou particular que, por contrato ou convênio, se obriga a prestar serviços públicos.

Fica excluída do conceito legal: pessoa física que mantém vinculação contratual com a Administração Pública para realizar atribuição que não lhe seja típica.

A equiparação do § 1º é aplicável só ao sujeito ativo do delito ou também ao passivo?

Ofender a honra subjetiva de um funcionário de autarquia, em razão de seu trabalho, é injúria ou desacato?

Há, sobre o tema, duas orientações:

1ª) Restritiva: a equiparação só incide sobre a figura do sujeito ativo do delito. De modo que constitui injúria e não desacato ofender funcionário de entidade paraestatal, ainda que o fato tenha relação com a sua atividade.

2ª) Extensiva: a equiparação se estende ao sujeito passivo do crime. Assim, no exemplo dado, temos desacato e não simplesmente injúria.

Entendemos correta a primeira corrente. A norma do art. 327 se encontra no final do Capítulo dos delitos cometidos por funcionário público contra a administração em geral. Se o legislador quisesse que fosse aplicável aos delitos cometidos por particular contra a administração em geral, tê-lo-ia colocado no final do Capítulo II. Além disso, o § 2º, que também contém uma equiparação, impõe aumento de pena "aos autores de crimes previstos" no Capítulo I, permitindo a interpretação de que tal equiparação somente serve para os sujeitos ativos dos crimes, excluindo a figura do sujeito passivo.

Por fim, o § 2º do art. 327 contém uma causa de aumento de pena aos autores de crimes definidos no Capítulo I, desde que "ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público".

Existem duas correntes a respeito da disposição:

1ª) Restritiva: entende que o parágrafo contém:

a) uma equiparação; e

b) uma causa de aumento de pena.

A equiparação e a causa de aumento de pena têm aplicação restrita aos sujeitos que menciona: devem ser "ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público". De modo que somente são funcionários públicos, sofrendo a

causa de aumento de pena dos crimes previstos no Capítulo I, as pessoas expressamente mencionadas, as que ocupam cargos em comissão ou exercem função de direção ou assessoramento nas entidades indicadas. Os outros, por exemplo, os que não exercem função de direção etc., não são funcionários públicos.

Essa é a posição que entendemos correta.

2ª) Ampliativa: para essa orientação, o novo § 2º do art. 327 permite interpretação no sentido de que todos os funcionários das entidades indicadas, exerçam posição de comando ou não, são funcionários públicos para os efeitos penais. A causa de aumento de pena, contudo, aplica-se somente às pessoas expressamente apontadas (as que ocupam cargos de comando etc.).

Se, entretanto, está o delito relacionado com licitação pública, não se aplica o § 2º do art. 327 do CP, e sim o art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações Públicas).

c) Conceito de funcionário público estrangeiro para efeitos penais

De acordo com o art. 337-D, caput, do CP, considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Além disso, equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais (parágrafo único).

A norma interpretativa e extensiva foi introduzida pelo art. 2º da Lei n. 10.467, de 11 de junho de 2002, oriunda do Projeto de Lei n. 4.143, de 2001, visando dar efetividade ao Decreto Legislativo n. 125, de 14 de junho de 2000, do Congresso Nacional, que aprovou a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros nas

Transações Comerciais Internacionais, concluída pelas Nações Unidas em Paris, em 17 de dezembro de 1997, e promulgada pelo Decreto n. 3.678, de 30 de novembro de 2000.

Tendo em vista ser muito restrito o conceito administrativo de funcionário público, o CP, no art. 337-D, como já o fizera no art. 327, ampliou-o para efeitos penais, devendo ser considerado funcionário público estrangeiro quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. A permanência ou a remuneração do funcionário pelo Estado estrangeiro não se faz necessária. Incluem-se, por consequência, não só os funcionários estrangeiros que desempenham cargos criados por lei, regularmente investidos, nomeados e pagos pelos cofres públicos de outro país, como também os que exercem funções públicas ou são investidos em empregos, contratados, mensalistas, diaristas ou nomeados a título precário.

Cargo público corresponde ao criado por lei, com denominação própria, em número certo e pago pelos cofres públicos estrangeiros. Emprego público indica os servidores públicos estrangeiros que não titularizam cargos criados por lei e mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública estrangeira. Função pública significa o conjunto de atribuições que o poder público estrangeiro impõe aos seus servidores para a realização de serviços no plano do Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo. O exercício de cargo, emprego ou função pública deve ser feito em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.

É também considerado funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais (parágrafo único do art. 337-D).

O novo tipo ampliativo por equiparação requer esforço interpretativo

diverso, na medida em que conceitua “funcionário público estrangeiro” de modo menos amplo do que a solução empregada no conceito de funcionário público nacional (art. 327, caput e § 1º, do CP). Na consideração de funcionário público brasileiro, para fins penais, a lei adotou solução direta: qualquer pessoa física incumbida do exercício de função pública, a qualquer título, com ou sem remuneração (art. 327, caput). Já os equiparados a funcionários públicos brasileiros são tanto os vinculados indiretamente ao poder público (art. 327, § 1º, primeira parte) como os que com ele se relacionam, a qualquer título, no exercício de atividades típicas da Administração (art. 327, § 1º, parte final).

Daí decorrem os seguintes conceitos:

a) funcionário público brasileiro (art. 327, caput): pessoa física incumbida do exercício de função pública, a qualquer título, com ou sem remuneração;

b) funcionário público brasileiro por equiparação (art. 327, § 1º):

1) vinculado de forma indireta ao poder público (1ª parte), exercendo funções junto à Administração indireta;

2) vinculado à empresa privada e ao poder público por contrato ou convênio (parte final), exercendo atividades típicas da Administração Pública.

Não foi essa a solução dada pela lei nova, que desprezou o exercício de atividades típicas do poder público estrangeiro, privilegiando somente a vinculação, a qualquer título, a cargo, emprego ou função em entidades estatais ou representações diplomáticas. Equiparou à consideração qualquer pessoa física integrante de empresas estatais controladas pelo poder público ou em atividade em organizações internacionais. Com isso, a inovação restringiu o conceito e não alcançou o empregado de empresa privada internacional que, por contrato ou convênio, realize atividades em representação de Estado estrangeiro ou organização internacional. Não se repetiu, na lei nova, o paralelo da equiparação imposta pela parte final do

art. 327, § 1º, do CP.

Com efeito. De acordo com o novo conceito, é funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, a ele se equiparando a pessoa física vinculada a empresas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público estrangeiro ou em organizações internacionais. O legislador concedeu primazia ao exercício de funções em entidades públicas estrangeiras, e nisso a norma penal se aproxima da solução dada pelo art. 327, caput, do CP. A solução diversa, entretanto, advém da regra de equiparação: é também considerado funcionário público estrangeiro aquele que exerce cargo, emprego ou função em “empresas controladas” por país estrangeiro ou em “organizações públicas internacionais” (parágrafo único do art. 337-D).

Diferentemente da regra estabelecida para os crimes funcionais cometidos por funcionários públicos nacionais, o novo dispositivo restringiu o alcance da equiparação aos que se vinculam diretamente a empresas estatais controladas pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas não nacionais, ou seja, não alcança profissionais ou empregados de empresas privadas estrangeiras, ainda que atuem em representação, por contrato ou convênio, de Estado estrangeiro. Com isso, considerou apenas a investidura em “entidades estatais” ou “representações diplomáticas” (caput) ou, quando ampliou o conceito, embutiu apenas os que se acham vinculados a “empresas controladas” ou em “organizações públicas internacionais”, não incluindo, como o fez na regra do art. 327, § 1º, parte final, os particulares que exercem atividades típicas da Administração Pública e do poder público vinculados por contrato ou convênio. A norma não prevê a equiparação de pessoa física vinculada a empresa privada internacional, ainda que, por contrato ou convênio, realize atividades típicas de entidades internacionais.

Em suma, de acordo com a lei nova, considera-se funcionário público

estrangeiro a:

a) pessoa física que, a qualquer título, exerce cargo, emprego ou função em entidades estatais estrangeiras ou em representações diplomáticas;

b) pessoa física que, a qualquer título, exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas pelo poder público estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DOS TIPOS

O elemento subjetivo do tipo dos crimes cometidos por funcionário público contra a administração em geral é o dolo, vontade livre e consciente de concretizar as elementares objetivas. Como o dolo deve abranger os elementos do tipo, torna-se necessário, para a adequação típica do fato, que o sujeito conheça a sua condição de funcionário público. Não é preciso que tenha consciência técnica sobre o assunto, bastando saber que realiza um serviço, junto ao Estado, que exige uma conduta especial e proíbe determinados comportamentos lesivos. Basta, pois, o dolo eventual, não sendo necessário o direto, i.e., pleno conhecimento da qualidade funcional.

6. CONCURSO DE PESSOAS

Na hipótese de concurso de pessoas, a elementar “funcionário público”, de natureza pessoal ou subjetiva, é comunicável entre os fatos dos participantes (CP, art. 30). A comunicabilidade, entretanto, não é incondicional. Para tanto, é necessário que o terceiro, que não apresenta a qualidade funcional, cometa o fato com conhecimento de sua presença na figura do autor principal. Em outros termos, o dolo, devendo abranger todos os elementos do tipo, precisa alcançar também a elementar funcional.

Suponha-se que alguém seja convidado a cometer um furto. Praticado o fato em concurso com o indutor, verifica-se que este, na verdade, era funcionário público, valendo-se dessa condição para cometer o peculato-furto. Além disso, observa-se que o coautor convidado desconhecia, no

parceiro, sua qualidade funcional. O crime do particular é furto e não peculato-furto. Isso porque o seu dolo não abrangeu a elementar questionada. Se, contudo, sabia que o parceiro era funcionário público, responderia por peculato-furto, nos termos do art. 30 do CP.

Não é preciso que o terceiro conheça com pormenores técnicos a situação funcional do autor principal. Nesse ponto, vale o dolo eventual, bastando que saiba que o executor primário exerce um serviço de natureza pública.

7. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Discute-se se o princípio da insignificância, cujo reconhecimento conduz à atipicidade material da conduta, se aplica aos crimes contra a Administração Pública.

Imagine, por exemplo, um servidor público que subtrai uma folha de papel sulfite da repartição onde trabalha, aproveitando-se do facilitado acesso que possui ao depósito onde fica armazenada. Cometeu crime? O fato se encaixa, do ponto de vista formal, ao tipo penal do art. 312, § 1º, do CP (peculato), pois subtraiu, em proveito próprio, bem pertencente à Administração, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

A inexpressividade da lesão ao erário, contudo, não justifica o reconhecimento da tipicidade material, isto é, o fato não é suficiente para atingir o bem jurídico protegido. A conduta é irregular, mas deve ser censurada administrativamente, e não com o emprego de normas penais.

Os tribunais superiores divergem a respeito do tema da aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública.

Para o STJ, não se aplica (Súmula 599: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública").

O STF, porém, admite a incidência, desde que presentes os quatro vetores formulados pela Suprema Corte como necessários para a aplicação

do princípio da bagatela:

- a) ausência de periculosidade social da ação;
- b) reduzida reprovabilidade do fato;
- c) mínima ofensividade;
- d) inexpressividade da lesão jurídica.

Cite-se, como exemplo, o caso de um carcereiro, acusado de crime de peculato-furto (CP, art. 312, § 1^o), por subtrair farol de milha que guarnecia uma motocicleta apreendida, cujo valor foi estimado em R\$ 13,00 (treze reais). Tratava-se, ainda, de agente primário. A Suprema Corte aplicou o princípio da insignificância ao caso, absolvendo o agente por atipicidade material do comportamento (STF, HC n. 112.388, Rel. p/ Acórdão Min. Cezar Peluso, 2^a Turma, julgado em 21-8-2012).

8. RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Lei n. 12.846/2013 dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Não se trata de normas penais, até porque não se cuida de atos cometidos por pessoas físicas, mas jurídicas e, tirante a esfera dos crimes ambientais, não há em nosso direito positivo a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Além disso, a natureza das sanções impostas nesta Lei se projeta na esfera civil e administrativa. Cuida-se, não obstante, de legislação relevante para a efetividade da proteção à Administração Pública. Esse Diploma caminha ao lado do Código Penal, este punindo as pessoas físicas, e aquele sancionando as pessoas jurídicas por atos ilícitos cometidos contra o poder público.

Capítulo VII

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Peculato

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Figuras típicas. 3. Sujeitos do delito. 4. Objeto material. 5. Elementos objetivos do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Elemento subjetivo do tipo. 8. Elemento normativo do tipo. 9. Peculato-furto. 10. Peculato culposo. 11. Formas típicas qualificadas. 12. Penas e ação penal. 13. Extinção da punibilidade e redução da pena.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Peculato, nos termos do art. 312, caput, do CP, constitui o fato de “apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio”.

Trata-se de uma modalidade especial de apropriação indébita cometida por funcionário público *ratione officii*. É o delito do sujeito que arbitrariamente faz sua ou desvia, em proveito próprio ou de terceiro, a coisa móvel que possui em razão do cargo, seja ela pertencente ao Estado ou a particular, ou esteja sob sua guarda ou vigilância.

Protege-se a Administração Pública no que diz respeito ao interesse patrimonial – preservação do erário público – e moral – fidelidade e probidade dos agentes do poder.

2. FIGURAS TÍPICAS

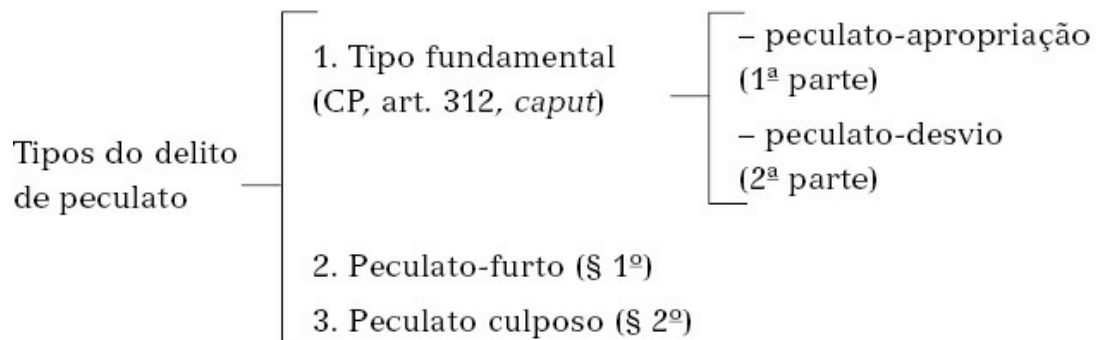
O delito de peculato possui os seguintes tipos penais:

1ª) figura típica fundamental: descrita no art. 312, caput, do CP, que se configura pela “apropriação” (1ª parte) ou “desvio” (2ª parte);

2ª) peculato-furto: definido no art. 312, § 1º; e

3ª) peculato culposo: § 2º.

O § 3º prevê uma causa extintiva da punibilidade e uma causa de diminuição da pena, restritas as duas à modalidade culposa.



3. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, o peculato somente pode ser cometido por funcionário público (CP, art. 327 e §§). Essa qualidade exigida, configurando elemento do tipo, comunica-se, em caso de concurso, aos demais participantes, ainda que particulares, desde que haja ingressado na esfera de seu conhecimento, nos termos do art. 30 do CP.

Sujeito passivo constante é o Estado. Quanto ao sujeito passivo eventual, convém distinguir. Se o objeto material for de natureza pública, sujeito passivo será o Estado ou outra entidade de direito público (Estado-Membro, Município, entidade paraestatal etc.). Cuidando-se de bem particular, o proprietário ou possuidor será o sujeito passivo.

A entidade paraestatal, sendo desmembramento da Administração Pública, quando patrimonialmente lesada pelos seus funcionários, surge como sujeito passivo de peculato (art. 327, § 1º).

E a sociedade de economia mista?

Quando o fato é cometido por funcionário comum, que não exerce atividade de comando, não há peculato, subsistindo a apropriação indébita. Há, entretanto, peculato quando o sujeito exerce função de direção etc., nos termos do § 2º do art. 327. De ver-se, contudo, que existe peculato, qualquer que seja a posição do funcionário na sociedade, se ele recebe delegação para a execução de serviço público.

4. OBJETO MATERIAL

Objeto material é a coisa sobre que recai a conduta do funcionário público: dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, de natureza pública ou privada.

Dinheiro é a moeda metálica ou papel-moeda circulante no País. Valor é qualquer título ou papel de crédito, documento ou efeito negociável representativo de obrigação em dinheiro ou em mercadorias: apólices, ações, letras de câmbio etc. Refere-se o CP, na cláusula final, a qualquer outro bem móvel: tudo o que pode ser transportado de um lugar para outro (exs.: máquina de escrever, móveis, aparelhos etc.). É um caso de interpretação analógica.

O objeto material do peculato é o mesmo do furto, do roubo e da apropriação indébita.

A energia elétrica pode ser objeto material de peculato, como ocorre no furto (art. 155, § 3º)?

Entendemos que sim, uma vez que constitui “bem móvel” a que faz referência o tipo incriminador.

A prestação de serviço, porém, não é “coisa”, não integrando a figura típica. Assim, não constitui peculato o fato de o funcionário público utilizar-se de outrem, também funcionário público, para a realização de atividade em proveito próprio (o chamado “peculato de uso”). Tratando-se,

entretanto, de Prefeito Municipal, o fato configura delito (Dec.-lei n. 201, de 27-2-1967, art. 1º, II).

5. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta pode realizar-se de duas formas:

1ª) apropriação; e

2ª) desvio.

Na apropriação há inversão do título da posse, dispondo o sujeito da coisa como se fosse dono (retendo-a, alienando-a etc.).

No desvio, o funcionário, embora sem o animus rem sibi habendi, i.e., sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua destinação específica, em proveito próprio ou alheio.

Nas duas hipóteses (apropriação e desvio), são exigidas as seguintes condições:

1ª) que o sujeito tenha a posse (ou a detenção) lícita do objeto material;

2ª) que a posse lhe tenha sido confiada em razão do cargo, i.e., que necessariamente exista uma relação de causa e efeito entre o cargo e a posse.

No peculato, a posse ou a detenção resulta da confiança imposta pela lei como indispensável ao exercício de cargo, emprego ou função pública.

A expressão “posse” deve ser tomada em sentido amplo, abrangendo a detenção. Assim, o texto penal é aplicável à posse indireta (disponibilidade jurídica sem apreensão material).

E se a apropriação decorrer de erro?

Neste caso, poderá haver o delito do art. 313, caput, do CP.

E se o sujeito não tinha a posse do objeto material?

Será aplicável, nesse caso, o disposto no art. 312, § 1º, do CP (peculato-furto).

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito, na modalidade peculato-apropriação, no momento em que o sujeito age como se fosse dono do objeto material (retendo-o, alienando-o etc.). No peculato-desvio, o momento consumativo ocorre com o ato do desvio, sendo irrelevante se consegue ou não o proveito próprio ou alheio.

E se o desvio ocorre em proveito da própria Administração Pública?

Inexiste peculato. Nesse caso, o fato pode configurar o delito do art. 315 do CP.

A consumação do peculato está sujeita a prazos e a tomada de contas?

Não. A tomada de contas constitui um ato regulamentar que a Administração realiza quando se torna necessário, não vinculando a consumação do crime. Desde que apurado o desfalque, o delito poderá ser demonstrado por qualquer meio. Os prazos e a tomada de contas servirão apenas para melhor demonstrar a prática delituosa, não condicionando o momento consumativo do delito.

A aprovação de contas pelo órgão competente impede a existência do crime?

Não. Caso contrário, a aprovação de contas constituiria requisito do delito. E a norma do art. 312, como vimos, não a contém como elementar.

A prestação de caução ou fiança, feita pelo funcionário público, impede o delito?

Não, uma vez que a fiança e a caução se destinam a assegurar a indenização do dano causado. Essas garantias podem reparar o dano, mas não impedem o delito.

Comete peculato o funcionário que se apropria ou desvia bens do Estado com a intenção de posterior devolução?

Sim. O funcionário que possui sob sua guarda bens do Estado tem a

obrigação de zelar pelo patrimônio público, não podendo deles dispor ou desviá-los, ainda que o faça com a intenção de reposição futura. De ver-se, entretanto, que não haverá delito se presente o estado de necessidade.

É admissível a compensação?

Não. Não se exclui o delito pela compensação do dinheiro desviado com créditos reais ou supostos do sujeito junto à Administração Pública.

Delito material, admite a figura da tentativa, aplicando-se o que foi dito em relação à apropriação indébita.

7. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de concretizar os elementos objetivos do tipo. Exige-se o animus rem sibi habendi, i.e., a intenção definitiva de não restituir o objeto material e de obter um proveito, próprio ou de terceiro, de natureza moral ou patrimonial. Assim, além do dolo, o tipo requer um fim especial de agir, o elemento subjetivo contido na expressão “em proveito próprio ou alheio”. Esse elemento é exigido nas duas modalidades (peculato-apropriação e peculato-desvio).

8. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Está contido na qualidade exigida do sujeito ativo (“funcionário público”).

9. PECULATO-FURTO

Nos termos do art. 312, § 1º, do CP, “aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário”.

O núcleo do tipo é o verbo subtrair, já apreciado nos crimes de furto e roubo. O peculato, aqui, está descrito na forma do furto. Nada mais é do que o furto cometido pelo funcionário público, valendo-se de sua condição perante a Administração Pública.

Duas são as hipóteses previstas no tipo:

1ª) o sujeito realiza a subtração; ou

2ª) voluntária e conscientemente, concorre para que outro subtraia o objeto material.

Nos dois casos, o funcionário não tem a posse ou a detenção do bem. Se tivesse, responderia pelo delito definido no caput da disposição. Aqui, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, possui facilidade, dada a sua condição na Administração Pública, de subtrair ou permitir que outrem subtraia o objeto material. A facilidade é uma condição de fato, verificável caso por caso, que propicia a prática delituosa.

Na modalidade de concorrência, cometem o delito o funcionário e o terceiro, aplicando-se a regra do art. 30 do CP (comunicabilidade da elementar referente à qualidade de funcionário público).

E se o funcionário arromba uma porta e, penetrando na repartição vizinha, subtrai bens públicos?

Responde por furto qualificado e não peculato-furto. Isso porque não se valeu da facilidade proporcionada pela condição de agente do poder público.

O peculato-furto atinge a consumação, quer cometido pelo funcionário quer por terceiro, nos mesmos moldes do furto.

Crime material, admite a tentativa, aplicando-se os mesmos princípios apreciados no delito de furto.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, vontade livre e consciente dirigida à subtração ou a concorrer com a conduta de terceiro, que subtrai o objeto material. Exige-se, além do dolo, outro elemento subjetivo do tipo, concernente à intenção de obtenção de proveito próprio ou alheio. Por fim, o dolo deve abranger a consciência de valer-se o sujeito da facilidade que lhe atribui a qualidade de funcionário público para subtrair o objeto

material, dada a possibilidade de entrar e permanecer nas repartições etc.

As penas são a reclusão, de dois a doze anos, e multa.

A ação penal é pública incondicionada.

10. PECULATO CULPOSO

Está descrito no art. 312, § 2º: “se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem”.

Nessa forma típica, o funcionário, por negligência, imprudência ou imperícia, concorre para a prática de crime de outrem, seja também funcionário ou simples particular. Assim, em face da ausência de cautela especial a que estava obrigado na preservação de bens do poder público (ou de terceiro) que lhe são confiados, o sujeito facilita a outrem a subtração, apropriação ou desvio dos mesmos.

É imprescindível que o sujeito tenha a posse ou a detenção do objeto material diante da atividade por ele realizada na Administração Pública.

Se o terceiro, também funcionário público, vale-se da facilidade de acesso que tem junto à repartição pública, concorrendo a conduta culposa de outro, este responde por peculato culposo; aquele, pelo delito do art. 312, § 1º.

O crime se aperfeiçoa com a conduta dolosa de outrem, havendo necessidade da existência de nexos causal entre os delitos, de maneira que o primeiro tenha permitido a prática do segundo.

Consuma-se o delito no momento em que outro crime atinge o seu momento consumativo. Culposa a modalidade, não admite tentativa.

A pena é de detenção, de três meses a um ano.

Ocorrendo reparação do dano antes da sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade, prejudicado o disposto no art. 16 do CP (arrependimento posterior); se lhe é posterior, reduz-se de metade a pena imposta (§ 3º).

A reparação do dano pode efetuar-se mediante restituição do objeto

material ou pela indenização do valor correspondente. Pode ser promovida pelo sujeito ativo do peculato ou por terceiro em seu nome.

A extinção da punibilidade estende-se ao terceiro que se aproveitou da conduta culposa do funcionário?

Não. Aproveita somente ao funcionário autor do peculato culposos.

A ação penal é pública incondicionada.

11. FORMAS TÍPICAS QUALIFICADAS

Se o autor do peculato, em qualquer de suas formas, for ocupante de cargo em comissão, função de direção ou de assessoramento, de aplicar-se o aumento de pena previsto no art. 327, § 2º, do CP.

12. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas impostas ao autor do peculato doloso (ou peculato-furto) são a reclusão, de dois a doze anos, e multa (art. 312, caput e § 1º).

No peculato culposos, a pena é de detenção, de três meses a um ano (§ 2º). Trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

13. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E REDUÇÃO DA PENA

Nos termos do § 3º do art. 312, no peculato culposos, “a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta”.

Essa matéria já foi estudada na Parte Geral, no tema da extinção da punibilidade, e no item 10, na apreciação do peculato culposos, a que remetemos o leitor.

Peculato mediante erro de outrem

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Forma típica qualificada. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O delito de peculato mediante erro de outrem, em sua forma singela, está definido no art. 313, caput, do CP com a seguinte proposição: “Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem”.

A espécie é denominada pela doutrina “peculato-estelionato”.

Tutela-se a Administração Pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Delito próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Nada impede, entretanto, que um particular participe do fato, respondendo pelo crime. Assim, pode ocorrer que o funcionário, após receber o objeto material de um terceiro, por erro deste, seja aconselhado por um particular a não o devolver.

Há dois sujeitos passivos. Em primeiro lugar, o Estado. De forma secundária, a vítima da fraude. O lesado, não sendo também vítima da fraude, surge como prejudicado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em o funcionário público apropriar-se de dinheiro ou qualquer outra utilidade mediante aproveitamento ou manutenção do erro de outrem. Imprescindível, para que exista delito, que a entrega do bem

tenha sido feita ao sujeito em razão do cargo que desempenha junto à Administração Pública e que o erro tenha relação com o seu exercício.

Assim, são elementares do tipo:

- 1ª) a apropriação de dinheiro ou qualquer outro bem;
- 2ª) que a apropriação tenha origem no erro de alguém; e
- 3ª) seja cometida por funcionário público no exercício do cargo.

O erro de quem entrega o objeto material deve ser espontâneo, e não provocado pelo funcionário. Caso haja provocação deste, o crime a ser considerado é o estelionato.

O erro pode versar sobre:

- 1ª) a coisa que é entregue ao funcionário;
- 2ª) a pessoa a quem se faz a entrega; e
- 3ª) a obrigação que dá origem à entrega.

É possível que a vítima do engano (particular ou outro funcionário público) entregue o objeto material ao funcionário A e não B. A, no momento da entrega ou posteriormente, percebendo o erro, recebe a coisa. Há, no caso, erro sobre a pessoa.

Imagine-se que a pessoa, ao entregar ao funcionário o objeto A, entregue o B. Há erro sobre a coisa. Na hipótese, pode ocorrer que, em vez de entregar determinada quantidade de certo produto, entregue quantidade a maior.

Suponha-se que alguém, lendo as cláusulas de um contrato, entenda erroneamente dever entregar a certa repartição determinado produto. O funcionário público, ao recebê-lo, não obstante a percepção do erro, não alerta o entregador. Há erro sobre a obrigação que dá origem à entrega.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de apropriar-se do objeto material.

Deve abranger a consciência do erro de outrem e que o objeto material vem ao seu poder em face da atividade pública exercida.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O delito atinge o momento consumativo quando o funcionário público se apropria do objeto material, agindo como se fosse dono (retendo-o, alienando-o etc.).

A tentativa é admissível. Ex.: o funcionário é surpreendido no momento em que está abrindo uma carta contendo valor, a ele entregue por erro de outrem.

6. FORMA TÍPICA QUALIFICADA

Tratando-se de funcionário ocupante de cargo em comissão, função de direção ou de assessoramento em determinadas entidades, de aplicar-se a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do CP.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são a reclusão, de um a quatro anos, e multa. Por se cuidar de delito com pena mínima não superior a um ano, afigura-se cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Inserção de dados falsos em sistema de informações

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Penas e ação penal. 7. Vacatio legis.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 313-A do CP, acrescentado pela Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, constitui o delito o fato de “inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”.

Essa incriminação tem por objetividade jurídica a Administração Pública, particularmente a segurança do seu conjunto de informações, inclusive no meio informatizado, que, para a segurança de toda a coletividade, devem ser modificadas somente nos limites legais. Daí se punir o funcionário que, tendo autorização para manipulação de tais dados, vem a maculá-los pela modificação falsa ou inclusão e exclusão de dados incorretos.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime funcional próprio, só pode ser praticado por funcionário público no exercício do cargo e devidamente autorizado para a preparação de informações armazenadas em meio informático ou em bancos de dados. O concurso de pessoas, no entanto, seja coautoria ou participação, é possível, na modalidade facilitar, já que para ela o funcionário consente que um terceiro possa adulterar os dados. O conceito de funcionário público, para efeito de enquadramento típico, encontra-se no art. 327 do CP.

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, o particular também pode

encontrar-se em tal situação, na hipótese em que, pela modificação dos dados, resultar-lhe prejuízo.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Os núcleos do tipo são os verbos inserir, que quer dizer introduzir, intercalar, implantar; facilitar, que significa auxiliar, tornar fácil, criar modos de acesso à prática do ato. Além deles, alterar, que possui o sentido de mudar, modificar. E, por fim, excluir, entendido como eliminação.

Trata-se de um tipo misto alternativo, em que a ocorrência de mais de um dos núcleos, num mesmo contexto fático, constitui crime único.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro elemento subjetivo da figura típica é o dolo, vontade livre e consciente dirigida à inserção ou à facilitação da inclusão de dados falsos e à alteração ou exclusão indevida de dados corretos em sistema de informações da Administração Pública. Além do dolo, o tipo requer um fim especial de agir, o elemento subjetivo contido na expressão “com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Crime formal, a inserção de dados falsos em sistema de comunicações atinge o momento consumativo no instante em que as informações falsas passam a fazer parte do sistema de informações que se pretendia adulterar.

Quanto à tentativa, ela se mostra admissível em todos os núcleos.

6. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas cominadas pelo art. 313-A são a reclusão, de dois a doze anos, e multa.

A ação penal é pública incondicionada.

7. *VACATIO LEGIS*

A Lei n. 9.983/2000, que inseriu esse tipo no CP, foi publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2000, entrando em vigor noventa dias após a sua publicação, isto é, em 15 de outubro de 2000.

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Causa de aumento de pena. 8. Penas e ação penal. 9. Vacatio legis.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 313-B do CP, introduzido pela Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, constitui delito o fato de “modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente”.

O objeto da tutela penal é a Administração Pública, particularmente a incolumidade de seus sistemas de informações e programas de informática, que só podem sofrer modificações ou alterações quando a autoridade competente solicita ou autoriza a determinado funcionário. Por isso, não havendo tal aquiescência, a conduta é punida, tanto mais por se levar em consideração que tais informações, muitas vezes, encerram sigilo e interesses estratégicos do próprio Estado.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime funcional próprio, só pode ser praticado por funcionário público no exercício do cargo, sem, no entanto, haver sido autorizado ou obtido solicitação da autoridade competente para a finalidade de alterar sistema de informações ou programa de informática.

O Estado é o sujeito passivo. Admite-se, como sujeito passivo secundário, o particular, na hipótese do dano a terceiro.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Os núcleos do tipo são os verbos modificar, cujo significado é mudar, e alterar, que quer dizer adulterar, transformar. Teria o legislador formulado verbos idênticos? Cremos que não, já que modificar prende-se a dados que dizem respeito à estrutura do sistema (de dados) ou ao programa de informática. Já o alterar vincula-se a informações contidas no sistema ou no programa. Ponderamos que a colocação de dois núcleos tão parecidos teve a finalidade de não deixar dúvidas aos intérpretes e aplicadores da norma penal.

Trata-se de um tipo misto alternativo, em que a concretização de mais um dos núcleos, num mesmo contexto fático, constitui crime único.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de modificar ou alterar o sistema de informações ou o programa de informática. É abrangente, devendo alcançar o elemento normativo do tipo. Não é exigido nenhum fim ulterior.

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Está contido na exigência de que a conduta seja realizada “sem autorização ou solicitação de autoridade competente”.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Crime de mera conduta, consuma-se com a alteração ou a modificação.

Admite-se a tentativa. Ex.: o funcionário, no momento de iniciar a modificação de determinado software, é surpreendido, frustrando-se a execução.

7. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

O parágrafo único do art. 313-B dispõe que “as penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a

Administração Pública ou para o administrado”.

O aumento aqui ocorre quando da hipótese de exaurimento do crime, configurado no dano, já que sua consumação se dá, como vimos, pela simples manipulação dos dados por funcionário sem autorização ou solicitação da autoridade competente.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são cumulativas: detenção, de três meses a dois anos, e multa.

O fato consubstancia infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). Trata-se, portanto, de delito abrangido pela competência *ratione materiae* dos Juizados Especiais Criminais. Admite, em razão da pena máxima, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e, dada a pena mínima não superior a um ano, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

9. *VACATIO LEGIS*

A Lei n. 9.983/2000 foi publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2000. Em razão da *vacatio legis*, entrou em vigor noventa dias após a sua publicação, isto é, em 15 de outubro de 2000.

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Objeto material. 4. Conduta típica. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Elemento subjetivo do tipo. 7. Subsidiariedade. 8. Tipo qualificado. 9. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O delito tem a seguinte definição: “Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente” (CP, art. 314).

Visa a incriminação a proteger a Administração Pública, no que diz respeito à ordem, regularidade e segurança de livros oficiais e documentação de natureza pública, ou privada, que devem manter-se íntegros. Por isso, pune-se o funcionário que, tendo a sua guarda em razão do cargo, vem a desviá-los, escondê-los ou inutilizá-los.

Tratando-se de funcionário público que exerce função fiscal, de aplicar-se o art. 3º, I, da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que descreve como delito o fato de “extraviar livro fiscal, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social”, impondo a pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público no exercício do cargo, uma vez que é a ele que são confiados os objetos materiais em razão de sua atividade pública. Admite-se, entretanto, a participação de

terceiro não qualificado.

Ausente a qualidade de funcionário público, poderá haver, conforme o caso, o crime do art. 337 do CP (subtração ou inutilização de livro ou documento).

Sujeito passivo é o Estado. Nada impede, porém, que também apareça o particular como segundo sujeito passivo, ocorrendo a hipótese quando lhe pertence o objeto material (ex.: um documento que esteja na posse da Administração Pública).

3. OBJETO MATERIAL

É o livro oficial ou qualquer documento (público ou particular). Exs.: livros de escrituração das repartições públicas ou de registros, protocolos, papéis de arquivos, relatórios, plantas, representações, projetos, denúncias, queixas, pareceres, provas de concursos oficiais, propostas de concorrências, autos de procedimentos administrativos etc.

A documentação pode ter qualquer natureza: histórica, patrimonial etc.

Cuidando-se de documentos de valor probatório ou autos de processos judiciais extraviados ou sonegados por advogado ou procurador, que os tenha recebido em face dessa qualidade, poderá haver o delito do art. 356 do CP.

4. CONDUTA TÍPICA

Tipo de formulação alternativa, a conduta típica pode ser concretizada de várias maneiras: extraviando, sonegando ou inutilizando os objetos materiais.

Extraviar quer dizer desencaminhar, desviar, alterar a sua destinação. Sonegar significa deixar de mencionar ou de apresentar quando é devido ou exigido por quem de direito, esconder etc. Inutilizar é tornar imprestável para o fim específico a que se destina o livro ou o documento, desgastar na

essência, tornar sem valor utilitário. A inutilização pode ser total (destruição) ou parcial (inutilização propriamente dita).

Tais condutas devem ser realizadas pelo funcionário incumbido *ratione officii* da guarda do livro ou documento. Existe a guarda quer na repartição pública quer em outro local destinado a tal fim pela Administração Pública.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a realização das condutas descritas no tipo (extravio, sonegação ou inutilização do objeto material), sendo irrelevante que, efetivamente, o poder público ou terceiro venha a sofrer dano concreto.

Na modalidade de extravio, o delito é permanente, protraindo-se a consumação no tempo. O mesmo ocorre com a sonegação (escondimento). Na inutilização, o delito é instantâneo de efeitos eventualmente permanentes.

De ver-se que na sonegação somente surge o delito quando o funcionário, tendo o dever jurídico de apresentar o objeto material, deixa de fazê-lo em face de o haver escondido, desencaminhado etc. Nesse caso, o momento consumativo ocorre no instante em que surge o dever de apresentação.

A tentativa é admissível nas modalidades de extravio e inutilização. Na sonegação, contudo, não é possível.

6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de realizar as condutas descritas no tipo, tendo o sujeito consciência de que exerce a guarda do objeto material em face do exercício do cargo.

7. SUBSIDIARIEDADE

O art. 314 do CP apresenta um caso de subsidiariedade expressa. O tipo

sancionador comina pena, ressaltando “se o fato não constitui crime mais grave”. Assim, é possível que o fato constitua peculato (art. 312), supressão de documento (art. 305), subtração ou inutilização de documento (art. 337) etc., casos em que é inaplicável o art. 314 (concurso aparente de normas).

8. TIPO QUALIFICADO

Tratando-se de ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento em determinadas entidades, de aplicar-se a causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do CP.

9. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui delito de maior gravidade objetiva (v. o preceito sancionador). Por se cuidar de delito com pena mínima não superior a um ano, afigura-se cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Vigência. 4. Modalidades do tipo. 5. Conduta típica. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Tipo qualificado. 8. Elemento subjetivo do tipo. 9. Exclusão da ilicitude. 10. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 315 do CP, constitui delito o fato de “dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei”.

É o chamado crime de desvio de verbas.

A ordem administrativa exige a regularidade da correta aplicação do dinheiro público. As verbas e rendas devem ser reservadas à aplicação de acordo com o fim de sua destinação. O funcionário não pode dar preferência arbitrária a esta ou àquela obra pública, sob pena de causar perturbação à atividade administrativa. Por isso, visando ao normal desenvolvimento da máquina administrativa, o legislador houve por punir autores de condutas que, pelo desvio ou emprego irregular de recursos públicos, venham a desatender às exigências da atividade estatal. O tipo protege, pois, a regularidade da atividade administrativa no que diz respeito à aplicação de verbas e rendas públicas.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público que tem poder de disposição de verbas e rendas públicas. Caso do Presidente da República, Governadores de Estado, Ministros ou Secretários de Estado, presidente ou diretores de autarquias etc.

Cuidando-se, entretanto, do Presidente da República, de ver-se o disposto no art. 11 da Lei n. 1.079/50 (crime de responsabilidade).

Tratando-se de Prefeito Municipal, de observar-se o art. 1º, III, do Decreto-lei n. 201/67 (delito de responsabilidade de Prefeito Municipal).

Sujeitos passivos são a União, os Estados, os Municípios etc.

3. VIGÊNCIA

O art. 315 do CP, que descreve o delito de desvio de verbas, não foi revogado pelo art. 1º da Lei n. 6.397/76, que deu redação diversa ao art. 59 da Lei n. 4.320/64.

4. MODALIDADES DO TIPO

A figura típica apresenta duas modalidades:

1ª) emprego irregular de verbas públicas; e

2ª) emprego irregular de rendas públicas.

“Verba” significa “a especificação quantitativa do custo da execução de um determinado serviço público”⁷. Corresponde, no orçamento, ao título do serviço que dá origem à despesa⁸. Neste caso, há uma verba por cuja conta não se poderia fazer despesa não incluída nela legalmente⁹. É o exemplo, fornecido por Nelson Hungria, do “prefeito que lança mão da verba destinada à construção de uma ponte rural para aplicá-la na construção de um jardim”¹⁰.

“Rendas” são o dinheiro percebido pela Fazenda Pública. Nesta hipótese, o funcionário se utiliza do dinheiro público para a realização de serviço não autorizado por lei.

As verbas públicas destinadas a um serviço não podem ser, total ou parcialmente, aplicadas em outro. E as rendas devem ser empregadas de acordo com as determinações legais.

Se as verbas ou rendas apresentam superavit, não pode este ser utilizado senão com permissão legal. Não havendo permissão, deve ser recolhido aos cofres públicos, ou neles permanecer.

5. CONDUTA TÍPICA

O núcleo do delito consiste em o sujeito, funcionário público, dar aos fundos públicos aplicação diversa da determinada ou não autorizada por lei. Torna-se, pois, como elementar imprescindível à tipicidade do fato, necessário que exista lei (orçamentária ou especial) regulamentando a aplicação do recurso financeiro.

O art. 315 do CP, ao falar em “aplicação diversa da estabelecida em lei”, refere-se “à lei orçamentária” (grifo nosso) e não a qualquer lei. É necessário, pois, que o funcionário descumpra a lei orçamentária regulamentadora da aplicação do recurso financeiro.

Diversamente do que ocorre no peculato, no crime de desvio de verbas ou rendas o sujeito não visa ao seu próprio favorecimento ou de terceiro, em detrimento da Fazenda Pública, uma vez que o objeto material, embora irregularmente, é empregado em benefício da própria Administração Pública. Assim, ainda que o funcionário público autor do fato venha a ser indiretamente favorecido pelo desvio, não há alteração no título do crime.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a aplicação indevida das rendas ou verbas. Não basta a simples indicação ou destinação sem execução.

A tentativa é admissível. Ex.: o funcionário, irregularmente, destina verbas públicas a fim diverso de sua destinação. Entretanto, por circunstâncias alheias à sua vontade, não é executado o serviço pretendido.

7. TIPO QUALIFICADO

Tratando-se de funcionário ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento, de aplicar-se a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 327 do CP.

8. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de aplicar diferentemente de sua destinação específica as rendas ou verbas de natureza pública. Não se exige nenhum fim específico, não sendo necessário, por isso, o intuito de lucro.

9. EXCLUSÃO DA ILICITUDE

As causas de exclusão da antijuridicidade previstas no art. 23 do CP são aplicáveis à espécie, deixando de subsistir o delito. Ex.: o funcionário, diante de uma calamidade pública, emprega verba destinada à construção de uma ponte no socorro das vítimas. Nesse caso, o estado de necessidade, afastando a ilicitude, exclui o delito.

10. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são alternativas: detenção, de um a três meses, ou multa.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Concussão

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Qualificação doutrinária. 7. Momento consumativo e tentativa. 8. Tipo qualificado. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 316 do CP, constitui delito o fato de o funcionário público “exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”.

O delito é denominado “concussão”, que deriva de *concutere*, verbo latino, expressão que se emprega quando se pretende indicar o ato de sacudir uma árvore para fazer cair os frutos. Segundo o conceito tradicional, trata-se de uma forma especial de extorsão cometida pelo funcionário público, com abuso de autoridade, contra o particular, que vem a ceder *metus publicae potestatis*. Consiste, pois, em o funcionário exigir de outrem, indevidamente, uma vantagem.

A espécie visa a proteger o normal desenvolvimento dos encargos funcionais, por parte da Administração Pública e na conservação e tutela do decoro desta. De forma secundária, protege-se também o patrimônio do particular contra a forma especial de extorsão cometida pelo funcionário, que se vale, para a prática do delito, da função que desempenha, empregando-a como meio de coação para a obtenção de seus fins.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo, em face de a concussão ser delito próprio, só pode ser o funcionário público, mesmo que ainda não tenha assumido o cargo, mas

desde que aja em virtude dele. Admite-se, entretanto, participação de pessoa não qualificada funcionalmente. Ex.: o particular aconselha o funcionário a cometer o fato (induzimento).

Tratando-se de crime funcional contra a ordem tributária, de aplicar-se o art. 3º, II, da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que descreve o fato de exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar o seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida, impondo a pena de reclusão de um a quatro anos, e multa.

Sujeito passivo é o Estado, titular do interesse protegido e violado pela lesão do dever de integridade que deve nortear a atividade funcional. No plano secundário, aparece também como sujeito passivo o particular vítima da exigência ou outro funcionário.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo exigir, que significa impor como obrigação, ordenar, intimar. A conduta incriminada consiste em o funcionário público exigir do sujeito passivo uma vantagem indevida, direta ou indiretamente, em razão do exercício da função.

A exigência pode ser:

1ª) direta; ou

2ª) indireta.

Na primeira espécie de exigência, a direta, expressa (a viso aperto ou facie ad faciem), o sujeito a formula diante do sujeito passivo. Na segunda, o autor do fato se vale de interposta pessoa para chegar ao conhecimento da vítima a sua pretensão ou formula a exigência de maneira velada, capciosa ou maliciosa (forma implícita de execução).

Não é necessário, para a tipicidade do fato, que o executor da exigência prenuncie ao sujeito passivo a prática de um mal determinado. Basta que a vítima sinta o temor que o exercício da autoridade inspira, influenciando sobre

ela o metus publicae potestatis.

Para que o receio seja sentido pela vítima, não é preciso que o autor, no momento da conduta, esteja no exercício efetivo da função. Como permite o tipo, é possível que se encontre licenciado ou mesmo que ainda não tenha assumido o cargo ou investido na atividade específica, exigindo-se, em todos os casos, que proceda em face da função pública. Não havendo função ou inexistindo relação de causalidade entre ela e o fato, inexistente concussão, podendo surgir outro delito, como a extorsão. Imprescindível, pois, para a subsistência da concussão, que o fato seja cometido em razão da função, prevalecendo-se o sujeito da autoridade que possui.

A vantagem pretendida deve ser indevida, i.e., ilícita ou ilegal, não autorizada por lei. A ilicitude é conferida por norma extrapenal, ou seja, a ilegalidade independe do Direito Penal.

A vantagem pode ser patrimonial ou econômica, presente ou futura, beneficiando o próprio agente ou terceiro.

E se a vantagem beneficia a própria Administração Pública?

Não há concussão, podendo ocorrer o delito de excesso de exação (CP, art. 316, § 1º).

E se não há exigência, mas mera solicitação?

Inexistente concussão, podendo haver corrupção passiva (CP, art. 317).

E se o particular oferece vantagem indevida ao funcionário para que faça ou deixe de fazer alguma coisa (no sentido de fato), havendo nexos causal com o exercício da função pública?

O crime, por parte do particular, será corrupção ativa (CP, art. 333).

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Encontra-se na expressão “indevida”, que qualifica a vantagem.

Se a vantagem é devida, o fato se ressurte de tipicidade a título de

concussão, podendo haver outro delito, como o abuso de autoridade etc.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro elemento subjetivo da figura típica é o dolo, vontade livre e consciente dirigida à exigência, devendo abarcar os outros dados típicos. Além dele, exige-se outro, previsto na expressão “para si ou para outrem”.

Se o sujeito, por erro, supõe devida a vantagem, há erro de tipo (CP, art. 20).

6. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

A concussão é delito formal ou de consumação antecipada. Integra os seus elementos típicos com a realização da conduta de exigência, independentemente da obtenção da indevida vantagem. Se conseguida, fala-se em concussão exaurida, circunstância que não altera o título do delito nem a pena.

7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito, como ficou consignado no item anterior, com a exigência (oral, escrita, por interposta pessoa, por gestos etc.), no momento em que esta chega ao conhecimento do sujeito passivo. Não se exige, para a consumação do delito, que é formal, a consecução do fim visado pelo agente, qual seja a obtenção da indevida vantagem. Se esta ocorre, há simples exaurimento.

Se a conduta do sujeito é provocada, ocorre o que se denomina “crime de flagrante provocado”, inexistindo delito e se aplicando a Súmula 145 do STF.

Quanto à tentativa, convém observar:

1^ª) cuidando-se de conduta unissubsistente, i.e., de ato único, é inadmissível. Ou o sujeito exige ou não;

2^ª) tratando-se, contudo, de conduta plurissubsistente (crime

plurissubsistente), a tentativa é admissível. Ex.: carta extraviada contendo a exigência que chega ao conhecimento da autoridade policial. No caso, o concussionário remete ao sujeito passivo uma carta contendo a exigência. Extraviada, chega ao conhecimento de terceiro (autoridade policial). Há tentativa de concussão.

8. TIPO QUALIFICADO

Tratando-se de sujeito ativo ocupante de função de direção ou de assessoramento ou de cargo de direção, de aplicar-se a causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do CP.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

São impostas penas cumulativas: reclusão, de dois a doze anos, e multa. A pena máxima do delito, que era de oito anos de reclusão, foi elevada pela Lei Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

O crime de concussão, em comparação com a corrupção passiva (art. 317), revela-se mais grave, pois neste o funcionário público exige a vantagem indevida, ao passo que naquele a solicita, a aceita ou a recebe. A despeito disso, ambos possuem a mesma pena, o que constitui ofensa ao princípio da proporcionalidade. Um fato objetivamente mais grave não pode ser punido de maneira abstratamente semelhante a outro, de menor gravidade.

A ação penal é de natureza pública incondicionada.

Excesso de exação

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Figuras do tipo penal. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elementos normativos do tipo. 6. Elementos subjetivos do tipo. 7. Consumação e tentativa. 8. Causa de aumento de pena. 9. Tipo qualificado. 10. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 316, § 1º, do CP, com redação da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, constitui delito o fato de o funcionário público exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza.

Trata-se de um subtipo de concussão, diferenciando-se da figura fundamental pela característica de que, aqui, o sujeito ativo não visa a proveito próprio ou alheio, porém, no desempenho de sua função, excede-se nos meios de sua execução.

O bem jurídico penalmente protegido é a Administração Pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público, admitindo-se, entretanto, a participação de particular. Não é necessário que tenha a missão funcional de arrecadação de tributos ou contribuições sociais. Na maioria das vezes, é certo, isso ocorre. Não há exigência típica, contudo, de que o sujeito seja competente para tal arrecadação. Em consequência, pode ser competente ou não.

Sujeito passivo, em primeiro lugar, é o Estado. Em segundo lugar, o particular vítima da conduta (como também outro funcionário).

3. FIGURAS DO TIPO PENAL

A descrição típica apresenta duas modalidades da infração:

1ª) exigência indevida de tributo ou contribuição social: nesse caso, o sujeito cobra do contribuinte tais atribuições, consciente de que ele não as deve ou devendo saber que são indevidas;

2ª) cobrança vexatória ou gravosa: nessa hipótese, o agente cobra as contribuições, devidas pelo sujeito passivo, de maneira injusta e não autorizada em lei.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Uma das condutas típicas alternativas consiste em o funcionário público exigir tributos, i.e., impostos, taxas e emolumentos.

Taxa é a contribuição correspondente a um serviço prestado à comunidade. Imposto é uma contribuição geral, não tendo correspondência, especificamente, a um serviço público, apresentando-se como um processo de repartição de encargos públicos entre os membros da comunidade. Emolumentos são custas, preços públicos.

Tais tributos, na primeira modalidade típica, são indevidos pelo contribuinte (não determinados por lei; já saldados ou devidos a menor).

O tipo pode também ser concretizado mediante a exigência de contribuições sociais (PIS, PASEP, contribuição social dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro, contribuição social dos trabalhadores etc.).

Na segunda forma típica de execução, as contribuições são devidas. O autor, entretanto, em sua cobrança, emprega meio vexatório ou gravoso (não permitido em lei). Meio vexatório é o que causa humilhação, tormento, vergonha ou indignidade ao sujeito passivo. Meio gravoso é o que lhe importa maiores despesas. Nas duas hipóteses, é necessário que a lei não autorize o emprego do meio escolhido pelo funcionário.

5. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO

Na primeira modalidade típica, concernente à exigência, o legislador inseriu a elementar “indevido”, referindo-se ao tributo. Se devido, o fato é atípico, salvo a ocorrência da conduta descrita na segunda parte do parágrafo ou outro delito (ex.: abuso de autoridade).

Na segunda forma típica, referente à cobrança vexatória ou gravosa, a expressão “que a lei não autoriza” configura outro elemento normativo. De modo que, autorizado o meio, o fato é atípico.

6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

São três:

1ª) o dolo, vontade livre e consciente de exigir ou cobrar tributos ou contribuições sociais, nos moldes descritos no tipo;

2ª) contido na expressão “que sabe” (indevido), referente à primeira modalidade típica (exigência). Nesse caso, é necessário, para que se aperfeiçoe a tipicidade do fato, que o sujeito tenha pleno conhecimento da ilegitimidade do tributo ou contribuição social;

3ª) inserido na expressão “deveria saber”. Nesta hipótese, o sujeito age com dolo eventual. Não tem plena certeza da natureza indevida da cobrança (dolo direto; modalidade anterior), mas tem conhecimento de fatos e circunstâncias que claramente a indicam.

O tipo não admite a modalidade culposa.

7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Na primeira modalidade típica, o delito se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da exigência. Formal o crime, a consumação independe do efetivo pagamento do tributo ou contribuição social. A conduta consiste em exigir e não receber.

Na segunda, o crime atinge a consumação com o emprego do meio

vexatório ou gravoso. Independe a consumação, da mesma forma, do efetivo recebimento do tributo ou contribuição social.

A tentativa é admissível de acordo com os mesmos princípios analisados por ocasião do estudo do crime de concussão, no tocante ao verbo “exigir”. Quanto ao verbo “cobrar”, da mesma maneira, é possível a tentativa quando fracionável o fato (ex.: cobrança vexatória por escrito, que não chega, por circunstâncias alheias à vontade do funcionário, ao conhecimento do contribuinte).

8. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Cometido o fato por ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento, em determinadas entidades, de aplicar-se a causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do CP.

9. TIPO QUALIFICADO

Nos termos do § 2º do art. 316, as penas são agravadas “se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos”.

Cuida-se de um tipo qualificado aplicável somente ao excesso de exação (§ 1º do dispositivo). De forma que não incide sobre a concussão descrita no caput.

Trata-se de um desdobramento da primeira modalidade típica descrita no § 1º do dispositivo, apresentando dois momentos:

1º) o funcionário recebe, indevidamente, taxa, imposto ou emolumento para recolher aos cofres públicos;

2º) após o recebimento, desvia o objeto material em proveito próprio ou alheio. Significa que, ao invés de recolher aos cofres públicos o que indevidamente recebeu, não o faz, dele se apoderando.

E se o apoderamento ocorre depois do recolhimento do tributo aos cofres

públicos?

Há delito de peculato.

O tipo apresenta dois elementos subjetivos:

1ª) o dolo, vontade livre e consciente de realizar a conduta objetiva descrita na norma;

2ª) a intenção de locupletação, contida na expressão “em proveito próprio ou alheio”.

Consuma-se o crime com o efetivo desvio do objeto. Tratando-se de crime material, admite a figura da tentativa.

10. PENAS E AÇÃO PENAL

O tipo simples comina as penas de reclusão, de três a oito anos, e multa. O tipo qualificado (§ 2ª) prevê penas de reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Estranhamente, a Lei n. 8.137/90, alterando a redação do § 1ª do art. 316, passou a cominar pena mínima mais grave para a modalidade simples.

A ação penal é pública incondicionada.

Corrupção passiva

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Tipo agravado pela qualidade do autor. 7. Corrupção passiva própria e imprópria qualificada. 8. Corrupção passiva própria privilegiada. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Dispõe o art. 317, caput, do CP, descrevendo o crime de corrupção passiva: "Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem".

Existem duas espécies de corrupção:

1ª) ativa, quando se tem em mira a figura do corruptor; e

2ª) passiva, em face da figura do funcionário público corrompido.

Trata-se de hipótese de concurso de agentes entre o corruptor e o corrompido. Nas várias legislações, há duas maneiras de conceituação legal do fato:

1ª) descrição de um só delito, aparecendo os dois sujeitos como coautores (delito de concurso necessário);

2ª) formulação típica de dois delitos, um para cada participante do fato (exceção pluralística do princípio unitário do concurso de agentes).

Nosso CP adotou a segunda posição, descrevendo a corrupção passiva (do funcionário) no art. 317, e a ativa (do terceiro), no art. 333.

A corrupção passiva pode ser considerada uma forma de "mercancia" de atos de ofício que devem ser realizados pelo funcionário. Por essa razão, desde há muito criou-se a prática repressiva nas diversas legislações

penais, punindo com severidade a corrupção daqueles que têm certa autoridade e poder dentro do exercício da função pública.

É um delito que apresenta um conteúdo torpe, atingindo o Estado no que diz respeito à Administração Pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Admite-se, entretanto, a participação do particular, mediante induzimento, instigação ou auxílio secundário.

Tratando-se de crime funcional contra a ordem tributária, de aplicar-se o art. 3º, II, da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define o fato de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente, impondo a pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa.

Tratando-se de testemunha, perito, tradutor ou intérprete judicial, realizada a corrupção em face de processo judicial ou administrativo, haverá o delito do art. 342 do CP.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta proibida consiste em o funcionário público solicitar ou receber a vantagem ou aceitar a promessa de recebê-la. Solicitar significa pedir, manifestar o desejo de alguma coisa; receber quer dizer aceitar. Pode também ocorrer o delito mediante a aceitação do recebimento da promessa, concordando o sujeito com a proposta feita pelo terceiro.

A solicitação pode ser direta ou indireta. Ocorre a forma direta quando o funcionário se manifesta de maneira explícita, frente a frente ou por escrito,

ao sujeito corruptor. Indireta quando age por interposta pessoa.

Na solicitação, a conduta pioneira é do funcionário; no recebimento, do corruptor.

A solicitação, recebimento ou aceitação da promessa de vantagem deve ser feita pelo funcionário público em razão do exercício da função, ainda que fora dela ou antes de seu início. Não é necessário, assim, que o sujeito seja titular de um cargo público, bastando que exerça, ainda que incidentalmente, uma função pública.

A corrupção pode ser:

1ª) própria; e

2ª) imprópria.

No primeiro caso, é ilegal, irregular o ato que se pretende que o funcionário realize (ou deixe de realizar). Dá-se o nome de corrupção passiva imprópria quando lícito o ato funcional.

Deve haver nexo de causalidade entre a conduta do funcionário e a realização do ato funcional. Caso contrário, inexistirá o delito questionado, podendo surgir outro.

Nossos tribunais superiores reconhecem o delito ainda quando o ato de ofício mercadejado não esteja direta e especificamente ligado às atribuições formais do cargo.

É o caso, por exemplo, de deputado federal que aceita vantagem indevida em troca de sua influência na nomeação de diretores de estatais. Ainda que não se tratasse de tarefa ligada imediatamente à atividade parlamentar (consistente em editar leis e fiscalizar o Executivo), o agente se beneficia de seu mandato para negociar com o Executivo federal tais nomeações, optando por fazê-lo em face do recebimento de propina e para permitir que cargos estratégicos da administração indireta sejam ocupados por pessoas dispostas a beneficiar ilicitamente empresas (as mesmas que

remuneraram o agente político) em licitações vultosas. Num dos processos decorrentes da “Operação Lava Jato”, a Suprema Corte julgou hipótese semelhante à retratada, proferindo decisão condenatória (STF, AP n. 996, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. em 29-5-2018).

O mesmo se nota no âmbito do STJ: “Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de ‘ato de ofício’”. Ainda: “Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão ‘em razão dela’, presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de ‘ato que está dentro das competências formais do agente’” (REsp n. 1.745.410, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe de 23-10-2018).

Como bem observou o Ministro Barroso do STF em voto proferido no Inquérito 4.506 (p. 2052), a se entender de modo diverso, “o guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune”.

Também se reconhece o crime em situações nas quais a propina aceita, solicitada ou recebida se dá como forma de manter um vínculo espúrio com o administrador, visando à obtenção de vantagens ilícitas futuras. Esse entendimento jurisprudencial também foi fruto de modificação de entendimentos das Cortes Superiores, motivado, em boa parte, pela revelação de grandes esquemas de corrupção no “Caso Mensalão” (AP n. 470) e na “Operação Lava Jato”, embora já pudesse ser antevisto em processos anteriores (“Caso Collor” – AP n. 307). Neste, frise-se, o STF reconheceu que a consumação do crime de corrupção passiva prescinde da efetiva realização do ato funcional, sendo suficiente que a prática ou a

omissão deste ato tenha sido a causa da solicitação, do recebimento, ou da aceitação da vantagem indevida ou da promessa de vantagem indevida. Essa tese foi novamente adotada pelo Supremo no “Caso Mensalão”, no qual não se exigiu que o ato de ofício efetivamente fosse omitido ou praticado, bastando a perspectiva desta prática ou omissão. Na ementa do acórdão desse famoso processo, constou que: “2.7.2. O comportamento reprimido pela norma penal e a pretensão de influência indevida no exercício das funções públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho, comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o regime republicano, não sendo, por isso, necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, certo, preciso e determinado. 2.7.3. O ato de ofício, cuja omissão ou retardamento configura majorante prevista no art. 317, § 2º, do Código Penal, é mero exaurimento do crime de corrupção passiva, sendo que a materialização deste delito ocorre com a simples solicitação ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o recebimento da propina venha a influir na prática de ato de ofício”.

Quanto ao objeto material, é a vantagem, que pode ser patrimonial ou moral. A lei não distingue. Precisa ser indevida (elemento normativo do tipo). Se devida, o fato não é típico em termos de corrupção passiva, podendo surgir outro delito (prevaricação, por exemplo). Pode ser destinada ao próprio sujeito ou a terceiro.

A corrupção pode ser:

1ª) antecedente; ou

2ª) subsequente.

É antecedente quando a vantagem é entregue ao funcionário antes de sua ação ou omissão funcional. A recompensa lhe é entregue em face de uma conduta funcional futura.

É subsequente quando a vantagem lhe é entregue depois da conduta funcional. Assim, se o sujeito solicita dinheiro para realizar um ato de ofício, cuida-se de corrupção antecedente; se, contudo, após a realização do ato faz a solicitação, trata-se da imprópria. Nosso CP, sem fazer distinção, pune as duas formas.

Qualquer dádiva, presente ou recompensa configura o delito de corrupção passiva?

Não. Nem todas as coisas podem ser consideradas objeto material de corrupção. Assim, as gratificações comuns, de pequena importância econômica, em forma de gratidão em face da correção de atitude de um funcionário, não integram o delito. Ex.: as “boas-festas” de Natal ou Ano Novo. Nesses casos, de ver-se que não há da parte do funcionário a consciência de estar aceitando uma retribuição pela prática de um ato de ofício, que é essencial ao dolo de corrupção. Mas se trata de questão de fato, a ser apurada caso por caso.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O tipo apresenta dois elementos subjetivos.

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de realizar as elementares de natureza objetiva. O segundo se encontra na expressão “para si ou para outrem”. Não se exige que o sujeito tenha a intenção de realizar ou deixar de realizar o ato de ofício objeto da corrupção.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Crime formal, a corrupção passiva atinge o momento consumativo no instante em que a solicitação chega ao conhecimento do terceiro, ou em que o funcionário recebe a vantagem ou aceita a promessa de sua entrega.

Quanto à tentativa, é necessário considerar:

1ª) No tocante à solicitação: tratando-se de forma verbal, não é

admissível. Ou o funcionário solicita ou não solicita. Cuidando-se, entretanto, de meio escrito, é possível a tentativa. Ex.: carta contendo a solicitação que, extraviada, não chega ao destinatário, sendo levada à autoridade policial. O funcionário tentou solicitar.

2ª) Em relação ao recebimento da vantagem: não é possível a figura tentada. Ou o sujeito a recebe ou não a recebe.

3ª) Quanto ao verbo aceitar promessa de vantagem: não é também admissível a tentativa, seja o meio verbal ou por escrito. Ou ele aceita ou não aceita. Se remete ao corruptor uma carta contendo a aceitação, ainda que ela não chegue ao seu conhecimento, o delito está consumado (consumou-se no momento em que, na carta, fixou a aceitação).

Pela sua natureza formal, o delito independe, para a consumação, de qualquer resultado ou conduta posterior. Assim, se o funcionário corrompido promete, em face da vantagem recebida, a realização de um ato funcional, o delito está consumado com o recebimento, independentemente do cumprimento da promessa. Se, contudo, realiza o prometido, incide uma causa de aumento de pena (art. 317, § 1ª).

6. TIPO AGRAVADO PELA QUALIDADE DO AUTOR

Tratando-se de funcionário público ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento, de aplicar-se a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2ª, do CP.

7. CORRUPÇÃO PASSIVA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA QUALIFICADA

De acordo com o art. 317, § 1ª, a pena é agravada "se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional".

São casos em que o exaurimento do delito funciona como condição de imposição de pena de maior severidade.

Nos dois primeiros, em que o funcionário retarda por tempo juridicamente relevante a realização da conduta funcional a que está obrigado ou deixa de realizá-la, cuida-se de ato de ofício lícito (corrupção passiva imprópria); no terceiro caso, em que realiza o ato de ofício violando dever funcional, ele é ilícito (corrupção passiva própria).

8. CORRUPÇÃO PASSIVA PRÓPRIA PRIVILEGIADA

Dispõe o § 2º do art. 317 uma forma privilegiada de crime que ocorre quando “o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem”. Nesse caso, a pena é abstratamente reduzida.

Diferencia-se das outras formas típicas pelo motivo que determina a conduta do funcionário. Ele não vende o ato funcional em face de interesse próprio ou alheio, pretendendo receber uma vantagem. Na verdade, transige com seu dever funcional perante a Administração Pública para atender pedido de terceiro (normalmente um amigo) influente ou não. Exige-se que haja pedido ou influência. É a deferência do sujeito ativo que dá origem ao delito.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

A forma típica simples apresenta a pena de reclusão, de dois a doze anos, além de multa (art. 317, caput).

Na corrupção passiva própria e imprópria qualificada, as penas são aumentadas de um terço (§ 1º).

Tratando-se de cargo ou função de comando etc., são aumentadas as penas de um terço (art. 327, § 2º).

Na corrupção privilegiada, as penas são alternativas: detenção, de três meses a um ano, ou multa. Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), razão pela qual se insere na competência material dos Juizados Especiais Criminais, admitindo, em tese,

transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Facilitação de contrabando ou descaminho

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Conceitos de contrabando e descaminho. 4. Conduta típica. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Elementos subjetivos do tipo. 7. Consumação e tentativa. 8. Tipo qualificado. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 318 do CP, constitui delito o fato de “facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho”.

Trata-se de uma exceção do princípio unitário que rege o concurso de agentes (CP, art. 29, caput). Embora, no sentido técnico, o funcionário que facilita o contrabando ou descaminho, violando dever funcional, seja partícipe do crime em que consiste o fato principal (descaminho ou contrabando – arts. 334 e 334-A do CP), a hipótese foi erigida à categoria de crime autônomo. Assim, o autor do descaminho ou contrabando responde, respectivamente, pelos delitos do art. 334 ou 334-A; o funcionário, pelo delito do art. 318.

A incriminação protege a Administração Pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Delito próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Não qualquer, mas aquele a quem é imposto o dever de reprimir ou fiscalizar o contrabando, ou cobrar direitos ou impostos devidos pela entrada ou saída de mercadorias do País. Se o funcionário, sem infringir dever funcional, concorre para o contrabando ou o descaminho, responde, como partícipe, pelos delitos dos arts. 334 ou 334-A do CP (contrabando ou descaminho). Pode ocorrer, porém, que o funcionário, sem violação de dever funcional inerente ao contrabando ou descaminho, venha a concorrer na facilitação

realizada pelo funcionário violador de seus deveres junto à aduana. Nesse caso, será partícipe do crime descrito no art. 318.

Sujeito passivo é o Estado.

3. CONCEITOS DE CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando é o fato de importar ou exportar mercadorias que são total ou parcialmente proibidas de entrar ou sair de nosso país.

Descaminho é a importação ou exportação de mercadorias sem o pagamento do tributo devido.

Diferem em que, no contrabando, a mercadoria é de importação ou exportação proibidas (total ou relativamente); no descaminho, a importação e a exportação da mercadoria são permitidas, consistindo o delito na fraude tendente a evitar o pagamento do tributo devido.

4. CONDUTA TÍPICA

O comportamento proibido consiste em o funcionário público facilitar o descaminho ou contrabando. Facilitar significa auxiliar, tornar fácil, arranjar meios de acesso à prática do fato. Pode ser realizada a conduta por ação ou omissão (não criar obstáculos, aconselhar, indicar os meios da execução da fraude etc.).

O descaminho, em sua modalidade principal (art. 334, caput, do CP), consiste em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

O contrabando, de sua parte, pune o ato de importar ou exportar mercadoria proibida (art. 334-A, caput, do CP).

Pune-se, desse modo, o servidor público que, no exercício de suas funções, facilita a prática de alguma dessas condutas (ou de suas figuras equiparadas, definidas no § 1º dos arts. 334 e 334-A – que serão estudadas adiante, quando do exame dos respectivos tipos penais).

O legislador, em 2014, desmembrou os tipos penais do contrabando e do descaminho, antes reunidos num só dispositivo (art. 334) em dois artigos (334 e 334-A). A alteração se mostrou correta, na medida em que os delitos são dotados de gravidade diversa e, originalmente, possuíam a mesma pena. Com o ajuste feito em 2014, o descaminho (que é essencialmente um crime tributário) e o contrabando (o qual viola não só o patrimônio fiscal do Estado, mas outros bens jurídicos, como a saúde pública, a depender do caso) passaram a ter penas abstratas distintas.

Essa diferente gravidade deve se refletir na punição do funcionário público que facilita um ou outro crime, impondo-se, in concreto, pena mais severa ao agente que auxilia na prática de contrabando.

A jurisprudência dos tribunais superiores construiu entendimento no sentido de que o descaminho não se configura quando o valor do tributo devido e acessórios (multa ou correção monetária) é inferior a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Trata-se de entendimento que invoca o princípio da insignificância, embora tenha como premissa central o princípio da subsidiariedade (derivado da intervenção mínima). Isso porque há lei federal dispensando a Fazenda de efetuar a cobrança judicial do tributo quando a dívida não atinge a cifra mencionada (Lei n. 10.522/2002). Se existe permissivo legal para não ser proposta a execução fiscal, não se deve admitir a propositura de uma ação penal. O Direito Penal, com isso, mantém seu caráter de ultima ratio (intervenção mínima e subsidiariedade).

Esse entendimento deve refletir-se na punição do servidor a quem se imputa a facilitação do descaminho (art. 318)? Ou seja, se o agente da receita federal, em fiscalização de passageiros procedentes do exterior, notando que um brasileiro pretende ingressar no Brasil com produto importado sem pagar o respectivo imposto (cujo valor total não excede R\$ 20.000,00), auxilia-o a sonegar o tributo, deve ser beneficiado com o posicionamento acima?

Não. Ainda que ele não esteja facilitando um fato criminoso, dada a atipicidade material da conduta do passageiro, realiza um comportamento que, à luz do art. 318, se subsume formal e materialmente ao tipo. De notar que o agente está defraudando dolosamente o dever de probidade que deve honrar para com a Administração Pública. O crime de facilitação do contrabando ou descaminho guarda autonomia em relação àqueles descritos nos arts. 334 e 334-A. Bem por isso, quanto à sua consumação, independe da realização integral destes (STF, ARE n. 1.162.384, Min. Gilmar Mendes, DJe de 25-10-2018). Caso o legislador não tivesse construído tipos penais autônomos, a atipicidade da conduta do autor do descaminho se refletiria inexoravelmente no ato praticado pelo facilitador. O Código, entretanto, optou por tratar das condutas em tipos penais diferentes (exceção pluralista à teoria monista), conferindo, assim, independência aos delitos. Além disso, o particular é isento de responsabilidade penal como consequência da dispensa de ajuizamento da execução fiscal para a cobrança do tributo, mas a responsabilidade criminal do servidor independe da propositura dessa ação.

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

A expressão com infração de dever funcional configura um elemento normativo do tipo. Sem ele o fato é atípico a título do crime do art. 318, passando a responder o sujeito, como ficou consignado, como partícipe do crime de contrabando ou descaminho (arts. 334-A ou 334).

6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

A figura típica exige dois elementos subjetivos:

1ª) o dolo, consistente na vontade dirigida à facilitação do contrabando ou descaminho; e

2ª) a consciência de o sujeito violar dever funcional.

Se inexistir, no fato, a consciência de o funcionário estar infringindo um

dever funcional específico, não há falar no crime do art. 318, passando o sujeito a responder como partícipe de descaminho ou contrabando (arts. 334-A ou 334).

7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a realização da conduta, comissiva ou omissiva, de facilitação. Delito formal, independe a consumação da prática efetiva do contrabando ou descaminho (STF, ARE n. 1.162.384, Min. Gilmar Mendes, DJe de 25-10-2018).

Quanto à tentativa, é admissível quando a facilitação é realizada mediante conduta comissiva; tratando-se, entretanto, de facilitação mediante omissão, a tentativa é inadmissível.

8. TIPO QUALIFICADO

Se o sujeito ativo exerce cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento em determinadas entidades ligadas à atividade aduaneira do Estado, de aplicar-se a causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do CP.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

São a reclusão, de três a oito anos, e multa, nos termos do art. 21 da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

A ação penal é pública incondicionada.

Prevaricação

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos normativos do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Prevaricação e outros delitos. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Prevaricação consiste no fato de o funcionário público “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal” (CP, art. 319).

Na prática do fato, o funcionário se abstém da realização da conduta a que está obrigado, ou a retarda ou a concretiza contra a lei, com a destinação específica de atender a sentimento ou interesse próprios.

É um delito que ofende a Administração Pública, causando dano ou perturbando o normal desenvolvimento de sua atividade. O funcionário não mercadeja sua função, o que ocorre na corrupção passiva, mas a degrada ao violar dever de ofício para satisfazer objetivos pessoais.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Não se exclui, porém, a participação de terceiro não qualificado (que não é funcionário público).

Sujeito passivo é o Estado. Eventualmente, pode também surgir como sujeito passivo secundário o particular que vem a sofrer dano ou perigo de dano em face da realização, omissão ou retardamento da prática do ato de ofício.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O crime pode ser realizado de três maneiras:

- 1ª) retardando ato de ofício;
- 2ª) deixando de realizá-lo; e
- 3ª) realizando-o.

Nas duas primeiras formas, o delito é omissivo; na terceira, comissivo.

Retardar significa protrair, não realizar o ato de ofício dentro de um prazo estabelecido pela lei, pouco importando que a demora venha a tornar sem validade o ato posteriormente praticado.

Na segunda forma de cometimento do delito, o sujeito, definitivamente, não realiza o ato. Na terceira, ele o realiza, embora de forma contrária à estabelecida na lei. Neste último caso, não se cuida de ato de ofício, mas de ato que transgride o mandamento legal (lei e não regulamento).

Ato de ofício é aquele que se encontra dentro da competência do funcionário, nos moldes das atribuições da função por ele exercida. Pode ser judicial ou administrativo.

4. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO

O retardamento e a omissão da realização do ato de ofício devem ser indevidos, o que constitui o primeiro elemento normativo do tipo. A realização do ato, na última figura típica, deve ser contra expressa disposição de lei (o segundo elemento normativo do tipo).

Se devidos o retardamento ou a omissão, o fato é atípico. Da mesma forma, não há falar em fato típico quando o ato é realizado de acordo com disposição expressa de lei.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente dirigida ao retardamento, omissão ou realização do ato. É necessário que abranja o conhecimento da

ilegalidade da conduta, i.e., é preciso que o sujeito saiba que está retardando ou deixando de realizar o ato de forma indevida ou que o esteja praticando contra a lei.

O segundo elemento subjetivo do tipo se encontra na expressão “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. Sem a finalidade alternativa, a conduta é absolutamente atípica.

Interesse pessoal é a vantagem pretendida pelo funcionário, seja moral ou material. Sentimento diz respeito ao afeto do funcionário para com as pessoas, como simpatia, ódio, vingança, despeito, dedicação, caridade etc.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O delito atinge o momento consumativo com a omissão, retardamento ou realização do ato.

Na omissão e no retardamento, sendo omissivo próprio o delito, não se admite a forma tentada. Na prática do ato, sendo comissivo o crime, a tentativa é admissível.

7. PREVARICAÇÃO E OUTROS DELITOS

1. Prevaricação e desobediência

Apresentam pontos de semelhança. Diferem, entretanto, em que na desobediência (CP, art. 330) o sujeito ativo só pode ser o particular ou o funcionário quando não age em razão de sua função.

2. Prevaricação e corrupção passiva

Na corrupção passiva, há um ajuste entre o corrupto e o corruptor, o que inexistente na prevaricação.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são a detenção, de três meses a um ano, e a multa.

O fato constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n.

9.099/95). O delito, portanto, é de competência dos Juizados Especiais Criminais, admitindo, desse modo, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Modalidade equiparada à prevaricação (ou prevaricação imprópria)

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito e objetividade jurídica. 3. Sujeitos do delito. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Elemento subjetivo do tipo. 7. Consumação e tentativa. 8. Penas e ação penal.

1. INTRODUÇÃO

A Lei n. 11.466, de 28 de março de 2007, introduziu no Código Penal o art. 319-A, sem rubrica própria, como modalidade equiparada à prevaricação. Cuida-se de novatio legis incriminadora e abrange comportamentos cometidos após a sua entrada em vigor, que se deu em 29 de março de 2007.

É de ver que referida lei também alterou a LEP, suprimindo lacuna normativa até então existente, na medida em que introduziu em seu art. 50 o inciso VII, o qual prevê constituir falta grave a conduta do preso definitivo que: “tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.

2. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O delito consiste em: “deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.

O bem jurídico tutelado na norma incriminadora é a Administração Pública, notadamente no que diz respeito à Administração Penitenciária.

3. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido pelo diretor da penitenciária ou por algum funcionário público encarregado de zelar pela ordem e disciplina durante a execução da pena (note que a lei fala em deixar de cumprir o dever de vedar ao preso acesso a aparelho telefônico etc.).

O termo penitenciária abrange estabelecimentos prisionais que abrigam presos definitivos e provisórios. De notar-se que o art. 87 da LEP, em seu parágrafo único, autoriza que entes da federação construam penitenciárias para receber presos provisórios. "Assim, será sujeito ativo do delito até mesmo o diretor de cadeia pública, dos centros de detenção provisória e outros congêneres..."¹¹.

Não se exclui a participação de terceiro não qualificado (que não é funcionário público).

O particular responsável pelo ingresso, promoção, intermediação, auxílio ou facilitação da entrada do aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, responde pelo crime do art. 349-A do CP (incluído pela Lei n. 12.012, de 6-8-2009).

Sujeito passivo é o Estado.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta nuclear deixar de cumprir o dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico etc. pode ser realizada de forma comissiva ou omissiva. Note que o dever de vedar o acesso impede o sujeito ativo de colaborar diretamente, por exemplo, entregando ao preso o aparelho telefônico, ou indiretamente, permitindo que terceiro o faça.

São objetos materiais do crime: (i) o aparelho telefônico; (ii) o aparelho de rádio; (iii) os aparelhos similares aos anteriores, que permitam a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

O tipo penal requer comportamento realizado em descumprimento ao dever (jurídico) de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar. O desrespeito ao mencionado dever constitui elemento normativo do tipo.

6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, isto é, a vontade livre e consciente dirigida ao descumprimento do dever de proibir o acesso ao preso de aparelho telefônico etc.

Não se exige qualquer outro elemento subjetivo. Dessa forma, não é preciso que o sujeito atue para satisfazer interesse ou sentimento pessoal (como ocorre na hipótese do art. 319 do CP).

7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime se consuma com o acesso do preso ao aparelho de telefone celular etc., ainda que este não consiga utilizá-lo (o uso efetivo do aparelho configura exaurimento). Admite-se a forma tentada, quando a conduta do sujeito ativo é comissiva (p. ex., o carcereiro ingressa com o aparelho de telefone celular no estabelecimento e, quando está prestes a entregá-lo ao preso, é surpreendido por seu superior, que o prende em flagrante).

8. PENAS E AÇÃO PENAL

A pena é a detenção, de três meses a um ano (cuida-se de infração de menor potencial ofensivo).

A ação penal é pública incondicionada.

Condescendência criminosa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Tipo qualificado. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito o fato de o funcionário público deixar, “por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento da autoridade competente” (CP, art. 320).

O delito ocorre quando o sujeito ativo, funcionário público, levado a agir ou deixar de agir por indulgência, não denuncia ou não responsabiliza seu subordinado que violou mandamentos de natureza administrativa, no exercício do cargo.

A incriminação protege a dignidade e a eficiência da máquina administrativa, no que diz respeito ao seu normal desenvolvimento. Levando em conta a ordem que deve nortear suas atividades, o Estado comina pena ao funcionário que age dessa maneira.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Admite-se, contudo, a participação do particular (mediante induzimento ou instigação).

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Há duas condutas típicas:

1ª) deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo; e

2ª) não levar o fato cometido pelo subordinado, quando a iniciativa da apuração de sua responsabilidade não é de sua competência, a conhecimento da autoridade competente.

Nos dois casos o delito é omissivo próprio, punindo-se simplesmente a omissão da conduta devida.

Deixar de responsabilizar significa não apurar o fato cometido pelo subordinado que cometeu a infração ou não lhe aplicar a sanção adequada, dentro da esfera de sua competência.

Na segunda hipótese, o funcionário, não sendo competente para efetuar a responsabilidade do subordinado pela falta cometida (infração), não dá notícia à autoridade competente.

O tipo exige que o subordinado tenha cometido infração (penal ou administrativa). A falta deve guardar conexão com o exercício do cargo. Assim, não há condescendência delituosa quando o subordinado cometeu um crime que não se relaciona com o exercício do cargo.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro elemento subjetivo da figura típica é o dolo, vontade livre e consciente dirigida às condutas omissivas. O segundo está na expressão "por indulgência". O funcionário deixa de agir por clemência, tolerância, brandura etc. Se a razão da conduta é outra, como o atendimento de sentimento ou interesse pessoal, o fato constitui prevaricação. Se pretende obter vantagem indevida, deve ser considerado o crime de corrupção passiva.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Crime omissivo próprio, atinge a consumação com a simples conduta negativa.

A tentativa não é admissível. Como sabemos, o delito omissivo próprio

não a permite.

6. TIPO QUALIFICADO

Tratando-se de ocupante de cargo em comissão ou de função de direção etc. em certas entidades, de aplicar-se a causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do CP.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são alternativas: detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

O crime constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), sendo abrangido pela competência material dos Juizados Especiais Criminais. Comporta, em face disso, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Advocacia administrativa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Tipo qualificado. 7. Causa de aumento de pena. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Advocacia administrativa consiste no fato de “patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário” (CP, art. 321).

Ao funcionário público não é permitido agir para a satisfação de interesse privado, valendo-se de sua qualidade em face da Administração Pública. Por isso, proibindo o fato, a lei penal protege o regular funcionamento da administração governamental, tutelando-a da conduta irregular de seus componentes que, em razão do cargo, procuram defender interesses alheios ao Estado, de particulares, lícitos ou ilícitos. A Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, não permite que o funcionário atue, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro (art. 117, XI). E o art. 30, I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, diz que o advogado servidor público não pode patrocinar qualquer interesse perante a Administração Pública que o remunere ou à qual seja vinculada a entidade que o emprega (Lei n. 8.906, de 4-7-1994).

Tratando-se de crime contra a ordem tributária, de aplicar-se o art. 3º, III, da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define o fato de “patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a

administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público”, impondo a pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa.

Cuidando-se de crime relacionado com licitação pública, de aplicar-se o art. 91 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que, impondo a pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, tem a seguinte redação: “Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário”.

Protege-se, pois, a Administração Pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Admite-se, entretanto, a participação de particular mediante induzimento, instigação ou auxílio secundário.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta proibida consiste em o funcionário público patrocinar interesse de outrem. Patrocinar significa pleitear, advogar, facilitar etc. O patrocínio pode ser:

1ª) formal e explícito: petições, razões etc.;

2ª) dissimulado: acompanhamento pessoal de processos, pedido a funcionário encarregado do procedimento etc.

O delito pode ser cometido direta ou indiretamente. Na forma direta, o funcionário age, ele próprio, para a obtenção da realização do interesse do terceiro. No meio indireto, o sujeito se vale de interposta pessoa, caso em que um terceiro faz as vezes do funcionário, de acordo com suas instruções, ocultando-o.

O interesse privado pode ser legítimo ou ilegítimo.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de patrocinar interesse privado junto à Administração Pública. Na forma qualificada (art. 321, parágrafo único), deve abranger a ilegitimidade do interesse.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a realização do primeiro ato de patrocínio, independentemente de o funcionário obter algum resultado pretendido. Admite-se a tentativa. Ex.: o funcionário é surpreendido no momento em que vai apresentar uma petição a quem de direito, sendo impedido de levá-la ao seu conhecimento por circunstância alheia à sua vontade.

6. TIPO QUALIFICADO

Tratando-se de interesse ilegítimo, incide a qualificadora do parágrafo único do art. 321.

7. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Tratando-se de ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento, de aplicar-se o § 2º do art. 327 do CP.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

No tipo simples, a pena é alternativa: detenção, de um a três meses, ou multa. Na forma qualificada, as penas são cumulativas: detenção, de três meses a um ano, e multa.

O fato consubstancia infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). Trata-se, portanto, de delito abrangido pela competência *ratione materiae* dos Juizados Especiais Criminais. Admite, em razão da pena máxima, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e, dada a pena mínima não superior a um ano, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Violência arbitrária

SUMÁRIO: 1. Revogação. 2. Conceito e objetividade jurídica. 3. Sujeitos do delito. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. REVOGAÇÃO

Há discussão na doutrina e na jurisprudência sobre a vigência do art. 322 do CP, que descreve o delito de violência arbitrária. Para alguns, ele foi revogado em 1965, pela extinta Lei n. 4.898/65, que definia os crimes de abuso de autoridade (estes, atualmente, se encontram na Lei n. 13.869/2019).

Prevalece, em nossos tribunais superiores, o entendimento de que não houve revogação tácita, ou seja, encontra-se em vigor o dispositivo legal.

Nesse sentido, há acórdãos tanto do STF quanto do STJ:

- STF, (HC n. 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 9-8-13 e RHC n. 95.617, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 16-4-2009;
- STJ, HC n. 48.083, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe de 7-4-2008.

2. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Consiste em delito o fato de “praticar violência arbitrária, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la” (CP, art. 322).

A lei penal tutela a Administração Pública. Além disso, protege a incolumidade física, liberdade etc. do particular contra a conduta abusiva do funcionário público.

O dispositivo deve ser compreendido como um tipo geral, o qual dará lugar a eventual tipo especial definido na Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869, de 5-9-2019).

3. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime próprio: só pode ser cometido por funcionário público. Admite-se, entretanto, a participação de particular mediante induzimento ou instigação.

Sujeito passivo é o Estado. Além dele, intervém o indivíduo sujeito ao abuso do funcionário (sujeito passivo secundário).

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O comportamento proibido consiste em praticar violência, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la.

A expressão “violência” significa emprego de força bruta, a vis corporalis, que se materializa em vias de fato, lesão corporal (leve, grave ou gravíssima) ou homicídio. Ficam excluídas a violência moral e a usada contra a coisa.

De ver que o dispositivo tem caráter geral, não prevalecendo diante dos tipos penais contidos na Lei de Abuso de Autoridade que descrevam comportamentos cometidos por agente público, no desempenho da função ou a pretexto de exercê-la, com violência, como, por exemplo, o art. 24 da Lei, que pune o ato de constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração.

É indispensável que o comportamento abusivo seja realizado no desempenho da função ou sob a desculpa (real ou suposta) de exercê-la. No primeiro caso, o sujeito realmente está realizando a atividade específica. No segundo, ele faz crer a outrem a realização de tal desempenho.

O emprego de violência real deve ser arbitrário, i.e., sem razão legítima, a ser apreciada pelo julgador.

Não há tipicidade se a violência está autorizada pela lei. Ex.: o CPP, nos

arts. 284 e 292, caput, autoriza o emprego da força física quando se torna necessária, por exemplo, para a realização de uma prisão. Neste caso, não há violência arbitrária por força de ausência de tipicidade do fato.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de praticar o ato violento. Exige-se outro: consciência da ilegitimidade da conduta.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a prática da violência (vias de fato, lesão corporal ou homicídio).

A tentativa é admissível. Ex.: o soldado desfere um golpe, usando um cassetete, contra a vítima, errando o alvo.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de três meses a três anos, além da correspondente à violência. Assim, havendo violência arbitrária com lesão corporal, aplica-se a regra do concurso material. Cuidando-se, entretanto, de simples vias de fato, estas ficam absorvidas.

Em razão da pena mínima (não superior a um ano), admite o delito o sursis processual (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Abandono de função

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Figuras típicas qualificadas. 8. Causa de aumento de pena. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 323 do CP, constitui crime o fato de o funcionário público “abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei”.

O nomen juris é impróprio, uma vez que o tipo fala em “cargo público”, que tem conceito diferente de “função pública”. A Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, diz em seu art. 3º, caput, que “cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor”. Os cargos públicos, reza o parágrafo único da mesma disposição, “são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão”. E o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n. 10.261, de 28-10-1968), em seu art. 4º, diz que “cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário”. “Função pública” corresponde a qualquer atividade realizada pelo Estado com a finalidade de satisfazer as necessidades de natureza pública. Como se vê, o conceito de “cargo público” é menos amplo do que o de “função pública”. Por isso, o nome do delito deveria ser “abandono de cargo” e não de “função”.

A lei penal protege a Administração Pública, no que concerne à regularidade da prestação de serviços públicos.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser sujeito ativo o funcionário público regularmente investido no cargo público. Por isso, não é todo abandono de função que caracteriza o delito.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo abandonar (cargo público), que significa afastar-se com propósito, ausentar-se de maneira arbitrária do local onde se exerce o cargo público. O abandono deve ser total, i.e., o sujeito deve afastar-se de maneira global de seus deveres para com a Administração Pública. Esse abandono deve acarretar probabilidade de dano ao setor público. Além disso, deve ser por um tempo razoável, juridicamente relevante. Se há abandono, porém sem causar probabilidade de dano ao poder público ou por tempo insignificante, não existe delito. Ex.: o funcionário abandona o cargo, imediatamente satisfeitos os seus deveres por um substituto. Pode haver falta disciplinar, mas não crime.

Se o funcionário pedir demissão, deverá aguardar o deferimento do pedido a fim de afastar-se de suas obrigações. Se foi demitido, não tem mais deveres com o poder público, podendo afastar-se definitivamente do exercício do cargo. De ver-se, entretanto, que se ele pede demissão e desde logo se afasta, não esperando o deferimento de seu pedido, pode haver o delito em exame.

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Encontra-se na expressão “fora dos casos permitidos em lei”.

Em algumas hipóteses, a lei admite o abandono do cargo público, como nas ocasiões de força maior (doença) ou de estado de necessidade (inundação, seca, guerra etc.). Nesses casos, o fato é atípico. A tipicidade decorre da realização da conduta “fora dos casos permitidos em lei”. Logo,

quando o abandono é legalmente permitido, não há adequação típica entre o fato concreto e o modelo legal.

De ver-se que há delito quando o funcionário, cessada a causa do abandono permitido, prossegue ausente.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de abandonar o efetivo exercício do cargo público, abrangendo o conhecimento da irregularidade da conduta e da probabilidade de dano à Administração Pública.

Não é punível a conduta negligente.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com o afastamento do exercício do cargo público por tempo juridicamente relevante.

Delito omissivo próprio, não admite a forma tentada.

7. FIGURAS TÍPICAS QUALIFICADAS

Os tipos apresentam duas formas qualificadas:

1ª) Quando o abandono causa prejuízo público (art. 323, § 1º).

Para o tipo simples (caput da disposição), basta a probabilidade de dano. Se este ocorre, a pena é agravada. Trata-se de uma hipótese de delito exaurido em que o resultado da conduta qualifica o tipo.

Cuida-se de prejuízo público, i.e., o causado aos serviços de natureza pública, não abrangendo o de natureza particular.

2ª) Se o abandono ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira (§ 2º).

Considera-se faixa de fronteira a situada a 150 km da nossa divisa com outros países (Lei n. 6.634/79, art. 1º). A proteção penal é de relevância, uma vez que o abandono realizado pelo funcionário, dada a natureza do

local, pode afetar os altos interesses nacionais junto às nossas fronteiras.

8. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Se o sujeito ativo exerce função de direção, cargo em comissão etc., de aplicar-se a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do CP.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

No tipo simples é prevista a pena de detenção, de quinze dias a um mês, ou multa (art. 323, caput).

Causando o fato prejuízo público, as penas são a detenção, de três meses a um ano, e a multa (§ 1º).

Constituem essas figuras infrações de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), admitindo transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

Ocorrendo o abandono na faixa de fronteira, as penas são a detenção, de um a três anos, e a multa (§ 2º). Neste caso, cabe apenas o sursis processual.

A ação penal é pública incondicionada.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Exclusão genérica da ilicitude. 6. Consumação e tentativa. 7. Tipo qualificado. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 324 do CP dispõe como delito o fato de o sujeito “entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso”.

O objeto jurídico é a regularidade da Administração Pública. O irregular exercício do cargo público perturba a normal atividade da máquina administrativa, causando prejuízo ao poder público em sua missão de prestação de serviços. Daí a incriminação do fato.

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime próprio. Por isso, só pode ser cometido por funcionário público (CP, art. 327). É esta qualidade do sujeito ativo (elemento normativo do tipo) que distingue o delito da usurpação de função pública, cometido por particular (CP, art. 328).

Observe-se que na segunda modalidade da figura típica, em que o autor continua, indevidamente, a exercer as obrigações que lhe foram impostas não obstante demitido, ele não é mais funcionário público.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A norma incriminadora descreve duas condutas:

1ª) entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais; e

2ª) continuar a exercê-la depois de exonerado, substituído, suspenso ou removido.

Na primeira modalidade típica, é indispensável que o sujeito já tenha sido nomeado para o cargo público, uma vez que o que se tem em vista é o início irregular da atividade funcional. Incrimina-se o início indevido da atividade pública, que ocorre no momento em que o agente realiza qualquer ato de ofício inerente às suas funções.

Trata-se de norma penal em branco, uma vez que o tipo penal não diz quais são as “exigências legais” que devem ser satisfeitas (elemento normativo do tipo). Estas estão contidas nos estatutos dos funcionários públicos civis da União e dos Estados. Para o início regular do exercício do cargo público, é necessário o ato da posse, que investe a pessoa em cargo ou função pública, que se concretiza “pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado” (art. 13, caput, da Lei n. 8.112, de 11-12-1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União). Há outras exigências legais, como a inspeção de saúde, eventual exame psicotécnico (para alguns cargos), prova de quitação do serviço militar, fiança (quando prevista em lei) etc.

Na segunda modalidade típica, o CP descreve uma forma de usurpação de função pública. O funcionário exonerado, removido, substituído ou suspenso persiste no exercício de suas atividades funcionais, sem autorização de quem de direito. Para que haja delito, é preciso que ele tenha conhecimento oficial de sua exoneração, remoção, suspensão ou substituição. Se mesmo assim ele permanece no exercício do cargo, sem a autorização devida, adapta sua conduta ao modelo legal.

Quanto à aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade, não é necessária a expedição do decreto para que o funcionário público passe à inatividade. Ela é automática, nos termos do art. 187 do estatuto dos servidores públicos civis da União: "A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo" (Lei n. 8.112/90). Logo, completados os setenta anos de idade, deve o funcionário afastar-se do exercício do cargo, independentemente do respectivo decreto, sob pena de incorrer na sanção penal, se presente a elementar subjetiva (dolo).

O exercício do cargo durante férias ou licença não ingressa na incriminação legal, que fala em exoneração, remoção, substituição ou suspensão.

Na segunda figura típica, é preciso que a permanência no exercício da função pública ocorra sem autorização. Cuida-se de um elemento normativo do tipo. Não obstante substituído ou removido, v.g., é possível que não se lhe obtenha um substituto imediato. Nesse caso, pode ser autorizado por quem de direito (funcionário competente) a prosseguir no exercício da função até ordem superior, inexistindo crime por atipicidade do fato (a ausência do elemento normativo do tipo "sem autorização" afasta a tipicidade).

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

Na primeira modalidade típica, o elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de antecipar o início da atividade funcional, que abrange o conhecimento da insatisfação das exigências legais.

Na segunda forma típica, o primeiro elemento subjetivo é o dolo, vontade de prosseguir no exercício da função pública. Exige-se um segundo elemento subjetivo, contido na expressão "depois de saber oficialmente" que foi exonerado etc. Não basta a publicação da exoneração etc. no Diário

Oficial. É indispensável provar que o funcionário público, pelo Diário Oficial ou outro meio, tomou conhecimento da exoneração etc. Não é suficiente, pois, a presunção de conhecimento. A dúvida também não aproveita à incriminação.

A ausência de qualquer elemento subjetivo do tipo conduz à atipicidade do fato.

5. EXCLUSÃO GENÉRICA DA ILICITUDE

Não há delito, por incidência de exclusão da ilicitude, quando presente circunstância que conduz o funcionário a iniciar ou prosseguir na atividade funcional por estado de necessidade, com a finalidade de evitar dano ao Estado, na ausência de um substituto imediato.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O momento consumativo do delito ocorre com a realização do primeiro ato de ofício indevido. Não é necessário que o funcionário realize indevidamente uma série de atos funcionais. Basta a prática de um.

A tentativa é admissível. Ex.: o agente, já na repartição pública, após sua exoneração, tenta realizar ato de ofício, sendo obstado pelo diretor.

7. TIPO QUALIFICADO

Tratando-se de funcionário ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento, em determinadas entidades, de aplicar-se a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do CP.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são alternativas: detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), razão pela qual se insere na competência material dos Juizados Especiais Criminais, admitindo, em tese, transação penal (art. 76 da Lei n.

9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).
A ação penal é pública incondicionada.

Violação de sigilo funcional

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Subsidiariedade expressa. 3. Sujeitos do delito. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Qualificação doutrinária. 6. Elementos subjetivos do tipo. 7. Exclusão da ilicitude. 8. Consumação e tentativa. 9. Tipo qualificado. 10. Sigilo funcional de sistema de informações. 11. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 325 do CP dispõe a violação de sigilo funcional como delito com a seguinte descrição: "Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação".

Certos fatos relacionados com a Administração Pública, não obstante a publicidade dos atos administrativos, devem ficar a coberto do conhecimento geral em razão do interesse funcional. Daí porque merecem ficar em segredo. Uma lei, regulamento ou uma ordem administrativa pode, excepcionalmente, impor o sigilo. O funcionário infiel que revelar o fato estará traindo a Administração Pública, causando dano ou a probabilidade de dano público ou particular. O legislador visa a proteger a Administração Pública no que concerne ao interesse de manter em segredo certos fatos da vida funcional.

2. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA

O delito de violação de sigilo funcional é subsidiário. O preceito sancionador ressalva a possibilidade de o fato constituir crime mais grave, que pode ser espionagem ou revelação de segredo com ofensa à Segurança Nacional (Lei n. 7.170, de 14-12-1983, Lei de Segurança Nacional, arts. 13, 14 e 21) ou a violação de sigilo militar (CPM, art. 326). Pode ocorrer, ainda, crime de transmissão ilícita de informações sigilosas no âmbito da energia nuclear (Lei n. 6.453/77). A Lei n. 13.431, de 2017, que estabelece o

sistema de proteção de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência pune, em seu art. 24, com um a quatro anos de reclusão, e multa, o ato de "violar sigilo processual, permitindo que depoimento de criança ou adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo, sem autorização judicial e sem o consentimento do depoente ou de seu representante legal".

3. SUJEITOS DO DELITO

Delito próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Se, ao tempo do fato, já estava demitido, inexistente o crime. Quanto ao aposentado ou posto em disponibilidade, pode ser sujeito ativo, uma vez que continua a ser funcionário. Apesar de inativo, frui vantagens do cargo e não fica desvinculado totalmente das obrigações que a lei lhe impõe.

O terceiro que somente recebeu as informações não responde pelo crime, a não ser que tenha induzido, instigado ou auxiliado secundariamente o funcionário infiel.

Sujeito passivo é o Estado. Eventualmente, também o particular prejudicado pela revelação.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Estão expostos dois núcleos típicos:

1ª) Revelar, que consiste em comunicar o fato ou circunstância a terceiro. É a chamada revelação direta, executada pessoalmente pelo funcionário, por escrito ou verbalmente. Cuida-se de conduta positiva.

2ª) Facilitar-lhe a revelação, que quer dizer concorrer com o comportamento próprio a fim de se tornar fácil o conhecimento do fato ou da circunstância pelo terceiro. É a chamada revelação indireta, que pode ser realizada mediante conduta positiva ou negativa (omissão). Assim, pode o funcionário, facilitando a revelação, deixar aberta uma gaveta, permitir o manuseio de um documento por terceiro, deixar uma porta aberta etc.

Se o terceiro, a quem se transmite a informação, já conhecia o segredo, inexistente delito. O crime exige a possibilidade de dano, que não há no exemplo.

Não é necessário que haja interesse perpétuo de se manter o fato em segredo, bastando a temporariedade do sigilo. Assim, revelado o segredo dentro do período de temporariedade, há delito.

Para que haja crime, é preciso que o funcionário tenha conhecimento do segredo em razão do cargo, i.e., por força das atribuições que lhe são impostas pela Administração Pública no setor de sua atividade funcional. Dessa forma, se um funcionário, por qualquer circunstância, vem a tomar conhecimento de um informe sigiloso de outra repartição pública, e o revela, não comete o delito do art. 325 do CP. Para isso, entretanto, é necessário que tenha tomado ciência do segredo fora de suas funções.

Trata-se de segredo de interesse público. Se de interesse particular, poderá haver o delito do art. 154 do CP.

Não é a revelação de qualquer fato que constitui o delito. Protege-se do conhecimento de terceiro “o fato que deva permanecer em segredo”, i.e., o de interesse público, aquele que, pela sua natureza, não deve ser do conhecimento geral, sob pena de se causar dano ou perigo de dano à Administração Pública.

Basta, para a tipicidade do fato, que se dê conhecimento do fato a uma terceira pessoa. Não é preciso que um número indeterminado de indivíduos venha a conhecer o fato sigiloso.

5. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

A violação de sigilo funcional é delito próprio e formal ou de consumação antecipada. Exige a potencialidade de dano para com a Administração Pública. Não o dano efetivo. Basta que a revelação ou facilitação seja de molde a possibilitar o dano ou o perigo de dano.

6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente dirigida à revelação indevida do segredo ou sua facilitação, abrangendo o conhecimento de que o fato deve, pela sua natureza, permanecer em sigilo.

O segundo elemento subjetivo do tipo está na expressão “de que tem ciência em razão do cargo” (grifo nosso). Se o sujeito não teve conhecimento do segredo em razão do cargo, não há o delito, podendo haver outro (p. ex.: o do art. 154 do CP).

A ausência de um dos elementos subjetivos do tipo conduz à atipicidade do fato.

A conduta culposa não é típica.

7. EXCLUSÃO DA ILICITUDE

Não há delito, por exclusão da antijuridicidade (e não da tipicidade), quando a revelação decorre de estado de necessidade, defesa de um direito etc.

8. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com o ato da revelação do segredo ou de sua facilitação. Crime formal, como se viu, independe da produção de dano, bastando a sua potencialidade. No primeiro caso (revelação), o delito atinge o seu momento consumativo no instante da revelação, i.e., no instante em que o terceiro toma conhecimento do conteúdo do segredo. No segundo (facilitação), da mesma forma, consuma-se a infração no momento em que o terceiro, em face da facilitação realizada pelo funcionário, toma ciência do fato sigiloso.

Na revelação, pode haver tentativa do crime quando realizada por escrito. Quando é empregado o meio oral, contudo, a figura tentada é inadmissível.

Na facilitação a tentativa também é possível, desde que, realizado o ato

infiel pelo funcionário, o terceiro, por qualquer circunstância, não venha a tomar conhecimento do conteúdo do segredo.

9. TIPO QUALIFICADO

Tratando-se de funcionário ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento em certas entidades, de aplicar-se a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do CP.

10. SIGILO FUNCIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

A Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2000, com entrada em vigor em 15 de outubro de 2000, inseriu um § 1º no art. 325 do CP, dispondo: “Nas mesmas penas incorre quem: I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública”. Na mesma esteira, o § 2º, também acrescido pela referida Lei, estabelece: “Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa”.

O § 1º comina as mesmas penas do caput, que compreendem a detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Aqui há previsão de condutas delituosas para a era da informática e, particularmente, da internet, a rede mundial de computadores. É um tipo de conduta comissiva vinculada.

O inciso I contém um caso de interpretação analógica, uma vez que menciona “qualquer outra forma”. O acesso há de ser de pessoas não autorizadas (elemento normativo do tipo).

O inciso II fala em acesso restrito ou utilização indevida. Se não estiverem presentes, o fato é atípico. Verifica-se aqui conduta comissiva de caráter material, ou seja, deve haver a efetiva utilização do acesso restrito para se consumir o delito, mas não se requer dano.

O § 2º contém uma causa de aumento de pena, desde que do fato resulte dano à Administração Pública ou a terceiro.

11. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DE ÁUDIO OU VÍDEO RETRATAM PRESOS FEDERAIS

De acordo com o art. 3º, § 2º, da Lei n. 11.671/2008, “os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário”.

As gravações efetuadas a partir do áudio e vídeo registrados, se indevidamente divulgadas, configuram o crime do art. 325 do CP, como expressamente determina o § 5º do citado dispositivo legal.

12. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são alternativas: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, “se o fato não constitui crime mais grave”.

O fato constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O delito, portanto, é de competência dos Juizados Especiais Criminais, admitindo, desse modo, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Violação de sigilo de proposta de concorrência

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Consumação e tentativa. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Tipo qualificado. 7. Penas e ação penal. 8. Efeito da condenação.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 326 do CP, dispondo como crime a violação de sigilo de proposta de concorrência, tinha a seguinte redação: “Devassar o sigilo de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo”. O crime, hoje, está definido no art. 94 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com a seguinte redação: “Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: Pena – detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa”.

Procura-se proteger a Administração Pública no que tange à lisura que deve nortear as licitações públicas, que têm a finalidade de imprimir moralidade nos negócios efetuados pelo poder público, concedendo plano de igualdade aos concorrentes e permitindo a justa escolha daquele que oferece melhores condições.

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de fato tipificado na Lei de Licitações, como se observou no item acima. Embora à primeira vista pareça delito comum, uma vez que a devassa pode ser cometida por qualquer pessoa, na verdade é crime próprio. Sujeito ativo só pode ser o funcionário público. Mas não qualquer funcionário. O tipo exige uma qualidade específica do autor: deve ser funcionário que tem a função especial de receber as propostas, guardá-las e permitir o seu conhecimento a quem de direito no momento próprio. Deve, pois, estar relacionado diretamente com as licitações públicas, guardando

segredo a respeito do conteúdo das propostas.

Há dois sujeitos passivos: o Estado e os licitantes eventualmente prejudicados pela devassa do conteúdo sigiloso das propostas.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Dois são os núcleos do tipo:

1^ª) Devassar: significa tomar conhecimento indevido da proposta de licitação.

Aplica-se o que dissemos a respeito do crime do art. 151, caput, do CP (violação de correspondência). Não é necessário que o envelope, em que se encontra a proposta, seja aberto, pois é possível conhecer-lhe o conteúdo por outros meios (ex.: colocar o envelope, que contém proposta com uma só folha, contra a luz, lendo o seu conteúdo).

2^ª) Proporcionar a terceiro o ensejo do devassamento. Nesse caso, por ação ou omissão, o funcionário dá oportunidade a que um terceiro tome conhecimento do conteúdo da proposta de concorrência.

O tipo exige um elemento modal: a devassa deve ocorrer antes do término da apresentação das propostas. É nesse período que o seu conhecimento pode levar prejuízo aos licitantes, uma vez que podem ser alteradas. Após esse momento a devassa é inócua, tendo em vista a proibição da alteração do conteúdo das propostas.

No verbo devassar, não se exige que o funcionário, embora seja esse o seu intento, dê a terceiro conhecimento do que se contém na proposta. Basta que ele tome conhecimento do seu conteúdo.

Anulada a licitação, desde que por motivo diverso do fato cometido pelo sujeito, desaparece o delito.

4. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no momento em que o funcionário (na devassa) ou o

terceiro (na hipótese do verbo proporcionar) toma conhecimento do conteúdo da proposta. Como vimos, na devassa o crime independe da circunstância de o funcionário conseguir transmitir a outrem o que se contém na proposta de concorrência.

A tentativa é admissível. Ex.: o funcionário é surpreendido abrindo o envelope da proposta, não conseguindo, por isso, conhecer-lhe o conteúdo.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente dirigida ao devassamento do conteúdo da proposta de licitação pública.

Não é típica a modalidade culposa.

6. TIPO QUALIFICADO

Tratando-se de sujeito ativo ocupante de função de direção etc., em determinadas entidades, de aplicar-se a causa de aumento de pena do art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666/93.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são cumulativas: detenção, de dois a três anos, e multa.

A multa deve ser fixada de acordo com o art. 99 da Lei n. 8.666/93: "A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. § 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. § 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal".

A ação penal é pública incondicionada, regida pela Lei n. 8.666/93 (arts.

100 a 108).

8. EFEITO DA CONDENAÇÃO

Nos termos do art. 83 da Lei n. 8.666/93, o funcionário público condenado pela prática do crime de violação de sigilo de proposta de licitação, ainda que tentado, sujeita-se à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.

Capítulo VIII

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

PRINCÍPIOS GERAIS

O CP, Capítulo II do Título XI, descreve delitos comuns, praticados por particular contra a Administração Pública em geral. Aqui o legislador também protege o normal funcionamento da máquina administrativa contra a conduta de estranhos, procurando conceder prestígio, lisura e seriedade à prestação de serviços.

Sujeito ativo desses delitos é o particular, não se excluindo o funcionário público quando se despe da qualidade funcional. Assim, o desacato em geral é cometido por particular. Nada impede, entretanto, segundo nossa posição, que venha a ser praticado por funcionário público contra outro. O CP, nos Capítulos I e II do Título XI, empregou as expressões “crimes praticados por funcionário público” e “crimes praticados por particular” para indicar que, no primeiro caso, o delito é próprio e, no segundo, é comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário quando age como particular.

Os delitos são os seguintes:

1ª) usurpação de função pública (art. 328);

2ª) resistência (art. 329);

3ª) desobediência (art. 330);

4ª) desacato (art. 331);

5ª) tráfico de influência (art. 332);

6ª) corrupção ativa (art. 333);

7º) descaminho (art. 334);

8º) contrabando (art. 334-A);

9º) impedimento, perturbação ou fraude de concorrência (art. 335);

10º) inutilização de edital ou de sinal (art. 336);

11º) subtração ou inutilização de livro ou documento (art. 337); e

12º) sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A).

O CP, ao contrário do que ocorre em outras legislações, não pune como delito especial o atentado ou constrangimento ilegal de funcionário público (CP italiano, art. 336), que consiste no emprego de violência física ou moral no sentido de que o funcionário aja ou deixe de agir. Diante da omissão, o fato constituirá crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146), resistência (art. 329) ou coação no curso do processo (art. 344).

Usurpação de função pública

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Tipo qualificado. 7. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 328 do CP, constitui delito o fato de o sujeito “usurpar o exercício de função pública”.

O objeto da tutela penal é a Administração Pública, no que concerne ao regular desenvolvimento de suas atividades, que não pode ficar submetido à interferência de estranhos ao poder público, exercendo funções que não são suas. Por essa razão o legislador houve por bem coibir comportamentos que lesam o exercício das funções públicas, evitando a tomada abusiva de cargos e funções por parte de terceiros.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive por funcionário que exerce função que não lhe compete (exercício abusivo de função alheia).

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo da figura típica é o verbo usurpar, que quer dizer exercer ilegitimamente, indevidamente, apoderar-se, tomar, arrebatado etc. Comete o fato quem, indevidamente, assume uma função pública e passa a realizar atos inerentes ao ofício. Age ilegalmente, uma vez que falta norma jurídica que legitime a sua conduta. O verbo exige que o sujeito realize pelo menos um ato oficial. Se ele somente alega que é titular de uma função pública, mas não realiza nenhum ato a ela inerente, não há delito, podendo ocorrer

a contravenção do art. 45 da lei especial (LCP).

De observar-se que não há delito nas hipóteses em que se permite a terceiro, particular, a realização de certos atos funcionais. Nesse caso, como é evidente, não existe usurpação de função pública.

A função pública pode ser de qualquer natureza, gratuita ou remunerada.

E se o funcionário, embora titular do ato de ofício, o realiza após ter sido suspenso por pronunciamento judicial?

Não há usurpação de função pública, ocorrendo o delito do art. 359 do CP.

E se a função pública inexistente?

Não há delito.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente dirigida a usurpar a função pública. Deve o sujeito ter plena consciência da ilegitimidade de sua conduta, i.e., saber que está realizando uma conduta funcional que não lhe é permitida.

O motivo do agente é irrelevante.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

O crime se consuma com a realização do ato de ofício. Basta um, não se exigindo sua reiteração ou a prática de condutas diversas.

A tentativa é admissível. Ex.: o sujeito, dizendo-se funcionário público, já na repartição, é impedido de realizar ato de ofício inerente à função alegada.

6. TIPO QUALIFICADO

Se o agente obtém vantagem moral ou material em razão da usurpação, o crime é qualificado (art. 328, parágrafo único). O sujeito pode auferir a vantagem para ele ou para terceiro.

7. PENAS E AÇÃO PENAL

Para o autor do tipo simples, o CP impõe penas de detenção, de três meses a dois anos, e multa; para o crime qualificado, a pena é de reclusão, de dois a cinco anos, além da multa.

O crime, na forma simples, constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), sendo abrangido pela competência material dos Juizados Especiais Criminais. Comporta, em face disso, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Resistência

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Tipo qualificado. 8. Concurso de crimes. 9. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 329, caput, do CP, constitui crime o fato de “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

O estatuto penal protege a autoridade e o prestígio da função pública, procurando resguardar os agentes do poder público da conduta de quem, mediante violência física ou grave ameaça, tenta impedir a execução de ato legítimo. Com isso, o Estado confere proteção à autoridade, pressupondo a eficiência de seus agentes e de quem lhes presta colaboração.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (crime comum). Em geral, é aquela a quem se dirige o ato da autoridade. Entretanto, nada impede que seja um terceiro alheio ao ato legal. Assim, tratando-se de prisão, não raro a resistência parte de terceiros.

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, ainda como sujeito passivo, aparece o funcionário a quem a conduta é dirigida ou o terceiro que lhe presta auxílio.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta incriminada é a oposição à execução de ato funcional.

Os meios empregados são a violência física e a ameaça.

Trata-se de violência contra pessoa. Não tipifica o fato a violência exercida contra a coisa. A figura típica fala em “violência ou ameaça a funcionário”. Assim, a conduta do sujeito deve dirigir-se à pessoa do sujeito passivo.

Ao contrário de outros tipos penais, aqui não se exige que a ameaça seja grave, bastando que se prenuncie à vítima a prática de um mal. Pode ela ser feita por escrito ou verbalmente. Dessa forma, conforme o meio executivo, não se exige a presença do funcionário (p. ex.: ameaça por bilhete).

É elemento do crime a legalidade do ato funcional. Se ilegal, a resistência será atípica.

O ato funcional deve ser contemporâneo à resistência. Se já foi executado ou se vai ser realizado no futuro, não há delito, uma vez que se incrimina a oposição à sua execução.

O funcionário deve ser competente para a execução do ato funcional. Se incompetente, o fato é atípico.

Não é punível nos termos do art. 329 a chamada resistência passiva, aquela em que inexiste comportamento agressivo contra o funcionário. Ex.: dada a voz de prisão a alguém, ele se agarra a um poste para não ser conduzido à Delegacia de Polícia. Nesse caso, pode haver o crime de desobediência (CP, art. 330).

As palavras ultrajantes que não configuram ameaça não constituem resistência, podendo haver desacato (CP, art. 331).

Quanto ao terceiro, pode estar agindo espontaneamente ou porque foi solicitado o seu auxílio pelo funcionário. Exige-se que a colaboração seja prestada na presença do agente do poder público e no local em que se desenvolve o ato funcional.

E se o ato funcional é legal, porém injusto?

Não se exclui a resistência, uma vez que a figura penal menciona a legalidade do ato.

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Está na expressão legal, que informa a natureza do ato do funcionário. Se ilegal, como foi dito, o fato é atípico. O ato deve ser substancial (quanto à natureza da ordem) e formalmente legal (quanto às suas formalidades).

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro elemento subjetivo da figura típica é o dolo, vontade livre e consciente de empregar violência contra o funcionário público (ou o terceiro) ou ameaça, abrangendo o conhecimento de sua competência e da legalidade do ato. O segundo elemento subjetivo está na finalidade da conduta: impedir a realização do ato funcional. Sem esse fim especial de agir não há resistência, podendo surgir outra infração, como ameaça, lesões corporais etc.

A ausência de qualquer dos dois elementos subjetivos conduz à atipicidade do fato a título de resistência.

A embriaguez do agente exclui o crime de resistência?

Há três orientações a respeito:

1ª) A embriaguez do agente não exclui o elemento subjetivo do crime de resistência.

Essa corrente se fundamenta no art. 28, II, do CP, segundo o qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade. Desde que o agente tenha praticado o fato em estado de embriaguez não fortuita, completa ou incompleta, não havendo exclusão da capacidade intelecto-volitiva por força de lei, responde pelo crime de resistência.

2ª) A embriaguez do agente exclui o elemento subjetivo do crime de resistência.

De acordo com essa posição, é suficiente que o sujeito se encontre em estado de embriaguez, não importando a sua intensidade, para que não responda por resistência. Entende-se que o dolo desse crime é incompatível com o estado de ebriez.

3ª) Não é qualquer estado de embriaguez que exclui o elemento subjetivo do crime de resistência, exigindo-se que elimine a capacidade intelecto-volitiva do agente.

Essa corrente faz distinção, não sendo suficiente a embriaguez para que seja excluído o elemento subjetivo da resistência. Para tanto, é necessário que o agente, por causa da ebriez, não tenha condições de compreender o caráter ilícito de seu comportamento ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (exclusão da capacidade intelecto-volitiva). É a de nossa preferência.

Não há corrente dominante.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime atinge a consumação com a violência ou ameaça. Delito formal, não exige que o sujeito consiga o fim almejado, i.e., que efetivamente impeça a execução do ato. Se isso ocorre, incide uma qualificadora (art. 329, § 1º).

A tentativa é admissível. Ex.: o sujeito envia um bilhete ameaçador ao funcionário, vindo a ser extraviado.

7. TIPO QUALIFICADO

Se o ato funcional, em razão da resistência, não é realizado, incide a qualificadora descrita no § 1º do art. 329. Cuida-se de hipótese de crime exaurido, punido o fato mais severamente pelo resultado obtido pelo agente. Para tanto, é necessário que o sujeito passivo não consiga realizar o ato por causa da violência física ou ameaça. Se ele, não obstante a resistência, pode executar o ato, mas não o faz, inexistente a forma

qualificada.

8. CONCURSO DE CRIMES

Nos termos do § 2º do art. 329, as penas “são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”.

O legislador prevê concurso material entre a resistência e o delito em que consiste a violência física (lesão corporal ou homicídio). A contravenção de vias de fato é absorvida pela elementar “violência”, não subsistindo como infração autônoma.

9. PENA E AÇÃO PENAL

A pena imposta no tipo simples é de detenção, de dois meses a dois anos (art. 329, caput). O fato consubstancia infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). Trata-se, portanto, de delito abrangido pela competência *ratione materiae* dos Juizados Especiais Criminais. Admite, em razão da pena máxima, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e, dada a pena mínima não superior a um ano, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

No tipo qualificado, é de reclusão, de um a três anos (§ 1º); não se trata de infração de menor potencial ofensivo, mas admite o *sursis* processual.

A ação penal é pública incondicionada.

Desobediência

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Cominação de sanção civil ou administrativa. 8. Formas especiais de desobediência. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 330 do CP, constitui delito o fato de “desobedecer a ordem legal de funcionário público”.

O objeto da tutela penal é a Administração Pública. O que se tem em vista, por intermédio da incriminação, é assegurar o prestígio e a dignidade da máquina estatal administrativa, no que diz respeito ao cumprimento de determinações legais expedidas por funcionário público.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser executado por qualquer pessoa, inclusive por funcionário público, desde que o objeto da ordem não se relacione com as suas funções. Se diz respeito às suas funções, pode haver prevaricação.

Sujeito passivo principal é o Estado; secundário, o funcionário autor da ordem.

A figura do funcionário público, elementar do tipo, deve ser interpretada restritivamente, sendo inaplicável a equiparação e extensão do art. 327, § 1º. Como vimos na parte introdutória do estudo dos crimes cometidos contra a Administração Pública, a equiparação somente serve para o sujeito ativo dos delitos, não para o passivo. Assim, não constitui desobediência deixar de atender ordem de funcionário de autarquia. De modo que o conceito de funcionário público, para efeito de desobediência, nos é

fornecido pelo Direito Administrativo: é a pessoa legalmente investida em cargo público criado por lei, com denominação própria, em número certo e paga pelos cofres públicos.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O comportamento proibido consiste em desobedecer à ordem do funcionário público, i.e., desatender, não cumprir.

Pode ser realizado mediante ação ou omissão, segundo consista o conteúdo da ordem em conduta positiva ou negativa do desobediente. Se a ordem impõe uma ação, a desobediência pode consistir em omissão, e vice-versa.

O funcionário deve emitir uma ordem. Inexiste delito quando se trata de simples pedido e não de ordem.

A ordem deve emanar de funcionário competente. Se incompetente, inexiste delito.

Deve ela ser transmitida diretamente ao destinatário (verbalmente ou por escrito).

É imprescindível que o destinatário da ordem tenha o dever jurídico de agir ou deixar de agir. Não há desobediência se o ordenamento jurídico não lhe impõe o dever de acatar o conteúdo da ordem.

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Consiste na legalidade da ordem, formal e materialmente (forma e conteúdo). Se a ordem é ilegal, não há crime. Assim, é preciso que o conteúdo da ordem esteja fundado em lei, emanada de funcionário público competente para dá-la, agindo dentro de suas atribuições e com observância das determinações legais. A justiça ou injustiça da ordem não importa à tipificação do fato.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo: vontade livre e consciente de desobedecer à ordem do funcionário público, abrangendo o conhecimento de sua legalidade. Assim, deve o sujeito estar consciente de que está deixando de cumprir o conteúdo de uma ordem legal emanada de funcionário público. É necessário também que o sujeito saiba que tem o dever de cumpri-la.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Conforme o conteúdo da ordem, se indica um comportamento positivo ou negativo, consuma-se o delito com a ação ou omissão do desobediente. Tratando-se de omissão, é preciso verificar se foi concedido prazo para a execução da ordem. Nesse caso, consuma-se o delito no momento de sua expiração. Não havendo prazo marcado, exige-se um período de tempo juridicamente relevante, capaz de indicar com segurança a desobediência.

Na forma comissiva de desobediência é cabível a tentativa; na omissiva, é inadmissível (delito omissivo próprio).

7. COMINAÇÃO DE SANÇÃO CIVIL OU ADMINISTRATIVA

Inexiste desobediência se a norma extrapenal, civil ou administrativa, já comina uma sanção sem ressalvar sua cumulação com a imposta no art. 330 do CP. Significa que inexiste o delito se a desobediência prevista na lei especial já conduz a uma sanção civil ou administrativa, deixando a norma extrapenal de ressalvar o concurso de sanções (a penal, pelo delito de desobediência, e a extrapenal). Exemplo de sanções cumuladas: CPC, art. 403. Exemplos de sanções não cumuladas: infração a regulamento de trânsito, desobediência ao Estatuto da Criança e do Adolescente etc.

8. FORMAS ESPECIAIS DE DESOBEDIÊNCIA

A Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei do Crime Organizado), que disciplina a investigação, os meios de prova, o procedimento, a definição de organização criminosa e as infrações correlatas, prevê modalidade especial

de desobediência em seu art. 21, assim redigido: “Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo” (pena: reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa).

A Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) tipifica o crime de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei” (art. 24-A). A pena é de detenção, de 3 meses a 2 anos. O dispositivo foi incluído pela Lei n. 13.641, de 3 de abril de 2018. Pretendeu-se, com isso, suprir uma lacuna existente na lei, decorrente de entendimento anterior pacificado pelo STJ, no sentido de que o inadimplemento de medida protetiva de urgência, por admitir a decretação de prisão preventiva contra o autor, não configurava o crime de desobediência do art. 330 do CP. O delito da Lei Maria da Penha “independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas” (art. 24-A, § 1º) e, “na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança” (art. 24-A, § 2º).

Interessante notar que a figura típica da Lei Maria da Penha somente se aplicará quando a medida protetiva desrespeitada houver sido imposta por decisão judicial. Assim, quando se cuidar de medida aplicada por delegado de polícia ou outro policial, nos termos do art. 12-C, II e III, da Lei n. 11.340/2006 (com redação dada pela Lei n. 13.827/2019), seu inadimplemento não se subsume ao art. 24-A da lei. Se a medida imposta pela polícia, contudo, depois de comunicada ao juiz competente, for por ele mantida, torna-se uma imposição decorrente de decisão judicial, admitindo a configuração do delito do art. 24-A da lei.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

A pena cominada é de detenção, de quinze dias a seis meses, além da multa.

O fato consubstancia infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei

n. 9.099/95). Trata-se, portanto, de delito abrangido pela competência *ratione materiae* dos Juizados Especiais Criminais. Admite, em razão da pena máxima, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e, dada a pena mínima não superior a um ano, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Desacato

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Controle de convencionalidade no crime de desacato. 7. Concurso de crimes. 8. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 331 do CP, constitui o crime o fato de “desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”.

Tutela-se a Administração Pública, no que concerne à dignidade, prestígio e respeito devidos aos seus agentes no exercício de suas funções.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa.

O funcionário público pode ser sujeito ativo de desacato?

Há três posições a respeito:

1ª) o funcionário público não pode ser sujeito ativo de desacato, a não ser que se tenha despedido da qualidade funcional ou o fato tenha sido cometido fora do exercício de suas funções;

2ª) pode ser, desde que seja inferior hierárquico do ofendido;

3ª) o funcionário público pode ser sujeito ativo de desacato em qualquer hipótese (seja superior ou inferior hierárquico do ofendido).

Para a primeira posição, como o desacato se encontra no capítulo dos crimes praticados “por particular” contra a administração em geral, entende-se que o autor deve ser um estranho. Se for funcionário público não haverá desacato, subsistindo a ofensa como infração autônoma (injúria, lesão, ameaça etc.). Encontra fundamentos em Nélson Hungria¹².

A segunda orientação exige que o ofensor seja subordinado hierárquico do ofendido (RT, 310:377; 409:297; RF, 199:294).

A terceira orientação é a que nos parece correta. O funcionário público que pratica o fato contra outro despe-se dessa qualidade, equiparando-se ao particular. Se o bem jurídico é o prestígio da função pública, não se compreende como possa haver lesão jurídica apenas quando a conduta é praticada por particular.

É a orientação do STJ: “É possível a prática do crime de desacato por funcionário público contra pessoa no exercício de função pública, pois se trata de crime comum em que a vítima imediata é o Estado e a mediata aquela que está sendo ofendida” (HC n. 104.921, Rel. Min. Jane Silva, 6ª Turma, DJe de 26-10-2009).

Sujeito passivo é o Estado (sujeito passivo principal). Secundariamente, como sujeito passivo, aparece o funcionário ofendido em sua honra profissional (funcional).

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, agredir, desprestigiar o funcionário público. Crime de forma livre, admite diversos meios de execução: palavras, gritos, gestos, vias de fato, ameaças, agressão física com lesão corporal ou qualquer ato que signifique irreverência, menosprezo ou desprestígio para com o sujeito passivo.

Crime formal, independe de o funcionário sentir-se ofendido em sua honra, bastando que a conduta seja capaz de causar dano à sua honra profissional.

A censura ponderada, a crítica sincera, ainda que feitas com veemência, não constituem o delito.

É necessário que a conduta seja realizada contra funcionário público “no exercício da função ou em razão dela”. São duas as modalidades da conduta

típica:

1ª) ofensa cometida no exercício da função; e

2ª) ofensa cometida em virtude da função.

No primeiro caso o funcionário, no momento do fato, está desempenhando um ato de seu ofício, pouco importando o local (na repartição pública ou fora dela). No segundo, o desacato está relacionado com o exercício da função, embora o sujeito passivo, no momento da conduta, não esteja realizando ato de ofício.

Exigindo-se nexo de causalidade entre a conduta e o exercício da função, no primeiro caso ele é ocasional (o delito é praticado por ocasião do exercício da função); no segundo, é meramente causal (o sujeito passivo não se encontra exercendo a função, porém o fato é cometido por causa dela).

Se, em uma audiência, alguém chama o delegado de polícia de “desonesto”, trata-se de desacato cometido contra a vítima no exercício da função. Se, entretanto, o mesmo fato vem a ser praticado em um teatro, onde se encontram os protagonistas, em razão do exercício do cargo de delegado de polícia, trata-se de crime cometido “em razão da função”.

É indispensável que o fato seja cometido na presença do sujeito passivo. Se na ausência, o crime a ser considerado é a injúria qualificada por ter sido o crime cometido contra funcionário público, em razão da função (CP, art. 141, II). De ver-se, contudo, que não se exige estejam ofensor e ofendido frente a frente, que ambos se vejam. É suficiente que o ofendido tome conhecimento imediato da ofensa. Assim, estando os sujeitos em salas distintas, com a porta aberta, é admissível o delito, desde que o ofendido possa perceber a conduta injuriosa, difamatória ou caluniosa.

Não há desacato na ofensa cometida por carta, telefone, rádio, telegrama, televisão etc., podendo subsistir crime contra a honra (calúnia, difamação ou injúria prevista no CP ou na Lei de Segurança Nacional).

A publicidade do fato não é elemento do tipo. Assim, pouco importa que a conduta seja realizada só na presença do sujeito passivo ou na de diversas pessoas.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. É este elemento subjetivo do tipo, dirigido à ofensa ao prestígio da função pública, que distingue o desacato cometido mediante violência física ou moral do crime de resistência. O dolo deve abranger o conhecimento da qualidade de funcionário público do sujeito passivo e sua presença no local da conduta. Deve ser apreciado em face das condições pessoais do sujeito ativo, como a classe social a que pertence, cultura etc.

O ânimo calmo constitui requisito do elemento subjetivo do crime de desacato?

Há, a respeito, duas orientações:

1ª) O crime de desacato exige ânimo calmo, sendo que o estado de exaltação ou cólera exclui o seu elemento subjetivo do tipo.

Essa corrente, fundamentando-se em Nélson Hungria, para quem o tipo exige “dolo específico”, consistente na “intenção ultrajante”, “propósito de depreciar ou vexar”¹³, entende que esse elemento subjetivo é incompatível com o estado de exaltação ou ira, que exclui o delito. Excluído o desacato por falta de “dolo específico”, subsiste a injúria. Esse entendimento foi, no passado, a orientação dominante em nossos Tribunais.

2ª) O desacato não exige ânimo calmo, pelo que o estado de exaltação ou cólera não exclui o seu elemento subjetivo do tipo.

Essa corrente entende que a posição contrária é perigosa para os interesses da justiça, uma vez que não existe acusado que não alegue exaltação de ânimo na prática do desacato. Além disso, não há que se falar

em “dolo específico” (ou elemento subjetivo específico) no tipo penal. Do contrário, estar-se-ia inserindo no dispositivo requisitos que este não contém. De acordo com o STJ, “O delito de desacato pressupõe o dolo de ultrajar, faltar com o respeito ou menosprezar funcionário público, sendo fundamental a demonstração da vontade livre do agente. Entrementes, a teor do art. 28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III, c, do mesmo diploma legal” (RHC n. 81.292, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe de 11-10-2017). Tem a nossa preferência.

A embriaguez do agente exclui o elemento subjetivo do tipo do crime de desacato?

Há três orientações a respeito do tema:

1ª) O crime de desacato exige “dolo específico”, e a embriaguez do agente, incompatível com esse elemento subjetivo, exclui o delito.

Para essa corrente, o crime de desacato exige o denominado “dolo específico”, consistente na intenção ultrajante, propósito de depreciar ou vexar, sabendo o agente que o ofendido reveste a qualidade de funcionário público e se acha no exercício de sua função, ou estando consciente de que a esta se vincula a ofensa¹⁴. Essa exigência é incompatível com o estado de ebrez do agente, o que exclui o delito.

2ª) O desacato não exige “dolo específico”, pelo que o estado de embriaguez do agente não exclui o crime.

Para essa posição, não há falar que existe um “dolo específico” que se mostra incompatível com a embriaguez do agente. Nos termos do art. 28, II, do CP, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeito semelhante, não exclui a imputabilidade, respondendo o agente pelo

fato a título de dolo. Só há exclusão quando a ebriez completa é proveniente de caso fortuito ou de força maior (CP, art. 28, § 1º). É a posição do STJ, conforme citamos anteriormente.

3ª) Não é qualquer estado de ebriez que exclui o elemento subjetivo do crime de desacato, exigindo-se que elimine a capacidade intelectual e volitiva do sujeito.

De acordo com essa orientação, é necessária a apreciação de caso por caso. Embora essa corrente entenda que o desacato exige o impropriamente chamado dolo específico, afirma que não é qualquer estado de embriaguez que exclui esse elemento subjetivo do tipo. Só há exclusão quando o estado de ebriez é de tal forma acentuado que exclui a capacidade intelecto-volitiva do agente. É posição minoritária em nossa jurisprudência. Tem, porém, a nossa preferência.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime se consuma no momento em que o sujeito realiza o ato ofensivo: injúria, calúnia, difamação, lesões corporais, vias de fato, gestos etc. Delito formal, independe da circunstância de o sujeito passivo sentir-se ofendido ou de restar abalado o prestígio ou a autoridade da função pública. Basta que a conduta seja capaz de produzir um desses efeitos.

O crime, por exigir a presença do sujeito passivo, torna-se unissubsistente, não admitindo a tentativa. Não convencem os exemplos que os autores dão como de crime tentado, como o arremesso de imundície com erro de alvo, tentativa de agressão física etc. Nesses casos, segundo entendemos, o crime é consumado. Assim, se o sujeito lança excremento contra a vítima, errando o alvo, sua atitude já configura desacato. No outro exemplo, em que o sujeito dá um soco na direção da vítima, sendo seu braço desviado por terceiro, há também delito consumado. Não se pode esquecer que a lei pune a atitude do autor, que pode consistir em simples gesto.

6. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO CRIME DE DESACATO

O controle de convencionalidade consiste no exame de compatibilidade entre as leis ordinárias e as Convenções ou Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, os quais, para o STF, salvo quando aprovados pelo Congresso pelo mesmo quórum de emendas constitucionais, têm valor supralegal (RE n. 466.343).

A 5ª Turma do STJ, em dezembro de 2016, julgando o REsp n. 1.640.084, Rel. Min. Ribeiro Dantas, realizando o controle de convencionalidade, decidiu que o crime de desacato seria incompatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, o qual assegura mecanismos de proteção à liberdade de expressão e pensamento. Destacou que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou a respeito da matéria, apontando a citada incongruência, ao examinar leis penais de outros países. Em função disso, a criminalização da conduta poderia gerar embaraço à liberdade de crítica de atos e agentes estatais e, sendo por vezes difícil diferenciar a crítica lícita, embora áspera, da ofensa criminosa, a subsistência do tipo penal poderia abrir espaço a tolher as pessoas de seu direito de expressar. Frisou-se que a atipicidade do desacato, em face de sua incompatibilidade com a CADH, não impediria eventual responsabilização civil ou até mesmo a configuração de algum crime contra a honra (calúnia, difamação ou injúria).

Meses depois, contudo, o STJ, em acórdão da 3ª Seção, que reúne os membros das 5ª e 6ª Turmas da Corte, reviu esse posicionamento e decidiu inexistir incompatibilidade entre a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Código Penal brasileiro. A Corte frisou que nossa lei penal não se presta a punir a mera crítica a agentes ou atos estatais. Esta, ainda quando áspera ou deselegante, não constitui desacato. A punição criminal se dá quando o agente extrapola sua liberdade de expressão. Acentuou-se, ainda, que as deliberações da Comissão Americana de Direitos Humanos citadas no REsp n. 1.640.084, além de não possuírem caráter vinculante,

disseram respeito a leis penais de outros países. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão que não é meramente instrutório ou cooperativo como a Comissão Americana, mas jurisdicional, já se posicionou acerca da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se esta de direito absoluto. Em face disso, o crime de desacato não pode ter sua tipificação afastada (HC n. 379.269, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ o Acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, DJe de 30-6-2017).

7. CONCURSO DE CRIMES

O desacato absorve, pelo princípio da consunção, as infrações de menor gravidade objetiva que o integram, como as vias de fato, a lesão corporal leve, a difamação e a injúria. Se a outra infração for mais grave, como a lesão corporal grave, haverá concurso formal (CP, art. 70).

E se o sujeito, com uma só conduta, ofende diversos funcionários?

Há um só crime, em razão de violar, com o fato, apenas um bem jurídico.

8. PENA E AÇÃO PENAL

A sanção é alternativa: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Tráfico de influência

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Concurso de crimes. 7. Causa de aumento de pena. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 332, caput, do CP, com redação da Lei n. 9.127, de 16 de novembro de 1995, dispõe como delito o “tráfico de influência”, com a seguinte redação típica: “Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em funcionário público no exercício da função”.

O objeto da tutela jurídico-penal é o prestígio da Administração Pública, que não pode ficar exposto a condutas de descrédito perante a sociedade, cumprindo não abrir mão da confiança que deve inspirar e do bom nome que deve possuir.

Apresenta semelhança com o crime do art. 357, a despeito de não possuir mais o mesmo nomen juris. Diferem, entretanto, em que aquele ofende a administração da Justiça. Assim, se o agente realiza a conduta a pretexto de influir em Juiz de Direito, Promotor de Justiça, jurado, testemunha etc., o crime é o do art. 357; se diz que é para influir em servidor público em geral, com exclusão de Juiz de Direito etc., o delito está descrito no art. 332.

2. SUJEITOS DO DELITO

O crime é comum. Pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive por funcionário público.

Sujeito passivo principal é o Estado. De forma secundária, a pessoa que compra o prestígio, que entrega ou promete a vantagem na ilusão de

concretizar um interesse ilegítimo. Ele supõe que, em concurso, está cometendo um delito de corrupção com o funcionário. Na verdade, está participando de uma farsa. Há, por parte do comprador do prestígio, delito putativo (pensa que está realizando corrupção ativa).

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O comportamento incriminado consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em funcionário público.

Trata-se de forma de fraude em que o sujeito, alegando ter prestígio junto a funcionário público, faz crer à vítima, enganosamente, possuir condições de alterar o comportamento daquele.

Não é preciso que haja um funcionário determinado, nem que se indique um que, na verdade, seja incompetente para a realização do ato (ou sua omissão) pretendido. Da mesma maneira, subsiste o delito ainda quando o funcionário indicado não existe ou se aponte nome imaginário. Entretanto, se o agente individualiza uma pessoa, é necessário que seja funcionário público, sob pena de desnaturar a tipicidade do fato.

É admissível que o sujeito aponte determinada pessoa que, segundo ele, tem prestígio junto a certo funcionário, sendo capaz de influenciá-lo na realização ou omissão de ato funcional. Ainda assim existe delito.

A expressão “a pretexto” significa sob fundamento, com a desculpa, no sentido de que o agente faz uma simulação, levando a vítima à suposição de que irá influir no comportamento funcional do agente do poder público. É possível que, na verdade, ele tenha prestígio junto ao funcionário. Subsiste o delito, uma vez que a incriminação reside na fraude, na promessa de influência, quando, na realidade, nenhuma atitude ele tomará junto à administração. Daí a denominação que se dá à sua conduta: “venda de fumaça”.

A vantagem pode ser de qualquer natureza, material ou moral.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, consistente na vontade livre e consciente dirigida à conduta ou ao engano da vítima, fazendo crer a ela que influenciará na atitude do funcionário, abrangendo a pretensão de obtenção de vantagem ou a promessa de sua obtenção. O tipo reclama outro elemento subjetivo, contido na expressão “para si ou para outrem”.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Nos verbos solicitar, exigir e cobrar o delito é formal, atingindo a consumação com a simples ação do sujeito.

No verbo obter, crime material, consuma-se no momento em que o sujeito obtém a vantagem ou sua promessa.

A tentativa é admissível, embora de difícil ocorrência.

Não desnatura o delito a circunstância de a vítima não cumprir a promessa ou a de o agente não procurar influenciar o funcionário público.

6. CONCURSO DE CRIMES

O tráfico de influência absorve o estelionato. Quando, contudo, falta algum elemento típico do crime do art. 332, subsiste o estelionato.

E se o agente corromper o funcionário?

Ciente o interessado do acordo, haverá dois delitos: corrupção passiva por parte do funcionário; ativa em relação ao interessado e corretor. A exploração de prestígio fica absorvida.

7. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

A pena é agravada se o “agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário” (CP, art. 332, parágrafo único).

Não é exigida declaração expressa, bastando que o sujeito dê a entender à vítima, por palavras ou gesto, que parte da importância ou qualquer outra vantagem é destinada ao funcionário público. É o caso que ocorre com maior frequência. O corretor, para elevar a quantia pedida, explica à vítima que parte dela será entregue ao funcionário. Subsiste a causa de aumento de pena ainda que a vítima, em dúvida quanto à circunstância de ele ficar com toda a importância, faça a entrega da vantagem ou a prometa.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas previstas para o tipo simples são de reclusão, de dois a cinco anos, e multa (art. 332, caput). Nos termos do parágrafo único, as penas são aumentadas de metade se o agente alega ou insinua que destinará parte da vantagem para o funcionário público.

A ação penal é pública incondicionada.

Corrupção ativa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Corrupção ativa e outros crimes. 8. Tipo qualificado. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 333, caput, do CP, constitui crime de corrupção ativa o fato de “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.

Procura-se proteger o prestígio e a normalidade do funcionamento da Administração Pública. A atividade governamental tem sentido dirigido ao bem coletivo, pelo que a regularidade administrativa é uma de suas missões. Daí a punição a quem corrompe ou procura corromper o funcionário público.

Trata-se de caso de exceção pluralista ao princípio unitário que norteia o concurso de agentes. Poderia haver um só delito para corruptor e corrupto. O legislador brasileiro, entretanto, para que uma infração não fique na dependência da outra, podendo punir separadamente os dois sujeitos, ou um só, descreveu dois delitos de corrupção: passiva (do funcionário; art. 317 do CP) e ativa (do terceiro; art. 333). Ao contrário do que se afirma, há concurso de agentes entre corruptor e corrupto. Só que o legislador, ao invés de adotar o princípio unitário, resolveu aplicar o pluralista: um delito para cada autor.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, a corrupção ativa pode ser cometida por qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário público, desde que não aja com essa qualidade.

Sujeito passivo é o Estado.

Note-se que o corruptor, ao invés de aparecer como sujeito passivo da corrupção passiva, surge como sujeito ativo da ativa (respectivamente, arts. 317 e 333 do CP).

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O comportamento incriminado consiste em oferecer ou prometer vantagem a funcionário público, com o fim de determiná-lo a realizar, omitir ou deixar de praticar ato de ofício.

Os núcleos do tipo são os verbos oferecer e prometer. Oferecer tem o significado de expor à aceitação, apresentar no sentido de que seja aceito pelo funcionário. Prometer quer dizer obrigar-se, comprometer-se, garantir a entrega de alguma coisa.

Os meios de execução do oferecimento ou da promessa são vários (crime de forma livre): palavras, atos, gestos, escritos etc.

Inexiste delito na hipótese de ausência de oferta ou promessa de vantagem. Assim, não há corrupção ativa no caso de o sujeito, sem oferecer ou prometer qualquer utilidade ao funcionário, pede-lhe que “dê um jeitinho” em sua situação perante a Administração Pública.

É indispensável que não exista exigência por parte do funcionário, caso em que há o crime do art. 316 do CP (concussão). O oferecimento e a promessa devem ser espontâneos. Se impostos pelo funcionário, inexistirá corrupção, surgindo outro delito.

A vantagem deve endereçar-se ao funcionário, não a terceiro (parente ou amigo).

O delito pode ser realizado mediante interposta pessoa (intermediário). Nesse caso, o terceiro aparece como partícipe do crime do art. 333, e não da corrupção passiva (art. 317).

E se o funcionário repele a conduta do sujeito?

Ainda assim há delito, uma vez que a lei incrimina o simples oferecer ou prometer a vantagem. O funcionário, porém, não responderá por delito algum (não aceitou a promessa nem recebeu a vantagem).

O objeto material é a vantagem de qualquer natureza (material ou moral) que se destina ao funcionário público (CP, art. 327), tendente a que ele realize, deixe de praticar no tempo devido ou omita ato de ofício de sua competência (judicial ou administrativo, lícito ou ilícito, regular ou irregular).

Não há crime na hipótese de o sujeito dar ao funcionário pequenas gratificações ou doações em agradecimento a comportamento funcional seu. Nesse caso, o servidor público não está sendo corrompido, mas objeto da gratidão do contribuinte, satisfeito com sua atuação funcional. Não existe oferta ou promessa de vantagem, mas conduta de agradecimento posterior ao ato de ofício, o que descaracteriza o delito.

Não se trata de qualquer funcionário, mas daquele que tem o dever de ofício de realizar ou não o ato objeto do dolo do agente. Assim, é necessário que o ato esteja dentro da esfera de atribuições do servidor público.

Não há corrupção ativa no caso de a vantagem ser oferecida ou prometida ao funcionário depois de sua conduta funcional (ativa ou omissiva). No delito que estamos estudando, o comportamento visado deve ser realizado no futuro. Se já foi realizado, não há crime: dá-se a vantagem para que se faça, não porque se fez ou não alguma coisa (no sentido de fato).

E se o agente oferece ou promete vantagem para impedir que o funcionário realize um ato ilegal que o prejudica ou que não é de sua competência?

Não há crime.

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Encontra-se na qualidade da vantagem: deve ser indevida, i.e., não autorizada pela lei, ilícita. Se devida, o fato é atípico em face da corrupção ativa.

Não há também delito quando o objeto da oferta ou da promessa é absolutamente impossível de concretizar-se. Ex.: prometer ao funcionário público, em troca da prática do ato de ofício, uma viagem ao Sol.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de oferecer ou prometer a vantagem, com conhecimento de que é indevida e se endereça a funcionário público. Exige-se um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão “para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. Se inexistir qualquer dos dois elementos, o fato é atípico.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Crime formal ou de consumação antecipada, atinge o momento consumativo no instante em que o funcionário toma conhecimento da oferta ou da promessa. Não se trata de crime de mera conduta. Neste, o tipo só menciona o comportamento do agente, sem fazer menção ao resultado visado. Na corrupção ativa, ao contrário, a figura penal expressa o resultado querido pelo sujeito, qual seja, a realização, omissão ou retardamento do ato de ofício.

A recusa do funcionário é irrelevante à consumação. Tomando ele conhecimento da oferta ou da promessa de vantagem indevida, o delito está consumado, independentemente da aceitação ou recusa.

Quanto à tentativa, ela depende da forma de execução. Cuidando-se de crime unissubsistente, como a oferta verbal, não é admissível. Tratando-se, entretanto, de crime plurissubsistente, como a oferta por carta, admite-se a tentativa.

7. CORRUPÇÃO ATIVA E OUTROS CRIMES

Tratando-se de corrupção ativa cometida no plano eleitoral, aplica-se o art. 299 do Código Eleitoral: “Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”.

Se a corrupção é de testemunha ou perito, tradutor ou intérprete (não oficiais), aplica-se a norma incriminadora do art. 343 do CP.

8. TIPO QUALIFICADO

O delito é qualificado, nos termos do parágrafo único do art. 333, “se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional”.

Consuma-se o delito com a oferta ou promessa de vantagem indevida, como vimos. É possível, não obstante, que o funcionário, por causa da vantagem, realize o comportamento visado pelo corruptor, omitindo o ato de ofício, retardando-o ou o praticando com infringência de dever funcional. Tal figura qualificada encontra semelhança no art. 317, § 1º, do CP.

E se o funcionário, em razão da vantagem ou promessa, pratica ato de ofício legal?

Não se aplica a qualificadora, uma vez que o tipo menciona ato de ofício realizado com infração de dever funcional. Nesse caso, subsiste a forma simples de crime descrita no caput da disposição.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas previstas no tipo simples são a reclusão, de dois a doze anos, e a multa (art. 333, caput). No tipo qualificado, elas são aumentadas de um terço (parágrafo único).

A ação penal é pública incondicionada.

Descaminho

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Questão prejudicial. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Descaminho por assimilação. 8. Tipo qualificado. 9. Penas e ação penal. 10. Extinção da punibilidade. 11. Perdimento de bens.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 334, caput, do CP, constitui crime o fato de “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”.

No sentido jurídico, a expressão descaminho significa fraude no pagamento de impostos e taxas devidos para a entrada ou saída do País de mercadorias ou gêneros. Cuida-se, portanto, de delito fiscal, aduaneiro.

A Lei n. 13.008, de 26 de junho de 2014, alterou a redação do art. 334 do CP, que antes continha no mesmo dispositivo os delitos de contrabando e descaminho, cindindo-os em dois tipos penais. O propósito do legislador foi, sobretudo, o de apenar mais rigorosamente o contrabando (reclusão, de dois a cinco anos) em comparação com o descaminho (reclusão, de um a quatro anos).

Justificava-se a providência, pois no contrabando a mercadoria importada ou exportada é proibida, podendo colocar, conforme o caso, diversos bens jurídicos em risco, inclusive a saúde pública, ao passo que no descaminho ela é permitida, porém o sujeito fraudula o pagamento do tributo devido.

O objeto jurídico tutelado no art. 334 do CP é o interesse estatal no que diz respeito ao erário lesado pelo comportamento do sujeito, que, deixando de pagar os impostos e taxas devidos, prejudica não só o poder público como a indústria nacional.

2. SUJEITOS DO DELITO

O descaminho é delito comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa.

O funcionário público que participa do fato, facilitando-o com infração de dever de ofício, comete o delito do art. 318 do CP. Se não infringe dever funcional específico, é coautor ou partícipe do descaminho.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O tipo penal prevê em seu caput a seguinte conduta: iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou pelo consumo de mercadoria.

A conduta consiste, portanto, em iludir, que significa burlar, enganar, de forma total ou parcial, o pagamento de direito ou imposto devido em face da saída, entrada ou consumo de mercadoria (de observar-se que não existe mais entre nós, com essa denominação, o referido imposto de consumo).

Mercadoria é a coisa móvel de qualquer natureza.

Trata-se de mercadoria cuja entrada ou saída de nosso território é permitida. O sujeito, contudo, fraudar o pagamento do tributo exigido. Assim, na importação é obrigatório o pagamento de direitos e do Imposto de Importação ou Imposto sobre Produtos Industrializados. Na saída da mercadoria é devido o Imposto de Exportação. Cometendo o delito, o sujeito ilude, engana o poder público, deixando de efetuar o pagamento devido mediante expediente fraudulento.

4. QUESTÃO PREJUDICIAL

O crime de descaminho, dada sua natureza tributária, fica submetido aos ditames da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, segundo a

qual: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de importar ou exportar a mercadoria dirigida à fraude no pagamento de direitos e impostos.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Para efeito de consideração do momento consumativo e da tentativa, é necessário verificar se a entrada ou saída de mercadoria deu-se:

1º) pela alfândega; ou

2º) por outro local que não pela aduana.

No primeiro caso, a consumação ocorre no momento em que a mercadoria é liberada. Se interrompida a conduta antes da liberação, há tentativa. Na segunda hipótese, o momento consumativo se dá no instante em que a mercadoria entra ou sai de nosso território. Se, por circunstância externa à vontade do agente, o objeto material não chega a entrar ou sair de nosso território, há tentativa.

7. DESCAMINHO POR ASSIMILAÇÃO

Nos termos do § 1º, I, do art. 334, do CP, incorre na mesma pena quem “pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei”.

A navegação de cabotagem, fora dos casos previstos em lei, é equiparada a descaminho. Essa modalidade de navegação é aquela realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores (art. 2º, IX, da Lei n. 9.432/97).

Trata-se de norma penal em branco, ocorrendo o crime somente quando realizado o fato “fora dos casos permitidos em lei”. De modo que, na

ausência desse elemento normativo do tipo, realizando-se a cabotagem de acordo com as normas legais, o fato é atípico.

As restrições a esse tipo de navegação encontram-se dispostas na Lei n. 9.432/97. Empresas estrangeiras, por exemplo, somente podem participar do transporte de mercadorias na navegação de cabotagem quando afretadas por empresas brasileiras de navegação (art. 7º da lei citada).

O inciso II comina a mesma pena a quem “pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho”.

É uma norma penal em branco, completando-se com leis especiais, como, v.g.:

1ª) Zona Franca: art. 39 do Decreto-lei n. 288, de 28 de fevereiro de 1967, que determina como crime de contrabando o fato de efetuar a saída de mercadorias de seus limites, sem autorização de quem de direito. Muito embora o dispositivo fale em “contrabando”, parece-nos que a equiparação diz respeito a “descaminho”, em face da natureza tributária da infração e do bem jurídico atingido pela conduta.

2ª) Tabaco estrangeiro: de acordo com o art. 3º do Decreto-lei n. 399, de 30 de dezembro de 1968, que trata de fumo de origem estrangeira.

Nos termos do inciso III, incorre em crime quem “vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem”.

Essa disposição foi introduzida no art. 334 do CP pela Lei n. 4.729, de 14 de julho de 1965, que tratava dos delitos de sonegação fiscal, sendo mantida pela Lei n. 13.008, de 26 de junho de 2014.

Na primeira parte, o dispositivo descreve comportamentos do próprio agente que, no desempenho de atividade comercial ou industrial, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer maneira, utiliza em proveito próprio ou alheio mercadoria de origem estrangeira que ele mesmo introduziu clandestinamente no País ou importou com fraude. O tipo descreve condutas do próprio autor do descaminho. Nesse caso, pelo princípio da especialidade, o conflito aparente de normas se resolve pela aplicação exclusiva do § 1º, III, do art. 334, afastada a incidência do caput. De modo que o sujeito que, v.g., pratica descaminho, e depois é surpreendido vendendo a mercadoria, não responde por dois delitos.

O inciso III, em sua segunda parte, define fatos que deveriam ser, em tese, crimes de receptação. O agente vende mercadoria objeto de descaminho cometido por terceiro. Nesse caso, não basta, v.g., a simples venda. É necessário que o sujeito tenha plena certeza da origem delituosa da coisa. Pelo princípio da especialidade, ele não responde por receptação (CP, art. 180, caput), mas sim pelo delito descrito no inciso III.

O inciso IV descreve o delito de quem “adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos”.

Estão definidas condutas que, normalmente, são consideradas receptação dolosa (CP, art. 180, caput): as ações pressupõem a entrada ilícita no país de mercadoria estrangeira, que chega ao sujeito: a) sem a documentação exigida pela lei; b) com documentação falsa, de conhecimento do agente.

Na hipótese de receptação de mercadoria objeto de descaminho, podem ocorrer dois delitos:

1º) se o sujeito agiu dolosamente, responde pelo crime do inciso IV, afastada a incidência do art. 180, caput, do CP;

2º) se agiu culposamente, incide nas penas da receptação culposa (art.

180, § 3º).

A ação deve ser desenvolvida “no exercício de atividade comercial ou industrial”. De acordo com o § 2º do art. 334, “equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências”. Não estando presente a elementar referente ao “exercício de atividade comercial ou industrial”, não se aplica o inciso IV, subsistindo o delito de receptação dolosa ou culposa previsto no CP (art. 180, caput e § 3º).

As condutas incriminadas se desenvolvem “no exercício de atividade comercial ou industrial”. Não basta, por isso, a realização de uma conduta. Exige-se habitualidade: reiterada prática delituosa, com destinação comercial ou industrial da mercadoria.

Os verbos típicos são os da receptação dolosa: adquirir (contrato gratuito ou oneroso), receber (ter posse, a qualquer título, que não se trate de propriedade) e ocultar (esconder). O objeto material é a mercadoria de origem estrangeira sem documentação legal (guias de despacho aduaneiro, notas fiscais ou faturas) ou com documentos falsos. O dolo consiste na vontade livre e consciente de realizar qualquer das condutas descritas no tipo. Além disso, exigem-se dois elementos subjetivos do tipo: que o sujeito tenha pleno conhecimento da introdução ilícita da mercadoria em nosso território e que aja “em proveito próprio ou alheio”. Na hipótese de mercadorias acompanhadas de documento falso, o dolo deve abranger o conhecimento da falsidade. O sujeito, nesse caso, não responde por delito de uso de documento falso, de responsabilidade penal de quem lhe entregou o objeto material.

8. TIPO QUALIFICADO

Nos termos do § 3º do art. 334, a pena é aplicada em dobro se o delito é cometido em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

A razão da maior punição está em que o sujeito serve-se de um meio para cometer o delito que torna mais difícil a fiscalização da autoridade. Por isso, a qualificadora fica reservada aos voos e navegações clandestinos, excluídos os regulares. Quanto a estes, existe a fiscalização aduaneira, não havendo motivo para a agravação da pena.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

A pena prevista para o autor dos fatos descritos no caput e incisos do § 1º do art. 334 é de reclusão, de um a quatro anos (cabe, portanto, sursis processual), aplicada em dobro se ele utiliza transporte aéreo, marítimo ou fluvial para o cometimento do delito (§ 3º).

10. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A Lei n. 6.910, de 27 de maio de 1981, cancelou a Súmula 560 do STF, que admitia a extinção da punibilidade, pelo pagamento do tributo antes de iniciada a ação penal, nos delitos de contrabando e descaminho.

Subsiste, porém, referida eficácia quanto ao descaminho, por aplicação analógica dos arts. 34, caput, da Lei n. 9.249/95, 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003 e 83, § 4º, da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei n. 12.382/2011, que preconizam a extinção do direito de punir do Estado quando se verifica o pagamento da dívida fiscal.

11. PERDIMENTO DE BENS

Nos termos da Súmula 138 do primitivo TFR, “a pena de perdimento de veículo, utilizado em contrabando ou descaminho” (Decreto-lei n. 1.455/76, art. 23), “somente se justifica se demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do seu proprietário na prática do ilícito”.

De ver que o art. 278-A do CTB, incluído pela Lei n. 13.804, de 2019, dispõe que o condutor que se utilize de veículo para a prática de receptação, descaminho ou contrabando, uma vez condenado com trânsito

em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para conduzir veículos por cinco anos.

Contrabando

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Questão prejudicial. 5. Princípio da especialidade. 6. Elemento subjetivo do tipo. 7. Consumação e tentativa. 8. Contrabando por assimilação. 9. Tipo qualificado. 10. Penas e ação penal. 11. Perdimento de bens.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 334-A, caput, do CP, constitui crime o fato de “importar ou exportar mercadoria proibida”.

No sentido jurídico, a expressão contrabando quer dizer importação ou exportação de mercadorias ou gêneros cuja entrada ou saída do País é defesa.

A Lei n. 13.008, de 26 de junho de 2014, inseriu no Código Penal o art. 334-A. Não se trata, porém, de nova incriminação, pois o delito encontrava-se previsto, juntamente com o descaminho, na redação anterior do art. 334 do CP.

A cisão em dois tipos penais se mostrou correta, notadamente para permitir apenar de maneira mais rigorosa o contrabando (reclusão de dois a cinco anos versus reclusão de um a quatro anos para o descaminho).

A diferença entre tais crimes reside em que, no primeiro, a mercadoria é proibida; no segundo, sua entrada ou saída é permitida, porém o sujeito fraudula o pagamento do tributo devido. Justifica-se, portanto, a sanção mais grave cominada ao primeiro, decorrente da citada alteração legislativa.

O objeto jurídico é o interesse estatal no que diz respeito ao erário lesado pelo comportamento do sujeito, que, importando ou exportando mercadoria proibida, prejudica não só o poder público como a indústria nacional. Tutelam-se, ainda, secundariamente, bens como a saúde pública, que pode

vir a ser lesada pela entrada de produtos nocivos a ela e, por isso, proibidos.

2. SUJEITOS DO DELITO

O contrabando constitui delito comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa.

O funcionário público que participa do fato, facilitando-o com infração de dever de ofício, comete o delito do art. 318 do CP. Se não infringe dever funcional específico, é coautor ou partícipe do contrabando.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Tipo de formulação alternativa, prevê o caput do art. 334-A a seguinte conduta: importar ou exportar mercadoria proibida.

Importar quer dizer fazer entrar a mercadoria em nosso território, quer por terra, ar ou mar. Exportar significa fazer sair a mercadoria de nosso território.

Mercadoria é a coisa móvel de qualquer natureza.

No contrabando, a proibição pode ser:

1ª) absoluta; e

2ª) relativa.

No primeiro caso, a mercadoria não pode entrar ou sair de nosso território de forma alguma; no segundo, pode, desde que satisfeitos certos requisitos. Cabe à lei extrapenal, como complemento da norma penal em branco, dizer quais são as mercadorias absoluta e relativamente proibidas. Assim, por exemplo, é absolutamente proibida a importação de escritos e objetos obscenos, obras contrafeitas, armas de guerra, entorpecentes etc.

Constitui contrabando a reintrodução em nosso território de mercadoria da indústria nacional, com destinação específica para exportação e de

venda proibida entre nós. Assim, responde por contrabando o sujeito que introduz em nosso território produto nacional destinado à venda exclusiva no exterior. A capitulação do fato dava-se, antes da Lei n. 13.008/2014, no caput do art. 334 do CP e, agora, verifica-se à luz do art. 334-A, § 1º, III: “Incorre na mesma pena quem: (...) III – reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação”.

4. QUESTÃO PREJUDICIAL

O crime de contrabando não depende, para a sua ocorrência, de qualquer questão prejudicial, como a sua apuração na esfera administrativa. Assim, o autor pode ser processado criminalmente a despeito de qualquer providência, autônomas que são as esferas penal e administrativa.

5. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

É possível que o mesmo fato esteja descrito em mais de uma norma penal incriminadora (conflito aparente de normas). Ex.: à primeira vista, parece que a importação de objeto obsceno se amolda às descrições dos arts. 234 e 334 do CP. Quando isso ocorre, aplica-se o princípio da especialidade: a norma específica afasta a incidência da genérica. No caso, a norma genérica é a do art. 334. Outros exemplos em que não prevalece a norma genérica: importação de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem; produto de indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem; produto que apresente falsa indicação geográfica (arts. 190 e 192 da Lei n. 9.279/96); importação de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33); importação de material bélico privativo das Forças Armadas (Lei n. 7.170/83, Lei de Segurança Nacional, arts. 12 e 14) etc.

6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de importar ou exportar a mercadoria absoluta ou relativamente proibida.

O erro sobre a natureza proibida da mercadoria é erro de tipo (erro sobre a elementar), aplicando-se o art. 20, caput, do CP. O erro sobre a natureza ilícita da conduta configura erro de proibição (CP, art. 21).

7. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Para efeito de consideração do momento consumativo e da tentativa, é necessário verificar se a entrada ou saída de mercadoria deu-se:

1ª) pela alfândega; ou

2ª) por outro local que não pela aduana.

No primeiro caso, a consumação ocorre no momento em que a mercadoria é liberada. Se interrompida a conduta antes da liberação, há tentativa. Na segunda hipótese, o momento consumativo se dá no instante em que a mercadoria entra ou sai de nosso território. Se, por circunstância externa à vontade do agente, o objeto material não chega a entrar ou sair de nosso território, há tentativa.

8. CONTRABANDO POR ASSIMILAÇÃO

Nos termos do § 1º, I, do art. 334, do CP, incorre na mesma pena quem “pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando”. É uma norma penal em branco, completando-se com leis especiais.

De ver que o art. 39 do Decreto-lei n. 288, de 28 de fevereiro de 1967, determina como crime de “contrabando” o fato de efetuar a saída de mercadorias dos limites da Zona Franca de Manaus, sem autorização de quem de direito. Muito embora o dispositivo fale em “contrabando”, trata-se de fato assimilado a “descaminho”, por conta da natureza tributária da infração descrita e do bem jurídico protegido pela norma. Antes do advento da Lei n. 13.008/2014, a ressalva possuía reduzida importância, porquanto o contrabando e o descaminho eram previstos no mesmo tipo penal (art. 334) e continham a mesma pena. Agora, porém, além de se cuidar de

dispositivos distintos (arts. 334 e 334-A), possuem apenamento diferenciado. Nesse caso, portanto, não se aplicará o art. 334-A, mas o art. 334 do CP.

Nos termos do inciso II, incorre em crime quem “importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente”.

De acordo com o inciso III, há contrabando quando o sujeito “reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação”.

Assim, responde por contrabando o sujeito que introduz em nosso território produto nacional destinado à venda exclusiva no exterior. Conforme já assinalado, a capitulação do fato dava-se, antes da Lei n. 13.008/2014, no caput do art. 334 do CP e, agora, verifica-se à luz do citado dispositivo.

O inciso IV trata do ato de quem “vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira”.

Se o mesmo sujeito praticar o contrabando, introduzindo no Brasil as mercadorias proibidas e, em seguida, as mantiver em depósito, as expuser à venda, vendê-las, ou, de qualquer modo, utilizá-las, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, pratica crime único. Nesse caso, pelo princípio da especialidade, o conflito aparente de normas se resolve pela aplicação exclusiva do § 1º, IV, do art. 334-A, afastada a incidência do caput.

O inciso V, por fim, descreve a conduta do agente que “adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira”.

Os verbos típicos são os da receptação dolosa: adquirir (contrato gratuito ou oneroso), receber (ter posse, a qualquer título, que não configure

propriedade) e ocultar (esconder). O objeto material é a mercadoria proibida pela lei brasileira. O dolo consiste na vontade livre e consciente de realizar qualquer das condutas descritas no tipo. Além disso, exigem-se dois elementos subjetivos do tipo: que o sujeito tenha pleno conhecimento da introdução ilícita da mercadoria em nosso território e que aja “em proveito próprio ou alheio”.

Se o fato for realizado fora de atividade comercial ou industrial, incorre o indivíduo no delito de receptação dolosa ou culposa previsto no CP (art. 180, caput e § 3º).

As condutas incriminadas se desenvolvem “no exercício de atividade comercial ou industrial”. Não basta, por isso, a realização de uma conduta. Exige-se habitualidade: reiterada prática delituosa, com destinação comercial ou industrial da mercadoria. Consideram-se atividades comerciais, para os efeitos do art. 334-A do CP, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências (§ 2º).

9. TIPO QUALIFICADO

Nos termos do § 3º do art. 334-A, a pena é aplicada em dobro se o delito é cometido em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

A razão da maior punição está em que o sujeito serve-se de um meio para cometer o delito que torna mais difícil a fiscalização da autoridade. Por isso, a qualificadora fica reservada aos voos e navegações clandestinos, excluídos os regulares. Quanto a estes, existe a fiscalização aduaneira, não havendo motivo para a agravação da pena.

10. PENAS E AÇÃO PENAL

A pena prevista para o autor dos fatos descritos no caput e incisos do § 1º do art. 334-A é de reclusão, de dois a cinco anos, aplicada em dobro se ele utiliza transporte aéreo, marítimo ou fluvial para o cometimento do

delito (parágrafo único).

A sanção foi elevada pela Lei n. 13.008/2014, que entrou em vigor no dia 27 de junho de 2014, não tendo, dado seu caráter gravoso, aplicação retroativa (CF, art. 5.º, XL, e CP, art. 2.º). Assim, portanto, se o contrabando foi cometido até o dia 26 de junho de 2014, será apenado com reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se ultrativamente a pena anterior; se praticado a partir do dia 27, incide a nova cominação. De lembrar-se que, para tais efeitos, deve-se ter em conta a data da conduta (ação ou omissão), ainda que outra seja a do resultado (CP, art. 4.º).

11. PERDIMENTO DE BENS

Nos termos da Súmula 138 do primitivo TFR, “a pena de perdimento de veículo, utilizado em contrabando ou descaminho” (Decreto-lei n. 1.455/76, art. 23), “somente se justifica se demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do seu proprietário na prática do ilícito”.

O art. 278-A do CTB, incluído pela Lei n. 13.804, de 2019, dispõe que o condutor que se utilize de veículo para a prática de receptação, descaminho ou contrabando, uma vez condenado com trânsito em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para conduzir veículos por cinco anos.

Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Concurso de crimes. 7. Abstenção venal de licitante. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 335, caput, do CP, dispunha como crime o fato de “impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem”.

O dispositivo encontra-se revogado tacitamente pela Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93). Não ocorreu, porém, abolitio criminis, pois as condutas continuam tendo caráter criminoso na citada lei. Observou-se o princípio da continuidade típico-normativa, de tal maneira que o fato manteve seu caráter criminoso sem solução de continuidade.

A matéria encontra-se regulada nos arts. 93 e 95 da Lei n. 8.666/93.

Eis as novas descrições típicas: art. 93 da Lei n. 8.666/93: “Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa”. Art. 95 da Lei n. 8.666/93: “Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida”.

As normas tutelam o patrimônio da Administração Pública, procurando conferir seriedade e normalidade às concorrências e hastas públicas, por meio das quais o Estado se vale para a aquisição e contratação de bens e serviços destinados à sociedade.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive por funcionário público, desde que não se adapte ao crime do art. 94 da Lei de Licitações ("devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo"). Nada impede que realize o fato o próprio licitante, interessado em afastar os outros concorrentes.

Quanto ao conceito de funcionário público, aplica-se o disposto no art. 84 e § 1º da Lei n. 8.666/93: "Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. § 1º Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público".

Sujeito passivo principal é o Estado; secundário, o licitante prejudicado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Os tipos descrevem duas modalidades delituosas:

1ª) Impedimento, perturbação ou fraude de qualquer ato de procedimento licitatório referente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, quando contratadas com terceiros, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.666/93 (art. 93 da mesma lei).

Impedir tem o significado de obstar o começo. Perturbar quer dizer atrapalhar e embaraçar; por último, fraudar indica causar erros ou enganos.

Licitação é a disputa ou competição entre interessados que a Administração Pública convoca, mediante avisos ou editais, para alienar bens, adquiri-los ou para realizar obras ou serviços de interesse social.

Cuida-se de licitação promovida pela administração federal, estadual ou municipal. Ficam excluídas do tipo penal em análise as arrematações ou praças judiciais realizadas por particulares. Neste caso, incide a norma incriminadora do art. 358 do CP.

2ª) Afastamento ou procura de afastamento de licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem (art. 95, caput, da Lei n. 8.666/93).

Os meios de execução do afastamento de concorrente ou licitante ou da tentativa de afastamento estão pormenorizados no tipo: violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem.

Afastar licitante significa arredar, pôr distante, fazer com que se retire. Importa que o licitante, em face do meio empregado pelo sujeito, deixe de participar da licitação pública. É irrelevante o seu afastamento físico, desde que, a partir de determinado momento, em face da execução da conduta delituosa, deixe de ser licitante.

A expressão “violência” indica força física, afastada a violência contra a coisa. Pode consistir em vias de fato ou lesão corporal (leve, grave ou gravíssima). Se o sujeito emprega violência contra coisa, responde pelo crime do art. 93 da Lei n. 8.666/93.

Não basta a simples ameaça. Deve ser grave: prenúncio de mal grave ao sujeito passivo.

Fraude é o emprego de artifício ou arдил, no sentido de enganar o licitante, afastando-o, com isso, da competição pública.

O oferecimento de vantagem pode ser realizado por qualquer meio: escrito, verbal, gestual etc. A vantagem pode ser de qualquer natureza: material ou moral.

O comportamento visa ao afastamento de licitantes, incluindo tanto os que já tinham feito a oferta ou apresentado a proposta como aqueles que estavam em condições de fazê-lo. Não há o delito quando se trata de licitante fictício, i.e., pessoa que simula ser licitante somente para receber a vantagem em face de seu afastamento. Neste caso, por parte do simulador, há crime de estelionato.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

Na primeira modalidade típica, é o dolo, vontade livre e consciente de realizar a conduta descrita. Na segunda, além do dolo, exige-se um outro elemento subjetivo: a intenção de afastar o licitante.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Na primeira figura típica, o delito atinge a consumação com o impedimento, perturbação ou fraude da licitação. A tentativa é admissível. Ex.: não obstante o ato tendente ao impedimento, realiza-se a licitação.

Na segunda modalidade típica, o delito se consuma com o emprego do meio de execução (violência física, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem). Crime formal, não exige que o concorrente realmente se afaste da competição. É suficiente a realização do ato executório com a finalidade de afastamento. Nesse caso, a tentativa é punível com a mesma pena do delito consumado, sem a redução. Não se pode dizer que no segundo tipo não se admite a figura tentada. Ela é possível. Entretanto, constitui caso de ressalva do parágrafo único do art. 14 do CP: à forma tentada é aplicável a mesma pena do delito consumado, sem a diminuição de um a dois terços. Assim, tanto faz que o sujeito realmente afaste ou fique na tentativa do afastamento. A pena abstrata é a mesma. Entretanto,

o Juiz, na dosagem concreta da pena, deverá levar em conta a consumação ou mera tentativa do crime.

6. CONCURSO DE CRIMES

Empregando o agente violência física, haverá concurso material com o delito de homicídio ou lesão corporal (leve, grave ou gravíssima), de acordo com o preceito sancionador do caput do art. 95 da Lei n. 8.666/93. No caso do emprego de vias de fato, a contravenção fica absorvida.

O afastamento de mais de um licitante não conduz ao concurso de delitos: há um só crime. Se, entretanto, ele emprega violência física contra mais de um concorrente, responde por tantos delitos de violência quantas forem as vítimas, subsistindo, porém, um só delito do art. 95 da Lei n. 8.666/93.

7. ABSTENÇÃO VENAL DE LICITANTE

Prevê o parágrafo único do art. 95 da Lei n. 8.666/93 a mesma pena imposta no caput a “quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida”.

A conduta incriminada consiste em deixar de participar, ou desistir, em razão de vantagem oferecida, de licitação promovida pela administração federal, estadual ou municipal.

O oferecimento de vantagem é um dos meios previstos pelo legislador para afastar o licitante (art. 95, caput). Aqui, o legislador impõe a mesma pena a quem, por causa da vantagem ofertada, abstém-se de participar da competição.

Subtipo de crime próprio, só pode ser cometido por licitante. Admite, entretanto, participação de terceiro não qualificado, mediante induzimento, instigação ou auxílio secundário.

É necessário que haja relação de causalidade entre o oferecimento da

vantagem e a desistência ou abstenção. Afastando-se o licitante ou concorrente por outra razão, o fato é atípico. Assim, não constitui delito o fato de o licitante afastar-se da hasta pública em razão de violência física, grave ameaça ou fraude. Nestes casos, só responde criminalmente o autor da violência etc. (art. 95 da Lei n. 8.666/93).

A abstenção admite diversos meios de execução: deixar de completar a documentação necessária, não apresentar a proposta, não fazer lance etc.

Consuma-se o delito no momento em que o sujeito se abstém de apresentar a proposta ou desiste da licitação. Crime omissivo próprio, não admite a figura da tentativa.

O dolo consiste na vontade e consciência de não participar ou desistir da licitação, com conhecimento de que o faz em razão da vantagem oferecida.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

Na hipótese do art. 93 da Lei n. 8.666/93, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos, e multa (infração de menor potencial ofensivo); nos casos do art. 95, caput e parágrafo único, de detenção, de dois a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à eventual violência.

A pena deve ser acrescida de terça parte na hipótese de o autor ser ocupante de "cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público".

A pena de multa, nos termos do art. 99 da Lei n. 8.666/93, consiste no "pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. § 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado

com dispensa ou inexigibilidade de licitação. § 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal”.

A ação penal é pública incondicionada, regida pela Lei n. 8.666/93 (arts. 100 a 108).

Inutilização de edital ou sinal

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito o fato de “rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto” (CP, art. 336).

O legislador protege a Administração Pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por funcionário público.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O tipo prevê duas figuras:

1ª) inutilização de edital; e

2ª) inutilização de sinal.

A primeira figura incriminada consiste em rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público.

Rasgar significa cortar, lacerar, total ou parcialmente. Inutilizar quer dizer transformar a coisa em objeto inservível, perder a sua destinação específica. Conspurcar é sujar, manchar, macular.

Essas condutas podem ser realizadas “de qualquer forma” (rasuras, pichamentos etc.). Trata-se de uma hipótese de interpretação analógica.

A objetividade material é o edital, comunicação de origem oficial com destinação de dar conhecimento de alguma coisa a todos e afixada em local público. Pode ser administrativo ou judicial. A afixação em lugar de costume deve ter sido ordenada por funcionário público competente. É necessário que possua atualidade, i.e., que o fato seja realizado durante o período em que o edital tem validade. Assim, se afixado para dar conhecimento da prática de algum ato dentro de certo período, só existe crime quando rasgado ou inutilizado dentro do prazo. Não há delito, diante disso, no ato de rasgar um edital de citação e interrogatório criminal meses depois de o réu ter sido ouvido (interrogado).

A segunda conduta típica consiste em violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto.

Violar indica romper, devassar, quebrar etc.

O objeto material é o selo ou sinal empregado para identificar ou cerrar (fechar) qualquer coisa (móvel ou imóvel). Pode ser de qualquer natureza: papel, lacre, chumbo etc. Imprescindível que seja determinado por lei e originário de funcionário público competente, com seu carimbo ou assinatura. Exige-se atualidade: não há crime no caso de o sinal ou selo não possuir mais utilidade pelo decurso do tempo.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de concretizar os elementos objetivos do tipo.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime atinge a consumação no ato de rasgar, inutilizar, conspurcar ou violar selo ou sinal. No verbo violar não é necessário que o sujeito consiga

conhecer o conteúdo do que o selo ou sinal encerra. É suficiente a conduta tendente a tal finalidade.

Crime material, admite a forma tentada.

6. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são alternativas: detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Subtração ou inutilização de livro ou documento

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Distinção com outros delitos. 3. Sujeitos do delito. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui crime o fato de “subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público” (CP, art. 337).

Trata-se de norma penal incriminadora subsidiária, aplicável somente no caso de o fato não configurar delito de maior gravidade, conforme consta do preceito sancionador (pena tal, “se o fato não constitui crime mais grave”). A subsidiariedade, que é expressa, pode conduzir a responsabilidade penal de maior severidade. Ex.: tratando-se de documento sob custódia oficial e com destinação de constituir prova, agindo o sujeito com o fim de locupletar-se com a conduta, o fato configura o delito de supressão de documento (CP, art. 305), em que é cominada pena mais grave.

2. DISTINÇÃO COM OUTROS DELITOS

O crime do art. 337 difere de outros crimes, como a supressão de documento (CP, art. 305), extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (art. 314) e a sonegação de papel ou documento de valor probatório (art. 356).

No crime do art. 305, o documento tem a destinação de demonstrar a existência de alguma relação jurídica. Além disso, o agente realiza a conduta a fim de beneficiar-se (ou a outrem).

No delito do art. 314, o sujeito ativo é o funcionário público.

No crime descrito no art. 356, o sujeito ativo só pode ser o advogado ou procurador.

3. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, a subtração ou inutilização de livro ou documento pode ser realizada por qualquer pessoa. Entretanto, quando cometido por funcionário público agindo no exercício de suas funções, desde que na guarda do objeto material, há o delito do art. 314. Quando praticado por advogado ou procurador, aplica-se o art. 356 do CP.

Sujeito passivo é o Estado. A pessoa que, em razão da subtração ou inutilização do objeto material, sofre prejuízo, aparece como sujeito passivo secundário.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A figura típica apresenta dois núcleos: os verbos subtrair e inutilizar, já apreciados em outras disposições.

Os objetos materiais, sobre os quais incidem as condutas, são: livro oficial, indicando os livros de registro, termos, atas, notas etc.; documento, referindo-se ao papel anotado; processo, reunião ordenada de autos, documentos e peças concernentes a procedimentos policiais, administrativos ou judiciários.

É necessário que os objetos materiais estejam confiados à custódia de funcionário público em razão do ofício, ou seja, por força de seu cargo, ou sob a guarda de particular prestando serviço público.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de realizar a conduta de subtrair ou inutilizar os objetos materiais, nas condições descritas no tipo. Não há exigência de nenhuma finalidade especial da conduta.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Na subtração, o delito atinge o momento consumativo nas mesmas condições do furto, i.e., no instante em que o objeto material sai da esfera de vigilância do funcionário público ou particular, ingressando na disponibilidade do sujeito. Na modalidade de inutilização, com a sua efetivação, total ou parcial.

Crime material, admite a forma tentada.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena cominada é a reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui delito de maior gravidade (exs.: crimes dos arts. 305, 314 ou 356 do CP).

A ação penal é pública incondicionada.

Sonegação de contribuição previdenciária

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Extinção da punibilidade. 7. Perdão judicial. 8. Causa de diminuição de pena. 9. Parcelamento do débito previdenciário. 10. Art. 95 da Lei n. 8.212/91. 11. Penas e ação penal. 12. Vacatio legis.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 337-A do CP, acrescentado pela Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, dispõe constituir crime o fato de “suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços; III – omitir, total e parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias”.

Esse dispositivo retirou do art. 95 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social) os crimes ali tratados.

As normas incriminadoras protegem o patrimônio do Estado e, particularmente, a Seguridade Social, a fim de permitir que ela, recebendo as contribuições de que é credora, pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), possa alcançar a finalidade de assegurar o direito concernente à saúde, à previdência e à assistência social.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, somente pode ser cometido pelo particular, quando omite ou deixa de lançar as informações necessárias na folha de pagamento, nos títulos de contabilidade ou mesmo quando omite, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos nos quais poderiam incidir contribuições sociais previdenciárias.

Sujeito passivo principal é o Estado, e, imediatamente em seguida, a Seguridade Social.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Os tipos apresentam três modalidades delituosas:

I – omitir, na folha de pagamento da empresa ou em documento de informações previsto pela legislação previdenciária, dados referentes a segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

O dispositivo tem a finalidade de coibir a prática em que os salários percebidos são muitas vezes diminuídos ou mesmo suprimidos, no momento de sua escrituração na documentação previdenciária, para que se evite ônus maior para a empresa.

Os conceitos dos beneficiados aqui trazidos podem ser localizados no Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). O inciso, entretanto, menciona “trabalhador autônomo”, que agora possui a designação de contribuinte individual.

O emprego da expressão “ou a este equiparado” está contemplado em uma norma penal em branco, uma vez que a incriminação fica na dependência da legislação previdenciária.

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa quantias já descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

Esse inciso tem em vista a correta escrituração da documentação contábil da empresa, tais como livros e assemelhados. E, valendo-se de maior precisão terminológica, empregou os termos empregador e tomador de serviços.

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

É cabível a aplicação da interpretação analógica, na qual uma fórmula exemplificativa antecede a uma genérica (“demais fatos geradores”).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir contribuição social por intermédio das condutas incriminadas. Não há exigência de nenhum outro elemento subjetivo do tipo.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Crime material, consuma-se com a efetiva supressão ou redução da contribuição social previdenciária, e não com a realização das condutas omissivas descritas nos incisos, simples meios executórios. A tentativa é admissível, embora de difícil ocorrência.

6. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

O § 1º do art. 337-A do CP contempla hipótese de extinção da punibilidade, estabelecendo: “é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal”.

Requisitos que devem ser realizados simultaneamente:

1º) Pessoaalidade;

2º) Espontaneidade nas condutas de declarar e confessar;

3ª) Prestação de informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento (caso de norma penal em branco);

4ª) Conduta extintiva da punibilidade anterior ao início da ação fiscal, que se dá com a notificação do lançamento do tributo.

7. PERDÃO JUDICIAL

O § 2º do art. 337-A do CP contempla mais uma hipótese de perdão judicial, além de um caso de aplicação exclusiva de multa. Dispõe: “É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais”. Na primeira hipótese, há perdão judicial (CP, arts. 107, IX, e 120); na segunda, indicação de aplicação isolada da pena de multa. Cuida-se de direitos penais subjetivos públicos do réu, desde que atendidos os requisitos pessoais e objetivos. A opção por uma ou outra medida depende da análise das circunstâncias do fato concreto.

Nos dois casos, além das condições subjetivas, é necessário que o valor das contribuições devidas e seus acessórios seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Aplicando parcialmente o princípio da insignificância, a disposição adota a norma que já vem sendo empregada nos delitos de contrabando e descaminho, onde se admite a atipicidade do fato quando o valor do objeto material ou do tributo não se mostra superior a R\$ 20.000,00. Aqui, contudo, em vez de reconhecer a falta de tipicidade do fato, o legislador somente admite o perdão judicial e a incidência exclusiva da multa.

8. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Além da hipótese já prevista no § 2º do art. 337-A do CP, o § 3º prevê que, “se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R\$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa”.

Nessa causa de diminuição de pena, o legislador teve em vista o sonegador de poucas posses, uma vez que restringe a folha de pagamento a dez salários-mínimos. Novamente, entendemos haver direito subjetivo do réu, desde que estejam presentes as condições objetivas, a saber:

1º) empregador pessoa física;

2º) folha de pagamento mensal de até R\$ 1.510,00.

O reajuste do valor aqui mencionado, a teor do § 4º, “será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social”. De acordo com a Portaria n. 9, do Ministério da Economia, de 15 de janeiro de 2019, esse valor é de R\$ 5.155,31.

9. PARCELAMENTO DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO

De acordo com o art. 83, § 1º, da Lei n. 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n. 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, “Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento”. Durante o período em que a pessoa física ou jurídica relacionada com o agente do crime do art. 337-A do CP estiver incluída no parcelamento, fica “suspensa a pretensão punitiva do Estado”, conquanto “o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal” (§ 2º). Suspende-se, igualmente, a prescrição da pretensão punitiva (§ 3º). Se houver o pagamento integral dos débitos objeto de parcelamento, extingue-se a punibilidade (§ 4º).

10. ART. 95 DA LEI N. 8.212/91

Muito controvertido o art. 95 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social), por, dentre outros motivos, apresentar tipos penais sem as respectivas penas, passou com seu conteúdo, feitos os devidos ajustes, a integrar o Código Penal. Na sonegação de contribuição previdenciária, as alíneas a, b e c, que cuidavam, respectivamente, dos crimes agora apenados pelos incisos I, II e III do art. 337-A do CP, por exemplo, não apresentavam preceitos sancionatórios. Para muitos, então, seriam equiparadas ao crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Como não podemos falar em analogia para tal espécie, a norma resultava inútil. Remanesceu, porém, o § 2º, que traz consequências à empresa transgressora das normas previstas na Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, perfeitamente transportadas para o que agora dispõe o CP. São elas:

- suspensão dos empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais;
- revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial;
- inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal;
- interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual;
- desqualificação para impetrar concordata;
- cassação de autorização para funcionar no País, quando for o caso.

11. PENAS E AÇÃO PENAL

As penas são cumulativas: reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Na hipótese do § 1º do art. 337-A do CP, há a previsão de extinção da punibilidade. Já o § 2º desse artigo contempla a possibilidade do perdão judicial. E, por fim, o § 3º prevê uma causa de diminuição da pena.

A ação penal é pública incondicionada.

12. *VACATIO LEGIS*

A Lei n. 9.983/2000 foi publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2000 e entrou em vigor noventa dias após a sua publicação, isto é, em 15 de outubro de 2000.

Capítulo IX

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

INADEQUAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES

A Lei n. 10.467, de 11 de junho de 2002, introduziu no Título XI do Código Penal o Capítulo II-A, definindo os crimes de corrupção ativa e tráfico de influência contra a administração pública estrangeira nas transações comerciais internacionais. Causa estranheza que o CP brasileiro contenha um capítulo definindo crimes “contra a Administração Pública estrangeira”. Na verdade, o legislador pretendeu cominar punições criminais para fatos que atentam contra a “lisura que deve orientar as transações comerciais internacionais”, “preservando as condições transacionais de competitividade” (trecho do voto do Deputado Federal Jarbas Lima durante apreciação, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, do Projeto de Lei n. 4.143, de 2001, de que se originou a Lei n. 10.467/2002).

Corrupção ativa em transação comercial internacional

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Origem da norma de conduta. 3. Exceção pluralista do princípio unitário. 4. Sujeitos do delito. 5. Condutas típicas. 6. Objeto material. 7. Transação comercial internacional. 8. Elementos subjetivos do tipo. 9. Consumação e tentativa. 10. Realização, retardamento ou omissão de ato de ofício por parte do funcionário público estrangeiro como causa de aumento de pena (parágrafo único). 11. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O CP, no art. 337-B, introduzido pela Lei n. 10.467, de 11 de junho de 2002, descreve o tipo simples de corrupção ativa de funcionário público estrangeiro no comércio transacional como o fato de “prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado a transação comercial internacional”.

A norma que define a corrupção ativa transnacional protege o prestígio, a transparência e a normalidade do funcionamento da Administração Pública estrangeira, no que tange às transações comerciais internacionais.

Como observa Carlos A. Manfroni, a lei penal pretende “preservar la transparencia y la equidad en el comercio internacional, con vistas a una economía mundial cada vez más competitiva, en cuya expansión, la tolerancia de prácticas corruptas llevaría las fricciones que pudieran suscitarse entre empresas y países y los sobrecostos derivados a los pueblos, a niveles insoportables para la convivencia”¹⁵.

2. ORIGEM DA NORMA DE CONDUTA

Tipo incriminador introduzido pelo art. 2º da Lei n. 10.467, de 11 de

junho de 2002, oriunda do Projeto de Lei n. 4.143, de 2001, visando dar efetividade ao Decreto Legislativo n. 125, de 14 de junho de 2000, do Congresso Nacional, que aprovou a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais, concluída pelas Nações Unidas em Paris, em 17 de dezembro de 1997, e pelo Decreto n. 3.678, de 30 de novembro de 2000, que a promulgou.

3. EXCEÇÃO PLURALISTA DO PRINCÍPIO UNITÁRIO

Poderia haver um só delito para corruptor (nacional ou estrangeiro) e corrupto (funcionário público estrangeiro). De ver-se, contudo, que o CP não definiu, nem poderia fazê-lo, o crime de corrupção passiva do funcionário público estrangeiro. De modo que o corruptor responde nos termos do art. 337-B; o corrompido (funcionário público estrangeiro), por eventual delito de corrupção passiva, perante a sua legislação penal. Assim, uma infração não depende da outra, podendo as legislações punir separadamente os dois autores.

4. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, a corrupção ativa nas transações comerciais internacionais pode ser cometida por qualquer pessoa, brasileiro ou estrangeiro, inclusive pelo funcionário público, brasileiro ou estrangeiro, desde que não aja com essa qualidade (note-se que se trata de crime cometido por “particular contra a Administração Pública”).

Sujeito passivo é a Administração Pública estrangeira.

5. CONDUTAS TÍPICAS

Consistem em oferecer, prometer ou dar, de forma direta ou indireta, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceiro, com o fim de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado a

transação comercial internacional. Não é suficiente que o polo passivo da corrupção seja funcionário público estrangeiro, sendo necessário que o fato se relacione a transação comercial internacional.

A conduta pode ser direta e indireta. Na primeira espécie, o sujeito expressamente formula sua pretensão de oferecimento etc. de vantagem ao funcionário público estrangeiro (a viso aperto ou facie ad faciem). Na segunda, o autor de fato vale-se de interposta pessoa para chegar ao conhecimento do funcionário a sua intenção ou apresenta o oferecimento ou a oferta de maneira velada, capciosa ou maliciosa (forma implícita de execução).

Oferecer significa apresentar ou propor alguma coisa para que seja aceita; dar como oferta (Aurélio), pôr à disposição (Delmanto). Pode ser entendido como exhibir uma coisa para que seja aceita. Prometer significa obrigar-se a fazer ou dar alguma coisa (Aurélio). Dar quer dizer ceder, doar, presentear (Aurélio).

Não há corrupção ativa no caso de o sujeito, sem oferecer ou prometer vantagem ao funcionário público estrangeiro, pedir-lhe que “dê um jeitinho” em sua situação (perante a Administração Pública estrangeira).

É indispensável que não exista exigência por parte do funcionário estrangeiro, caso em que há o crime de concussão perante a legislação penal estrangeira. O oferecimento e a promessa devem ser espontâneos. Se impostos pelo funcionário, desaparece a corrupção ativa. Assim, diante do mesmo contexto de fato, não é possível que o funcionário público estrangeiro cometa concussão, e o particular, corrupção ativa. Não fica impedido, entretanto, que o crime surja em face de sugestão do funcionário público estrangeiro.

A vantagem deve endereçar-se ao funcionário público estrangeiro ou a “terceira pessoa” (parente, cônjuge, amigo, entidade ou pessoa jurídica). A redação do tipo é equívoca. Devemos entender que o comportamento de

corrupção é sempre endereçado ao servidor público estrangeiro, no sentido da alteração de sua atitude funcional, visto que a vantagem é que pode ser destinada a ele ou a terceiro.

As condutas de corrupção devem endereçar-se a um funcionário público estrangeiro determinado. Se indeterminado, não há crime.

O delito pode ser realizado mediante interposta pessoa. Nesse caso, o terceiro aparece como partícipe do crime do art. 337-B, e não da eventual corrupção passiva do funcionário público estrangeiro, a ser punida em seu país.

E se o funcionário repele a oferta?

Há delito em relação ao ofertante, uma vez que a lei incrimina o simples dar, oferecer ou prometer a vantagem. O funcionário público estrangeiro não responde por delito algum (não aceitou o oferecimento ou a promessa).

A conduta funcional do servidor público estrangeiro pretendida pelo corruptor pode ser lícita ou ilícita. Quando o ato funcional é lícito, fala-se em corrupção própria; quando ilícito, imprópria.

Deve haver nexo de causalidade entre a conduta do funcionário público estrangeiro e a realização do ato de ofício. Caso contrário, inexistirá o delito questionado, podendo surgir outro. Exige-se, pois, que o funcionário tenha atribuição para a realização do ato oficial. Não se trata, pois, de qualquer funcionário público estrangeiro, mas daquele que tem o dever de ofício de realizar ou não o ato. Assim, é necessário que o ato esteja dentro da esfera de atribuições do servidor público estrangeiro no que diz respeito a transação comercial internacional.

Não há corrupção ativa no caso de a vantagem ser oferecida, prometida ou dada ao funcionário público estrangeiro depois de sua conduta funcional (ativa ou omissiva). O comportamento visado deve ser realizado no futuro. Se já ocorreu, não há crime.

6. OBJETO MATERIAL

Qualquer vantagem constitui o objeto do crime, material ou imaterial, econômica ou não, presente ou futura. Constitui vantagem:

a) todo bem, móvel ou imóvel, tangível ou intangível, ou toda soma de dinheiro, título de propriedade, título de participação ou reconhecimento de dívida, auferidos pelo agente a pretexto de presente, comissão, porcentagem, gratificação, empréstimo, honorário, recompensa ou comissão;

b) todo encargo, emprego ou contrato;

c) todo pagamento, liberação, dispensa ou liquidação, no todo ou em parte, de empréstimo ou qualquer outra obrigação;

d) qualquer outro serviço ou favor, a título gracioso ou preferencial, e toda utilização indevida de material ou pessoal;

e) o exercício, cumprimento ou abstenção de um direito, poder ou dever;

f) todo ato, interesse ou proveito, de qualquer natureza; e

g) toda oferta, compromisso ou promessa, sob condição ou não, de proveito referido nas alíneas anteriores¹⁶.

A vantagem deve ser indevida, i.e., ilegítima, ilícita ou ilegal, não autorizada por lei. Se devida, não há crime por atipicidade.

Nem todas as coisas podem ser consideradas objeto material de corrupção. Assim, as gratificações comuns, de pequena importância econômica, em forma de gratidão em face da correção de atitude de um funcionário público estrangeiro, não integram o delito. Por exemplo: as "boas-festas" de Natal ou Ano Novo. Nesses casos, de ver-se que não há da parte do ofertante ou doador a consciência de estar oferecendo ou dando uma retribuição pela prática de um ato de ofício por parte do funcionário, que é essencial ao dolo de corrupção. Mas se trata de questão de fato, a ser apurada caso por caso.

7. TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL

É necessário que a conduta do corruptor esteja relacionada a transações comerciais internacionais, assim consideradas as que concernem a contratos:

I – que tenham como objeto, direta ou indiretamente, a importação ou exportação de bens ou serviços;

II – de transporte internacional, por qualquer via, de pessoas, cargas, malotes postais, remessas expressas ou qualquer outro bem;

III – que impliquem transmissão de informações, por qualquer meio de comunicação, entre pessoas localizadas ou sediadas em países distintos;

IV – relativos a empréstimos e quaisquer outras obrigações, ou que possibilitem a circulação de valores de qualquer natureza, cujas partes estejam localizadas ou sediadas em países distintos;

V – que tenham como objeto cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações ou valores referidos no inciso anterior; e

VI – quaisquer outros que impliquem produção ou circulação de bens ou serviços cujos elementos o vinculem a mais de um sistema jurídico¹⁷.

Se a transação internacional não é comercial, não há o crime do art. 337-B. Assim, não se incluem no tipo os convênios de natureza cultural, política ou militar, salvo quando envolvam interesses econômicos.

8. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de oferecer, prometer ou dar a vantagem, com conhecimento de que é indevida e se trata de funcionário público estrangeiro e transação comercial internacional. Exige-se um segundo, contido na expressão “para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. Se inexistir qualquer dos dois elementos, o fato é atípico. A motivação é irrelevante. Assim, não desnatura o tipo subjetivo a circunstância de a corrupção destinar-se à realização de uma transação

comercial internacional que tenha influência política. Se o sujeito, por erro invencível, supõe devida a vantagem, há erro de tipo (CP, art. 20).

9. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Em relação aos verbos prometer e oferecer, cuida-se de crime formal, de consumação antecipada, atingindo o momento consumativo no instante em que o funcionário público estrangeiro toma conhecimento da oferta ou promessa. Não é necessário que o funcionário, em face da corrupção, aja ou deixe de agir. A concretização do fim visado pelo corruptor só é exigida na figura típica do parágrafo único do art. 337-B. No verbo dar, a consumação ocorre no instante em que o funcionário público estrangeiro recebe a vantagem. De ver-se, entretanto, no que tange ao verbo dar, que, se houve promessa ou oferta anterior, a consumação acontece antes da dação. É irrelevante à consumação a recusa do funcionário em aceitar a vantagem. Tomando ele conhecimento da oferta ou da promessa de vantagem indevida, o delito está consumado, independentemente da aceitação ou recusa.

A tentativa depende da forma de execução do delito. Cuidando-se de crime unissubsistente, que se perfaz com ato único, como a oferta verbal, não é admissível. Tratando-se, entretanto, de crime plurissubsistente, como a oferta por carta, é possível.

10. REALIZAÇÃO, RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE ATO DE OFÍCIO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA (PARÁGRAFO ÚNICO)

Consuma-se o delito, na forma típica comum (caput), com a dação, promessa ou oferta de vantagem indevida. Se o funcionário público estrangeiro, em razão da vantagem recebida ou promessa ou oferta, retarda ou omite ato de ofício, aumenta-se a pena de um terço (parágrafo único do art. 337-B). O mesmo ocorre se, em face da conduta do corruptor,

pratica ato de ofício com infração de dever funcional inerente à sua administração.

11. PENAS E AÇÃO PENAL

No tipo simples (caput), a pena é de reclusão, de um a oito anos, além de multa; no agravado, a pena é aumentada de um terço (parágrafo único).

A sanção prevista no tipo penal demonstra a falta de visão sistemática do legislador brasileiro em suas reformas pontuais no CP. A corrupção ativa comum (art. 333) é punida com reclusão, de dois a doze anos, e multa, ao passo que a corrupção ativa em transação comercial internacional (art. 337-B) é apenada com um a oito anos de reclusão (e multa). Nada justifica seja esta menos grave do que aquela. Não há razão jurídica alguma para que a conduta mereça censura maior quando vulnera a Administração Pública brasileira em comparação com a Administração Pública estrangeira. Bem ao contrário: essa disparidade constitui afronta ao disposto no art. 3º, n. 1, da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n. 125, de 14 de junho de 2000, e promulgada pelo Decreto Presidencial n. 3.678, de 30 de novembro de 2000. De acordo com a norma citada: "A corrupção de um funcionário público estrangeiro deverá ser punível com penas criminais efetivas, proporcionais e dissuasivas. A extensão das penas deverá ser comparável àquela aplicada à corrupção do próprio funcionário público da Parte...". Nota-se, portanto, que desde a elevação da pena da corrupção ativa comum (art. 333), ocorrida em 2003, o Estado brasileiro se encontra em mora, no sentido de não dar cumprimento integral à citada Convenção Internacional.

A ação penal é pública incondicionada.

Tráfico de influência em transação comercial internacional

SUMÁRIO: 1. Origem da norma de comando. 2. Conceito e objetividade jurídica. 3. Sujeitos do delito. 4. Condutas típicas. 5. Vantagem. 6. Elementos subjetivos do tipo. 7. Momento consumativo e tentativa. 8. Causa de aumento de pena. 9. Penas e ação penal.

1. ORIGEM DA NORMA DE COMANDO

O tipo criminal do art. 337-C do CP foi introduzido pelo art. 2º da Lei n. 10.467, de 11 de junho de 2002, oriunda do Projeto de Lei n. 4.143, de 2001, visando dar efetividade ao Decreto Legislativo n. 125, de 14 de junho de 2000, do Congresso Nacional, que aprovou a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais, concluída pelas Nações Unidas em Paris, em 17 de dezembro de 1997, e promulgada pelo Decreto n. 3.678, de 30 de novembro de 2000.

2. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 337-C do CP, configura o crime de tráfico de influência em transação comercial internacional o fato de solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional. A forma típica comum está descrita no art. 332 do CP; a transnacional, que visa o funcionário público estrangeiro nas transações comerciais internacionais, encontra-se definida no art. 337-C do mesmo estatuto.

O CP tutela o prestígio e a normalidade do funcionamento da

Administração Pública estrangeira, no que tange às transações comerciais internacionais.

3. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, o tráfico de influência nas transações comerciais internacionais pode ser cometido por qualquer pessoa, nacional ou estrangeiro, inclusive pelo funcionário público, brasileiro ou estrangeiro.

Sujeito passivo principal é o Estado. De forma secundária, a pessoa que compra o prestígio, que entrega ou promete a vantagem na ilusão de concretizar um interesse ilegítimo (o pretenso corruptor, “comprador de fumaça”).

4. CONDUTAS TÍPICAS

Consistem em solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato de funcionário público em transação comercial internacional. De observar-se que o delito, em sua forma singela, é cometido pelo particular que, simulando possuir prestígio junto a funcionário público estrangeiro, solicita, exige, cobra ou obtém vantagem indevida do interessado, alegando que se destina a influenciá-lo em ato de ofício inerente às suas funções em transação comercial internacional. O sujeito, alegando ter prestígio perante funcionário público estrangeiro, faz crer à vítima, enganosamente, possuir condições de alterar o comportamento daquele em transação comercial internacional.

Solicitar significa rogar, pedir. Exigir quer dizer impor, ordenar. Cobrar significa fazer com que seja pago (Delmanto). Obter indica conseguir.

É atípica a conduta de quem promete ou entrega a vantagem ao simulador, não havendo previsão de incriminação. Trata-se de crime putativo por erro de tipo: ele supõe estar participando de manobra tendente à prática do crime de corrupção ativa transnacional (CP, art. 337-B), i.e., ele pensa que o funcionário público estrangeiro vai ser corrompido.

Subsiste o delito ainda quando o funcionário público estrangeiro indicado não existe ou se aponte nome imaginário. De ver-se, contudo, que, se o agente individualiza uma pessoa, é necessário que seja funcionário público estrangeiro, sob pena de ficar excluída a tipicidade do fato.

A expressão “a pretexto” significa sob fundamento, com a desculpa, no sentido de que o autor faz uma simulação, levando a vítima à suposição de que influirá no comportamento funcional do agente do poder público estrangeiro. É possível que, na verdade, ele tenha prestígio junto ao funcionário, caso em que subsiste o delito, uma vez que a incriminação reside na fraude, na promessa de influência, quando, na realidade, nenhuma atitude ele tomará perante a administração pública. Daí a denominação que se dá à sua conduta: “venda de fumaça”.

5. VANTAGEM

Pode ser de qualquer natureza, material ou moral, e até sexual.

6. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, consistente na vontade livre e consciente dirigida à conduta ou ao engano da vítima, fazendo crer a ela que influenciará na atitude futura do funcionário público estrangeiro, abrangendo a pretensão de obtenção de vantagem ou a promessa de sua obtenção. O tipo reclama outro, contido na expressão “para si ou para outrem”.

7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Nos verbos solicitar, exigir e cobrar, o delito é formal, atingindo a consumação com a conduta do autor. No verbo obter, crime material, consuma-se no momento em que o sujeito obtém a vantagem ou sua promessa. A tentativa é admissível, embora de difícil ocorrência.

8. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

A pena é agravada de metade se o autor alega ou insinua que a

vantagem é também destinada ao funcionário público estrangeiro (parágrafo único do art. 337-C). Alegar significa dar como explicação (Aurélio). Insinuar quer dizer dar a entender de maneira indireta (Aurélio). Assim, não é exigida declaração expressa, bastando que o sujeito, enganosamente, dê a entender à vítima, por palavras, gestos ou qualquer outro meio, que parte da importância ou vantagem é destinada ao funcionário público estrangeiro a ser corrompido.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

Para o tipo simples (caput do art. 337-C), estão cominadas reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Na figura típica agravada (parágrafo único), a pena é aumentada de metade. Atendendo à recomendação da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais, no sentido de que a resposta penal do tráfico de prestígio de funcionário público estrangeiro deve ser proporcional ao mesmo tipo comum do CP, as penas abstratas cominadas ao tráfico de influência transnacional (CP, art. 337-C) são as mesmas impostas à figura típica comum (art. 332 do CP): reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

A ação penal é pública incondicionada.

Capítulo X

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Reingresso de estrangeiro expulso

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Qualificação doutrinária. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Elemento subjetivo do tipo. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 338 do CP, constitui crime “reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso”.

O legislador protege o prestígio, a autoridade e a eficácia do ato de expulsão.

Vale destacar que a figura da expulsão encontra-se disciplinada, atualmente, na Lei de Migração (Lei n. 13.445, de 24-5-2017). Segundo esta, a expulsão é uma medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado (art. 54, caput). Ela poderá ocorrer quando o estrangeiro sofrer condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de: a) crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto n. 4.388, de 25 de setembro de 2002; b) crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a

gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional.

A Lei de Migração, ainda, inseriu no Código Penal o art. 232-A (promoção de migração ilegal – estudado no Volume 3 desta obra). O legislador, em absoluta dissintonia com a natureza de cada Título da Parte Especial, que se dedica à proteção de um determinado bem jurídico, inclui o delito citado dentre os crimes contra a dignidade sexual (Título VI). Nada mais absurdo. A promoção de migração ilegal deveria ser incluída no Título XI, o qual trata dos delitos contra a Administração Pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo só pode ser o estrangeiro, admitindo-se participação de terceiro, nacional ou não, ainda que não expulso.

Sujeito passivo é o Estado.

3. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

Trata-se de crime próprio, uma vez que o tipo exige especial qualidade do sujeito ativo, qual seja, a de estrangeiro.

Cuida-se de crime instantâneo.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em o estrangeiro, expulso de nosso território, nele penetrar. Reingressar significa voltar, entrar de novo. O tipo pressupõe que o estrangeiro tenha sido expulso legalmente, nos termos dos arts. 54 a 60 da Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017).

Cuida-se de o estrangeiro reingressar em nosso território jurídico, alcançado pela nossa soberania, não abrangendo o chamado território por extensão (CP, art. 5º, § 1º). Assim, não constitui delito penetrar o estrangeiro expulso em navios ou aeronaves brasileiros de natureza militar ou em navios particulares em alto-mar.

O delito consiste no reingresso, de maneira que não o comete o

estrangeiro que, expulso, nega-se a deixar nosso território.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no instante em que o estrangeiro, expulso de nosso território, nele penetra.

A tentativa é admissível.

6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de penetrar em nosso território. Como o dolo deve abranger os elementos do tipo, é necessário que o sujeito tenha conhecimento da expulsão.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão, após seu cumprimento (parte final do dispositivo sancionador). Por se cuidar de delito com pena mínima não superior a um ano, afigura-se cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Denúncia caluniosa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Denúncia caluniosa, calúnia, comunicação falsa de crime ou contravenção e autoacusação falsa. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Tipos qualificado e privilegiado. 8. Formas especiais de denúncia caluniosa. 9. Penas. 10. Ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O delito consiste em “dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente” (CP, art. 339, com redação da Lei n. 10.028, de 19-10-2000).

O bem jurídico é a administração da justiça, no que concerne ao interesse que tem o Estado em que não seja inutilmente acionada em face de comunicação falsa da prática de crime. Há uma objetividade jurídica mediata, consistente na honra da pessoa atingida.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, salvo o agente público, conforme o art. 30 da Lei n. 13.869/2019. Assim, se o particular comparece à Delegacia de Polícia narrando ao delegado um crime cometido por terceiro, sabendo-o inocente, incorre no art. 339 do CP, mas se a própria autoridade policial, de ofício, instaura o inquérito para investigar quem sabe ser inocente, pratica abuso de autoridade, em face do princípio da especialidade.

Na hipótese de o crime imputado ser de ação penal privada ou pública

condicionada à representação, somente pode ser sujeito ativo quem tem legitimidade para exercer o direito de queixa ou de representação. Não porque a queixa e a representação constituam elementos do tipo ou condições objetivas de punibilidade, mas sim porque naquelas hipóteses não pode haver investigação policial ou processo penal sem a representação ou a queixa. De modo que, sem essas condições de procedibilidade, não pode a autoridade dar início às investigações policiais, nem haver ação penal. Assim, é impossível qualquer sujeito “dar causa a instauração de investigação policial ou de processo judicial”, como reclama o tipo.

Há dois sujeitos passivos:

1ª) o Estado; e

2ª) a pessoa atingida em sua honra pela denúncia caluniosa.

Tratando-se de denúncia por ato de improbidade administrativa contra “agente do poder público ou terceiro beneficiário”, tendo conhecimento o autor da representação de que se cuida de pessoa inocente, aplica-se o art. 19 da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992. A Lei n. 10.028/2000, que deu nova redação ao art. 339 do CP, não revogou o art. 19 da Lei n. 8.429/92. As duas disposições podem coexistir pacificamente de acordo com duas regras: 1ª) quando o denunciante atribui falsamente à vítima ato de improbidade que constitui infração administrativa, mas não configura crime, aplica-se o art. 19 da Lei n. 8.429/92. Ex.: ato praticado com desvio de finalidade (art. 11, I, da Lei n. 8.429/92); 2ª) quando a denúncia incide sobre ato que, além de atentar contra a probidade administrativa, constitui também delito, aplica-se o art. 339 do CP. Ex.: art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, em que a fraude em arrematação judicial, além de configurar ato de improbidade administrativa, constitui também crime (CP, art. 358). De ver-se que o fato da denúncia é atípico quando seu objeto configura somente ato meramente infracional, não possuindo natureza ímproba nem

criminosa. Ex.: promotor de justiça que trata testemunha sem urbanidade (art. 43, IX, da LONMP – Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993).

3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, CALÚNIA, COMUNICAÇÃO FALSA CRIME OU CONTRAVENÇÃO E AUTOACUSAÇÃO FALSA

A denúncia caluniosa não se confunde com a calúnia (CP, art. 138). Nesta, o sujeito somente atribui, falsamente, ao sujeito passivo, a prática de um fato descrito como delito. Na denúncia caluniosa ele vai além: não somente atribui à vítima, falsamente, a prática de um delito, como leva o fato ao conhecimento da autoridade, causando a instauração de inquérito policial ou de ação penal contra ela.

Difere também da “comunicação falsa de crime ou de contravenção” (CP, art. 340). A distinção entre as figuras típicas reside em que na denúncia caluniosa há imputação a pessoa determinada ou determinável, ao passo que na comunicação falsa de crime não há acusação contra alguém. Isso significa que a diferença entre os dois crimes está na presença da “calúnia”, que integra o primeiro e não faz parte do segundo. Assim, se o sujeito denuncia à autoridade a prática de um crime que sabe não ter ocorrido, imputando a alguém a autoria, temos denúncia caluniosa. Se, entretanto, o sujeito noticia à autoridade o cometimento imaginoso de um delito, deixando de lhe apontar a autoria, há falsa comunicação de crime.

Na doutrina e legislações estrangeiras em que as duas figuras são descritas e estudadas, os autores apontam a mesma distinção. São exemplos os Códigos Penais da Itália e da Suíça.

O disposto no art. 339 do CP brasileiro corresponde ao art. 368 do estatuto peninsular, enquanto nosso art. 340 equivale ao art. 367. Neste, sob o título “Simulazione di reato” (nossa “falsa comunicação de crime”), o legislador descreve a denúncia de crime imaginário, não se referindo o autor a pessoa determinada, mas suposta. No art. 368, com o título “Callunia”, verifica-se o contrário, uma vez que o autor atribui a prática do

delito a pessoa determinada.

No Código Penal suíço, a denúncia caluniosa se encontra descrita no art. 303; a simulação de crime, no art. 304.

Por fim, distingue-se a denúncia caluniosa da autoacusação falsa. Nesta, o denunciado é o próprio denunciante; naquela, é terceira pessoa.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A materialidade do delito consiste em o sujeito dar causa a instauração de investigação policial, processo judicial etc. contra alguém, imputando-lhe a prática de crime.

Dar causa significa provocar, originar. A causação pode ser:

- a) direta; ou
- b) indireta.

No primeiro caso, o sujeito, diretamente, apresenta a notícia criminal à autoridade policial ou judiciária, verbalmente ou por escrito; no segundo, ele dá causa à iniciativa da autoridade por qualquer outro meio, como carta e telefonema anônimos, gestos, rádio, telegrama, televisão, colocação de droga ou objeto furtado na bolsa de alguém, recado à autoridade etc.

A ação da autoridade pública deve ter sido causada por conduta espontânea do sujeito, i.e., a iniciativa de movimentar a autoridade deve ser ato próprio do agente, não de terceiro. Assim, não há denúncia caluniosa no caso de um réu ou uma testemunha acusar alguém da prática de infração penal durante o interrogatório ou o depoimento. Nessas hipóteses, subsiste a responsabilidade do réu a título de calúnia; da testemunha, a título de falso testemunho.

A imputação diz respeito à prática de um crime (caput da disposição) ou contravenção, caso em que a pena é reduzida (§ 2º).

Havendo emprego de nome suposto ou de anonimato, a pena é agravada

(§ 1º).

A imputação deve visar a uma pessoa determinada. A denúncia caluniosa, ensina a doutrina, pode ser realizada por duas formas: a) direta, quando se aponta o agente por seu nome ou atributos pessoais que permitam fácil identificação; b) indireta, quando são fornecidos elementos que permitem seja o indivíduo identificado.

A imputação pode ser:

1º) de fato infracional verdadeiro, dirigida a quem não o realizou ou dele participou;

2º) de fato que não aconteceu.

A imputação de fato de gravidade objetiva mais grave constitui delito. Assim, existe crime nas hipóteses de o sujeito atribuir à vítima a prática de um homicídio, quando ocorreu lesão corporal; roubo, quando praticou furto; estupro, a quem cometeu constrangimento ilegal etc.

O fato imputado deve ser determinado e típico. Além disso, precisa ser antijurídico, não afastada a ilicitude por qualquer das causas do art. 23 do CP (legítima defesa, estado de necessidade etc.). Mais ainda: é necessário que não esteja extinta a punibilidade e não incida uma escusa absolutória (ex.: furto praticado pelo filho contra o pai). De modo que não subsiste a denúncia caluniosa quando o fato não é típico ou incide uma causa excludente da ilicitude, ou extintiva da punibilidade, ou uma escusa absolutória. Isso porque, nessas hipóteses, a autoridade não pode agir, estando impedida de iniciar a investigação policial ou o processo penal.

A ação do sujeito deve causar “investigação policial, processo judicial” etc. contra o sujeito passivo.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de denunciar caluniosamente a vítima, tendo conhecimento de que está dando causa a investigação

policial, processo penal, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa.

Exige-se um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão “de que o sabe inocente”.

O dolo, nesse delito, está na vontade de dar causa a investigação policial, processo penal etc. contra o sujeito passivo por intermédio da denúncia falsa. A expressão “de que o sabe inocente” não constitui dolo, mas elemento subjetivo do tipo.

Não há delito quando o sujeito apenas tem dúvida a respeito da existência do crime ou de sua autoria. A figura típica requer que tenha plena certeza da inocência da vítima.

O dolo superveniente não integra o tipo. Dessa maneira, inexistente crime quando o agente, no momento da denúncia, tem certeza da ocorrência do delito, vindo a saber, mais tarde, que este realmente não ocorreu.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a instauração da investigação policial, o processo penal etc. Quanto à autoridade policial, não se exige a instauração do inquérito, bastando, para o delito alcançar o momento consumativo, que dê início à coleta de elementos no sentido de apurar o objeto da denúncia (buscas, oitiva de testemunhas etc.).

Admite-se a tentativa. Ex.: a autoridade policial, diante da narrativa do sujeito, não leva a sério a falsa denúncia.

7. TIPOS QUALIFICADO E PRIVILEGIADO

Se o sujeito se serve de anonimato ou de nome suposto, o crime é qualificado (art. 339, § 1º).

Se a imputação falsa diz respeito a fato contravencional, o crime é privilegiado (§ 2º).

8. FORMAS ESPECIAIS DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

A Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, que disciplina a investigação, os meios de prova, o procedimento, a definição de organização criminosa e infrações correlatas, prevê modalidade especial de denúncia caluniosa em seu art. 19, assim redigido: “Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas” (pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa).

A disposição incrimina o delator da organização criminosa que, em busca dos benefícios decorrentes da colaboração premiada (elemento subjetivo específico), dentre os quais o perdão judicial (art. 4º da Lei n. 12.850/2013), aponta mentirosamente o envolvimento de alguém que sabe ser inocente em infração penal ou traz dados falsos a respeito da estrutura da organização.

O Código Eleitoral, em virtude de modificação ocorrida em 4 de junho de 2019 (Lei n. 13.834/2019), passou também a conter uma figura específica de denúncia caluniosa, tipificada em seu art. 326-A, consistente em dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral.

Duas elementares diferenciam a denúncia caluniosa comum (CP) da eleitoral:

a) o elemento subjetivo do tipo: a denúncia caluniosa eleitoral exige que o fato seja praticado com “finalidade eleitoral”, ou seja, requer tenha o agente objetivado interferir na regularidade ou competitividade de algum pleito a cargo público eletivo, prejudicando ou favorecendo determinado candidato.

b) a inclusão no tipo de imputações falsas de ato infracional: a figura

prevista no Código Eleitoral, diferentemente do CP, também considera denúncia caluniosa o ato de dar causa à investigação etc. contra alguém, atribuindo-lhe o cometimento de ato infracional. Imagine-se, por exemplo, um candidato a vereador, com dezoito anos de idade, a quem se impute um ato infracional grave, equiparado a estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), por ele supostamente cometido quando possuía 17 anos. Nesse caso, fosse o fato verdadeiro, o agente responderia pelo ilícito cometido enquanto adolescente, pois o ECA se aplica a menores de 18 anos até que os agentes, inimputáveis ao tempo do fato, completem 21 anos de idade. (Nesse sentido, a Súmula 605 do STJ: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.)

O fato possui pena similar à do Código Penal (reclusão, de dois a oito anos, e multa).

Contém, ainda, figuras majorada (§ 1º) e minorada (§ 2º), que reproduzem *ipsis literis* o texto do art. 339, §§ 1º e 2º: “A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto” e “A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção”.

Há, por fim, a figura prevista no art. 30 da Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade (cuja análise se encontra nos comentários ao art. 350 do CP, nesta obra). O fato, apenado com detenção, de 1 a 4 anos, e multa, consiste em dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente.

9. PENAS

No tipo simples, é imposta a pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa (art. 339, caput).

No tipo qualificado, a pena é aumentada de um sexto (§ 1º).

A pena é diminuída de metade para o autor do tipo privilegiado (§ 2º). Admite-se, nesse caso, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

10. AÇÃO PENAL

A ação penal é pública incondicionada.

Suponha-se que, diante da falsa denúncia, a autoridade policial dê início ao inquérito policial, ou que o Promotor de Justiça ofereça denúncia contra o sujeito passivo, quando se descobre a falsidade da imputação. Nesse caso, a ação penal pelo crime de denúncia caluniosa fica na dependência do arquivamento do inquérito policial ou da absolvição do imputado na ação penal?

O arquivamento do inquérito policial ou a absolvição do denunciado não constituem questão prejudicial da ação penal por denúncia caluniosa. Diante disso, sob o aspecto técnico, não deveria o processo contra o denunciante ficar aguardando o desfecho do inquérito policial ou da ação penal contra o denunciado. De ver-se, entretanto, que sob o aspecto prático haveria a possibilidade de decisões conflitantes nos procedimentos criminais contra denunciado e denunciante. Diante disso, é preferível que, havendo inquérito policial instaurado contra o denunciado, se aguarde, para o início da ação penal contra o denunciante, o seu arquivamento. Nada impede, nesse caso, que o Promotor de Justiça, recebendo os autos do inquérito policial instaurado contra o denunciado, percebendo a denúncia caluniosa, ofereça denúncia contra o denunciante. Ocorrendo hipótese de ação penal iniciada contra o denunciado, deve-se aguardar, para o procedimento contra o denunciante, a absolvição do denunciado.

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito o fato de “provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado” (CP, art. 340).

É protegida a administração da justiça. Procura o legislador evitar as falsas provocações da autoridade pública em sua missão de coibir as práticas delituosas, com gastos inúteis, perturbação de pessoas honestas, insegurança social etc.

A comunicação falsa de infração penal não se confunde com a denúncia caluniosa. Nesta, o sujeito indica uma pessoa determinada como autora (suposta) da infração; na falsa comunicação, ao contrário, não se aponta um indivíduo determinado como autor do crime ou da contravenção que se alega ter acontecido.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta típica consiste em “provocar a ação da autoridade pública, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção”.

A comunicação pode ser verbal ou por escrito, anônima ou com nome imaginário.

Não basta a simples comunicação. É necessário que a autoridade pública aja, iniciando diligências (ouvindo pessoas, colhendo dados etc.). Não é preciso, entretanto, que seja instaurado inquérito policial.

Refere-se o texto à autoridade pública (judicial, policial ou administrativa).

O crime objeto da comunicação pode ser doloso, culposo ou preterdoloso, tentado ou consumado, simples ou qualificado.

A comunicação precisa ser falsa, i.e., a infração penal (crime ou contravenção) não deve ter ocorrido. Não pode o sujeito ter indicado o autor. Se isso acontece, responde por denúncia caluniosa (art. 339). Subsiste o delito de falsa comunicação ainda quando o sujeito aponta como autor da infração pessoa imaginária.

E se a infração realmente ocorreu?

Não há delito por atipicidade do fato.

É possível que o sujeito aponte um furto, quando realmente ocorreu um roubo. Nesse caso, não há delito. Existe delito, contudo, quando o fato apontado é essencialmente diferente daquele que foi cometido (estupro em vez de furto).

E se houve extinção da punibilidade em relação à infração alegada? Ex.: o sujeito leva ao conhecimento da autoridade policial a notícia (falsa) da prática de um furto. Pelos dados por ele fornecidos, o delegado de polícia verifica que já se extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Nessa hipótese, entende-se que não há delito.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O tipo subjetivo apresenta um primeiro elemento, que é o dolo, vontade livre e consciente de provocar a iniciativa da autoridade pública pela comunicação da prática de um crime ou contravenção. Exige-se um segundo elemento subjetivo, consistente na consciência que tem o agente de que a

infração penal não se verificou. Não basta que tenha dúvida sobre a sua ocorrência, caso em que inexistente delito. É preciso que ele tenha pleno conhecimento de que, realmente, a comunicação é falsa.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a ação da autoridade (audiência de pessoas, coleta de informações, diligências etc.).

A tentativa é admissível.

6. PENAS E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa. Por se cuidar de delito com pena mínima não superior a um ano, afigura-se cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Autoacusação falsa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito o fato de o sujeito “acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente, ou praticado por outrem” (CP, art. 341).

O objeto jurídico é a administração da justiça, protegendo-se a normal atividade da máquina judiciária.

Não se confunde com a denúncia caluniosa. Nesta, o sujeito acusa um terceiro da prática do delito. No crime em questão, ao contrário, o agente acusa a si próprio. Na prática, em regra, a autoacusação falsa é realizada com o fim de encobrimento de outro crime. Não se exclui, porém, seja o fato cometido por um doente mental.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa.

O delito pode ser cometido pelo autor, coautor ou partícipe do crime anterior (crime objeto da autoacusação falsa)?

Cremos que não.

Pressuposto da autoacusação falsa é a circunstância de o sujeito não se ter apresentado como autor, coautor ou partícipe do crime antecedente. Em outros termos, o delito exige que o sujeito ativo não tenha sido autor, coautor ou participado do crime cuja autoria atribui a si próprio.

Na Itália o crime se denomina autocallunia (CP peninsular, art. 369). Entre nós, ensinava Heleno Cláudio Fragoso que, para a existência da autoacusação falsa, “deve ficar afastada qualquer possibilidade de

coautoria, ou seja, qualquer participação delituosa no fato”¹⁸ criminoso antecedente.

A solução é clara. Se o delito do art. 341 do CP contém a elementar “crime praticado por outrem”, o fato posterior é atípico quando “o delito não foi praticado por outrem”, mas pelo autoacusador. O crime se denomina autoacusação falsa. Se não é falsa, mas verdadeira, impõe-se a aplicação do disposto no art. 1º do CP, que consagra a teoria da tipicidade: o fato é absolutamente atípico.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em o sujeito atribuir-se a prática de um crime inexistente ou que foi cometido por terceiro (sem a participação do autoacusador).

O objeto da autoacusação deve ser crime. Se for contravenção, o fato será atípico. Pouco importa a natureza do delito: doloso, culposos, preterdoloso etc.

A conduta deve ser realizada perante a autoridade (judicial, policial ou administrativa). Se for realizada perante funcionário público que não seja autoridade, não haverá delito. Da mesma forma, não haverá crime quando a autoacusação se fizer perante particular.

Não se exige que o fato seja cometido diante da autoridade, como a princípio leva a atender a expressão “perante”. O conhecimento da prática do delito pode ser levado à autoridade por escrito, verbalmente, por nome suposto etc.

É necessário que se trate de crime inexistente ou cometido por terceiro (a autoacusação deve ser falsa).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de acusar-se da prática de crime que não existiu ou foi cometido por terceiro. Se o sujeito, por erro, acredita que participou de crime cometido por terceiro, incide um relevante erro de tipo, capaz de excluir o dolo (CP, art. 20, caput).

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no instante em que a autoridade toma conhecimento da autoacusação. Crime formal ou de consumação antecipada, torna-se irrelevante para a consumação eventual efeito da conduta (instauração de inquérito policial etc.).

Quanto à tentativa, é admissível na forma realizada por escrito (crime plurissubsistente); na autoacusação verbal, a tentativa é impossível (crime unissubsistente).

A retratação não tem efeito de extinguir a punibilidade ou o delito, podendo funcionar como circunstância atenuante genérica.

6. PENA E AÇÃO PENAL

É de detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), razão pela qual se insere na competência material dos Juizados Especiais Criminais, admitindo, em tese, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Se o sujeito, além da autoacusação, atribuir participação no delito a terceiro, haverá concurso formal com a denúncia caluniosa.

Há isenção de pena se o agente cometer o fato para beneficiar o cônjuge ou parente próximo?

Não, uma vez que nenhum privilégio está legalmente previsto.

A ação penal é pública incondicionada.

Falso testemunho ou falsa perícia

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Concurso de pessoas. 4. Qualificação doutrinária. 5. Elementos objetivos do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Elemento subjetivo do tipo. 8. Figuras típicas agravadas. 9. Retratação. 10. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito o fato de “fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral” (CP, art. 342, caput).

O objeto da tutela penal é a administração da justiça, no que diz respeito ao prestígio e seriedade da coleta de provas.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido pelas pessoas taxativamente indicadas no tipo: testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete.

Qualquer pessoa que, por observação própria ou por referência de terceiro, toma conhecimento de prática delituosa não pode isentar-se do dever de depor perante a autoridade policial ou o Juiz (CPP, art. 206, a contrario sensu). Tão relevante é o interesse estatal no exercício desse dever que a lei determina que, se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o Juiz poderá requisitar à autoridade policial sua apresentação ou impor seja conduzida por oficial de justiça (“debaixo de vara”), que poderá solicitar o auxílio da força pública (art. 218 do estatuto citado). Além disso, estará sujeita a multa (CPP, art. 453), sem prejuízo de processo por crime de desobediência (CPP, art. 219, e

CP, art. 330).

É ainda dever da testemunha dizer a verdade a respeito do que souber e lhe for perguntado (CPP, art. 203). Assim, a testemunha que se cala, sem motivo legal, comete falso testemunho (CP, art. 342). Tão grande é a preocupação do legislador com a subsistência da prova testemunhal que impôs o dever de a testemunha comunicar ao Juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às sanções do não comparecimento (CPP, art. 224).

Esses deveres são impostos à testemunha a partir da ciência do fato. Significa que a pessoa, a partir do momento em que presencia ou toma conhecimento por qualquer forma da prática delituosa, torna-se sujeito passivo de certas obrigações impostas pela lei, sujeitando-se à imposição de severas sanções em caso de descumprimento. A lei só abre exceção a raros casos, especificamente previstos, como os da isenção por parentesco, afinidade, relação de casamento etc. (CPP, art. 206). E há os casos legais de proibição de depor como testemunha em razão de função, ministério, ofício ou profissão. São pessoas que, por motivo do exercício desses misteres, devem guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada (CPP, art. 207).

Pode também ser sujeito ativo do crime o perito (pessoa que, com capacidade técnica, é chamada a auxiliar o Juízo na coleta de provas), o contador, o tradutor ou o intérprete.

É necessário que essas pessoas, no momento do fato, se revistam da qualidade jurídica exigida pela figura típica.

Quanto à testemunha, o compromisso previsto no art. 208 do CPP não é elemento do crime, podendo cometê-lo a numerária ou simplesmente informante. Há, a respeito, duas orientações:

1ª) Não comete crime a testemunha não compromissada.

Nos termos do que dispõem os arts. 206 e 208 do CPP, não prestam

compromisso como testemunha o ascendente ou o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que separado judicialmente, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Diante dos termos do art. 203 do mesmo estatuto, segundo o qual a “testemunha fará, sob promessa de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado”, essa corrente jurisprudencial entende que a testemunha informante, não tendo a obrigação de dizer a verdade, uma vez que não é compromissada, não pode responder por falso testemunho. “Tratando-se de testemunha com fortes laços de afetividade (esposa) com o réu, não se pode exigir-lhe diga a verdade, justamente em detrimento da pessoa pela qual nutre afeição, pondo em risco até a mesmo a própria unidade familiar” (STJ, HC n. 92.836, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe de 17-5-2010). Na doutrina, era a opinião de Magalhães Drummond¹⁹.

2ª) A testemunha informante (não compromissada) pode cometer crime de falso testemunho.

Para essa corrente, que adotamos, o crime de falso testemunho surge da desobediência ao dever de afirmar a verdade, “que não deriva do compromisso” (RT, 392:116). No CP de 1890, o art. 261, que definia esse delito, continha a elementar “sob juramento ou afirmação” (“Asseverar em juízo como testemunha sob juramento ou afirmação...”). Assim, a tipicidade do fato ficava condicionada ao juramento. O CP vigente, porém, não repetiu essa elementar. Daí entender-se que o juramento é irrelevante na tipificação da conduta.

Sujeito passivo imediato é o Estado; mediato, a pessoa que vem a ser prejudicada pela falsidade.

3. CONCURSO DE PESSOAS

Durante muitos anos nossos tribunais discutiram se caberia concurso de pessoas no crime de falso testemunho. Essa questão, atualmente, encontra-se pacificada, no sentido de reconhecer a possibilidade de participação,

embora não se admita a coautoria ou a autoria mediata.

Nesse sentido, “O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, apesar do crime de falso testemunho ser de mão própria, pode haver a participação do advogado no seu cometimento” (HC n. 30.858, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6ª Turma, DJ de 1º-8-2006, p. 549).

Sobre a impossibilidade de autoria mediata ou coautoria, convém uma breve explicação:

a) a autoria mediata é aquela que se dá quando alguém, detendo o domínio da vontade, se utiliza de terceiro como instrumento de sua vontade: a testemunha mendaz não pode servir-se de outrem para a realização do delito instrumentalizando-o;

b) a coautoria propriamente dita: a testemunha não pode prestar depoimento mendaz em parceria com terceiro, seja qualificado (testemunha) ou não qualificado (estranho).

O que subsiste, conforme já adiantamos, é a possibilidade de participação nos delitos de mão própria ou de atuação pessoal, como é o caso do falso testemunho.

Em face do CP brasileiro, em sua redação original (ou seja, antes das Leis n. 10.268/2001 e 12.850/2013), o falso testemunho não admitia participação. Assim, embora parecesse estranho e injusto, não havia crime no fato de alguém induzir ou instigar testemunha a cometer o falso. Só a testemunha respondia pelo delito do art. 342 do CP; o terceiro ficava impune.

Isso se dava porque o legislador, no tema do falso testemunho, criou uma exceção pluralística ao princípio unitário do concurso de pessoas. Quando se trata de “suborno de testemunha”, esta responde pelo crime do art. 342; aquele que dá, oferece ou promete dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, a fim de que ela cometa o falso, sofre as penas do crime do art. 343. As penas para as duas disposições eram as mesmas para os tipos

simples antes do advento das Leis n. 10.268/2001 e 12.850/2013.

Agora, porém, os dois dispositivos cominam penas diferentes, sancionando mais severamente o subornador da testemunha, motivo por que a solução, aplicável a regra do art. 29 do CP, é a seguinte: a testemunha sofre a pena agravada do art. 342; o subornador responde pelo delito do art. 343, com pena maior; por fim, o terceiro, na condição de partícipe, adequa sua conduta à figura simples ou qualificada do art. 342.

Se o legislador apanhasse, como antes, certas formas de participação do art. 342 e as mantivesse em núcleos típicos de figura penal autônoma (art. 343) e, não obstante sua maior gravidade objetiva pela presença do suborno, lhes cominasse as mesmas penas da testemunha faltosa, se entenderia que considerou impuníveis os outros tipos mais brandos de participação (induzimento e instigação, sem suborno). Não é mais o caso, contudo.

4. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

O falso testemunho é delito:

- a) instantâneo;
- b) formal;
- c) próprio;
- d) de mão própria.

5. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

São três os verbos típicos:

- 1ª) fazer afirmação falsa;
- 2ª) negar a verdade; e
- 3ª) calar a verdade.

No primeiro caso, a testemunha afirma uma inverdade a respeito de um

fato. Ex.: diz que o réu agiu em legítima defesa (falsidade positiva).

Na segunda hipótese (falsidade negativa), o sujeito nega um fato real. Ex.: nega que o indiciado tenha reagido a uma agressão injusta, quando, na verdade, agiu em legítima defesa.

Em terceiro lugar, em que há a chamada “reticência”, a testemunha esconde o que é de seu conhecimento ou se recusa a responder.

A testemunha depõe sobre fatos. Para que haja o falso, é necessário que verse sobre fato juridicamente relevante ao deslinde do processo e que possa, de algum modo, influir na decisão judicial. Não há crime quando o depoimento questionado incide sobre dados secundários e sem importância do fato objeto do processo, sem potencialidade lesiva. Assim, não versando a falsidade sobre fato, inexistente o delito. Por isso, entendemos que não comete falso a testemunha que mente a respeito de sua qualificação, como, por exemplo, ocultando parentesco com uma das partes (podendo subsistir o crime do art. 307 do CP, conforme o caso).

Existem duas teorias a respeito da falsidade:

1ª) objetiva;

2ª) subjetiva.

Para a teoria objetiva, há falso testemunho quando o relatado não corresponde ao fato real.

De acordo com a teoria subjetiva, a falsidade reside na contradição entre o que a testemunha presenciou e conhece e aquilo que relatou.

É dominante a teoria subjetiva: o falso testemunho se revela na diferença entre o que o sujeito diz (nega ou cala) e o que sabe. Assim, há delito ainda quando a testemunha afirma falsamente que viu um fato que realmente aconteceu (o fato é real, mas a testemunha não o viu).

A conduta deve ser realizada em processo judicial (criminal, civil ou trabalhista), em inquérito policial, em processo administrativo, juízo arbitral

ou inquérito parlamentar (Lei n. 1.579/52).

Cremos que inexistente delito quando a testemunha, por exemplo, nega a verdade para não se incriminar. Nesse caso, aplica-se a teoria da inexigibilidade de conduta diversa.

E se o processo vem a ser anulado?

Desaparece o delito, uma vez excluída a possibilidade de dano.

É irrelevante, para a existência do crime, que o falso testemunho tenha influído na decisão da causa. O crime de falso testemunho é de natureza formal, notando-se que o tipo descreve a conduta e o resultado, não exigindo a produção deste. Em face disso, a figura típica consumada não requer a efetiva lesão do valor tutelado (normal funcionamento da administração da justiça), sendo suficiente que o comportamento seja apto à sua produção. Assim, não integra o crime a exigência de o falso testemunho haver influído na decisão da causa, sendo suficiente que tenha incidido sobre “fato juridicamente relevante” (CP, art. 342, caput). Suponha-se que o magistrado decida a ação de forma contrária ao conteúdo do depoimento falso. Essa não interferência do falso no decisório não influi na existência do crime. É a orientação de nossa jurisprudência.

E se houve extinção da punibilidade em relação ao delito anterior? Subsiste o falso testemunho?

Como ficou consignado, o falso testemunho é delito formal, consumando-se com o depoimento falso, independentemente da produção do efetivo resultado material visado pelo sujeito. Este, falseando a respeito de fato juridicamente relevante, pretende uma decisão injusta, com dano à administração da justiça. Esse dano, entretanto, para que exista o delito, não precisa ser causado. Por isso, diz-se que basta a potencialidade do dano. Daí entender-se que o delito de falso testemunho independe do exercício da punibilidade no tocante ao processo-crime em que foi cometido. Por consequência, a extinção da punibilidade, pela prescrição da

pretensão punitiva, atingindo a ação penal em que foi cometido o falso, não exclui o crime. A não ser assim, a morte do agente durante o processo em que foi cometido o falso excluiria o próprio falso testemunho, o que é insustentável.

O STF, em mais de uma oportunidade, pronunciou-se no sentido de que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não produz efeito em relação ao falso testemunho, subsistindo o crime (RTJ, 95:573 e RT, 546:431).

O falso testemunho não é um crime condicionado, isto é, que subordina a sua punibilidade a uma condição exterior e posterior à consumação (condição objetiva de punibilidade). Em face disso, a concretização da pretensão punitiva no processo em que foi cometido não condiciona a punibilidade do falso. Além disso, não é um “crime acessório”, que depende de outro, como a receptação e o favorecimento. O falso existe por si só.

E se o sujeito, em fases sucessivas, depõe falsamente?

Há um só delito. Ex.: a testemunha afirma a mesma mentira na fase do inquérito policial, em Juízo e no Júri.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

O falso testemunho se consuma com o encerramento do depoimento. Tecnicamente, o fato está consumado no instante em que a testemunha mente. Entretanto, ela pode retificar o que declarou até o encerramento do depoimento. Por isso, entende-se que a consumação ocorre no segundo momento.

A tentativa, se tanto difícil de ocorrer, é admissível. Ex.: o depoimento, por qualquer circunstância, não se encerra.

Consuma-se a falsa perícia com a entrega do laudo à autoridade. É admissível a tentativa, pelo menos doutrinariamente. Ex.: o laudo não chega às mãos da autoridade por circunstâncias alheias à vontade do

perito. Tratando-se de contador, o delito atinge a consumação com a entrega dos cálculos.

E se o falso é cometido no Juízo deprecado?

Nos termos do que dispõe o art. 70, caput, do CPP, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”. O delito de falso testemunho atinge a consumação quando as declarações, reduzidas a termo, são assinadas pela testemunha, Juiz e partes (CPP, art. 216; e também Magalhães Noronha²⁰). Logo, quando cometido no Juízo deprecado, este é o competente. Na jurisprudência, há precedente do STJ (CC n. 30.309/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, 3ª Seção, julgado em 28-11-2001).

7. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de falsear a verdade ou de negá-la.

8. FIGURAS TÍPICAS AGRAVADAS

De acordo com o § 1º do art. 342, com redação da Lei n. 10.268, de 28 de agosto de 2001, “as penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta”. A redação anterior apresentava uma qualificadora no § 1º (falso testemunho destinado a produzir prova em processo penal), cominando pena de reclusão, de dois a seis anos, e multa, e uma causa de aumento de pena no § 2º (crime cometido mediante suborno), com acréscimo de um terço. Na lei, o legislador reuniu essas duas circunstâncias em uma só figura típica (§ 1º), configurando causas de aumento de pena (de um sexto a um terço), e acrescentou mais uma. O novo § 1º contém três circunstâncias especiais: 1ª) suborno; 2ª) falso testemunho destinado a produzir efeito em processo penal; 3ª) falso testemunho destinado a produzir efeito em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta (nova

circunstância).

Delito formal, não é necessário que o depoimento falso realmente venha a produzir efeito. O fato é praticado “com o fim de produzir” esse efeito. Basta, pois, a potencialidade do dano.

O tipo, além do dolo, exige mais um elemento subjetivo, contido na expressão “com o fim de”.

Quanto ao suborno, trata-se da corrupção de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, que recebe dinheiro ou qualquer outra utilidade para a prática do fato delituoso. Há a agravação da pena mesmo quando existe mera promessa de recompensa. Exige-se que a falsidade tenha sido efetivamente cometida.

Cuidando-se de perito (etc.) oficial, o crime é o descrito no art. 317 do CP.

No mais, aplicam-se os princípios da forma típica singular.

9. RETRATAÇÃO

Nos termos do § 2º do art. 342, “o fato deixa de ser punível, se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade”.

Apreciamos essa matéria no estudo das causas extintivas da punibilidade, a que remetemos o leitor.

Não se requer que a retratação seja espontânea, bastando a voluntariedade.

Precisa ser completa. Havendo dubiedade, incerteza etc., não aproveita ao agente.

Deve ser feita perante a autoridade policial, judicial ou administrativa. A retratação extrajudicial só tem valor quando trazida para os autos.

A expressão “sentença” indica o ato do Juiz que, pela primeira vez no

processo, aprecia o fato cometido pelo sujeito em face da prova produzida, não se exigindo trânsito em julgado. A retratação é admissível até o momento em que o Juiz entrega a sentença em mãos do escrivão, publicando-a.

É cabível até a sentença final do procedimento em que foi praticado o falso testemunho (ou a falsa perícia).

A expressão “sentença”, nos processos da competência do Júri, se refere à pronúncia (CPP, art. 413) ou à decisão final? Se a expressão se refere à decisão final, é possível a retratação extintiva da punibilidade após a pronúncia; se se refere à pronúncia, esta é preclusiva da retratação.

Nos crimes da competência do Júri, a retratação só é possível até a sentença de pronúncia. A retratação deve ocorrer “antes do primeiro julgamento ou decisão que dirime a controvérsia”²¹. Deve ser considerada, entretanto, como circunstância atenuante, se feita depois.

Para os que admitem a possibilidade de concurso de agentes no falso testemunho, a retratação é comunicável ou incomunicável?

Como ficou consignado, não admitimos participação nesse delito. Assim, para nós, essa questão não existe. Se admitíssemos o tema, nossa posição seria a da comunicabilidade. O CP não diz que “o agente deixa de ser punível” ou “isento de pena”, como no art. 143, mas sim que “o fato deixa de ser punível”. Dessa forma, se o fato, diante da retratação de um dos concorrentes, “deixa de ser punível”, não pode subsistir “punível” para os demais.

10. PENAS E AÇÃO PENAL

O tipo descrito no caput prevê as penas de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

De ver-se que a sanção foi elevada de um a três anos de reclusão para o patamar atual, por força da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013. Essa

alteração configura novatio legis in pejus e, portanto, não tem alcance retroativo.

O subtipo do § 1º impõe a agravação da pena de um sexto a um terço.

A ação penal é pública incondicionada.

Em que momento pode ser proposta?

Há quatro orientações a respeito:

1ª) Não é possível iniciar a ação penal por crime de falso testemunho enquanto não for proferida sentença no processo em que foi cometido, uma vez que até esse momento é possível a retratação extintiva da punibilidade.

2ª) A ação penal por crime de falso testemunho não está condicionada ao ato processual da sentença no processo em que foi praticado ou a seu trânsito em julgado. Tanto é que o CPP, em seu art. 211, permite ao Juiz, no momento de proferir a sentença no processo em que foi praticado o falso, determinar a extração de peças para o início da ação penal. O falso testemunho atinge a consumação no momento da conduta e não com o ato da sentença ou seu trânsito em julgado. Caso contrário, não teria nenhum efeito a retratação efetuada antes da sentença. Se o crime só passasse a existir a partir da sentença ou de seu trânsito em julgado, a retratação efetuada antes desses dois momentos não teria onde incidir, ausente que estaria o objeto, isto é, a punibilidade.

3ª) Não só pode ter início como pode ser julgada a ação penal, por crime de falso testemunho, antes da sentença proferida no processo em que o crime foi cometido. Isso porque a retratação, causa extintiva da punibilidade, não é pressuposto ou elemento do crime.

4ª) O processo pode ser iniciado de imediato, independentemente do julgamento da ação penal em que o fato foi praticado, mas não pode haver decisão antes de julgada a ação penal originária, a fim de evitar decisões flagrantemente contraditórias. É a posição que acolhemos.

Para nossos tribunais superiores, nada impede que a ação penal pelo falso testemunho seja ajuizada antes de proferida sentença no feito onde o fato foi praticado, sendo necessário, porém, que se aguarde tal decisão para o julgamento da imputação relativa ao art. 342 do CP, até porque a testemunha pode se retratar, extinguindo a punibilidade (STJ, REsp n. 174.486, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 3-12-1998 e RHC n. 61.515, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe de 18-5-2016).

Corrupção ativa de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Figura típica agravada. 6. Qualificação doutrinária. 7. Momento consumativo e tentativa. 8. Concurso de pessoas. 9. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito, definido no art. 343 do CP, o fato de “dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação”.

O bem jurídico é a administração da justiça. Tutela a incriminação a normal atividade do Judiciário em sua missão de distribuir justiça, visando principalmente à coleta das provas, livrando-a da ação de quem, mediante o expediente de dar vantagem a testemunha, perito etc., pretende obter uma decisão favorável aos seus interesses ou aos de terceiro.

2. SUJEITOS DO DELITO

Delito comum, pode ser cometido por qualquer pessoa.

A testemunha subornada (ou o perito) não responde por esse crime, mas sim pelo definido no art. 342.

Sujeito passivo é o Estado. Aparece também como sujeito passivo, de forma mediata, a pessoa eventualmente lesada pela conduta.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O crime, sob o aspecto material, consiste em dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador,

tradutor ou intérprete.

A conduta está expressa pelos verbos típicos “dar” (entregar), “oferecer” (colocação do dinheiro ou vantagem à disposição da testemunha etc.) e “prometer” (obrigar-se a entregar).

O objeto material do delito é o dinheiro ou qualquer outra vantagem material ou moral (caso de interpretação analógica).

O comportamento pode ser realizado por qualquer meio de execução: palavra escrita, oral, gestos etc.

A ação visa ao perito, testemunha, contador, tradutor ou intérprete, pretendendo que falseiem o depoimento, a perícia, os cálculos, a tradução ou a interpretação. Cuidando-se, entretanto, de perito, tradutor ou intérprete oficiais, o crime será o descrito no art. 333 do CP.

É preciso que, no momento do comportamento típico, as pessoas estejam realmente nas condições de testemunha, contador, perito, tradutor ou intérprete. Assim, não há falar em crime no caso, por exemplo, de alguém que possivelmente venha a ser intérprete etc.

Pretende o sujeito que o perito, ou testemunha, venha a “fazer afirmação falsa, calar ou negar a verdade”.

É necessário que haja um processo judicial (penal ou civil) ou administrativo em andamento. Não se exclui o fato cometido durante a tramitação de inquérito policial.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de realizar as condutas descritas no tipo. Exige-se um segundo, contido na intenção de falsear a verdade.

5. FIGURA TÍPICA AGRAVADA

Está definida no art. 343, parágrafo único, com redação da Lei n.

10.268/2001: "As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta".

A expressão "processo penal" abrange a ação penal (na fase policial ou judiciária) e o inquérito policial. É indiferente, para a existência da agravação da pena, ser a prova desejada dirigida à condenação do réu ou à sua absolvição. O interessado pode ser o próprio autor da corrupção ativa ou terceiro. Pode incidir sobre crime ou contravenção.

6. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

Trata-se de crime formal ou de consumação antecipada, não exigindo a concretização do fim do agente.

7. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Delito de natureza formal, consuma-se no momento em que o sujeito dá, oferece ou promete o objeto material, independentemente de qualquer resultado advindo da ação. Por isso, é indiferente, para a existência do delito, que o perito, por exemplo, aceite a vantagem ou que a testemunha falseie a verdade em seu depoimento ou que seja repelido o suborno. Não deixa de subsistir o delito ainda quando o intérprete, por exemplo, após receber o suborno, não falseia a verdade na interpretação.

A retratação do agente é irrelevante, salvo no tocante à fixação concreta da pena.

Quando cometido o delito oralmente, a tentativa é inadmissível (crime unissubsistente). Quando, entretanto, o sujeito emprega o meio escrito, admite-se a forma tentada (delito plurissubsistente).

8. CONCURSO DE PESSOAS

O delito admite a participação de terceiro. Ex.: o sujeito, sem ter o

domínio do fato, induz alguém a dar dinheiro ao perito para o fim visado. Não é possível, entretanto, a participação do próprio perito etc. Neste caso, se, por exemplo, a testemunha recebe dinheiro para falsear a verdade em processo, responde pelo delito do art. 342, § 1º, do CP.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

Para a forma simples são cominadas as penas de reclusão, de três a quatro anos, e multa (art. 343, caput). Para o tipo agravado, o aumento é de um sexto a um terço (parágrafo único).

A ação penal é pública incondicionada.

Coação no curso do processo

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Qualificação doutrinária. 6. Consumação e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O legislador, no art. 344 do CP, com o nome de “coação no curso do processo”, pune o fato de “usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em júízo arbitral”.

A lei protege a administração da justiça, impondo sanção a quem, mediante violência física ou moral, vem a coagir, para a satisfação de um interesse particular ou de terceiro, a autoridade pública, a parte ou outra pessoa que intervém nas lides judiciais e administrativas. Visa o legislador a tutelar o normal andamento da atividade jurisdicional.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, a coação no curso do processo pode ser cometida por qualquer pessoa.

Sujeito passivo principal é o Estado, titular da administração da justiça. Secundariamente, surge como sujeito passivo material a pessoa sobre a qual recai a conduta: autoridade, parte ou qualquer pessoa que intervém na atividade da máquina judiciária.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O crime, sob o aspecto objetivo, consiste em usar de violência ou grave ameaça contra autoridade, parte ou qualquer pessoa que funciona ou é

chamada a intervir em processo judicial, administrativo ou em Juízo arbitral.

Crime de forma vinculada, somente admite como meios de execução a violência e a grave ameaça.

Trata-se de violência física, exercida contra pessoa. Não basta o emprego de ameaça. É necessário que seja grave, i.e., capaz de incutir temor a um homem normal. Esse, o mal prenunciado, pode ser justo ou injusto.

A conduta deve ser realizada contra autoridade que funciona no processo (Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Desembargador, Procurador de Justiça, Defensor Público, Delegado de Polícia etc.), parte (autor, réu etc.) ou outra pessoa que intervém ou é chamada a intervir (escrivão, intérprete, jurado, perito etc.).

O processo pode ser judicial (civil ou criminal), administrativo ou em curso em juízo arbitral. Não se exclui o inquérito policial.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de exercer violência física ou moral contra as pessoas mencionadas. O tipo exige um segundo elemento subjetivo, que consiste em realizar a conduta “com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio”.

Não importa a natureza do interesse que o sujeito quer favorecer. Desde que tenha relação com o objeto do processo, pode ser moral ou material.

5. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

A coação no curso do processo é delito formal e de forma vinculada.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com o emprego da violência física ou grave ameaça. Crime formal, não se exige que o sujeito realmente consiga favorecer o interesse questionado. Basta que a conduta seja tendente à concretização

desse fim.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Fatos como a coação no curso de processo, que possuem pena mínima não superior a um ano, são compatíveis com a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Havendo violência física, o sujeito responde por dois crimes em concurso material: coação no curso do processo e outro delito (homicídio, lesão corporal leve, grave ou gravíssima). Ocorrendo somente vias de fato, a contravenção fica absorvida pelo delito. É o que determina o preceito sancionador do art. 344: pena tal, além da correspondente à violência.

A ação penal é pública incondicionada.

Exercício arbitrário das próprias razões

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 345 do CP, constitui delito o fato de o sujeito “fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”.

O objeto da tutela penal é a administração da justiça. Almeja-se que alguém que tenha uma pretensão não a satisfaça pessoalmente, incumbindo à justiça a sua realização. Ninguém deve ser juiz e parte a um tempo. No fato penalmente proibido, o agente despreza a justiça e toma para si a tarefa de realizar o seu direito.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser realizado por qualquer pessoa. Tratando-se de funcionário público, entretanto, pode surgir outro delito, como abuso de autoridade.

Sujeitos passivos: o Estado e a pessoa diretamente lesada.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em fazer justiça pelas próprias mãos, realizando uma ação tendente a satisfazer uma pretensão.

Crime de forma livre, admite qualquer meio de execução: direto ou indireto, fraude, violência física, violência moral (grave ameaça), subtração etc.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de fazer justiça pelas próprias mãos.

O tipo reclama um segundo elemento subjetivo, contido na expressão “para satisfazer pretensão, embora legítima”. De modo que se exige que o sujeito realize a conduta para a concretização de um fim determinado: satisfazer a sua pretensão.

A pretensão deve referir-se a um direito que o sujeito realmente tem ou supõe possuir. Assim, pode ocorrer hipótese de:

- a) pretensão legítima; ou
- b) pretensão ilegítima.

É irrelevante que a pretensão seja legítima ou ilegítima. Neste caso, porém, exige-se que o sujeito a suponha legítima. Como a lei fala em pretensão “embora legítima”, de admitir-se a ilegítima, necessitando, contudo, que o agente, por razões convincentes, a suponha lícita.

A pretensão pode incidir sobre qualquer direito: real (propriedade, posse etc.), pessoal (contratos) ou de família (guarda de filhos, por exemplo).

É necessário que a pretensão, em sua essência, possa ser satisfeita perante o Judiciário. Assim, não há exercício arbitrário das próprias razões nas hipóteses em que o sujeito não poderia levar sua pretensão ao conhecimento da autoridade judiciária, como nos casos de dívida prescrita, prego carnal etc.

A pretensão pode ser do próprio agente ou de terceiro, nos casos em que age como mandatário etc.

E se o sujeito tem plena consciência da ilegitimidade de sua pretensão?

Não comete esse delito, podendo responder por outro, de acordo com o meio executório empregado (furto, lesão corporal, violação de domicílio, ameaça etc.). Ocorre que o elemento subjetivo é endereçado à satisfação

da pretensão legítima ou supostamente tal ("embora legítima"), de maneira que inexistente delito, por atipicidade do fato, quando o agente tem certeza de que a pretensão é ilegítima.

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Está contido na expressão "salvo quando a lei o permite". Não há delito, por atipicidade do fato, quando a conduta do sujeito está autorizada pela lei, i.e., quando a lei admite a justiça particular. Ex.: direito de retenção, desforço imediato (CC, art. 1.210).

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Crime formal, consuma-se no momento típico imediatamente anterior ao resultado visado pelo sujeito, i.e., com a realização da conduta que visa à satisfação da pretensão. Note-se que o comportamento do sujeito, contido nas elementares "fazer justiça pelas próprias mãos", é realizado "para satisfazer pretensão". De modo que não é necessário que o agente consiga a satisfação de sua pretensão. Basta que empregue meios executórios tendentes àquele fim. Não concordamos, pois, com a orientação que exige, para a consumação, a efetiva satisfação da pretensão.

A tentativa é admissível.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. Havendo violência física, o sujeito responde por dois crimes (ou mais) em concurso material: exercício arbitrário das próprias razões e homicídio, lesão corporal (leve, grave ou gravíssima) etc. Ocorrendo somente vias de fato, fica a contravenção absorvida pelo delito.

O crime constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), sendo abrangido pela competência material dos Juizados Especiais Criminais. Comporta, em face disso, transação penal (art. 76 da

Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal pode ser:

- a) pública incondicionada; ou
- b) privada.

Havendo violência física (violência contra a pessoa), o crime é de ação penal pública incondicionada. Ocorrendo outro meio de execução, incluindo a violência moral (grave ameaça) e a violência contra a coisa, a ação penal é privada (CP, art. 345, parágrafo único).

Subtração ou dano de coisa própria em poder de terceiro

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Objeto material. 4. Elemento normativo do tipo. 5. Elementos objetivos do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Elemento subjetivo do tipo. 8. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O CP, no art. 346, pune como crime o fato de “tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção”.

Trata-se de um subtipo, punido com maior gravidade, do crime de exercício arbitrário das próprias razões definido no art. 345.

É protegida a administração da justiça. Visa o legislador, proibindo o fato, a tutelar o prestígio da determinação judicial e o respeito que merece o conteúdo dos acordos de vontade.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido pelo proprietário do objeto material, ressalvada a hipótese de concurso de pessoas, pelo qual o terceiro, ainda que não dono da coisa, responde pela infração.

Sujeito passivo é o Estado. Surge, também, como sujeito passivo a pessoa prejudicada pelo desrespeito à determinação judicial ou convenção.

3. OBJETO MATERIAL

O objeto da conduta é a coisa, móvel ou imóvel.

4. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

A coisa deve ser própria, i.e., de propriedade do sujeito ativo. Se de terceiro, o fato é atípico em face do art. 346 do CP, podendo surgir outro crime, como o furto.

5. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Quatro são os verbos típicos: tirar (subtrair), suprimir (fazer a coisa desaparecer), destruir (subversão do objeto material, sua eliminação) e danificar (estragar a coisa).

É necessário que o objeto material esteja na posse legítima de terceiro por determinação judicial ou convenção (ordem, decisão do Juiz; contrato), seja este credor do agente ou não.

E se o objeto material pertencer ao agente e a terceiro, como na sociedade, ocorrendo subtração?

Neste caso, haverá o delito do art. 156 do CP (furto de coisa comum).

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no momento em que o sujeito suprime, subtrai, destrói ou danifica o objeto material.

Crime material, admite a forma tentada.

7. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de subtrair, suprimir, destruir ou danificar o objeto material, consciente o sujeito de que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção.

O motivo do agente é irrelevante.

Se, por erro que recai sobre o objeto material, o agente supõe que ele é de sua propriedade, ocorre erro de tipo (CP, art. 20, caput). Se o erro do sujeito incide sobre a propriedade, supondo-o seu, há também erro de tipo (recai sobre o elemento normativo). Se o agente, por erro de direito, supõe

que a coisa é de sua propriedade, existe erro de proibição (CP, art. 21).

8. PENA E AÇÃO PENAL

A pena abstratamente imposta é de detenção, de seis meses a dois anos, além da multa. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Fraude processual

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Qualificação doutrinária. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Fraude em processo criminal. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui crime de fraude processual “inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito” (CP, art. 347).

Protege-se a administração da justiça. Pretende a disposição proibir os meios de iludir o Juiz e o perito na coleta e na apreciação da prova, evitando injustiças nos julgamentos.

Denominada “estelionato processual”, na verdade a fraude processual se distingue do estelionato. Neste, a fraude visa a permitir que o sujeito venha a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Na fraude processual, a intenção do agente é enganar o Juiz ou o perito.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (autor, réu, interveniente ou terceiro). Pouco importa que o sujeito tenha interesse direto ou mediato na lide.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em o agente inovar, de forma artificiosa, na tramitação de processo judicial (civil ou criminal) ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa.

Inovar artificialmente significa modificar, alterar, substituir determinada situação referente ao estado de lugar (ex.: abertura de um caminho), de coisa (colocação de uma arma de fogo ao lado de um cadáver) ou de pessoa (alteração do aspecto físico de uma pessoa).

A enumeração dos estados é taxativa, não podendo ser ampliada.

Não é suficiente a simples inovação. Deve ser realizada artificialmente, i.e., com fraude (artifício ou ardil).

É necessário que haja processo judicial em andamento (civil ou administrativo), de modo que inexistente delito se a ação ainda não foi iniciada. Em relação, porém, ao processo penal, hipótese prevista no parágrafo único do art. 347, não é preciso que a ação penal já tenha sido proposta, desde que haja elementos no sentido de que vai ser instaurado o processo. Além disso, cuidando-se de ação penal privada ou pública condicionada, só existe delito quando oferecida a queixa, exercida a representação ou apresentada a requisição ministerial.

A inovação deve ser idônea objetiva e subjetivamente. Sob o aspecto material, deve ser capaz de alterar realmente a feição probatória de lugar, coisa ou pessoa. Assim, não há delito na inovação grosseira, mal realizada, perceptível à vista. Sob o aspecto subjetivo, deve ser capaz de conduzir a erro o Juiz ou o perito.

4. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

É delito formal ou de consumação antecipada.

Trata-se de infração penal subsidiária.

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O fato só é punível a título de dolo, vontade livre e consciente de inovar, fraudulentamente, na pendência de processo judicial ou administrativo, o estado de lugar, coisa ou pessoa. Exige-se um segundo elemento subjetivo

do tipo, contido na expressão “com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito”.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime atinge o momento consumativo com a efetiva inovação, não sendo necessário que o sujeito chegue a enganar o Juiz ou o perito. Crime formal, como se consignou, tem consumação antecipada, não se exigindo que o agente obtenha ou produza o fim ou o resultado visado. Assim, há delito ainda que a fraude não chegue ao conhecimento do Juiz ou do perito.

A tentativa é admissível. Ex.: o sujeito é surpreendido no instante em que está começando a limpar as manchas de sangue do punhal que usou para matar a vítima.

7. FRAUDE EM PROCESSO CRIMINAL

Nos termos do parágrafo único do art. 347, as penas aplicam-se em dobro “se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado”.

Trata-se de uma causa de aumento de pena. Aplicam-se os mesmos princípios do crime simples, com duas diferenças:

1ª) a inovação se destina a produzir prova em processo de natureza penal;

2ª) não é necessário que a ação penal já se tenha iniciado.

Pode o delito com a pena agravada ser cometido pelo acusado, vítima, advogado ou terceiro.

Quanto à ação penal privada ou pública condicionada, de ver-se o que foi dito no n. 3.

8. SUPRESSÃO DE VESTÍGIOS EM LOCAL DE CRIME

O art. 158-C do CPP trata da coleta dos vestígios em local de crime,

estipulando que esta deverá ser realizada preferencialmente por um perito oficial, que os encaminhará, depois de arrecadados, para a central de custódia.

O § 2º da norma dispõe que é proibida a entrada de pessoas em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, tipificando tal retirada como fraude processual.

O dispositivo enuncia que a retirada dos vestígios constitui o crime. E sua alteração, por exemplo, com a introdução de elementos novos no local, de maneira a induzir a erro o expert? Também configura o crime do art. 347 do CP, tendo em vista a perfeita subsunção do fato aos elementos do tipo, pois se cuida de inovação artificiosa no estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito criminais.

9. PENAS E AÇÃO PENAL

Para o tipo simples, a pena é de detenção, de três meses a dois anos, além de multa.

O fato consubstancia infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). Trata-se, portanto, de delito abrangido pela competência *ratione materiae* dos Juizados Especiais Criminais. Admite, em razão da pena máxima, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e, dada a pena mínima não superior a um ano, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Para o tipo qualificado (parágrafo único), as penas devem ser aplicadas em dobro. Nessa situação, caberá apenas o *sursis* processual.

A ação penal é pública incondicionada.

Favorecimento pessoal

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Figuras típicas. 7. Escusa absolutória. 8. Penas e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui favorecimento pessoal o fato de “auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime” (CP, art. 348).

O legislador procurou proteger, por intermédio da incriminação, a administração da justiça criminal. Impõe-se o dever de o sujeito não colocar obstáculos à ação judiciária na luta contra a criminalidade.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, menos o coautor ou partícipe do delito anterior. Assim, se o sujeito, por exemplo, prometeu auxílio ao criminoso antes ou durante a anterior prática delituosa, responde como partícipe desse crime e não por favorecimento pessoal.

Não há autofavorecimento. No concurso de pessoas, se o partícipe prestar auxílio aos outros, beneficiando-se também, não responde por este delito. Somente há crime quando beneficiar apenas os comparsas.

O advogado também pode ser sujeito ativo desse crime, desde que no fato estejam presentes as elementares da definição legal.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em prestar auxílio a autor de crime com o fim de subtraí-lo à ação da autoridade pública.

Crime de forma livre, o auxílio admite qualquer modo de realização (material ou moral), como o emprego de meios para a fuga, engano da autoridade, ocultação do autor do delito etc.

É preciso que o sujeito preste ajuda a autor de crime anterior, não bastando a simples contravenção antecedente. Neste caso, o fato é atípico.

A expressão "autor de crime" é empregada em sentido amplo, abrangendo o autor propriamente dito, os coautores e partícipes.

O auxílio deve ser prestado após a consumação do delito. Se antes dele ou durante sua prática, haverá coautoria ou participação no delito antecedente, e não favorecimento pessoal.

O delito antecedente pode ser doloso, culposo ou preterdoloso, consumado ou tentado.

Não há favorecimento pessoal nos seguintes casos: se, em relação ao fato anterior, ocorreu causa excludente da ilicitude; se incide, no tocante ao fato antecedente, causa excludente da culpabilidade; se houve extinção da punibilidade; se ocorreu escusa absolutória (CP, art. 181). O fundamento reside em que, nestes casos, ou não há crime, ou o sujeito não é culpado, ou inexiste pretensão punitiva ou executória. De modo que não há falar em subtrair o sujeito à ação da autoridade pública.

E se o crime anterior for de ação penal privada ou pública condicionada?

Não se pode falar em favorecimento pessoal enquanto não for oferecida a queixa ou exercida a representação ou apresentada a requisição ministerial.

Autoridade pública é a judiciária, policial ou administrativa.

Não é necessário que no momento do auxílio o criminoso esteja sob perseguição da autoridade pública.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de prestar auxílio ao criminoso,

sabendo o sujeito de que o fará livrar-se da ação da autoridade pública.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o crime no momento em que o beneficiado, em razão do auxílio do sujeito, consegue subtrair-se, ainda que por breves instantes, da ação da autoridade pública.

Se, prestado o auxílio, o beneficiado não se livra da ação da autoridade pública, de reconhecer-se a tentativa.

6. FIGURAS TÍPICAS

Há dois tipos penais:

1^ª) simples: quando ao delito anterior é cominada pena de reclusão (art. 348, caput);

2^ª) privilegiado: quando imposta abstratamente ao crime antecedente pena de detenção (§ 1^º).

7. ESCUSA ABSOLUTÓRIA

O legislador isenta de pena o ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso (§ 2^º).

Trata-se de escusa absolutória (causa pessoal de isenção de pena, já estudada por nós na Parte Geral).

A enumeração legal é taxativa, não podendo ser ampliada. Assim, não abrange os afins nem a relação de adoção. Neste caso, porém, nada impede que seja absolvido o sujeito por inexigibilidade de conduta diversa, excludente da culpabilidade.

8. PENAS E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de um a seis meses, e multa, quando imposta reclusão ao delito anterior (caput do dispositivo); se imposta detenção ao autor do crime anterior, a pena do favorecimento pessoal é de detenção, de

quinze dias a três meses, e multa (§ 1º).

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Favorecimento real

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Distinções. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elementos subjetivos do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui favorecimento real o fato de “prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime” (CP, art. 349).

O objeto da proteção penal é a administração da justiça. Procura o legislador evitar que se preste colaboração a criminoso após a prática do crime no sentido de tornar seguro o proveito obtido, dificultando a ação da justiça.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, com exceção do participante do delito antecedente.

Sujeito passivo é o Estado.

3. DISTINÇÕES

A prestação de auxílio a criminoso deve ser realizada “fora dos casos de coautoria ou de participação”, de acordo com o texto. Assim, o favorecimento real se diversifica das hipóteses de concurso de pessoas e de receptação, como a seguir ficará consignado.

O legislador empregou a expressão “coautoria” no sentido amplo, abrangendo a coautoria propriamente dita e a participação. Para que haja favorecimento real, é necessário que o sujeito que presta o auxílio não tenha sido coautor ou partícipe do delito anterior. Além disso, se prometeu

auxílio antes ou durante a anterior prática delituosa, responde como partícipe do crime antecedente e não por favorecimento real.

Da receptação, o favorecimento real se distingue nos seguintes pontos:

1ª) no favorecimento real, o sujeito age exclusivamente em favor do autor do delito antecedente; na receptação, age em proveito próprio ou de terceiro, que não o autor do crime anterior;

2ª) no favorecimento, o proveito pode ser econômico ou moral; na receptação, o proveito só pode ser econômico;

3ª) no favorecimento real, a ação do sujeito visa ao autor do crime antecedente; na receptação, a conduta incide sobre o objeto material do crime anterior.

Diversificam-se o favorecimento real do pessoal: no real, o sujeito visa a tornar seguro o proveito do delito; no pessoal, a tornar seguro o autor do crime antecedente.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em prestar auxílio a criminoso com o fim de tornar seguro o proveito do crime.

A prestação de auxílio admite qualquer forma de execução: direta ou indireta, material ou moral.

Proveito é toda utilidade material ou não, abrangendo o objeto material do delito, o preço do delito e as coisas obtidas com a prática criminosa (p. ex.: o dinheiro obtido com a venda do objeto material). Ficam excluídos os instrumentos do crime.

O tipo pressupõe a prática de um crime, patrimonial ou não, tentado ou consumado. Não se exclui a hipótese de o sujeito receber o preço pela prática de um delito que ficou na fase da tentativa.

E se era inimputável o autor do crime antecedente?

Cremos que subsiste o favorecimento real. A inimputabilidade apenas exclui a culpabilidade, que não integra o delito. Assim, mesmo que a conduta anterior tenha sido realizada por um inimputável (menor, doente mental etc.), não fica excluído o crime anterior.

E se houve extinção da punibilidade em relação ao crime anterior?

Admite-se o favorecimento real, ressalvando-se as hipóteses da abolitio criminis e da anistia.

E se a infração anterior foi contravenção?

Não há favorecimento real, uma vez que o tipo menciona "crime".

5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O fato só é punível a título de dolo, vontade livre e consciente de prestar colaboração a criminoso. É necessário que o sujeito tenha consciência de que, por intermédio do auxílio, tornará seguro o proveito do crime. Assim, além do dolo, o tipo reclama outro elemento subjetivo: o fim de tornar seguro o proveito do delito.

Se o comportamento do sujeito visa à obtenção de lucro, haverá crime de receptação.

Não há forma culposa.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Crime formal, consuma-se com a prestação do auxílio, independentemente de se tornar seguro o proveito do crime anterior.

A tentativa é admissível.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de um a seis meses, e multa.

O fato consubstancia infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). Trata-se, portanto, de delito abrangido pela competência

ratione materiae dos Juizados Especiais Criminais. Admite, em razão da pena máxima, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e, dada a pena mínima não superior a um ano, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Favorecimento real impróprio

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito e objetividade jurídica. 3. Sujeitos do delito. 4. Elementos do tipo. 5. Elemento subjetivo do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Penas e ação penal.

1. INTRODUÇÃO

A Lei n. 12.012, de 6 de agosto de 2009, introduziu no Código Penal o art. 349-A, sem rubrica própria, como modalidade equiparada ao favorecimento real. Cuida-se de novatio legis incriminadora e abrange comportamentos cometidos após a sua entrada em vigor, que se deu em 7 de agosto de 2009.

A neocriminalização tem como escopo combater o ingresso de aparelhos de comunicação no interior de estabelecimentos prisionais, punindo aqueles que efetuam a entrada do objeto no presídio; pretende-se, desse modo, manter a disciplina e a ordem durante o encarceramento (definitivo ou provisório) e obstar que pessoas privadas de sua liberdade se comuniquem livremente com o mundo exterior.

É preciso lembrar que a Lei n. 11.466, de 2007, acrescentou ao Código Penal o art. 319-A (prevaricação imprópria), definindo como infração penal o ato de o diretor da penitenciária ou agente público omitir-se em seu dever de impedir o ingresso do aparato de telecomunicação. Esse diploma também alterou a LEP, definindo em seu art. 50, VII, como falta grave a conduta do preso condenado à pena privativa de liberdade que: "tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo".

Pode-se dizer, em síntese, que a entrada de um aparelho telefônico, de rádio ou similar, no recinto prisional pode configurar:

a) crime de favorecimento real impróprio (art. 349-A do CP), por parte da

pessoa que diligencia para que o objeto adentre os muros da prisão;

b) crime de prevaricação imprópria (art. 319-A do CP), para o funcionário (diretor ou agente público) que se omite (dolosamente) em seu dever de impedir mencionado ingresso;

c) falta grave (art. 50, VII, da LEP), para o preso que tem em sua posse o aparato.

2. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O delito consiste em: “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional” (art. 349-A do CP).

O bem jurídico tutelado na norma incriminadora é a Administração Pública, notadamente no que diz respeito à Administração Penitenciária.

3. SUJEITOS DO DELITO

Consiste o favorecimento real impróprio em crime comum, que pode ter qualquer pessoa como sujeito ativo, inclusive o próprio preso (desde que este auxilie, moral ou materialmente, a entrada do aparelho no estabelecimento penal).

O funcionário público que colabora com a atitude do sujeito ativo não incorre no art. 349-A, mas comete o art. 319-A; trata-se de exceção pluralística à teoria monista. Isto faz com que o intraneus responda por crime cometido por funcionário contra a Administração, e o extraneus, por delito contra a Administração da Justiça (punidos ambos com pena de detenção, de três meses a um ano).

O sujeito passivo é o Estado, titular do bem juridicamente tutelado.

4. ELEMENTOS DO TIPO

Os comportamentos delitivos que consubstanciam a presente infração

penal consistem em ingressar (ou seja, adentrar) ou, ainda, promover (diligenciar para que ocorra), intermediar (atuar como intermediário), auxiliar (concorrer para a realização) ou facilitar (ajudar, colaborar) a entrada do objeto material. O favorecimento real impróprio é crime de ação múltipla ou conteúdo variado, porquanto contém diversas ações nucleares, separadas por conjunção alternativa (se o agente incorrer em mais de um comportamento, ligados causalisticamente, haverá crime único).

Chama atenção o excesso de comportamentos repetitivos mencionados no tipo penal. Teria sido suficiente referir-se ao ato de ingressar, e as demais condutas já estariam incluídas na disposição em razão da norma de extensão pessoal prevista no art. 29 do CP. De qualquer modo, sempre é bom recordar que, em se tratando de servidor público vinculado à Administração Penitenciária ou aos órgãos encarregados de zelar pela segurança do estabelecimento penal, o crime que pratica quando deixa de cumprir seu dever de impedir o ingresso é o do art. 319-A do CP.

Podem ser objetos materiais do crime: (i) o aparelho telefônico; (ii) o aparelho de rádio; (iii) os aparelhos similares aos anteriores, que permitam a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

É necessário que o ato seja praticado sem autorização legal (elemento normativo do tipo). Não se punirá, obviamente, o oficial de justiça que ingressa nas dependências prisionais para cumprir mandados judiciais portando seu aparelho de telefone celular (exceto se o fizer para entregar a algum preso).

Para que o delito se aperfeiçoe, é preciso que o agente busque adentrar em um estabelecimento penal. Entende-se por tal qualquer local destinado ao cumprimento de penas privativas de liberdade (como estabelecimentos de segurança máxima, média, colônias penais ou casas de albergado) ou ao recolhimento de presos provisórios (p. ex.: centros de detenção provisória ou celas situadas em distritos policiais).

5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, isto é, a vontade e a consciência de praticar os atos descritos no tipo.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime se consuma com o efetivo ingresso do aparelho de telefone celular etc. no estabelecimento prisional, ainda que não chegue às mãos do destinatário (o que caracterizará mero exaurimento). Admite-se a forma tentada (p. ex., o visitante oculta o aparelho de telefone celular e, ao passar pela revista pessoal, é flagrado pelos agentes penitenciários tentando adentrar ao local com o objeto de comunicação).

7. PENAS E AÇÃO PENAL

A pena é a detenção, de três meses a um ano (cuida-se de infração de menor potencial ofensivo).

A ação penal é pública incondicionada.

Abuso de poder (ou exercício arbitrário) e abuso de autoridade (Lei n. 13.869, de 5-9-2019)

SUMÁRIO: 1. Revogação. 2. Terminologia. 3. Conceito e objetividade jurídica. 4. Sujeitos do crime. 5. Elemento subjetivo específico. 6. Ação penal. 7. Crimes em espécie. 7.1. Decretação indevida de medida privativa de liberdade e figuras equiparadas. 7.2. Decretação indevida de condução coercitiva. 7.3. Falta de comunicação da prisão em flagrante ao juiz competente e demais providências relacionadas à detenção e à execução da soltura do agente. 7.4. Constrangimento moral de preso ou detento. 7.5. Constrangimento de testemunha com dever de sigilo. 7.6. Falta de identificação ou falsa identificação do responsável pela prisão ou detenção. 7.7. Submissão de preso a interrogatório noturno. 7.8. Impedimento ou retardamento de envio de pedido de apreciação da legalidade de prisão. 7.9. Impedimento de entrevista pessoal e reservada entre o preso e seu advogado. 7.10. Manutenção de presos em estabelecimento inadequado em razão de sexo ou idade. 7.11. Invasão de domicílio com abuso de autoridade. 7.12. Fraude processual especial. 7.13. Constrangimento de servidor de saúde para alteração de registro de óbito. 7.14. Realização ou utilização de prova manifestamente ilícita. 7.15. Requisição ou instauração de procedimento investigatório criminal ou administrativo sem justa causa. 7.16. Divulgação indevida de gravação sem relação com a prova. 7.17. Falsidade sobre informação em procedimento judicial ou investigatório. 7.18. Denúncia caluniosa ou perseguição infundada. 7.19. Procrastinação indevida de investigação. 7.20. Negativa de acesso aos autos de procedimento investigatório. 7.21. Exigência de informação ou cumprimento de obrigação sem amparo legal. 7.22. Invocação de condição de agente público para obtenção de vantagem pessoal ou privilégio indevido. 7.23. Decretação exacerbada

de indisponibilidade de ativos financeiros. 7.24. Retardamento demasiado de pedido de vista. 7.25. Antecipação de juízo de culpa. 7.26. Violação de prerrogativas profissionais. 7.27. Penas e ação penal. 7.28. Revogação da Súmula 172 do STJ.

1. REVOGAÇÃO

Durante muitos anos se discutiu a respeito da vigência do art. 350 do CP, o qual tipificava o crime de abuso de poder. A controvérsia se dava em razão da edição, em 1965, da antiga Lei de Abuso de Autoridade, que punia comportamentos similares aos tratados no dispositivo do Código Penal.

Segundo o art. 350 do CP, cometia delito de exercício arbitrário ou abuso de poder, sujeito à pena de detenção, de um mês a um ano, quem “ordenasse ou executasse medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder”.

De acordo com o parágrafo único, incorria “na mesma pena o funcionário que: (i) ilegalmente recebesse e recolhesse alguém a prisão, ou a estabelecimento destinado a execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança; (ii) prolongasse a execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade; (iii) submetesse pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei; (iv) efetuasse, com abuso de poder, qualquer diligência”.

Para nós, era o caso de revogação parcial, notadamente do caput e do inciso III do parágrafo único, reproduzidos nas alíneas a e b do art. 4º da extinta Lei n. 4.898/1965, de modo que continuavam em vigor os incisos I, II e IV do parágrafo único do art. 350.

Com a edição da atual Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869, de 5-9-2019), o debate se encontra superado, pois esta revogou expressamente a Lei de 1965 e o art. 350 do CP.

2. TERMINOLOGIA

De ver-se que, sob o ponto de vista jurídico-penal, os crimes definidos na Lei n. 13.869/2019 não receberam nomen juris apropriado.

Não se trata de abuso de autoridade, mas de abuso de poder. Em face de nossa legislação penal, não se confunde o abuso de poder com o de autoridade. O abuso é o uso fora dos limites correspondentes a todo poder ou autoridade, o seu exercício excessivo e ilegítimo. Na hipótese de abuso de autoridade, cuida-se de seu uso ilegítimo no âmbito de relações privadas; na de abuso de poder, o agente deve possuir cargo ou ofício público. Tanto é assim que o CP, quando determina as circunstâncias legais gerais, trata do abuso de autoridade na alínea f, II, do art. 61, enquanto o abuso de poder vem disposto na alínea g. Dessa forma, não olvidando que a lei descreve condutas abusivas em face do Direito Civil e Administrativo, pelo prisma do Direito Penal os crimes que elas contêm são de abuso de poder e não de autoridade.

3. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O abuso de autoridade consiste em praticar, no exercício de função pública ou a pretexto de exercê-la, condutas que impliquem exorbitar o poder atribuído por lei ao agente público. O comportamento somente terá caráter criminoso, por óbvio, quando se subsumir a quaisquer dos tipos penais contidos na Lei n. 13.869, de 2019. De ver que, caso a conduta não se enquadre em nenhum dos tipos penais do mencionado diploma, subsiste a possibilidade de configuração do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP ("praticar violência, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la").

Os crimes contidos na lei de 2019 possuem dupla objetividade jurídica.

1ª) objetividade jurídica mediata: é o interesse concernente ao normal funcionamento da Administração Pública em sentido amplo, no que se refere à conveniência de garantia do exercício da função pública sem

abusos da autoridade;

2ª) objetividade jurídica imediata: proteger as garantias individuais estatuídas pela CF. Neste campo, a Carta Magna, nos incisos de seu art. 5º, determina garantias concernentes à liberdade de locomoção (incisos LXI, LXII, LXV e LXVI), inviolabilidade do domicílio (inciso XI), incolumidade física (caput) etc.

4. SUJEITOS DO CRIME

O abuso de autoridade é crime próprio, somente podendo figurar como sujeito ativo o agente público, servidor ou não, que atuar no exercício da função ou a pretexto de exercê-la.

Incluem-se dentre estes os servidores civis ou militares. Aqueles serão julgados pela Justiça Comum, e estes, pela Justiça Militar, já que o fato, sendo praticado por militar em serviço, configura crime militar nos termos do art. 9º, II, do CPM.

O art. 2º da Lei n. 13.869, de 2019, esclarece que pode ser sujeito ativo, ainda, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a: I – servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas; II – membros do Poder Legislativo; III – membros do Poder Executivo; IV – membros do Poder Judiciário; V – membros do Ministério Público; VI – membros dos tribunais ou conselhos de contas.

De acordo com o parágrafo único, reputa-se agente público, para os efeitos da lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo.

O leque de sujeitos ativos dos crimes de abuso de autoridade, portanto, é

maior do que o rol de possíveis autores dos demais crimes funcionais tipificados no CP, de vez que, quanto a tais, só podem praticá-los quem exerce, ainda que em caráter transitório, cargo, emprego ou função pública (art. 327).

Note-se que alguns tipos penais definidos na Lei n. 13.869/2019 somente podem ser cometidos por determinados agentes públicos, isto é, para estes, não se aplica o conceito amplo contido no art. 2º da lei. É o caso, v.g., do art. 37, que pune quem “demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento”. Esse fato pode ter como sujeito ativo apenas o julgador, integrante de órgão colegiado, como o desembargador de um tribunal de justiça ou regional.

De ver-se, ainda, que todos os tipos admitem a participação de terceiro, o qual pode ser até mesmo um particular, em face da regra do art. 30 do CP, uma vez que a qualidade de agente público é elementar dos crimes, estendendo-se a todos os concorrentes.

Há dupla subjetividade passiva.

Sujeito passivo mediato: é o Estado, titular da Administração Pública.

Sujeito passivo imediato: é o cidadão, titular da garantia constitucional lesada ou molestada.

5. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO

Os crimes de abuso de autoridade contêm elemento subjetivo específico.

Nos termos do art. 1º, § 1º, da lei, para sua configuração deve o agente público atuar com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

A necessidade de comprovação dessa finalidade específica, cuja prova é de difícil produção, pode limitar a incidência dos tipos penais da Lei n.

13.869, de 2019.

Essa elementar deve ser considerada, no âmbito da lei, como regra geral, cedendo lugar sempre que existir, no próprio tipo penal, elemento subjetivo diverso. É o caso, por exemplo, dos arts. 23 e 29 da lei. Este pune o ato de prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Cuidando-se de dispositivo legal que exige buscar, com a conduta, prejudicar interesse do investigado, não há como reconhecer a existência do delito se, em vez disso, o agente visar somente a beneficiar a si mesmo. Trata-se de antinomia que deve ser solucionada valendo-se do critério da especialidade.

6. AÇÃO PENAL

O art. 3º da Lei n. 13.869, de 2019, determina que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal de iniciativa pública incondicionada. Desse modo, tanto a investigação criminal quanto a ação penal devem ser propostas independentemente da vontade do sujeito passivo. O dispositivo assegura, ainda, o direito à vítima de propor queixa subsidiária, caso o Ministério Público, depois de concluída a investigação, não ofereça a denúncia no prazo legal (CPP, art. 46). A norma contida na lei especial reproduz o regramento dos arts. 100 do CP e 29 do CPP.

7. CRIMES EM ESPÉCIE

7.1. Decretação indevida de medida privativa de liberdade e figuras equiparadas

De acordo com o art. 9º da Lei, é crime punido com detenção, de 1 a 4 anos, e multa, decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.

O verbo nuclear traduz o ato de impor, determinar. A conduta abrange a decretação de qualquer medida que implique privação da liberdade, exigindo, porém, que se dê em desconformidade com as hipóteses previstas

em lei (elemento normativo do tipo).

Assim, incorre no dispositivo, por exemplo, o juiz de direito que impõe prisão preventiva em caso de infração penal apenada exclusivamente com multa, em patente desrespeito à proibição prevista no art. 283, 1^a, do CPP.

O sujeito ativo do crime é a autoridade (policial ou judiciária) que decretar a medida. O sujeito passivo é a pessoa cuja liberdade de locomoção foi cerceada.

O crime se consuma com a decretação da medida manifestamente descabida, ainda que esta não venha a ser executada, devido à falta de captura do agente ou em razão de sua revogação por decisão posterior.

Trata-se de crime de mera conduta.

Não cabe tentativa, pois o tipo penal encerra infração unissubsistente.

Existem, ainda, condutas equiparadas no parágrafo único do dispositivo. Este comina a mesma pena a quem, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal; substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível; deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.

7.2. Decretação indevida de condução coercitiva

O art. 10 da lei pune quem decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo.

Decretar significa determinar com caráter coercitivo, ordenar.

O sujeito ativo, nesse caso, é o magistrado responsável pela expedição da ordem de condução coercitiva, sem a observância dos parâmetros legais e constitucionais.

Quanto à decretação de condução coercitiva de testemunha, deve-se

observar o disposto nos arts. 218 do CPP e 455, § 5º, do CPC, ou seja, somente depois de ser regularmente intimada e não comparecer ao ato processual, é que ficará sujeita à condução coercitiva. Se o juiz, ao arremetimento da lei, determinar a medida sem que a testemunha tenha, por primeiro, deixado de comparecer à audiência, incorrerá no tipo penal.

No que tange à condução coercitiva de investigado, esta será sempre descabida. Deve-se alertar que o Plenário do STF decidiu, por maioria, no julgamento das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 395 e 444, que não cabe condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. De acordo com a Suprema Corte, tal providência, embora prevista no art. 260 do CPP, se choca com o “direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio”, com a dignidade da pessoa humana, com a presunção de não culpabilidade e uma restrição indevida à liberdade de locomoção. Decidiu-se, no acórdão, declarar “a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

O crime se consuma com a expedição da ordem, ainda que esta não seja cumprida, por ter sido cassada pela superior instância.

Por se tratar de delito unissubsistente, não comporta a tentativa. Ou a ordem foi emitida, e o fato atingiu sua realização integral, ou não o foi, inexistindo infração penal.

O fato é punido com detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

7.3. Falta de comunicação da prisão em flagrante ao juiz competente e demais providências relacionadas à detenção e à execução da soltura do agente

O art. 12 incrimina o ato de deixar injustificadamente de comunicar prisão

em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal.

O parágrafo único da disposição pune, ainda, os atos de:

(i) deixar de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou;

(ii) deixar de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;

(iii) deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;

(iv) prolongar a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.

A CF, em seu art. 5º, LXII, determina que “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente...”. Já o inciso LXIV dispõe que “o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial”. E o inciso LXV impõe: “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”.

A conduta típica incriminada, reforçando penalmente os mandamentos constitucionais, consiste em o sujeito não levar ao conhecimento da autoridade judicial, incontinenti, o fato da prisão de alguém. Quer se cuide de prisão em flagrante, ou em virtude de condenação penal, preventiva etc., cumpre ao destinatário da norma comunicá-la, imediatamente, ao juiz competente. Pune-se, ainda, a falta de entrega ao agente preso (em flagrante) da nota de culpa e o prolongamento indevido do tempo de prisão (seja a decorrente de decisão condenatória, seja a prisão processual), de medida de segurança (CP, arts. 96 a 99) ou internação (CPP, art. 319, VII)

de alguém.

Crime omissivo próprio, consuma-se no momento em que a autoridade, podendo fazê-lo, deixa de realizar os atos descritos no caput ou nos incisos do parágrafo único, como o de comunicar ao juiz competente a prisão de alguém por tempo juridicamente relevante.

Quanto à falta de comunicação “imediata” acerca da prisão em flagrante de alguém à autoridade judiciária competente, deve-se entender como tal aquela não efetuada em até 24 horas contadas da conclusão da lavratura do auto de prisão em flagrante (CPP, art. 306, § 1^o). Não integra o tipo a demora causada pelos empecilhos burocráticos, desde que presente a vontade de comunicar-se com o juiz competente.

A tentativa, cuidando-se de omissão própria, não é admissível.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.4. Constrangimento moral de preso ou detento

O art. 13 da lei pune o ato de constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

(i) exhibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública (por exemplo: ameaçar agredir preso para que exiba seu rosto descoberto a jornalistas que acompanham sua captura);

(ii) a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei (como, v.g., obrigar o preso a utilizar algemas fora das hipóteses previstas na Súmula Vinculante 11 do STF);

(iii) produzir prova contra si mesmo (p. ex.: fazendo o preso ingerir, com emprego de violência, substância química que o obriga a dizer a verdade, autoincriminando-se).

O verbo núcleo do tipo (“constranger”) indica obrigar alguém a fazer algo e, no caso do tipo penal, forçá-lo a realizar condutas que violam seus direitos fundamentais.

O fato deve ser cometido com emprego de violência, grave ameaça ou violência imprópria (quando se reduz a capacidade de resistência da vítima).

O sujeito ativo é o agente público responsável por compelir a vítima a realizar as ações descritas no tipo, e o sujeito passivo é o preso (sujeito cuja prisão foi decretada) ou o detento (assim entendido como aquele que foi detido em flagrante delito, sem que tal providência tenha sido ratificada pela autoridade policial competente).

O crime se consuma com a realização, pelo preso ou detento, do ato a que foi submetido indevidamente.

Admite-se a forma tentada, pois, a despeito do emprego de violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima, pode ser que esta não ceda à pressão e não realize o ato a que foi compelida.

A pena é de detenção, de 1 a 4 anos, e multa, sem prejuízo da correspondente à violência. Se a autoridade policial, por exemplo, obrigar o preso a erguer seu rosto para ser filmado ou fotografado por meios de imprensa e, para tanto, o agrida produzindo lesões corporais, dar-se-á o concurso material necessário.

7.5. Constrangimento de testemunha com dever de sigilo

O art. 15 define como abuso de autoridade o ato de constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo.

Constranger significa obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade. O que se pune é o constrangimento, sob ameaça de prisão, a que preste depoimento testemunha que deva manter segredo ou sigilo decorrente de sua atividade profissional.

O sujeito ativo é o presidente da audiência de inquirição da testemunha em favor de quem há o dever de sigilo ou segredo. Pode ser o juiz, por

ocasião da audiência de instrução do processo (criminal ou não), a autoridade policial (na fase de inquérito policial) ou o membro do MP (no procedimento investigatório criminal).

O dispositivo se refere às testemunhas proibidas de depor por dever de sigilo ou segredo, referidas pelo art. 207 do CPP (e no art. 448, II, do CPC).

Essas pessoas somente prestarão depoimento se desobrigadas pela parte interessada, ou seja, por aquele a quem o sigilo aproveita (ex.: o paciente do psicólogo ou o cliente do advogado) e quiserem dar o seu testemunho.

O crime tem natureza formal e se consuma com o constrangimento ilegal efetuado sobre a testemunha, ameaçando-a a depor sob pena de prisão, ainda que ela não ceda à pressão e se negue a fazê-lo.

Não admite tentativa, pois tem caráter unissubsistente (seu iter criminis não comporta fracionamento).

A pena é de detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

7.6. Falta de identificação ou falsa identificação do responsável pela prisão ou detenção

Configura abuso de autoridade deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão.

A Constituição Federal assegura aos presos, no art. 5º, LXIV, o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

O Código de Processo Penal, em razão disso, determina que, na lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá a autoridade policial, como ato final, entregar ao preso um documento chamado “nota de culpa”, o qual terá que conter o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas (art. 306, 2º).

O tipo penal inclui como sujeito ativo desde o agente público responsável

pela detenção de alguém, ao cumprir mandado de prisão ou ao capturá-lo em flagrante delito, até a autoridade a quem essa pessoa é apresentada, como providência subsequente à captura ou detenção.

Assim, por exemplo, pode ser sujeito ativo do crime o policial militar que, surpreendendo a pessoa em estado flagrancial, lhe dá a voz de prisão e a conduz à presença da autoridade policial, ou esta, que, ratificando a voz de prisão, procede à lavratura do respectivo auto. Ambos deverão identificar-se ao preso e, se não o fizerem ou apresentarem identidade falsa, responderão pelo crime.

O delito se consuma, no caso de identificação falsa, quando esta é apresentada e, em se cuidando de falta de identificação, quando a diligência é encerrada. No caso da prisão em flagrante, esse limite é de 24 horas contadas da prisão, pois se cuida do prazo fatal para a entrega da nota de culpa.

Não se admite a tentativa, pois o delito é unissubsistente (isto é, seu iter criminis é indivisível).

O parágrafo único prevê como conduta equiparada o ato de o responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal deixar de identificar-se ao preso ou atribuir a si mesmo falsa identidade, cargo ou função.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.7. Submissão de preso a interrogatório noturno

De acordo com o art. 18, constitui abuso de autoridade submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações.

O verbo núcleo do tipo é submeter, que significa sujeitar, compelir. O objeto material é o agente preso. A submissão deve se referir à realização

de interrogatório no período de repouso noturno, o qual deve ser compreendido como aquele entre 21 horas e 5 horas, por interpretação sistemática da Lei de Abuso de Autoridade, que, no art. 22, veda o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar no mencionado horário.

O sujeito ativo é a autoridade policial. Esta incorrerá no crime pelo só fato de realizar o interrogatório do indivíduo encarcerado no período de repouso noturno.

O sujeito passivo é a pessoa presa, a qualquer título, exceto quando se tratar de flagrante delito.

Não há crime se o interrogatório referir-se a sujeito preso em flagrante delito (CPP, arts. 301 e s.) ou estiver assistido por advogado e anuir em ser ouvido.

Admite-se a tentativa, pois o delito é plurissubsistente. Pode o interrogatório noturno indevido não se concretizar por circunstâncias alheias à vontade da autoridade policial, como a intervenção do órgão correicional, depois de acionado por familiares ou advogado do ofendido.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.8. Impedimento ou retardamento de envio de pedido de apreciação da legalidade de prisão

Pune-se com detenção, de 1 a 4 anos, e multa o ato de impedir (obstar) ou retardar (atrasar), injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia (art. 19). A mesma pena é imposta ao magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.

O dispositivo salvaguarda o direito de petição, o qual tem origem no Bill of Rights, de Guilherme III, de 1689, que em seu art. 5º rezava: “É direito dos súditos apresentar petições ao rei, e todas as prisões e perseguições, por motivo de tais pedidos, são ilegais”.

A declaração francesa de 1793, em seu art. 32, determinava: “O direito de petição aos depositários da autoridade pública não pode, em caso algum, ser interdito, suspenso ou limitado”.

Consiste o direito de petição em poder o cidadão reclamar contra as autoridades, denunciando ilegalidades ou “abuso de poder”, solicitando providências aos poderes constituídos.

A Carta Magna vigente, em seu art. 5º, XXXIV, a, estatui: é a todos assegurado “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.

O crime é material, de maneira que atinge sua realização integral quando o agente público responsável por encaminhar o requerimento à autoridade judiciária competente, de maneira dolosa, retarde ou impeça o pleito de chegar ao conhecimento desta.

Admite-se a forma tentada, quando o agente tenta impedir que o requerimento seja encaminhado ao juiz competente, mas este o recebe graças à intervenção de terceiro. Imagine, por exemplo, o ato de um preso que entregue ao diretor do estabelecimento petição dirigida ao juiz das execuções penais, relatando ilegalidades no ambiente prisional (como superlotação ou falta de condições mínimas de salubridade e habitabilidade), e o servidor deixe dolosamente de dar andamento ao pedido, mas o carcereiro, ciente da entrega da petição, consiga fazer a informação chegar ao conhecimento do magistrado.

7.9. Impedimento de entrevista pessoal e reservada entre o preso e seu advogado

O Texto Fundamental assegura aos presos o direito à assistência de advogado (art. 5º, LXIII). Essa prerrogativa, não obstante, por ser decorrência do princípio da ampla defesa (art. 5º, LV), é extensível a todas as pessoas que sejam acusadas criminalmente, estejam elas presas ou soltas.

Especificamente quanto ao direito de entrevista pessoal e reservada entre o preso e seu advogado, determina o art. 8, n. 2, d, da Convenção Americana de Direitos Humanos que toda pessoa acusada de delito tem direito de ser assistida por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com ele. O Código de Processo Penal, na mesma linha, prevê, em seu art. 185, 5º, 1ª parte, que: “em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor”. Cite-se, também, o art. 7º da Lei n. 8.906/94, cujo inciso III declara ser prerrogativa do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Há, ainda, outros dispositivos legais que reconhecem o mesmo direito: art. 41, IX, da LEP, art. 128, VI, da Lei Complementar n. 40/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública) e art. 124, III, do ECA.

A Lei n. 13.869/2019, em seu art. 20, visando a conferir eficaz proteção a esse direito, determina que constitui forma de abuso de autoridade impedir (obstar), sem justa causa (elemento normativo do tipo), a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado.

O dispositivo se aplica tanto ao interrogatório policial quanto ao judicial. De ver, contudo, que a presença do advogado na fase inquisitiva não é obrigatória, diversamente da fase judicial. Isto é, se o sujeito for detido em flagrante e não possuir advogado, a autoridade poderá realizar o interrogatório do agente, mesmo sem a presença do profissional. Em juízo, porém, a presença do defensor é indispensável, daí porque todo

interrogatório judicial deverá ser efetivado somente depois de se confirmar que o preso e seu defensor puderam conversar de maneira privada.

O sujeito ativo é a autoridade, policial ou judiciária. O sujeito passivo é o preso cujo direito à entrevista com seu advogado foi suprimido indevidamente.

O crime se consuma com a obstaculização do direito, ou seja, no momento em que a autoridade, sendo requerida pelo preso ou por seu advogado a realização da entrevista reservada, o impeça sem justa causa.

Admite-se a tentativa, caso a barreira imposta pela autoridade seja superada por circunstâncias alheias à sua vontade.

O parágrafo único descreve, como figura equiparada, o ato de impedir o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.10. Manutenção de presos em estabelecimento inadequado em razão de sexo ou idade

O art. 21 da Lei n. 13.869/2019 visa a assegurar o respeito ao direito fundamental descrito no inciso XLVIII do art. 5º da CF (“a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado”).

Nesse sentido, comete o crime quem mantiver presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento ou, ainda, mantiver na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Interessante observar que a Constituição trata da garantia em matéria de pena privativa de liberdade, isto é, prisão decorrente de decisão condenatória, ao passo que a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade incrimina não só o recolhimento misto na mesma cela de pessoas cumprindo pena, mas também de indivíduos presos provisoriamente (isto é, por força de prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária).

Trata-se de crime comissivo. Comete-o o agente público que aloca o preso em cela com pessoas de sexo distinto ou a criança ou adolescente juntamente com o adulto, mantendo-o em tal situação, cometendo o delito mediante ação.

De notar que o verbo nuclear ("manter") traduz situação que deve perdurar no tempo, não se configurando quando o fato foi breve e episódico.

E se o servidor responsável pelo estabelecimento prisional, ciente da ilicitude efetuada por terceiro, deixar de tomar providências para saná-la (como um delegado que assume o plantão em Distrito Policial com celas, tomando conhecimento que numa delas foram recolhidos um homem e uma mulher)?

Comete o crime, a título de omissão imprópria. De lembrar-se que a omissão é penalmente relevante, no dizer do art. 13, § 1º, do CP, quando o agente podia e devia agir para impedir o resultado.

Admite-se a forma tentada, quando iniciada a execução (ou seja, a alocação por tempo juridicamente relevante de preso com pessoas de sexo diverso ou adultos junto com crianças ou adolescentes), mas não consegue o agente consumar o crime por motivos alheios à sua vontade (como a intervenção de autoridade superior que, percebendo a iminente ilegalidade, impede que ela se concretize).

A pena é de detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

7.11. Invasão de domicílio com abuso de autoridade

O art. 22 contém uma figura especial de violação de domicílio. A conduta encontrava-se punida originalmente no art. 150, § 2º, do CP, o qual foi revogado expressamente pela Lei de Abuso de Autoridade.

O crime consiste em invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei.

Incorre na mesma pena (detenção, de 1 a 4 anos, e multa) quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências ou cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas.

Não haverá crime, porém, se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre.

Note-se que o dispositivo, diversamente do art. 150 do CP, pune o ingresso em “imóvel” alheio e não em “casa” alheia. Devido à amplitude da elementar “casa”, que abrange, além de cômodos em imóveis, qualquer compartimento habitado, como a boleia de um caminhão, a entrada clandestina de um agente público à revelia do caminhoneiro no citado compartimento não se enquadra no art. 22 da Lei de Abuso de Autoridade, configurando, porém, violação de domicílio (art. 150, caput, do CP).

Os núcleos do tipo são os verbos invadir (ingressar desautorizadamente) e permanecer. Quanto à permanência, pressupõe ela a entrada lícita. Entrando ilicitamente na residência alheia e nela permanecendo, o sujeito não responde por dois delitos, mas por infração única. Isso porque se trata de crime de formulação típica alternativa. Para existência da infração penal, é irrelevante que o sujeito realize conduta que se enquadre num ou em vários verbos.

É necessário que a invasão ou permanência seja realizada contra a vontade do dono. Havendo consentimento, expresso ou implícito, o fato é atípico.

A invasão e a permanência podem ser francas, astuciosas ou clandestinas. Quando a invasão ou a permanência é franca, fala-se que o dissentimento do dono pode ser expresso ou tácito. Quando a invasão ou a permanência é astuciosa ou clandestina, o dissentimento é presumido. Assim, dissentimento presumido existe na hipótese de o sujeito invadir ou permanecer em casa alheia astuciosa ou clandestinamente. Entrada ou permanência franca é a realizada sem astúcia ou clandestinidade. Neste caso, o dissentimento pode ser expresso ou tácito. Existe entrada ou permanência franca com dissentimento expresso quando o dono manifesta a vontade de excluir o sujeito ativo. O dissentimento tácito resulta de fatos anteriores, que demonstram claramente a intenção de o titular não admitir a entrada do sujeito.

O crime é de mera conduta. Na espécie, a figura não se refere a qualquer mudança do aspecto material da residência da vítima causada pela invasão ou permanência. É claro que a simples entrada do sujeito já muda o mundo exterior. Entretanto, o resultado de que se cuida não é aquele contido no próprio comportamento. É necessário que a mudança do mundo exterior seja causada pela conduta do sujeito ativo.

O fato, na modalidade “invadir”, é delito instantâneo; na modalidade “permanecer”, como a expressão indica, é permanente.

A consumação se dá com a invasão ou permanência. É preciso que a invasão seja concreta. Assim, é necessário que o sujeito entre com o corpo inteiro na casa da vítima. A permanência, para constituir delito consumado, requer duração juridicamente relevante.

É possível a tentativa, porquanto se cuida de delito plurissubsistente.

7.12. Fraude processual especial

Trata o art. 23 da lei de modalidade especial de fraude processual cometida por agente público, na qual ele inova artificialmente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade.

Inovar artificialmente significa modificar, alterar, substituir determinada situação referente ao estado de lugar (ex.: abertura de um caminho), de coisa (colocação de uma arma de fogo ao lado de um cadáver) ou de pessoa (alteração do aspecto físico de uma pessoa).

Há elemento subjetivo especial, correspondente ao propósito de se furtar à responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade penal. A existência dessa elementar afasta a aplicação, ao art. 23, do art. 1º, § 1º, da lei, vez que a norma específica prevalece sobre a norma geral.

Também fica sujeito à pena do caput (detenção, de 1 a 4 anos, e multa) quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência ou omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.

Cuida-se de crime formal, de tal maneira que sua realização integral independe do resultado (escapar de responsabilização criminal ou imputar ilicitamente a alguém uma infração penal ou agravar-lhe a responsabilidade).

Admite-se a tentativa, pois o agente pode dar início à execução do fato e ser impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Exemplo: o agente toma uma arma para colocar ao lado de um cadáver e, com isso, sugerir que matou a vítima em troca de tiros e, portanto, em legítima defesa, mas é obstado por uma testemunha, que filma a ação e o impede de inserir

artificialmente o instrumento bélico e, desse modo, obsta a consumação do crime.

7.13. Constrangimento de servidor de saúde para alteração de registro de óbito

A Lei n. 13.869/2019 previu nova figura penal, consistente em constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração.

O verbo constranger significa obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade.

O constrangimento deve recair sobre funcionário ou empregado de instituição hospitalar, a fim de que admita para tratamento pessoa falecida. Imagine, por exemplo, que a polícia, em diligência investigatória, entre em confronto com o suspeito e, a tiros, o mate, sem que ele tenha oferecido qualquer resistência à intervenção policial. Para evitar que o local do crime seja preservado e se apure eventual homicídio praticado, os agentes públicos o coloquem na viatura e o encaminhem ao hospital, simulando um socorro e, chegando ao nosocômio, obriguem o funcionário a aceitar o cadáver como se vivo estivesse, assim o declarando.

O fato deve ser praticado com emprego de violência ou grave ameaça. A violência pode recair sobre coisa ou pessoa, já que o dispositivo não distingue. Recaindo sobre o próprio funcionário do estabelecimento de saúde, denomina-se violência direta ou imediata. Sendo empregada sobre coisa ou terceira pessoa vinculada ao ofendido, fala-se em violência indireta ou mediata. A grave ameaça é a renúncia da prática de um mal dirigido a alguém. Para que sirva de meio de execução do crime é necessário que seja grave.

O crime é punido com detenção, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena

correspondente à violência. Se esta ocorrer, existirá o cúmulo material obrigatório, somando-se a pena do abuso de autoridade com a de eventual crime de lesão corporal (CP, art. 129).

Consuma-se o fato quando a vítima realiza a ação exigida pelo autor.

É possível a tentativa, quando o agente emprega violência ou grave ameaça contra o funcionário do estabelecimento de saúde, mas este, a despeito da atitude do agente público, se recusa a admitir no hospital como viva pessoa já falecida.

7.14. Realização ou utilização de prova manifestamente ilícita

O art. 25 da lei pune o ato de proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito.

O tipo penal mira reforçar a vedação constitucional da utilização da prova ilícita (CF, art. 5º, LVI).

Proceder à obtenção quer dizer realizar procedimentos tendentes à confecção da prova ilícita.

O dispositivo compreende apenas a realização dolosa de prova cuja ilicitude for manifesta, inequívoca. Prova ilícita é a realizada com violação a regras de direito material, seja por configurar crime (como a confissão obtida mediante tortura ou a interceptação telefônica realizada sem autorização judicial) ou por ofender direitos fundamentais (como a intimidade, o domicílio, a inviolabilidade da correspondência etc.).

Se o agente público torturar o preso para que este confesse o crime e, obtida a prova manifestamente ilícita, juntá-la no procedimento investigatório ou fiscalizatório, responde por dois crimes em concurso?

Entendemos que sim, em razão da pluralidade de bens jurídicos atingidos. Constitui crime de tortura, previsto no art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/97, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-

lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Trata-se de delito equiparado a hediondo, punido com reclusão, de 2 a 8 anos. Tutela-se a integridade psíquica, física e o privilégio contra a autoincriminação. O abuso de autoridade, por sua vez, tem como objeto jurídico a Administração Pública.

A pena cominada ao art. 25 da lei é de detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

Nos termos do parágrafo único, incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.

Assim, se o membro do Ministério Público, tendo ciência da natureza manifestamente ilícita da prova, dela fizer uso, fundando seu pleito judicial, pratica abuso de autoridade.

O fato, em sua modalidade fundamental, atinge sua realização integral com a juntada da prova nos autos do procedimento de investigação ou fiscalização.

O crime admite a forma tentada, por seu caráter plurissubistente.

7.15. Requisição ou instauração de procedimento investigatório criminal ou administrativo sem justa causa

A instauração de procedimentos investigatórios de infração penal ou administrativa requer cheque ao conhecimento da autoridade responsável a notícia da prática do respectivo ilícito. Esta, porém, deverá se mostrar verossímil e vir corroborada por algum elemento ou “começo de prova”, como uma declaração ou documento.

Ausente qualquer lastro à notitia, deverá a autoridade responsável efetuar uma sindicância ou investigação preliminar sumária, a fim de obter o necessário suporte à informação e, somente depois de logrado este elemento, caberá a instauração do procedimento investigatório ou administrativo.

Nesse sentido, o art. 27 da Lei n. 13.869/2019 incrimina o ato de requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, esclarecendo, no parágrafo único, que não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.

O delito se consuma, no caso de requisição, quando esta chega ao conhecimento do destinatário e, na modalidade “instauração”, quando o procedimento é formalmente iniciado, por exemplo, com a expedição da portaria inaugural do inquérito policial.

Cabe tentativa quando se tratar de requisição de instauração de procedimento, pois esta pode ser extraviada, não se concretizando o resultado esperado pelo agente por circunstâncias alheias à sua vontade. No caso da instauração do procedimento, não se admite a tentativa, pois o *iter criminis* é incidível.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.16. Divulgação indevida de gravação sem relação com a prova

O art. 28 da lei pune o ato de divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado.

Divulgar quer dizer tornar público, fazer a informação chegar ao conhecimento de terceiras pessoas. O objeto material é a gravação ou trecho desta, que foi produzida no curso de procedimento investigatório ou ação penal. Cite-se, por exemplo, o conteúdo de interceptação telefônica devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, no qual se apure crime de corrupção passiva (CP, art. 317) e, nos diálogos, capte-se conversa entre o suspeito e sua amante, em diálogo que revela a infidelidade, mas não

guarda qualquer relação com o fato objeto da investigação. A divulgação desse trecho da conversa constitui o crime em questão. Essa divulgação pode ser efetuada direta e ostensivamente ou, ainda, de modo indireto. Assim, comete o crime, v.g., a autoridade policial que, obtendo o trecho não relacionado com a prova, compartilha-o num grupo de aplicativo com amigos, expondo a intimidade, a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do suspeito; do mesmo modo, incorre no dispositivo o juiz de direito que, com o propósito de fazer a informação chegar ao conhecimento do público, levanta o sigilo existente sobre diálogos de interceptação telefônica, de tal maneira que a parcela da conversa não relacionada com a prova seja disponibilizada a terceiros.

De notar, ainda, que o tipo penal não condiciona à existência de segredo de Justiça. O que se busca proteger é a vida privada, a intimidade, a honra ou a imagem da pessoa investigada ou acusada, de tal maneira que pouco importa se o áudio revelado publicamente encontrava-se ou não protegido por sigilo judicial.

Se a autoridade divulga a gravação ou o trecho desta com o objetivo de influenciar o desfecho de uma disputa eleitoral em andamento, pratica abuso de autoridade?

Em tese sim, desde que o trecho cujo conhecimento se tornou público refira-se a conteúdo desvinculado do objeto da prova. A conduta, de certo, será apta a produzir o resultado estipulado no dispositivo legal (notadamente ferir a imagem do agente). Além disso, estará presente um dos elementos subjetivos do tipo necessários ao aperfeiçoamento dos crimes de abuso de autoridade, in casu, a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a terceiro.

A consumação ocorre quando a informação chega ao conhecimento de terceiros, estranhos ao procedimento em que a gravação foi colhida ou juntada.

O delito é compatível com a forma tentada.

O fato, por fim, é punido com detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

7.17. Falsidade sobre informação em procedimento judicial ou investigatório

Trata o art. 29 do crime de prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado.

Prestar significa fornecer, prover a informação a terceira pessoa. É preciso que a informação se refira a procedimento judicial (de qualquer natureza, como ação penal, medidas preparatórias, ação civil etc.), policial (como o inquérito policial ou o termo circunstanciado), fiscal (p. ex., auto de infração e imposição de multa por sonegação fiscal) ou administrativo (v.g., sindicância ou procedimento administrativo para apuração de falta funcional).

A informação prestada deve ser falsa, ou seja, desprovida de veracidade. Deve haver uma dissintonia entre a informação fornecida e o conteúdo do procedimento.

E se a informação prestada realmente estiver nos autos, mas não for verídica, isto é, cuidar-se de algo que em verdade não ocorreu?

Não há crime. Imagine, por exemplo, que uma testemunha minta em suas declarações no inquérito policial, sendo seu depoimento encartados nos autos. Suponha, então, que o delegado de polícia, prestando informações ao juiz de direito, para instruir processo de habeas corpus impetrado pela defesa, reproduza trechos das declarações das testemunhas, inclusive daquela que faltou com a verdade. O delegado de polícia não comete abuso de autoridade, pois está reportando ao magistrado aquilo que consta dos autos. Diferente seria a situação se ele, nas informações, relatasse conteúdo diferente do que há no procedimento

e, portanto, falseasse a informação, com o objetivo de ver a ordem de habeas corpus negada, em prejuízo do paciente.

O tipo penal possui um elemento subjetivo específico próprio, o que, em nosso entender, afasta aqueles previstos no art. 1º, § 1º, da lei. Ora, se o dispositivo legal exige que se busque, com a conduta, prejudicar interesse do investigado, não há como reconhecer a existência do delito se, em vez disso, o agente visar somente a beneficiar a si mesmo. Trata-se de antinomia que deve ser solucionada com o critério da especialidade. Assim, reconhece-se que o elemento típico decorrente do art. 1º da lei consubstancia regra geral, que cederá sempre que existir norma específica, isto é, elemento subjetivo especial diverso no próprio tipo penal, como ocorre no art. 28.

O legislador exige que o ato seja praticado com o propósito de prejudicar investigado, mas, em nosso modo de ver, a conduta também abrange fatos praticados para trazer prejuízo a réus em ações penais. Parece-nos que o legislador disse menos do que pretendia (*lex minus dixit quam voluit*), reclamando interpretação extensiva, de maneira a se entender investigado em sentido amplo, até porque o tipo penal fala em prestar informação falsa não só sobre procedimento investigatório, fiscal ou administrativo, mas também sobre procedimento judicial.

Para a consumação do crime não é necessário que o agente tenha efetivamente conseguido trazer prejuízo ao investigado (crime formal). Assim, por exemplo, se o juiz de direito, prestando informações em habeas corpus ao tribunal, mentir sobre dado contido no processo, para que o tribunal não conceda a ordem, incorre no crime, em sua forma consumada, ainda que o órgão superior julgue procedente o writ impetrado.

Não se admite, como regra, a forma tentada, por se tratar de crime unissubistente. Caberá, porém, em situações excepcionais, quando o fato tiver natureza plurissubistente, como no caso de informações prestadas por

escrito, contendo informações falsas sobre o procedimento, as quais se vejam extraviadas e, portanto, não cheguem ao conhecimento do destinatário.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.18. Denúnciação caluniosa ou persecução infundada

De acordo com o art. 30 da Lei n. 13.869, de 2019, configura abuso de autoridade o ato de dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente.

O legislador criou uma figura especial de denúnciação caluniosa, que pune a conduta da autoridade pública responsável por iniciar ou conduzir investigações ou ações criminais, cíveis ou administrativas, fazendo-o contra quem sabe ser inocente ou sem justa causa devidamente fundamentada.

Quanto à imputação de fato sabendo que o investigado ou réu é inocente, duas situações podem ocorrer: a) se um particular comparece à Delegacia de Polícia e noticia fato criminoso, atribuindo-o a quem sabe ser inocente, incorre no crime do art. 339 do CP, sujeitando-se a uma pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa; b) se o agente público (delegado de polícia, por exemplo), instaura de ofício o procedimento (v.g., inquérito policial) para investigar quem sabe ser inocente, comete abuso de autoridade, ficando sujeito à pena de 1 a 4 anos de detenção, e multa, cominada no art. 30 da Lei n. 13.869/2019.

Nota-se o contrassenso do legislador, ao punir de maneira mais severa o particular que o agente público.

Também há o crime de abuso de autoridade quando o responsável pelo procedimento o inicia ou a ele procede sem justa causa fundamentada. Muito embora exista controvérsia em doutrina a respeito do significado desta expressão, consiste a justa causa no lastro probatório mínimo,

necessário à deflagração do procedimento.

Em se tratando de justa causa para a persecução penal, deve-se distinguir se se cuida da fase investigatória ou processual. No primeiro caso, deve a análise ser pautada pelo art. 5º do CPP, isto é, de maneira a se considerar como justa causa para se dar início ou proceder à investigação criminal a existência de uma *notitia criminis* plausível/verossímil e minimamente embasada (com qualquer elemento informativo que constitua, ao menos, início de prova). No segundo caso, isto é, na fase judicial, entende-se por justa causa a observância do binômio: prova da materialidade e indícios de autoria ou participação; significa dizer que a denúncia oferecida pelo Ministério Público deve vir acompanhada de elementos que comprovem a existência da infração penal e apontem para a probabilidade de ter o réu sido autor ou partícipe do fato.

Os verbos nucleares são “dar início”, é dizer, deflagrar o procedimento, instaurando-o, ou, no caso de ação judicial, propô-la; e proceder, que quer dizer acolher a ação, recebendo-a e determinando seu processamento. O primeiro verbo diz respeito à conduta do agente que instaura a investigação (civil, penal ou administrativa) ou do autor da ação judicial; o segundo alude ao comportamento do órgão judicial, que acolhe a ação proposta.

Considera-se persecução civil a resultante da instauração de inquérito civil ou a propositura de ação civil pública. No caso de persecução administrativa, trata-se da sindicância ou do processo administrativo.

As medidas devem ser iniciadas ou aceitas sem que exista justa causa ou quando o agente, de maneira consciente, sabe da inocência do imputado.

Consuma-se com a deflagração do procedimento pelo autor (basta a propositura da ação ou a instauração da medida investigatória) ou com seu processamento pelo órgão judicial. O crime é de mera conduta.

Não se admite a tentativa, pois o fato tem natureza unissubsistente.

7.19. Procrastinação indevida de investigação

O art. 31 da Lei n. 13.869, de 2019, incrimina o fato de estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado.

Também incorre no tipo quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.

Há investigações que possuem prazo previamente fixado em lei para a conclusão. É o caso do inquérito policial, o qual deve ser concluído em 10 dias, quando houver indiciado preso, ou em 30 dias, nos demais casos (indiciado solto ou investigação sem indiciado) – art. 10, caput, do CPP. Esses prazos, porém, podem ser prorrogados, nos termos do art. 10, § 3º, do CPP. Na Lei de Drogas, os prazos do inquérito são de 30 e 90 dias, respectivamente, no caso de indiciado preso ou não (art. 51, caput), os quais também comportam prorrogação. O procedimento investigatório criminal (PIC), instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público para investigar infrações penais de ação penal pública, deve ser concluído no prazo de 90 dias, conforme dispõe a Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, podendo ser prorrogado por igual período por decisão do órgão responsável por sua instauração (art. 13, caput).

Nesses casos, é preciso avaliar se a investigação foi estendida sem motivo justificável, ou seja, vinculado à necessidade de colher mais elementos tendentes à obtenção da prova da materialidade ou indícios de autoria ou participação.

Em se cuidando de procedimentos sem prazo definido para sua conclusão, o delito se dá quando a autoridade responsável o estender sem qualquer motivação.

A consumação do crime não se dá com a mera expiração do prazo investigatório ou sua extensão imotivada por tempo juridicamente

relevante, mas com a produção de prejuízo ao investigado ou fiscalizado (resultado naturalístico). O fato, portanto, admite a forma tentada, pois a realização integral depende de resultado, o qual pode não advir por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.20. *Negativa de acesso aos autos de procedimento investigatório*

Comete abuso de autoridade, nos termos do art. 32 da lei, quem negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível.

O delito visa a assegurar o respeito à prerrogativa profissional garantida na Lei n. 8.906/94, art. 7º, XIV ("examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital"), e na Súmula Vinculante 14 do STF ("É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa").

O verbo nuclear é o ato de negar o acesso, isto é, impedir a consulta, obstar que se tenha vista dos autos. O fato deve ser relativo a autos de investigação preliminar (como o procedimento preparatório de instauração de inquérito civil), termo circunstanciado (art. 69 da Lei n. 9.099/95), inquérito policial, qualquer outro procedimento relativo à investigação de infração penal (como o procedimento investigatório criminal instaurado pelo

Ministério Público), infração civil (p. ex.: inquérito civil instaurado para apurar lesão a interesses difusos e coletivos) ou infração administrativa (v.g., sindicância para apuração de falta funcional).

Também há crime quando, embora tenha sido franqueado o acesso ao conteúdo dos autos, o agente público impede a obtenção de cópias, exceto de peças relativas a diligências em curso (como uma interceptação telefônica em andamento), ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível (p. ex.: uma ordem de serviço expedida pelo delegado de polícia determinando que os investigadores identifiquem o endereço de determinada testemunha chave e, até então, não mencionada nos autos, a fim de evitar o risco de que sofra coação).

O sujeito ativo é o agente público que preside a investigação ou quem age em seu nome. Assim, por exemplo, pode cometer o delito o delegado de polícia que obsta o acesso ao termo circunstanciado ou ao inquérito policial ou o escrivão de polícia responsável que impede o advogado de consultar os autos. De mesmo modo, incorre no delito o promotor de justiça que nega ao defensor o acesso aos autos do procedimento investigatório criminal ou o oficial de promotoria que faz o mesmo.

O sujeito passivo é o advogado, cuja prerrogativa profissional foi indevidamente obstada.

O fato se consuma com a negativa manifestada pela autoridade competente, desde que esta resulte em efetivo obstáculo, frustrando a vista dos autos ou, no caso de extração de cópias, com o impedimento de fazê-lo.

Admite-se a forma tentada quando o acesso aos autos é franqueado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Imagine, por exemplo, o delegado de polícia que negou acesso aos autos, mas, diante da convocação pelo advogado de um representante da Comissão de Prerrogativas da OAB ou um Delegado da Corregedoria Geral de Polícia,

permita a consulta – deverá responder por crime tentado.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.21. Exigência de informação ou cumprimento de obrigação sem amparo legal

De acordo com o art. 33 da Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, pune-se com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa quem exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal.

Exigir significa compelir. Para que exista uma “exigência”, é necessário que o comando seja acompanhado do prenúncio de alguma sanção, expressa ou implícita. O tipo penal é excessivamente amplo, abrangendo qualquer tipo de obrigação. Há elemento normativo, traduzido na elementar “sem expresso amparo legal”. O fato será atípico, portanto, quando se cuidar de exigência prevista expressamente em lei. O juiz que, por exemplo, determina à testemunha que diga a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de responder por crime de falso testemunho, atua amparado por texto expresso de lei (CPP, art. 203, CPC, art. 458 e CP, art. 342). Se o magistrado, porém, exige do réu que diga a verdade acerca dos fatos que lhe serão perguntados em interrogatório, pratica abuso de autoridade.

O fato se consuma no instante da exigência (crime formal), ainda que o destinatário da ordem não se intimide com a determinação abusiva.

Se o fato é praticado na forma oral, será unissubsistente e, portanto, não comportará a forma tentada. No caso de exigência efetuada por escrito, admite-se a tentativa, pois, tendo em vista o meio em questão, o fato se torna plurissubsistente, admitindo o fracionamento do iter criminis.

7.22. Invocação de condição de agente público para obtenção de vantagem pessoal ou privilégio indevido

O parágrafo único do art. 33 da lei pune com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

Há dois verbos nucleares: “utilizar” (fazer uso) e “invocar” (mencionar em seu benefício). O agente deve empregar seu cargo ou função pública ou a estes se referir para se furtar do cumprimento de alguma obrigação legal ou obter vantagem ou privilégio.

Louva-se a incriminação dessa conduta. O agente público que se arrima de sua condição funcional para se eximir de obrigação legal ou lograr alguma vantagem ou privilégio atua de maneira não republicana.

Imagine, por exemplo, o oficial da Aeronáutica que, chegando atrasado em voo comercial, invoque sua condição funcional para impedir a decolagem da aeronave, a despeito de o embarque encontrar-se encerrado.

Suponha, ainda, o juiz de direito, promotor de justiça ou delegado de polícia que, na fila do caixa de um estabelecimento empresarial, arrogue-se de sua função para ter atendimento preferencial.

É o caso, também, do ministro de Estado ou de tribunal superior que, citando sua condição, se recusa a passar pelo aparelho de raio X de aeroporto ou pela fiscalização alfandegária quando chega de viagem de férias do exterior.

O fato configura crime formal, de tal maneira que o fato de utilizar ou simplesmente invocar a condição funcional já é suficiente para a realização integral do tipo, ainda que o sujeito não consiga obter o benefício ilícito almejado.

Admite-se a forma tentada, salvo quando se tratar de comportamento unissubsistente, como ocorre com o ato de invocar a condição de servidor público por meio verbal.

7.23. Decretação exacerbada de indisponibilidade de ativos financeiros

O art. 36 da lei pune com detenção, de 1 a 4 anos, e multa, o fato de decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la.

O verbo nuclear é o ato de decretar (em processo judicial), ou seja, impor, determinar. A decisão deve se referir à indisponibilidade de ativos financeiros, ou seja, qualquer bem de natureza econômica, como bens imóveis, automóveis, quantias depositadas em instituições financeiras, valores mobiliários etc. É preciso que o valor dos ativos cuja indisponibilidade foi decretada, no total, supere de maneira exagerada e inequívoca o valor estimado para a satisfação da dívida da parte.

Também há crime quando, não configurada a discrepância demasiada por ocasião da decisão judicial, esta é demonstrada (de maneira clara e incontroversa) pela parte interessada, e o magistrado não a corrige.

Pode-se figurar como exemplo o ato do juiz que decreta o arresto de bens imóveis (art. 136 do CPP), atendendo a requerimento do ofendido no curso do processo penal, com vistas a garantir a futura indenização civil (a qual constitui efeito automático da condenação criminal, ex vi do art. 92, I, do CP). Se o valor do imóvel superar, em muito, o montante a que faria jus o sujeito passivo a título de ressarcimento dos danos, haverá o crime.

Pergunta-se: e se o juiz decretar o arresto do imóvel, cuja avaliação seja correspondente a mais de 10 vezes o valor do dano sofrido pelo ofendido, mas não forem encontrados outros bens em nome do réu?

Entendemos que, nesse caso, não há crime. O delito somente se configura quando, diante de alternativa menos gravosa, o juiz decreta ou mantém o ônus sobre bens em valores exorbitantemente maiores que o montante a que faria jus a parte. Do contrário, na hipótese figurada, ao

sujeito passivo se negaria proteção jurídica de natureza acautelatória. Em situações como a figurada, quando não forem localizados outros bens integrantes do patrimônio do réu, cumpre a este oferecer outros de menor valor (desde que suficientes para ressarcir eventual prejuízo). Se não o fizer, a manutenção da indisponibilidade do ativo não tem natureza criminosa.

No instante em que decretada ou mantida indevidamente a indisponibilidade, consuma-se a infração, ainda que o bem seja posteriormente liberado por força de decisão proferida por superior instância em grau de recurso.

Não se admite a tentativa, em virtude de se tratar de crime unissubsistente.

7.24. Retardamento demasiado de pedido de vista

De acordo com o art. 37 da lei, há abuso de autoridade quando o membro de órgão colegiado demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista no órgão que integra, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento.

O sujeito ativo da infração penal é o integrante de órgão colegiado que, no curso da sessão de julgamento, pedir vista dos autos para melhor estudar o processo. O tipo abrange, portanto, o desembargador ou ministro de tribunal, mas também inclui membros de diferentes colegiados, ainda que não sejam magistrados, como o conselheiro de tribunal de contas, do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) ou o “juiz” dos tribunais de impostos e taxas, órgãos de natureza administrativa responsáveis por julgar recursos contra autuação fiscal.

O pedido de vista tem como propósito permitir que o julgador possa se aprofundar melhor no estudo do caso e, com isso, elaborar um voto mais embasado. O que não se admite é que tal pedido seja feito com propósito meramente procrastinatório, retardando de maneira exagerada a conclusão

do julgamento.

O pedido de vista dos autos deve observar prazos regimentais.

Assim, no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro pedir vista de julgamento para elaborar seu voto, deverá devolver os autos para prosseguimento da votação, até a segunda sessão ordinária subsequente (art. 134, caput, do Regimento Interno do STF).

Quando não existir prazo estipulado legalmente ou por norma administrativa referente à vista dos autos, entende-se demasiada e injustificada a demora que extrapole excessivamente o tempo médio de vista, sem que exista motivação plausível para tanto. Como se cuida da configuração de ilícito penal, afigura-se recomendável, para confirmar a existência do crime, que a autoridade responsável pelo pedido de vista não devolva os autos depois de provocada expressamente pelo presidente do órgão colegiado e não motive adequadamente sua demora por tempo demasiado.

O fato não admite tentativa, pois se cuida de tipo penal ensejador de conduta unissubsistente.

A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

7.25. Antecipação de juízo de culpa

O ato de antecipar atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, consubstancia delito de abuso de autoridade, punido com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa (art. 38 da lei).

O verbo nuclear é o ato de “antecipar”, ou seja, adiantar, revelando a conclusão a respeito da culpabilidade do investigado sem que o procedimento apuratório esteja formalmente concluído e a acusação devidamente formalizada.

É preciso compreender o dispositivo em sintonia com o dever dos agentes públicos de prestar contas pelos seus atos. Desse modo, o fato de a

autoridade policial informar aos meios de comunicação social que tomou determinada atitude no curso do procedimento investigatório, como a realização de alguma diligência ou a formalização do indiciamento do agente, não tem natureza criminosa.

O que se pune é o comportamento de manifestar-se precipitadamente, atribuindo a alguém a culpa por determinado comportamento ilícito, sem que as apurações tenham se encerrado e a acusação tenha sido formalizada.

O dispositivo se refere a comportamento da autoridade responsável por investigações (criminais ou não). Inclui, portanto, o delegado de polícia responsável pelo inquérito policial, o promotor de justiça que instaurou o procedimento investigatório criminal ou o inquérito civil.

O fato deve ser cometido por algum meio de comunicação, seja este físico (como em uma entrevista a jornal impresso) ou virtual (p. ex.: em programa de rádio ou televisão), aí incluídas as redes sociais.

O sujeito ativo é a autoridade responsável pelo procedimento investigatório, e o sujeito passivo, a pessoa cuja imagem foi atingida pela antecipação do juízo de culpabilidade.

A consumação se dá quando o fato chega ao conhecimento de terceiros.

Admite-se a tentativa, embora se cuide de crime de mera conduta, pois o tipo penal descreve comportamento plurissubsistente. Assim, por exemplo, se o agente elabora o texto da postagem com a antecipação de culpa em sua rede social, mas o envio da mensagem não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade, como falha na transmissão de dados pela internet, responde por crime tentado.

7.26. Violação de prerrogativas profissionais

A Lei de Abuso de Autoridade inseriu, no Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), o art. 7º-B, que tipifica o fato de “violar direito ou prerrogativa

de advogado previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei”.

As prerrogativas cuja violação tem natureza criminosa são:

1) a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;

2) a comunicação com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;

3) a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB;

4) a vedação de ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar.

A pena cominada é de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

7.27. Penas e ação penal

Os crimes de abuso de autoridade são apenados com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa ou, quando mais graves, detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

Há uma exceção quanto a tais patamares punitivos, referente ao crime de violação de prerrogativas profissionais de advogados, previsto no art. 7º-B da Lei n. 8.906/94, cuja pena é de detenção, de 3 meses a um ano, e multa.

No primeiro caso, trata-se de infração de menor potencial ofensivo, ficando sujeita ao procedimento comum sumaríssimo e à competência do

Juizado Especial Criminal, admitindo, bem por isso, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95), salvo quando o sujeito ativo for militar, hipótese em que a competência será da Justiça Militar, na qual não incidem os dispositivos da Lei n. 9.099.

Os fatos punidos com detenção de 1 a 4 anos, além de multa, são de competência do juízo comum, sujeitam-se ao procedimento comum ordinário e admitem suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

7.28. Revogação da Súmula 172 do STJ

De acordo com a Súmula mencionada: “Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço”. Esse entendimento se baseava no fato de que a conduta, por não ser tipificada no Código Penal Militar, configurava crime comum. Só havia duas espécies de crime militar: a) próprio, quando o fato encontrava-se previsto exclusivamente na legislação militar; b) impróprio, quando o ato estava previsto tanto na legislação militar quanto na comum. O abuso de autoridade, não estando tipificado no CPM, mas em lei penal comum, não se encaixava em nenhuma das duas espécies, consubstanciando delito comum (de competência da Justiça Comum, portanto).

Ocorre, porém, que a Lei n. 13.491, de 2017, ampliou o conceito normativo de delitos militares, admitindo que estes também possam existir quando o fato cometido pelo agente, em situação de serviço, estiver previsto na legislação penal comum, o que abrangeu o abuso de autoridade.

Como visto, antes da citada lei, se o militar cometesse abuso de autoridade em serviço, o fato não era considerado crime militar pela ausência de previsão da conduta dentro do Código Penal Militar. Isso, porém, não é mais relevante. É possível, desde a alteração citada, que se

reconheça um crime militar, ainda que o tipo penal se encontre fora do CPM – é o chamado “crime militar por equiparação ou extensão” – art. 9º, II, do CPM.

Em conclusão, se um policial militar praticar abuso de autoridade em situação de serviço, praticará delito militar e, como consequência, será julgado pela Justiça Militar Estadual.

Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Figuras típicas. 4. Elementos objetivos do tipo. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Elemento subjetivo do tipo. 7. Forma típica culposa. 8. Tipos qualificados. 9. Momento consumativo e tentativa. 10. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui crime “promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva” (CP, art. 351).

É protegida a Administração Pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa (particular ou funcionário público), menos pelo próprio preso ou internado (submetido a medida de segurança). Este, ainda que induza ou instigue terceiro a lhe promover a fuga, não responde pelo delito.

Sujeito passivo é o Estado.

3. FIGURAS TÍPICAS

1ª) tipo simples: caput do art. 351;

2ª) tipos qualificados: §§ 1º e 3º;

3ª) forma culposa: § 4º.

4. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Dois são os verbos do tipo: promover e facilitar a fuga de preso ou submetido a medida de segurança. Promover significa realizar, executar a

fuga, tomando medidas que a concretizem. Facilitar quer dizer prestar meios para que o próprio preso ou internado fuja, realizando atos que permitem a evasão.

Preso é a pessoa sujeita à privação da liberdade, seja a prisão provisória (preventiva, flagrante etc.) ou definitiva. Pode tratar-se de submetido à imposição de medida de segurança (inimputável ou semirresponsável, nos termos dos arts. 96 e 98 do CP).

O crime pode ser cometido intra ou extramuros, i.e., dentro ou fora de estabelecimento prisional.

O crime pode ser cometido com:

1ª) violência física contra pessoa;

2ª) violência moral (grave ameaça);

3ª) violência contra a coisa;

4ª) fraude (ex.: engano do carcereiro com a apresentação de alvará de soltura falso).

Admite-se a execução mediante ação ou omissão (desde que o sujeito tenha o dever jurídico de impedir a fuga).

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

É necessário que a pessoa esteja legalmente presa ou submetida a medida de segurança. A expressão legalmente constitui elemento normativo do tipo. Se ilegal a prisão ou a submissão à imposição da medida de segurança, não há crime por atipicidade do fato.

A legalidade deve ser apreciada não só quanto aos requisitos formais da prisão ou da medida de segurança, como também no tocante à sua execução (duração, local etc.).

6. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de promover a fuga de preso ou

internado, com conhecimento da legalidade da prisão ou da medida de segurança.

7. FORMA TÍPICA CULPOSA

O tipo culposo define um crime próprio, uma vez que só pode ser cometido por “funcionário incumbido da custódia ou guarda” (§ 4º). A fuga pode ser executada pelo próprio detento ou promovida por terceiro. Não havendo fuga, inexistente o delito. Assim, não há falar em delito quando o carcereiro, por erro, liberta a pessoa errada (não ocorreu fuga).

Devem ser legais a prisão e a medida de segurança.

8. TIPOS QUALIFICADOS

A pena é agravada “se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento” (§ 1º).

A primeira qualificadora é o emprego de arma (própria ou imprópria).

A segunda é o concurso de pessoas (duas ou mais).

A terceira é o arrombamento, que significa emprego de força contra coisas que constituem obstáculos à fuga.

O crime também é qualificado quando “praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou internado” (§ 3º). Cuida-se de um tipo especial ou próprio, uma vez que não pode o fato ser cometido por qualquer pessoa, mas somente por quem possui o dever funcional específico de guarda ou custódia do preso ou internado (carcereiro, guarda etc.). Assim, não comete o fato o particular, que não tem o dever jurídico de impedir a fuga. Ex.: suponha-se que, efetuada prisão em flagrante por um particular, ele liberte o detido. Não comete delito algum.

9. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no momento em que se concretiza a fuga, ainda que o detento ou internado obtenha a liberdade por pouco tempo.

A tentativa é admissível (salvo quanto à forma culposa).

10. PENA E AÇÃO PENAL

Para o tipo simples, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos (art. 351, caput).

O crime constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), sendo abrangido pela competência material dos Juizados Especiais Criminais. Comporta, em face disso, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Se o delito é cometido a mão armada, por duas ou mais pessoas, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de dois a seis anos (§ 1º). Neste caso, havendo violência física contra pessoa, aplica-se a regra do concurso material de crimes (§ 2º).

Na hipótese de o crime ser cometido por sujeito qualificado, i.e., por pessoa que tem o dever funcional de guarda ou custódia do preso ou internado, a pena é de reclusão, de um a quatro anos (§ 3º).

Para a modalidade culposa, a pena é de detenção, de três meses a um ano, ou multa (§ 4º).

A ação penal é pública incondicionada.

Evasão mediante violência contra pessoa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O CP pune o fato de “evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa” (art. 352).

É protegida a administração da justiça.

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime próprio, só podendo ser cometido por preso ou indivíduo submetido à imposição de medida de segurança detentiva. Só há delito nos casos de prisão e internação legais.

Sujeito passivo principal é o Estado. De forma mediata, também são sujeitos passivos as pessoas submetidas à violência física.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O verbo principal é evadir-se, que significa fugir, libertar-se, escapar. A simples fuga, sem violência, não constitui delito, considerada conduta normal ao anseio de liberdade do indivíduo. Pune-se o fato quando o agente, preso ou internado, emprega violência física para alcançar a liberdade. Nesse caso, a tentativa de fuga é equiparada, para efeito típico, à fuga consumada. Na aplicação da pena concreta, entretanto, o Juiz deve levar em conta a circunstância de o sujeito ter alcançado ou não a consumação de seu intento.

A violência contra coisa não é incriminada na disposição. Nem a grave

ameaça tendente à fuga.

A violência incriminada é a real, empregada contra carcereiro, policial, oficial de justiça, guarda, outro detento ou internado ou terceiro.

O fato pode ocorrer intra ou extramuros, i.e., dentro ou fora de estabelecimento prisional ou de internação.

É necessário que o sujeito se encontre preso ou internado legalmente. Não há crime quando é ilegal a submissão do preso ou internado à custódia ou guarda.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente dirigida à evasão mediante emprego de violência contra a pessoa. O tipo não reclama nenhum fim especial. Não exige, pois, nenhum outro elemento subjetivo.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com o emprego da violência física contra pessoa.

A tentativa é possível. Contudo, é tipicamente equiparada ao delito consumado. De modo que, em face da pena abstrata, pouco importa que o crime seja consumado ou tentado, uma vez que o legislador tipifica a conduta de “evadir-se ou tentar evadir-se”. Assim, aplica-se a ressalva do parágrafo único do art. 14 do CP: não incide a redução da pena de um a dois terços. Relevante é o tema da tentativa, contudo, para efeito da aplicação da pena concreta, constituindo circunstância judicial a ser considerada pelo Juiz na dosagem da pena-base (CP, art. 59, caput).

6. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de reclusão, de três meses a um ano. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

Havendo violência física, com lesão corporal ou homicídio, o CP impõe o concurso material de crimes. Ocorrendo somente vias de fato, fica a contravenção absorvida pelo delito, ínsita na expressão "violência".

A ação penal é pública incondicionada.

Arrebatamento de preso

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elementos subjetivos do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui delito, nos termos do art. 353 do CP, “arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda”.

É tutelada a administração da justiça.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa.

Sujeito passivo principal é o Estado. De forma mediata, o preso arrebatado também é sujeito passivo.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo “arrebatar”, que quer dizer tirar, arrancar, tomar.

Objeto material é o preso, que o sujeito tira de quem o detém, à força, com o fim de seviciá-lo.

Pouco importa o local do arrebatamento: intramuros (dentro do estabelecimento prisional) ou extramuros (fora).

A guarda ou a custódia pode ser exercida por carcereiro, escolta policial etc.

Não se aplica a disposição ao sujeito submetido a medida de segurança.

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO

O crime só é punido a título de dolo, consistente na vontade livre de

arrebatando pessoa, consciente o sujeito de que se trata de preso e que está sob custódia ou guarda de outrem.

Exige-se um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão “a fim de”. Sem ele, a tipicidade do fato não se aperfeiçoa.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Trata-se de crime formal. Consuma-se com o arrebatamento, não sendo necessário que o preso venha a ser seviciado. A tentativa é admissível.

6. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de reclusão, de um a quatro anos, além da correspondente à violência. Assim, vindo o sujeito a maltratar o preso, responde, em concurso material, pelo crime do art. 353 e pelo outro delito em que consiste a violência. Inexistindo o concurso de delitos, o fato admitirá, em razão da pena mínima (não superior a um ano), o sursis processual (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Motim de presos

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 354 do CP, constitui crime “amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão”.

Protege-se, por intermédio da incriminação, a administração pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime coletivo ou de concurso necessário, exigindo que o fato seja cometido por “presos”. O CP não menciona o número mínimo de amotinados. Creemos que se exige, no mínimo, três sujeitos ativos. Isso porque o estatuto penal, quando se contenta com a participação de duas pessoas, no mínimo, na realização da conduta, manifesta-se expressamente (exs.: arts. 155, § 4º, IV; 157, § 2º, II etc.). Aqui, por interpretação sistemática, de exigir-se mais de dois.

Cuida-se de crime próprio, que só pode ser realizado por “presos”, não se excluindo a participação de terceiros, estranhos ao cumprimento de pena.

Sujeito passivo é o Estado. São sujeitos passivos mediatos as pessoas vítimas da violência.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O crime consiste na amotinação de presos, i.e., no comportamento comum de rebeldia de pessoas presas, agindo para o fim de reivindicações justas ou não, vingança, fuga ou pressão sobre funcionários para que façam ou não alguma coisa.

É necessário que a conduta dos presos venha a perturbar a ordem ou a disciplina da prisão, mediante violências pessoais, depredação de instalações etc.

Não constituem delito a simples desobediência, a irreverência a funcionários etc., que não cheguem a perturbar a administração prisional.

Como a lei fala em “presos” e “prisão”, entende-se inexistir delito em relação a sujeitos a medidas de segurança.

Não há necessidade de que o fato seja cometido dentro de prisão. Assim, a amotinação pode ocorrer quando da transferência de presos de um a outro estabelecimento prisional.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente dirigida ao motim, conhecendo o sujeito que sua conduta perturba a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

É crime material, consumando-se com a efetiva perturbação da ordem ou da disciplina da prisão.

Como delito material, admite-se a figura tentada.

6. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de seis meses a dois anos. O motim de presos consubstancia infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). Trata-se, portanto, de delito abrangido pela competência *ratione materiae* dos Juizados Especiais Criminais. Admite, em razão da pena máxima, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e, dada a pena mínima não superior a um ano, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Ocorrendo, em razão da violência, outro delito, aplica-se a regra do

concurso material (parte final do preceito secundário do art. 354 do CP).

A ação penal é pública incondicionada.

Patrocínio infiel

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do que dispõe o caput do art. 355 do CP, constitui crime de patrocínio infiel o fato de o sujeito “trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado”.

Protege-se a administração da justiça.

2. SUJEITOS DO DELITO

Tratando-se de crime próprio, sujeito ativo só pode ser o advogado, regularmente inscrito na OAB, ou estagiário de advocacia, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Não desfigura o delito a circunstância de o advogado não receber remuneração. Pouco importa, também, que seja constituído ou nomeado pelo Juiz.

Sujeito passivo imediato é o Estado. Secundariamente, aparece como sujeito passivo (mediato) a pessoa prejudicada.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta consiste em trair o dever profissional, prejudicando o interesse que alguém confiou, em Juízo, ao patrocínio do sujeito.

O comportamento pode ser comissivo ou omissivo. O advogado pode trair o cliente, mostrando ao outro litigante um documento importante ou

perdendo o prazo processual.

São requisitos da figura típica:

1ª) Prejuízo de interesse.

Pode ser material ou moral. Deve ser legítimo. Não há crime quando é prejudicado interesse ilegítimo, subsistindo apenas infração a dever profissional.

O prejuízo deve ser efetivo, não bastando o potencial.

2ª) Que o patrocínio da causa tenha sido confiado e aceito pelo sujeito.

É necessário que exista um mandato, seja por escrito ou meramente verbal, remunerado ou não, tenha sido o agente constituído pela parte ou nomeado pelo Juiz. Se o fato é cometido por ocasião da feitura de um parecer, consulta etc., não haverá delito, restando somente uma falta disciplinar do profissional.

3ª) Que haja uma causa judicial. A traição deve ocorrer “em juízo”, como diz o tipo, civil ou criminal.

Havendo consentimento do prejudicado, não subsiste crime por ausência de antijuridicidade, desde que disponível o interesse confiado ao profissional.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de trair o dever profissional, prejudicando o interesse confiado ao agente.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Cuidando-se de crime material, consuma-se com a produção do efetivo prejuízo.

A tentativa é possível na forma típica comissiva. Ex.: o advogado remete, via postal, um documento para o litigante adverso, contendo um segredo, porém a carta se extravía. Doutrinariamente, ocorre tentativa do crime, em

concurso com tentativa do crime do art. 154 do CP.

A tentativa é inadmissível na forma omissiva.

6. PENA E AÇÃO PENAL

As penas são de detenção, de seis meses a três anos, e multa. O patrocínio infiel, dada a pena mínima (não superior a um ano), admite o delito o sursis processual (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Patrocínio simultâneo ou tergiversação

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Constitui patrocínio simultâneo ou tergiversação o fato de o advogado ou procurador judicial defender na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias (CP, art. 355, parágrafo único).

A incriminação protege a administração da justiça.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo só pode ser o advogado ou estagiário de advocacia. Aquele deve estar regularmente inscrito na OAB. A figura do estagiário de advocacia está prevista no art. 3º da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Trata-se de crime próprio.

Sujeito passivo imediato é o Estado; mediato, a pessoa que sofre o prejuízo em decorrência da conduta do sujeito.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O tipo prevê duas condutas:

1ª) patrocínio simultâneo; e

2ª) patrocínio sucessivo de partes contrárias (tergiversação).

No primeiro caso, o advogado ao mesmo tempo defende interesses, na mesma causa, de partes contrárias. Não é preciso que seja no mesmo processo, uma vez que a figura penal fala “na mesma causa”. Uma causa pode ter mais de um processo.

Na segunda hipótese, o advogado, após defender um litigante, passa a defender o outro.

O verbo típico é defender, que significa pleitear alguma coisa em favor de alguém, patrocinar.

Partes contrárias são as pessoas com interesses diversos na mesma causa (pessoas físicas ou jurídicas, autor, réu, ofendido etc.).

O consentimento exclui a ilicitude da conduta.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de defender, ao mesmo tempo ou sucessivamente, interesses de partes contrárias em litígio.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Trata-se de crime formal, consumando-se com a realização de ato processual indicativo do patrocínio infiel ou tergiversação. O simples fato de receber mandato não caracteriza o ilícito penal.

Não se exige nenhum prejuízo em decorrência da conduta criminosa.

A tentativa é admissível nas duas modalidades (patrocínio infiel e tergiversação).

6. PENA E AÇÃO PENAL

As penas são de detenção, de seis meses a três anos, e multa. Tendo em vista a pena mínima (não superior a um ano), afigura-se cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Sonegação de papel ou objeto de valor probatório

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O CP, no art. 356, pune o sujeito que “inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador”.

Tutela-se a administração da justiça.

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime próprio, somente podendo ser cometido por advogado ou procurador. Aquele deve estar inscrito na OAB. Por procurador, entende-se procurador judicial.

Sujeito passivo principal é o Estado; secundário, quem sofre o prejuízo.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Dois são os verbos (crime de forma múltipla): inutilizar e deixar de restituir. Inutilizar é deixar o documento ou o papel imprestável, destruindo, riscando ou borrando. Pode ser total ou parcial. Não restituir significa reter, sonegar.

Os objetos materiais são: autos de processo criminal ou cível; documento de valor probatório (contrato, título de crédito etc.); objeto de valor probatório (qualquer coisa que demonstre a existência de um fato de relevância jurídica).

O crime pressupõe que o sujeito, na qualidade de advogado ou procurador judicial, tenha recebido em confiança o objeto material de

funcionário da justiça ou terceiro particular, antes ou durante a tramitação de processo (salvo no caso de autos).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de inutilizar ou não devolver o objeto material. A simples negligência não tipifica o fato.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Na inutilização, o crime atinge o momento consumativo quando o objeto material perde o seu valor probatório (total ou parcial). Na forma de sonegação de autos, a consumação ocorre quando o sujeito, regularmente intimado, de acordo com a legislação processual, nega-se a devolvê-los. Na sonegação de documento ou objeto, consuma-se o crime quando o sujeito, legalmente solicitado à restituição, deixa de devolvê-lo por um lapso temporal juridicamente relevante.

Na forma comissiva de inutilização é possível a tentativa; na omissiva de sonegação, é impossível.

6. PENA E AÇÃO PENAL

As penas são cumulativas: detenção, de seis meses a três anos, e multa. A figura penal admite a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95). A ação penal é pública incondicionada.

Exploração de prestígio

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo. 6. Qualificação doutrinária. 7. Tentativa. 8. Tipo qualificado. 9. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Pune-se, no art. 357 do CP, o fato de o agente “solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha”.

Protege-se o prestígio da administração da justiça.

2. SUJEITOS DO DELITO

Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de exploração de prestígio.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta se expressa em dois verbos: solicitar, que significa requerer, pedir etc.; e receber, que quer dizer aceitar.

O objeto material é dinheiro ou qualquer outra utilidade. O dinheiro pode ser nacional ou moeda estrangeira. A utilidade pode ser material ou moral (o tipo menciona qualquer utilidade, indicando caso de interpretação analógica).

A solicitação ou o recebimento de dinheiro ou qualquer outra utilidade deve ter por fundamento a desculpa fantasiosa de que o sujeito vai influenciar as pessoas mencionadas na figura típica. Trata-se, na verdade, de uma fraude, mentira. Se, efetivamente, a utilidade ou o dinheiro se

destina às pessoas enumeradas, há crime de corrupção ativa ou passiva (CP, arts. 317 e 333).

A lei expressamente cita as pessoas que servem à justiça (juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha). O rol é taxativo, não podendo ser ampliado.

Por órgãos do Ministério Público deve-se entender os membros do Ministério Público estadual, ou seja, Promotor de Justiça e Procurador de Justiça, ou do Ministério Público da União, isto é, Procurador da República, Procurador Regional da República, Subprocurador-geral da República, Procurador do Trabalho, Promotor de Justiça Militar, Procurador de Justiça Militar etc.

Os elementos objetivos do tipo se assemelham aos do crime descrito no art. 332 do CP, ao qual remetemos o leitor.

Se o sujeito não solicita a vantagem ou não a recebe, apenas anunciando que pode influir nas pessoas indicadas, inexistente delito.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de solicitar a vantagem ou recebê-la, com a desculpa (a pretexto) de influenciar as pessoas indicadas.

5. MOMENTO CONSUMATIVO

Consuma-se o delito com a simples solicitação ou o recebimento. Na solicitação, existe crime ainda que ocorra rejeição.

6. QUALIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

Na modalidade de solicitar, o crime é formal; na de receber, é material.

7. TENTATIVA

Na solicitação verbal, o crime não admite a figura da tentativa; na por escrito (delito plurissubsistente), admite.

Na forma de recebimento, é admissível a tentativa.

8. TIPO QUALIFICADO

A pena é agravada se o sujeito alega ou insinua que a vantagem solicitada ou recebida se destina às pessoas enumeradas na definição (art. 357, parágrafo único). No primeiro caso, ele deixa claro que o dinheiro ou a utilidade se destinam àquelas pessoas (alegação); no segundo, deixa entrever, dá a entender (insinuação). Há a qualificadora, ainda que a pessoa não leve a sério a alegação ou a insinuação do sujeito.

9. PENA E AÇÃO PENAL

As penas, para o tipo simples, são de reclusão, de um a cinco anos, e multa (admite a suspensão condicional do processo – art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Para a forma típica qualificada, as penas detentiva e pecuniária são aumentadas de um terço.

A ação penal é pública incondicionada.

Violência ou fraude em arrematação judicial

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O legislador, no art. 358 do CP, pune o fato de o sujeito “impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem”.

Procura-se proteger a administração da justiça no que tange às arrematações judiciais.

Esse delito se assemelha aos descritos nos arts. 93 e 95 da Lei n. 8.666/93 (impedimento, perturbação ou fraude de licitação pública; antigo art. 335 do CP), deles se diferenciando somente quanto à objetividade jurídica: aqui, protege-se a arrematação judicial; pela incriminação daqueles fatos, tutela-se a licitação pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo.

Sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, surgem como sujeitos passivos os concorrentes lesados.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Os mesmos comentados no crime de impedimento etc. de licitação pública (antigo art. 335 do CP), ao qual remetemos o leitor.

Note-se que a descrição típica se refere à arrematação judicial de natureza particular. Tratando-se de arrematação promovida pela

administração pública (federal, estadual ou municipal), há os crimes dos arts. 93 e 95 da Lei n. 8.666/93 (antigo art. 335 do CP).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de impedir ou fraudar a arrematação judicial etc. Não há forma culposa.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Seguem os mesmos princípios expostos na apreciação do crime do art. 335 do CP.

6. PENA E AÇÃO PENAL

As penas são alternativas: detenção, de dois meses a um ano, ou multa. Nesse caso, trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

Ocorrendo violência física e dela resultando lesão corporal (leve, grave ou gravíssima) ou morte, o sujeito responde por dois crimes em concurso material: pelo do art. 358 e pelo delito em que consistir a violência. É o que determina a parte final do dispositivo sancionador: pena tal, "além da pena correspondente à violência".

A ação penal é pública incondicionada.

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O CP, no art. 359, define como delito o fato de o sujeito “exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial”.

Tutela-se, na espécie, o normal desenvolvimento da justiça, principalmente a criminal. A incriminação visa a proteger a autoridade da justiça contra quem, privado por decisão judicial de exercer um direito etc., rebela-se, procurando menosprezar seus princípios. Tratando-se de decisão proferida em face da prática de crime de trânsito, de aplicar-se o art. 307 do Código de Trânsito (Lei n. 9.503, de 23-9-1997).

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime próprio, uma vez que só pode ser cometido por quem foi suspenso ou privado, por decisão judicial, de exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus (CP, art. 92, I a III).

Sujeito passivo é o Estado, titular da administração da justiça.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo exercer, que significa desempenhar, executar, exercitar. Cuida-se de punir o fato de quem, após uma decisão judicial impondo um dos efeitos específicos da condenação previstos no art. 92 do CP, passa a desempenhar uma atividade, direito, função etc. de que estava

suspenso ou privado de executar: perda de cargo ou função, incapacidade para o exercício do pátrio poder etc. e inabilitação para dirigir veículo.

A desobediência ao cumprimento das penas restritivas de direitos concernentes às interdições temporárias previstas no art. 47 do CP, segundo entendemos, não constitui o delito descrito nesta disposição, tendo em vista que a rebeldia do condenado conduz à conversão da sanção em pena privativa de liberdade (art. 45, II).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de exercer a atividade etc. de que foi privado ou suspenso por decisão condenatória criminal. É necessário que o sujeito tenha conhecimento da proibição judicial. Inexiste a forma culposa.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Consuma-se o delito no momento em que o sujeito, desobedecendo o conteúdo da decisão judicial, passa a realizar a atividade ou a exercer a função etc. de que estava suspenso ou de cujo exercício estava privado.

A tentativa é possível.

6. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

O crime constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), sendo abrangido pela competência material dos Juizados Especiais Criminais. Comporta, em face disso, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Capítulo XI

DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS

Contratação de operação de crédito

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Elemento espacial. 7. Exclusão da ilicitude. 8. Consumação e tentativa. 9. Operação de crédito irregular. 10. Responsabilidade civil, administrativa e penal. 11. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O crime de contratação de operação de crédito consiste em “ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa”. O art. 359-A foi inserido no CP pela Lei n. 10.028, de 19 de outubro de 2000, que acrescentou o Capítulo IV ao Título XI do CP, que define crimes contra a Administração Pública, além de alterar a legislação referente ao comportamento funcional de agentes públicos.

A descrição desses delitos no CP representa o tratamento criminal para o descumprimento das disposições da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Ilícitos administrativos praticados no exercício da função pública, no que tange ao controle, aplicação e disponibilidade do erário, ganham status de crime. Não se tolera mais o desrespeito à exigência legal de autorização legislativa por parte dos agentes responsáveis pelos atos de gestão financeira do Estado.

O objeto da tutela penal é a probidade da administração, no que diz

respeito às operações realizadas no âmbito das finanças públicas do Estado. Pune-se o desrespeito ao princípio da legalidade administrativa, quando realizadas condutas de contratação sem prévia autorização legislativa.

2. SUJEITOS DO DELITO

Trata-se de crime próprio, pois se exige uma condição especial do sujeito ativo. A Lei Complementar n. 101/2000, em seu art. 1º, “estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”, vinculando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Incluiu, ainda, o Poder Executivo, o Poder Legislativo (abrangidos os Tribunais de Contas), o Poder Judiciário e o Ministério Público, além das fundações públicas, autarquias etc. De ver-se, entretanto, que as operações de crédito, constituindo atividade de gestão financeira do Estado, são de atribuição do Poder Executivo, excluindo os demais entes enumerados pelo dispositivo citado em relação à qualificação especial do sujeito ativo. Por isso, o autor do crime será sempre um agente público. Não, porém, qualquer um. Só pode cometer o crime quem possui atribuição, conferida por lei, para emitir o ato administrativo, seja ordem, autorização para operação de crédito ou competência para a sua realização. Se o ato administrativo de ordem, p. ex., for emanado de agente incompetente, estará eivado de vício e será passível de anulação pelo poder público, tornando atípico o fato.

Tratando-se do Presidente da República, de ver-se o disposto no art. 10 da Lei n. 1.079/50, alterada pela Lei n. 10.028/2000. Se o autor for Prefeito Municipal, de observar-se o art. 1º, XX, do Decreto-lei n. 201/67, alterado pela mesma Lei.

Sujeitos passivos são a União, os Estados, os Municípios etc.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O tipo incriminador traz no preceito primário três condutas: ordenar,

autorizar e realizar. Trata-se de crime de conduta múltipla alternativa, ou de conteúdo variado.

Ordenar é dar ordem, determinar, mandar que se faça algo. O administrador toma a atitude, determina que se realize operação de crédito, sem anterior autorização legislativa. A iniciativa é do mandante.

Autorizar significa dar permissão, corroborar, validar. O agente não tem a iniciativa na contratação de operação de crédito, mas lhe concede validade: o ato impulsionador é de outrem. De observar-se que pode ocorrer, nos atos administrativos complexos, a necessidade de atos preparatórios ou acessórios, como condição de validade do ato principal.

Realizar é efetivar, pôr em ação ou em prática, efetuar.

O legislador descreveu no tipo três condutas a fim de abranger tanto o agente público que emite o ato administrativo como o que realiza a operação de crédito. Comportamento único daria margem à inaplicabilidade do tipo: quem realizasse a operação argumentaria sempre estar agindo em nome alheio, de quem emitiu a ordem. Este, por sua vez, nunca estaria “realizando” a operação de crédito.

Operação de crédito é o “compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros” (art. 29, III, da LC n. 101/2000, ampliando o tipo).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

O crime só é punível a título de dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo. Abrange o conhecimento da inexistência de prévia autorização legislativa (dolo abrangente). O tipo subjetivo não exige nenhuma

finalidade especial (favorecimento de outrem, lucro etc.).

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

A conduta só é incriminada quando realizada “sem prévia autorização legislativa”. A falta de autorização anterior constitui elemento normativo do tipo. Se presente, o fato é atípico. Se o agente tem a autorização legislativa anterior e contrata, mas ultrapassa os limites nela previstos, a tipificação é outra (parágrafo único, I, do art. 359-A do CP).

6. ELEMENTO ESPACIAL

A figura típica contém a expressão “interno ou externo”, constituindo elemento espacial. Independe, para ocorrência do delito, a circunstância de o ente federativo efetivar operação de crédito nacional ou internacional. Sendo dentro do território nacional ou relacionado com Estado estrangeiro, caberá a reprimenda do art. 359-A.

7. EXCLUSÃO DA ILICITUDE

É possível a ocorrência das causas de exclusão da antijuridicidade previstas no art. 23 do CP. Ex.: estado de necessidade. Nesse caso, afastada a ilicitude, exclui-se o delito.

8. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime atinge a consumação com a ordem, autorização ou realização da operação de crédito. Nas três modalidades de comportamento, cuida-se de crime de mera conduta, uma vez que os tipos não exigem resultado naturalístico. Emitida a ordem ou autorização para contratação de operação de crédito, sem a anterior permissão, estão preenchidos todos os elementos da definição legal. A operação de crédito, qualquer que seja, não precisa ser efetivada. A manifestação de vontade do ente público, unilateral, seja advinda de uma ordem, seja de uma autorização, é suficiente para consumação do crime.

O verbo realizar exige mais do que a manifestação de vontade unilateral do administrador. É necessário que se materialize a contratação de operação de crédito, consumando o delito.

Nas modalidades de “ordenar” e “autorizar”, a tentativa é inadmissível pela impossibilidade de fracionar a conduta. O tipo requer que o sujeito ativo só possa ser o administrador responsável, competente para “ordenar” ou “autorizar” a operação de crédito. Pertencendo o autor à Administração Pública, sua atividade se exterioriza por intermédio de atos administrativos. Então, ou o ato administrativo, de ordem, p. ex., foi praticado, e o crime está consumado, ou faltam requisitos legais para sua validade, tornando o fato atípico. É necessário, contudo, que o ato administrativo, formalmente perfeito, seja exteriorizado. Na hipótese de “realizar”, a tentativa é admissível.

9. OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR

De acordo com o parágrafo único do art. 359-A do CP, incorre na mesma pena do caput do dispositivo “quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:

I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei”.

No primeiro caso, o agente público tem a autorização legislativa para contratação de operação de crédito. Ele, entretanto, exorbita os poderes nela inseridos. A questão é quantitativa, tendo em vista que o administrador deve obediência aos limites estabelecidos na autorização, seja oriunda de lei ou de resolução do Senado Federal.

O inciso II refere-se ao “montante da dívida consolidada”. Se a contratação de operação de crédito resulta em desrespeito ao limite

máximo do montante previamente autorizado por lei, há adequação típica. A Lei Complementar n. 101/2000 define, em seu art. 29, I, dívida consolidada como o “montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operação de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses” (destaque nosso).

10. RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL

Nos termos do art. 73 da Lei Complementar n. 101/2000, as infrações nele previstas devem ser punidas de acordo com o CP, a Lei n. 1.079/50, o Decreto-lei n. 201/67, a Lei de Improbidade Administrativa e as demais normas pertinentes. Com isso, será comum a coexistência, para o mesmo fato, da apuração de responsabilidade civil, administrativa e penal.

11. PENA E AÇÃO PENAL

É cominada pena de reclusão, de um a dois anos. Não há previsão de multa.

O fato consubstancia infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). Trata-se, portanto, de delito abrangido pela competência *ratione materiae* dos Juizados Especiais Criminais. Admite, em razão da pena máxima, a transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e, dada a pena mínima não superior a um ano, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 359-B, constitui delito o fato de “ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei”.

A Lei Complementar n. 101/2000 trata do assunto em seu art. 42, que configura o fundamento da incriminação. Não se permite ao administrador assumir obrigações financeiras sem que haja recursos disponíveis para, posteriormente, efetuar o pagamento. Evita-se que obrigações de despesas sejam passadas às próximas gestões, prejudicando o bom andamento da administração fiscal do Estado.

Tutelam-se a probidade e a regularidade na administração das finanças públicas.

2. SUJEITOS DO DELITO

Crime próprio, só pode ser cometido por agente público. É sujeito ativo do crime o administrador competente para assumir a obrigação de despesa, incluindo-a em restos a pagar. A Lei Complementar n. 101/2000, no art. 42, esclarece quais as pessoas proibidas de contrair essa espécie de obrigação: titular de poder público ou órgão referido em seu art. 20. Admite-se, entretanto, a participação de terceiro não qualificado.

Sujeito passivo é o Estado.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Há dois núcleos no tipo incriminador: ordenar e autorizar. Ordena quem determina, quem faz prevalecer sua vontade. No verbo “autorizar”, da mesma maneira, apesar de a permissão ser emitida complementando a vontade de outrem, prevalece o princípio da legalidade administrativa para a admissão de inscrição em restos a pagar, i.e., previsão expressa para o ato do administrador.

A conduta típica pode apresentar-se sob duas formas:

1ª) ordem ou autorização de inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada;

2ª) ordem ou autorização de inscrição de despesa que exceda o limite estabelecido em lei.

Na primeira hipótese, o administrador assume despesa que passará à próxima gestão e não efetua o resguardo necessário, o empenho de recursos para saldar, cumprir a obrigação. Ele não pode, pois, inscrever despesas que não serão cumpridas integralmente em seu mandato, ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte. Para isso, deve separar os recursos que ensejaram o cumprimento da obrigação. Com isso, há segurança nas relações jurídicas das diferentes gestões fiscais.

Amolda-se ao tipo, também, a ordem ou autorização de inscrição, em restos a pagar, de despesa que ultrapassa limite estabelecido em lei. Para manter a regularidade da gestão fiscal do Estado, o administrador deve respeitar o limite dos encargos financeiros passados ao próximo exercício.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não foi previamente empenhada ou de despesa que exceda limite estabelecido em lei. Não se exige finalidade específica por parte do agente (p. ex.:

prejudicar o sucessor, rival político etc.).

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Encontra-se na expressão “que exceda limite estabelecido em lei”. É lícita e comum a inscrição de despesas em restos a pagar, passando-se encargos financeiros de uma gestão à outra. Por isso, se o agente realizou a conduta nos limites estabelecidos em lei, o fato é atípico.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a vigência da ordem ou autorização para inscrição de despesa em restos a pagar. O meio usado pelo autor é o ato administrativo, ordem ou autorização, o que torna a conduta unissubsistente e, por isso, consequentemente, impossível a figura tentada.

E se o agente emite a ordem ou autorização e, depois de vigente, o ato administrativo vem a ser revogado ou anulado?

A alteração administrativa da essência do ato emanado pelo agente competente, seja anulação ou revogação, não tem o condão de retirar a tipicidade do fato. Tratando-se de crime de mera conduta, o crime já está consumado. Se o próprio agente, entretanto, invalidar ou revogar sua ordem ou autorização, incidirão os benefícios da lei penal, como a atenuação genérica da pena (art. 65, III, b, do CP).

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de seis meses a dois anos.

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O fato admite transação penal e suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Elemento temporal do tipo. 6. Consumação e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O CP, no art. 359-C, prevê como crime o fato de “ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa”.

A Lei Complementar n. 101/2000, que estabeleceu as normas regulamentadoras da responsabilidade na gestão fiscal com relação às finanças públicas, demonstrou preocupação com a transparência e equilíbrio das contas estatais. Por isso, diversos dispositivos visam impedir atos de gestores do dinheiro público que resultem em prejuízo para seus sucessores e para a regularidade da gestão fiscal do Estado. Seguindo o mesmo caminho, a Lei n. 10.028/2000, que incluiu no CP o capítulo referente aos crimes contra as finanças públicas, criou mais de um tipo penal que pune atos funcionais irregulares de final de mandato geradores de despesas a serem cumpridas pelas próximas gestões.

Tutelam-se a regularidade e o equilíbrio das contas públicas em relação à sucessão de administradores titulares de mandato.

2. SUJEITOS DO DELITO

O sujeito ativo é o titular de mandato com atribuição para assumir obrigação em nome do ente público que representa. Por isso, cuida-se de

crime próprio. É importante notar que a qualidade especial do sujeito ativo encontra-se no fato de ocupar o cargo com atribuição legal para a assunção de obrigação prevista no tipo. Tratando-se de mandato, poderá ocorrer substituição da pessoa inicialmente competente para assumir a obrigação no respectivo período típico. Com isso, poderá ser autor do crime pessoa que está apenas temporariamente no cargo, como, por exemplo, o Vice-Presidente, o Vice-Governador etc., desde que no efetivo exercício de cargo com atribuição legal para assumir a obrigação típica.

Sujeito passivo é o ente da Federação a que pertence o sujeito ativo (exs.: União, Estado, Município etc.).

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Pune-se a ilegal assunção de obrigação por meio da descrição de duas espécies de ato administrativo: ordem e autorização. No primeiro caso, a iniciativa é do autor, que emite a ordem para criar o vínculo obrigacional. No segundo, por sua vez, a iniciativa é de outrem e o autor anui, concorda, emite o ato de autorização imprescindível para gerar a obrigação.

Assunção, do latim *assumptione*, é a ação ou resultado de assumir. A obrigação oriunda da ordem ou autorização, descrita no tipo, está diretamente ligada à criação de despesa que acaba por ser transmitida à próxima gestão. A conduta pode ser realizada sob duas formas:

1ª) assunção de obrigação cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro;

2ª) assunção de obrigação que resulte em parcela a ser paga no exercício seguinte e que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa.

O administrador, no lapso temporal descrito no tipo, deve assumir obrigação para inteiro cumprimento dentro de seu mandato, ou seja, é permitido e não há crime se o gestor das finanças públicas assume

obrigação que será inteiramente cumprida até o final de seu exercício. A lei, implicitamente, permite que da obrigação nascida no período descrito resultem parcelas para cumprimento no próximo exercício, pelo próximo administrador, desde que haja disponibilidade de caixa. A tipicidade do fato nasce quando a ordem ou autorização cria obrigação, gerando despesa que será passada ao próximo exercício, sem a necessária disponibilidade de caixa.

Para não haver dúvida quanto à abrangência do tipo incriminador, o legislador inseriu na descrição os termos “mandato”, referente ao Executivo e Judiciário, e “legislatura”, concernente aos membros do Poder Legislativo.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

O crime só é punível a título de dolo, vontade livre e consciente de assumir obrigação geradora de despesa que acarrete cumprimento total ou parcial no exercício próximo. Deve abranger o conhecimento de que a despesa não pode ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso haja parcela a ser saldada no seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa.

5. ELEMENTO TEMPORAL DO TIPO

A figura típica descreve como delito o fato da assunção de obrigação “nos últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura”. A inclusão do elemento temporal no tipo deve-se ao fato da objetividade jurídica do crime: tutela-se o equilíbrio das contas públicas no tocante à rotatividade dos administradores titulares de mandato.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Consuma-se o delito com a ordem ou autorização de indevida assunção de obrigação, dentro do período previsto no tipo. Atente-se para o seguinte: é a assunção de obrigação que deve encontrar-se dentro do prazo, e não o

ato administrativo de ordem ou autorização. De lembrar-se que a ameaça de punição penal visa a proteger o equilíbrio das contas públicas em relação à sucessão de agentes públicos no exercício do poder de gestão financeira do Estado (rotatividade de administradores titulares de mandato). Por isso, para consumação do crime, o ato pode ser anterior aos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, desde que a obrigação faça referência a esse prazo.

A conduta se manifesta por meio de ato administrativo. Assim, ou o ato de ordem ou autorização foi emitido, realizado, ou ainda se encontra em fase de preparação. Tratando-se de crime unissubsistente, a tentativa é inadmissível.

7. PENA E AÇÃO PENAL

O crime é punido com pena de reclusão, de um a quatro anos.

Por se cuidar de delito com pena mínima não superior a um ano, afigura-se cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação é pública incondicionada.

Ordenação de despesa não autorizada

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O art. 359-D do CP define como crime o fato de “ordenar despesa não autorizada por lei”.

A Lei Complementar n. 101/2000 regulamenta, no Capítulo IV, a geração de despesas (Seção I) e a despesa com pessoal (Seção II). Não se tolera mais do administrador o gasto irregular na gestão das verbas públicas. Dessa maneira, a infração administrativa de determinar despesas não autorizadas transforma-se em conduta típica.

Tutelam-se a probidade e a normal regularidade financeira do Estado no que diz respeito ao equilíbrio e transparência das contas públicas.

2. SUJEITOS DO DELITO

Exigindo uma qualidade especial do sujeito ativo, trata-se de crime próprio. Somente podem cometê-lo os agentes públicos legalmente investidos na atribuição de gerar despesa pública.

Sujeito passivo é a entidade pública a que pertence o autor da ordem. Ex.: a União, se o Presidente da República figura como autor da ordem geradora da despesa.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A conduta incriminada consiste em o agente competente ordenar, determinar a geração de despesa, contrariando a lei.

É imprescindível que haja lei disciplinando a gestão financeira, no tocante

à criação de despesa. Trata-se da Lei Orçamentária. O fundamento para alteração do CP, nele inserindo o art. 359-D, encontra-se na Lei Complementar n. 101/2000. Esta, nas disposições sobre a geração de despesa, prevê que a ação governamental que resulte no aumento de despesa deve ser acompanhada de declaração de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Cumprindo respeitar a legalidade administrativa, o gestor das finanças públicas, mesmo competente, não pode ordenar despesa senão de acordo com autorização da Lei Orçamentária.

Ressalte-se que o autor do crime não é beneficiado com a criação de despesa, e nem sempre a Administração Pública será prejudicada com a ordem. A falta de requisitos exigidos pela lei orçamentária para criação da despesa resulta no crime, mesmo que não decorra consequência danosa ao poder público.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, vontade livre e consciente de ordenar a geração de despesa, contrariando a lei orçamentária respectiva. Não se exige nenhuma finalidade específica, mas é preciso que o sujeito tenha conhecimento de que a despesa não se encontra autorizada em lei (dolo abrangente).

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

Emitido o ato administrativo de ordem (ex.: decreto do Presidente da República), está consumado o delito. Trata-se de crime de mera conduta. Pouco importa, para a consumação, que a ordem seja posteriormente revogada, anulada etc.

A conduta se perfaz com um único ato administrativo, tornando inadmissível a tentativa. Ou o agente emite a ordem, e o crime está consumado, ou realiza atos preparatórios impuníveis.

6. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de reclusão, de um a quatro anos.

Em razão da pena mínima (não superior a um ano), admite o delito o sursis processual (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Prestação de garantia graciosa

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Consumação e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Configura o delito o fato de “prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei” (art. 359-E). A Lei Complementar n. 101/2000 dispensa, no Capítulo VII, uma seção para regulamentar as garantias e contragarantias concedidas pelas pessoas que se submetem às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade da gestão fiscal. Os dispositivos referentes à matéria condicionam a validade da garantia à contragarantia em valor igual ou superior. A importância dada pela lei ao assunto, visando impedir que as ações de gestores sejam graciosas, “gentis”, confiantes na adimplência daqueles que contratam com o poder público, resultou na inclusão do crime previsto no art. 359-E do CP, acrescentado pela Lei n. 10.028/2000. Pune-se, assim, o agente público que concede garantia em operação de crédito desrespeitando a imposição de constituir contragarantia em valor igual ou superior.

A objetividade jurídica é a proibição na gestão fiscal do Estado.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo é o agente público competente para prestar garantia em operação de crédito. Por exigir essa qualidade especial do autor, cuida-se de crime próprio, seguindo a mesma construção dos demais tipos acrescentados ao CP pela Lei n. 10.028/2000.

Sujeito passivo é o ente público onde o sujeito ativo exerce suas funções. Ex.: o Município, se o sujeito ativo for o Prefeito, o Vice-Prefeito etc.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O núcleo do tipo é o verbo “prestar”, que significa conceder, dar ou fazer sob certas condições. O agente público responsável pela concessão de garantia incorre no crime se a conceder sem prevenção de possíveis riscos que a operação de crédito pode trazer, ou seja, é inafastável a contragarantia para a regular gestão fiscal do Estado. O art. 40 da Lei Complementar n. 101/2000 determina que “os entes poderão conceder garantia em operações de crédito...”. De ver-se, entretanto, que, de acordo com § 1º do mesmo dispositivo, “a garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida...”. Assim, o fato somente é considerado típico se o agente prestar garantia sem constituir contragarantia em valor menor em relação à concedida. A finalidade da norma reside em impedir as garantias gratuitas, impondo o dever de constituir contragarantia. A punição seria inócua se não houvesse a obrigatoriedade de haver o mesmo valor, ou maior, da contragarantia.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de prestar garantia sem constituir contragarantia em valor no mínimo igual àquela. Não se exige finalidade específica (p. ex., favorecer terceiro, sabendo que se encontra inadimplente). Note-se que, mesmo provando que a contragarantia era dispensável na operação de crédito, o fato permanece típico.

5. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime atinge a consumação quando o agente público concede a garantia em operação de crédito sem constituir a contragarantia nos moldes

típicos exigidos. A expressão “sem que tenha sido constituída” pode dar a ideia de anterioridade. De observar-se, contudo, que se mostra comum a circunstância de a contragarantia, em contrato administrativo, ser constituída no mesmo momento da garantia. Anterior ou concomitante, o crime está consumado. A tentativa é inadmissível.

6. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de três meses a um ano.

O fato constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95). O delito, portanto, é de competência dos Juizados Especiais Criminais, admitindo, desse modo, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Não cancelamento de restos a pagar

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Elemento normativo do tipo. 6. Momento consumativo e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

O legislador, no art. 359-F do CP, define como crime o fato de “deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei”.

Demonstra-se a preocupação com a administração das finanças públicas, regulamentando a transição dos agentes públicos. Exige-se que o gestor mantenha as contas públicas dentro da regularidade, evitando-se o efeito “bola de neve” nas sucessivas administrações. Essa intenção vem expressamente prevista no § 1º do art. 1º da Lei Complementar n. 101/2000, quando menciona que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas...”.

A objetividade jurídica é a regularidade na administração das finanças públicas, no que diz respeito à inércia diante de encargos financeiros passados à próxima gestão fiscal.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo é o agente público com atribuição legal de corrigir o desvio no montante de restos a pagar. Trata-se de crime próprio. Deve ter a atribuição legal de cancelar a inscrição irregular de restos a pagar. Não é imprescindível, porém, que o autor inerte seja o mesmo que ordenou a inscrição superior ao permitido em lei. A obrigação de cancelamento da

inscrição irregular pode recair em pessoa diversa da que havia ordenado ou autorizado esse procedimento.

Sujeitos passivos são a União, os Estados, os Municípios etc.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

O crime é omissivo próprio, i.e., a simples conduta negativa do autor, deixando de tomar as providências exigidas para corrigir a irregularidade de inscrição de restos a pagar em valor superior ao permitido em lei, já constitui delito, independentemente de ulterior dano ao patrimônio público.

“Deixar de” é abster-se, não cumprir a obrigação. A conduta se apresenta sob três formas:

1ª) “Deixar de ordenar”: o autor deve tomar a iniciativa do cancelamento, porém não emite a ordem. Não é o administrador que efetiva o cancelamento, mas terceira pessoa a seu comando. A ordem, que não foi emitida, tornaria sem efeito o montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

2ª) “Deixar de autorizar”: já há iniciativa de corrigir o desvio por parte de terceira pessoa, porém, o autor, que possui a atribuição legal de corroborar com o cancelamento, fica inerte, não impedindo que se cancele o montante inscrito em valor superior ao previsto em lei. A autorização deve ser imprescindível para a correção da ilegalidade.

3ª) “Deixar de promover”: o sujeito tem atribuição de corrigir o desvio, cancelando o montante inscrito em valor superior ao descrito na lei. Apesar de ser a pessoa indicada para o encargo, não efetua o cancelamento.

Como se observa, a Lei n. 10.028/2000, para dar maior efetividade à Lei Complementar n. 101/2000, pune a irregularidade e o deixar de corrigi-la em dois tipos autônomos. O agente público não pode ultrapassar os limites legais na inscrição de restos a pagar e, se ocorrer excesso, deve cancelar a inscrição. A criação de dois tipos justifica-se, pois nem sempre há

identidade de quem faz a inscrição e de quem tem a obrigação legal de ordenar, autorizar ou promover seu cancelamento.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de abster-se, não ordenar, não autorizar ou não promover o cancelamento de restos a pagar, cujo valor excede o permitido em lei.

5. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

O fato só é punível se o autor permanece inerte em relação ao cancelamento do montante inscrito em valor superior ao “permitido em lei”. O não cancelamento de inscrição de restos a pagar regular é atípico. Se há irregularidade por outro motivo, que não seja o valor maior previsto no tipo penal, o fato é atípico, podendo ensejar responsabilidade administrativa.

6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Crime omissivo próprio, atinge a consumação com a simples conduta negativa. Presente a atribuição legal de ordenar, autorizar ou promover o cancelamento, o crime se consuma com a inércia do autor. A tentativa é inadmissível.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de detenção, de seis meses a dois anos.

O crime constitui infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n. 9.099/95), sendo abrangido pela competência material dos Juizados Especiais Criminais. Comporta, em face disso, transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95) e suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Elemento típico temporal. 6. Consumação e tentativa. 7. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

Nos termos do art. 359-G do CP, acrescentado pela Lei n. 10.028/2000, configura delito o fato de “ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura”.

Com o mesmo alicerce dos demais tipos penais contra as finanças públicas, qual seja, a Lei Complementar n. 101/2000, cria-se tratamento penal para o fato de o autor aumentar a remuneração de agentes públicos no final do mandato. O costume político de conceder aumento a funcionários públicos quando se caminha para o final do mandato, deixando o encargo financeiro resultante ao sucessor, não é mais penalmente tolerado. Essa irregularidade, já prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, resulta num tipo penal a fim de coibir os desvios capazes de alterar a regularidade e equilíbrio das contas públicas.

Tutela-se, pois, a regularidade das contas públicas, no tocante à rotatividade dos gestores das finanças públicas, titulares de mandato.

2. SUJEITOS DO DELITO

Apenas os titulares de mandato com competência para aumentar a despesa total com pessoal podem ser sujeitos ativos do crime, que é próprio. O conceito engloba os Três Poderes. Todos os agentes públicos com poder legal de aumentar o gasto do ente da Federação, com relação a

quaisquer espécies remuneratórias (art. 18 da LC n. 101/2000), enquadram-se no conceito de sujeito ativo.

Sujeito passivo é a entidade pública da Federação onde o autor exerce o mandato.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

A figura típica menciona três núcleos: ordenar, autorizar e executar.

Ordenar é determinar, mandar que alguém faça algo. Autoriza, por sua vez, quem concorda, dá validade, avaliza a ideia de outrem. Na ordem, a iniciativa é do autor. Na autorização, o sujeito apenas complementa a intenção já manifestada, corroborando. O último verbo é executar, que significa levar a efeito, fazer, efetuar.

A análise dos núcleos do art. 359-G do CP, à vista da Lei n. 10.028/2000, demonstra a preocupação do legislador em subsumir a conduta funcional irregular nas várias figuras acrescentadas à legislação criminal, não deixando margem para dúvida quanto à adequação típica de qualquer deslize administrativo. Sendo o autor agente público, inquestionável a natureza jurídica do alvo de suas manifestações: o ato administrativo. Com isso, não é demais englobar o mandante, o autorizador e o executor. Essas figuras poderão misturar-se, i.e., o mesmo agente pode ser competente para ordenar e executar. A previsão de um só verbo, executar, por exemplo, ensejaria a discussão da espécie de ato administrativo criador do aumento de despesa com pessoal. O executor alegaria cumprir ordem manifestamente legal, e o mandante, mais uma vez, não estaria “executando”. Por isso, o crime é de conduta múltipla alternativa, ou de conteúdo variado.

O ato deve acarretar aumento de despesa total com pessoal. A Lei Complementar n. 101/2000, em seu art. 18, define o termo como a soma dos gastos do ente da Federação com quaisquer espécies de servidor público (ativos, inativos, pensionistas etc.) e referentes a quaisquer

espécies remuneratórias (vencimentos, vantagens, subsídios, proventos de aposentadoria etc.). Note-se, ainda, que a incriminação da conduta também se apoia no art. 21, parágrafo único, da mesma lei, ao declarar nulo de pleno direito o ato que aumente despesa com pessoal, expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato.

Apesar de o termo mandato, por si só, abranger os Três Poderes, o legislador achou por bem se precaver, incluindo a expressão legislatura. Assim, essa expressão identifica-se com os membros do Poder Legislativo, enquanto mandato, elemento do tipo, refere-se aos demais poderes (Presidente da República, Presidente do Tribunal de Justiça etc.).

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

O crime só é punível a título de dolo, que consiste na vontade livre e consciente de, por intermédio de ato administrativo, aumentar a despesa total com pessoal no período de tempo previsto no tipo.

5. ELEMENTO TÍPICO TEMPORAL

Aumentar despesa total com pessoal só é crime se o ato for praticado “nos cento e oitenta dias” que antecedem o final do mandato ou legislatura. Esse é o período previsto em lei para tornar típica a conduta do agente público. A previsão do elemento temporal se deve ao fato de se pretender proteger o equilíbrio das contas públicas, impedindo que a atitude “altruísta” do administrador de hoje transforme-se, para os cofres públicos, na desgraça de amanhã. O aumento de despesa total com pessoal, fora do período descrito, não é interpretado pela lei penal como manobra que prejudica o sucessor político e o equilíbrio das finanças públicas, e sim como poder discricionário na gestão fiscal do Estado.

6. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

O crime se consuma com o ato que resulta em aumento de despesa total

com pessoal, seja na modalidade de ordem, autorização ou execução. É importante salientar que o ato deve ter sua vigência dentro do limite temporal previsto no tipo incriminador, ou seja, nos últimos cento e oitenta dias de mandato ou legislatura. Trata-se de crime de mera conduta, pois não há previsão de resultado típico naturalístico.

A tentativa é inadmissível nas modalidades “ordenar” e “autorizar”. Emitida a ordem ou autorização, o crime está consumado. Antes da vigência dos respectivos atos administrativos, há apenas condutas preparatórias impuníveis. Na modalidade “executar”, é possível a ocorrência de crime tentado.

7. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de reclusão, de um a quatro anos.

Por se cuidar de delito com pena mínima não superior a um ano, afigura-se cabível a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação penal é pública incondicionada.

Oferta pública ou colocação de títulos no mercado

SUMÁRIO: 1. Conceito e objetividade jurídica. 2. Sujeitos do delito. 3. Elementos objetivos do tipo. 4. Elemento subjetivo do tipo. 5. Momento consumativo e tentativa. 6. Pena e ação penal.

1. CONCEITO E OBJETIVIDADE JURÍDICA

De acordo com o art. 359-H do CP, configura crime o fato de “ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia”.

A descrição desse delito foi acrescida ao CP pela Lei n. 10.028/2000 como tratamento criminal à regulamentação da gestão fiscal já inserida no ordenamento jurídico pela Lei Complementar n. 101/2000. Assim, torna-se crime a ação irregular de administradores na movimentação do mercado financeiro por intermédio da emissão de títulos da dívida pública. De maneira que a falta de lei criadora dos respectivos títulos, ou mesmo a falta do devido registro, constitui crime contra as finanças públicas.

O objeto jurídico-penal é a probidade administrativa e a regularidade da gestão fiscal em relação à oferta etc. de títulos da dívida pública.

2. SUJEITOS DO DELITO

Sujeito ativo é o agente público responsável por ordenar, autorizar ou promover as condutas descritas no tipo. Por se exigir qualidade especial do sujeito ativo, trata-se de crime próprio. Em respeito ao princípio da legalidade administrativa, torna-se imprescindível a previsão legal de competência do agente em relação à oferta e à colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública.

Sujeitos passivos são a União, os Estados, os Municípios etc.

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO

Há três núcleos no tipo do art. 359-H do CP: ordenar, autorizar e promover. Confirmando a intenção demonstrada na definição de outros delitos contra as finanças públicas, o legislador separou o agente que ordena do que autoriza. Com isso, procurou evitar a atipicidade por falta de perfeita adequação da conduta ao verbo típico. Ordenar significa determinar, fazer valer sua vontade, sua iniciativa. Autorizar é dar o aval, corroborar, concordar com a ideia de outrem. A iniciativa é diversa em cada núcleo. De observar-se, contudo, que em ambos os casos a finalidade é a mesma: oferta pública ou inclusão no mercado de títulos da dívida pública. Promover, do latim *promovere*, é realizar, ser a causa de, levar a efeito. Dessa forma, o agente pode ordenar, autorizar ou promover:

1ª) a oferta pública;

2ª) a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública:

I – sem que tenham sido criados por lei; ou

II – sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia.

4. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública nas condições descritas na norma. Trata-se de crime punível somente na forma dolosa. Não requer finalidade específica ulterior, exigindo-se, porém, que o dolo alcance o conhecimento de que os títulos da dívida pública não foram criados por lei ou não se acham devidamente registrados.

5. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVA

Nas modalidades de ordem ou autorização, o crime se consuma com o aperfeiçoamento do ato administrativo. Ou o ato existe e o crime está consumado, ou ainda está prestes a nascer, permanecendo o agente na realização de atos preparatórios impuníveis. Não se admite tentativa.

Na terceira modalidade (execução), consuma-se o delito no momento em que o agente promove a oferta pública ou a colocação de títulos da dívida pública no mercado financeiro. A tentativa é admissível.

6. PENA E AÇÃO PENAL

A pena é de reclusão, de um a quatro anos.

Em razão da pena mínima (não superior a um ano), admite o delito o sursis processual (art. 89 da Lei n. 9.099/95).

A ação é pública incondicionada.

1. AMARAL, Sylvio do. Falsidade documental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. p. 87.

2. IMPALLOMENI, Giovan Battista. Codice penale italiano illustrato. v. 3. p. 33.
3. HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1955. v. 7. p. 209, n. 78.
4. NORONHA, Magalhães. Código Penal brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1958. v. 5. p. 163. n. 242.
5. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. São Paulo, 1959. v. 4. p. 821. n. 897, in fine.
6. Idem. Lições de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo, 1978. v. 2. p. 81. n. 444.

7. AZEVEDO, Eurico de Andrade. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, *Justitia*, 26:94.
8. DEODATO, Alberto. Manual de ciências das finanças, 5. ed. p. 294.
9. DRUMMOND, Magalhães. Comentários ao Código Penal. Forense, v. 9. p. 280.
10. HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 9. p. 356.
11. CAMPOS, Pedro Franco de Campos et al. Direito penal aplicado. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 344.

- 12.** HUNGRIA, Néson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 9. p. 422.
- 13.** HUNGRIA, Néson. Op. cit., 1958. v. 9. p. 422-3, n. 16.
- 14.** HUNGRIA, Néson. Op. cit., 1958. v. 9. p. 422.

- 15.** MANFRONI, Carlos A. La Convención Interamericana contra la Corrupción. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 135.
- 16.** JESUS, Damásio de. Temas de direito criminal, 2ª série. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 142.
- 17.** Ibidem, p. 142.

- 18.** FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. 1965. v. 4. p. 1212. n. 1.096.
- 19.** DRUMMOND, Magalhães. Comentários ao Código Penal. v. 9. p. 375.
- 20.** NORONHA, Magalhães. Direito penal. 3. ed. 1968. v. 4. p. 444. n. 1.482.
- 21.** SIQUEIRA, Galdino. Tratado de Direito Penal. p. 666. n. 1.285, in fine.